InDret
REVISTA PARA EL
ANÁLISIS DEL DERECHO

WWW. INDRET.COM

El remedio indemnizatorio en el derecho español de daños*

Análisis, aplicación e instrumentos comparados

2013

2ª edición

Pablo Salvador Coderch (Ed.)
Catedrático de derecho civil, abogado, fundador y *senior editor* de InDret

Carlos Gómez Ligüerre
Profesor titular de derecho civil

Antoni Rubí Puig
Doctor en derecho, profesor lector de derecho civil

Sonia Ramos González
Doctora en derecho, investigadora del programa Ramón y Cajal

Álvaro Luna Yerga
Doctor en derecho, abogado (Cuatrecasas), profesor asociado de derecho civil

Antoni Terra Ibáñez
Doctorando en derecho, estudiante de economía

*Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco del proyecto de investigación "Análisis de los remedios (*Remedies*) en derecho privado español según la teoría general de la aplicación del derecho (*Law Enforcement Theory*), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Plan Nacional de I+D+I, 2011-2013, DER2010-15624).

Índice

Capítulo 1º: Fundamentos analíticos del remedio indemnizatorio en el derecho español de daños 1
Pablo Salvador Coderch, Antoni Terra Ibáñez

Capítulo 2º: Las cuatro reglas básicas de responsabilidad y los límites del derecho de daños 28
Pablo Salvador Coderch, Sonia Ramos González

Capítulo 3º: Negligencia (I): Circunstancias de la negligencia 37
Pablo Salvador Coderch, Antoni Rubí Puig

Capítulo 4º: Negligencia (II): Estimación del riesgo 54
Pablo Salvador Coderch

Capítulo 5º: Negligencia (III): Negligencia *per se* y *res ipsa loquitur* 68
Pablo Salvador Coderch, Sonia Ramos González

Capítulo 6º: Negligencia (IV): Culpa comparativa y culpa contributiva 97
Pablo Salvador Coderch, Carlos Gómez Ligüerre

Capítulo 7º: Causalidad de hecho 121
Pablo Salvador Coderch, Sonia Ramos González, Antoni Rubí Puig

Capítulo 8º: Imputación objetiva 142
Pablo Salvador Coderch, Antoni Terra Ibáñez

Capítulo 9º: Responsabilidad objetiva 162
Antoni Rubí Puig

Capítulo 10º: Daño 187
Sonia Ramos González

Capítulo 11º: Responsabilidad por hecho ajeno
Carlos Gómez Ligüerre

Capítulo 12º: Prescripción
Carlos Gómez Ligüerre

Capítulo 13º: El proceso civil de reclamación de responsabilidades civiles 239
Álvaro Luna Yerga

Capítulo 1º
Fundamentos analíticos del remedio indemnizatorio en el derecho español de daños

1. Estructuración del análisis 1
1.1. Preliminar: Cuatro modos de estructurar un discurso 1
1.2. La transversalidad del derecho de daños. Responsabilidad civil y responsabilidad civil derivada de delito o falta penales: atropello múltiple en la estación de ferrocarril de Castelldefels, Barcelona (23.6.2010) 5
1.3. Accidente de ferrocarril 9
2. Fuentes primarias y secundarias/ *Primary and Secondary Sources* 11
2.1. Legislación / *Statutes* 11
2.2. Jurisprudencia / *Case-law* 12
2.3. Doctrina / *Secondary Literature or Secondary Sources* 13
3. Análisis económico del derecho / *Law and Economics* 15
4. Concepto y clases de accidente, y limitaciones del derecho de daños. La minimización de los costes sociales de los accidentes 16
4.1. Concepto y clases de accidente 16
4.2. Algunas limitaciones del derecho privado de daños 17
4.3. La minimización de los costes sociales de los accidentes (Guido CALABRESI, 1970; Steven SHAVELL, 2004) y las simplistas pero escasamente realistas asunciones iniciales de los modelos analíticos del moderno derecho de daños 18
5. La acción de daños de los perjudicados por un ilícito competencial y la Propuesta de Directiva comunitaria de 11.6.2013 19
6. Responsabilidad civil y penal / *Tort and Crime* 22
7. Responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad (también civil, pero) contractual / *Tort and Contract* 23
8. ¿Es el derecho de daños una especialidad bien definida? 26

1. Estructuración del análisis

1.1. Preliminar: Cuatro modos de estructurar un discurso

Los buenos profesionales del derecho se expresan, verbalmente y por escrito, con un discurso estructurado sobre el caso o los casos que analizan. A continuación se presentan cuatro buenas maneras de estructurar el análisis de los casos en derecho y en derecho de daños, pero solo la primera es propia del jurista:

IRAC: el punto de vista del jurista:

a) *Issue*: ¿cuál es o cuáles son las cuestiones legales que plantean los hechos alegados y probados por las partes en el caso?
b) *Rules*: ¿cuáles son las reglas de derecho aplicables a los hechos del caso? En su caso: ¿cuál es la jurisprudencia?
c) *Analysis*: ¿cuáles son las razones, en derecho, de las partes, de cada una de ellas?
d) *Conclusion*: ¿qué concluiría el Juez o Tribunal en un caso como el presentado o qué habría de haber resuelto?

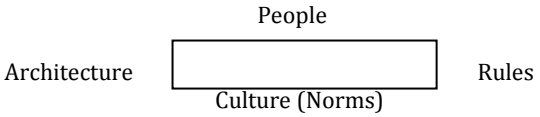
Para más información, véase http://www.csun.edu/~kkd61657/brief.pdf

Lecciones para el futuro: el punto de vista del ingeniero:

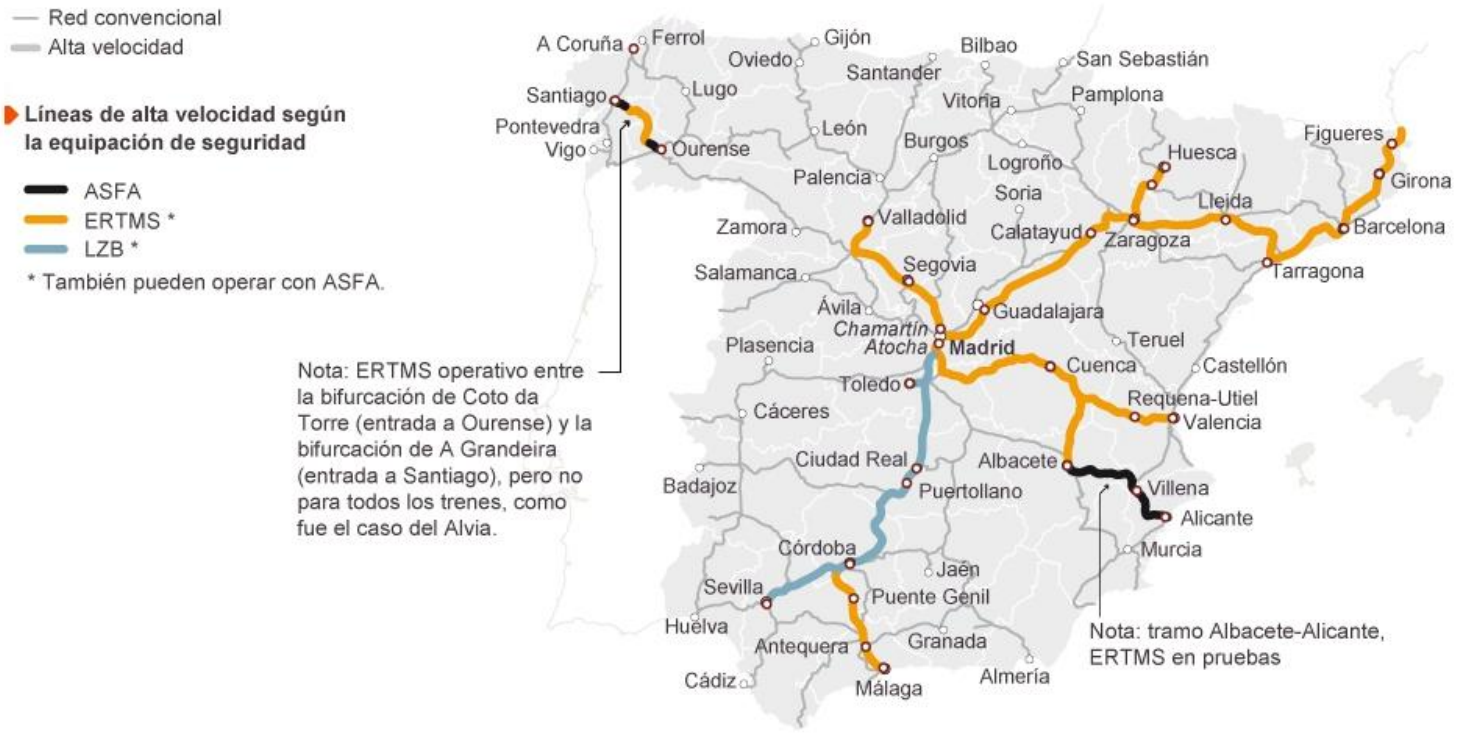
J. BUONGIORNO, R. BALLINGER, M. DRISCOLL, B. FORGET, C. FORSBERG, M. GOLAY, M. KAZIMI, N. TODREAS, J. YANCH, *Technical Lessons Learned from the Fukushima-Daichii Accident and Posible Corrective Actions for the Nuclear Industry: An Initial Evaluation*, Nuclear Science & Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Canes publications, May 2011
http://web.mit.edu/nse/pdf/news/2011/Fukushima_Lessons_Learned_MIT-NSP-025.pdf

a) Observations from the accident
b) Key questions
c) Possible corrective actions
d) Possible design improvements in the future

PARC: El punto de vista del científico social:

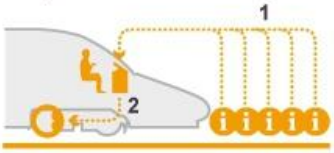


El 24 de julio de 2013, un tren Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Ferrol descarriló en una curva a la entrada de Santiago de Compostela. 79 personas fallecieron y más de 130 resultaron heridas de diversa consideración. Iniciadas actuaciones penales, una de las cuestiones planteadas se relaciona con la posible responsabilidad –penal y civil– del maquinista del tren, pues el convoy entró en la curva a una velocidad a todas luces superior a la permitida. Pero la discusión sobre la arquitectura, sobre la infraestructura de seguridad del sistema ferroviario, emerge como otra de las cuestiones cruciales para analizar el caso. En el tramo accidentado, el sistema de seguridad instalado era el ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático – vídeo RENFE, 1983), menos avanzado que el ERTMS (European Rail Traffic Management System):



ERTMS (1.974 kilómetros instalados. Sólo en alta velocidad)

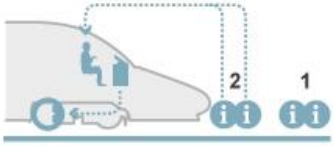
1. Comunicaciones e información del trayecto permanentes a lo largo de toda la ruta. En implantación a nivel europeo.



2. El ordenador actúa sobre el tren en el momento en que se supera la velocidad máxima establecida o rebasa señales que indican detención.

LZB (498 km. Sólo en alta velocidad)

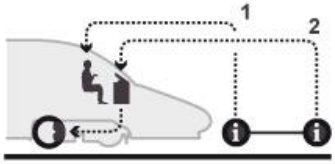
1. Trayecto dividido en cantones. Información cada 100 metros de la velocidad máxima que se puede desarrollar en cada punto del cantón.



2. El ordenador avisará al maquinista y frenará el tren si no actúa para llevar al tren a la velocidad permitida.

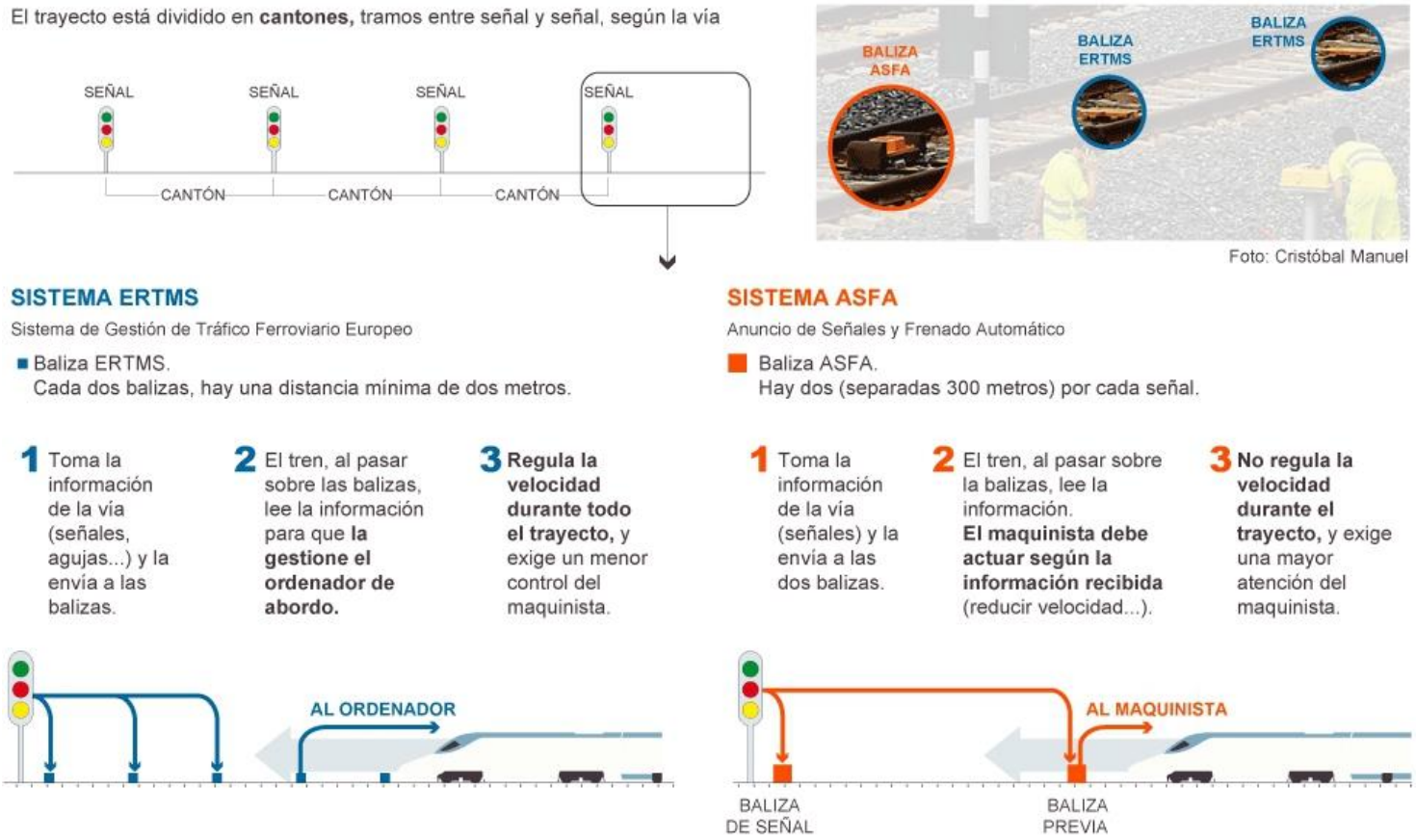
ASFA (instalado en toda la red, incluida la convencional. 13.398 km)

1. El maquinista debe actúar según la información que se recibe en cabina en puntos concretos del tramo.



2. Frenado automático si se rebasa una segunda baliza de información gemela, incumpliendo la limitación de parada o con velocidad superior a 200 km/h.

El País, 8.8.2013, http://elpais.com/elpais/2013/08/05/media/1375732774_197519.html



El País, 26.7.2013, http://elpais.com/elpais/2013/07/26/media/1374872840_505323.html

— Funcionamiento del sistema ASFA en el accidente de Santiago de Compostela: http://elpais.com/elpais/2013/08/08/media/1375970174_064671.html

Redacción legal: el punto de vista del escritor legal:

Distribuye el tiempo disponible para redactar tu discurso legal, de acuerdo con la siguiente regla de las cinco E's (PSC (1985)):

- ***Escucha***. Mucha gente no lo hace, sino que espera, ansiosa, su turno para hablar.

- ***Estudia***. Ni el mejor redactor legal está solo en el mundo -solo lo está ante la pantalla del dispositivo electrónico que está usando. Si el texto que vas a redactar es un examen escrito, las dos primeras E's pueden reducirse a una: antes de arrancar a escribir, asegúrate de que has entendido bien las cuestiones formuladas en el examen.

- ***Esquematiza***. Construye un esquema de tu discurso y hazlo por escrito. En derecho, IRAC es una buena manera de organizar los esquemas.

> En cuanto al contenido específicamente retórico de tu discurso, la organización triádica es clásica, pues permite exponer y defender tres ideas o reiterar una fundándola en tres razones distintas. Más de tres –sean ideas o razones- resulta arriesgado, pues casi nadie es capaz de recordar un discurso basado en cinco, seis o siete principios (prueba: defiendan los lectores una causa durante diez minutos y, al cabo, pidan a sus oyentes que resuman la intervención). Siguen tres

ejemplos de discursos clásicos, retóricamente logrados, todos ellos accesibles en la red: el primero es el de Steve Jobs, *How to Live Before You Die*, cuya estructura es claramente triádica, pero si consigues concebir y formular una buena y única idea el resultado puede ser histórico. Así, este año de 2013, hemos conmemorado el cincuentenario de la alocución, conocida como *"I have a dream",* de Martin Luther King, el 28 de agosto de 1963, un ejemplo legendario de un discurso centrado en un tema único, la igualdad racial. Mas, para un profesor veterano y, sobre todo, para un alumno listo, el *How schools kill creativity* de Ken Robinson es una de las dos o tres admoniciones de referencia. Los Lectores interesados en hacerse con una buena formación para abogar por las causas en las que crean harán bien en recurrir con cierta frecuencia a *TED Ideas worth spreading*.

- ***Escribe***. Al final, las palabras son el arma principal del abogado, del juez. Y un buen test para un Estado de derecho es calificar de 0 a 10 el grado de coherencia entre las palabras del juez y las razones auténticas de su decisión.

Un buen libro para aprender a escribir en derecho es el de Terrill POLLMAN, Judith M. STINSON, Richard K. NEUMANN, Jr., Elisabeth POLLMAN, *Legal Writing*, 1st edition, Wolters Kluwer, New York, 2011.

- ***Edita***. Dedica por lo menos una cuarta parte del tiempo de que dispones a editar el texto que acabas de redactar. Hay algunas buenas maneras de editar un texto: una, que no siempre es posible, es hacerlo editar por otra persona mayor o más joven que tú; otra, que lo hagas tú al día siguiente de haber redactado el primer borrador. Si, por fin, has de editar tu propio texto, concédete una pausa, por breve que sea, antes de empezar.

En cualquier caso, editar es siempre encoger el texto: córtalo sin piedad ni consideración alguna, que suelen ser demasiado largos, se repiten. "repetirse", en la frase anterior, reitera la idea de "ser demasiado largo", que podría no estar.

Las cinco reglas anteriores, las cinco E's ayudan a evitar errores. Hay una sexta que es solo para profesionales:

- ***¡Empieza de nuevo!***

¿Quién, tras volver a escribir de cabo a rabo el texto que había borrado sin querer de su dispositivo electrónico, no ha experimentado nunca la sensación de que el nuevo discurso es más claro y sencillo que el original?

1.2. La transversalidad del derecho de daños. Responsabilidad civil y responsabilidad civil derivada de delito o falta penales: atropello múltiple en la estación de ferrocarril de Castelldefels, Barcelona (23.6.2010)

Cuando se habla de responsabilidad civil de alguien, es decir, de la posible obligación de indemnizar puesta a cargo de quien ha causado un daño a otro, la primera intuïción legal es que sobre la cuestión resolverá un tribunal civil, de acuerdo con las regles, materiales y procesales, civiles.

No es así, pues el derecho de la responsabilidad civil es transversal, multijurisdiccional: sobre un mismo daño pueden conocer varias jurisdicciones en función del sujeto que lo causó, de las circunstancias que rodearon su causación.

En efecto, una característica singular del derecho español, comparada con otros ordenamientos jurídicos, es que la cuestión sobre la posible responsabilidad civil derivada de accidentes mortales o que causan lesiones corporales es resuelta habitualmente por tribunales penales, los cuales deciden sobre la responsabilidad propiamente penal, por delito o falta, y sobre la específicamente civil derivada de la anterior.

Si el tribunal penal archiva el caso o resuelve que no hay delito ni falta, normalment queda abierta a las víctimas o a sus allegados la posibilidad de iniciar un nuevo pleito y acudir a un tribunal civil, a la jurisdicción civil, en busca de un remedio indemnizatorio por los daños causados.

Esta singularidad del derecho español ha generado discusiones sin cuento entre quienes, por una parte, consideran que la atracción de las cuestiones de pura responsabilidad civil por la jurisdicción penal es una solución práctica que permite resolver en un solo litigio penal los temas civiles y penales cuestiones y quienes, por la otra, opinan que ventilar en un juicio penal los intereses puramente Civiles, además de los penales, distorsiona el proceso penal y el derecho penal mismo o que, en el caso de que haya que volver a litigar porque el tribunal penal descarte la existencia de una infracción penal, los pleitos se eternizan. De ello trataremos en varias de las Sesiones de este curso. Baste ahora con indicar que, para bien o para mal, este rasgo del derecho español caracteriza todo el derecho de daños. El caso que se plantea a continuación y que, en la fecha de cerrar esta edición, sigue planteado ante los tribunales, es un ejemplo también característico de lo anterior: más de tres años después del accidente, todavía se está discutiendo si el caso tiene relevancia penal o exclusivamente civil.

El 23.6.2010, a las 23:23 horas (vigilia de San Juan), en la estación de trenes de Rodalies (Cercanías) RENFE de Castelldefels Platja (Castelldefels, Barcelona), un convoy arrolló a un grupo numeroso de personas que, en aquellos momentos estaban cruzando las vías del ferrocarril. 12 personas fallecieron y 17 resultaron heridas de diversa consideración.

Las víctimas, viajeros de un tren de Cercanías que había llegado a la estación poco antes de que lo hiciera el convoy de media distancia que les arrolló, habían salido de sus vagones cerca de un paso subterráneo habilitado para pasar al otro lado del andén, pero se habían dirigido a una pasarela superior, más próxima a ellos y que era la antigua salida de la estación, que estaba inhabilitada y el paso cerrado por una cadena. Entonces algunos viajeros, en lugar de volver sobre sus pasos y cruzar por el paso subterráneo, resolvieron fatalmente saltar a las vías para cruzarlas y acceder a la playa.

Sigue una grabación extraída de un informativo que dio la noticia poco después del accidente: http://www.youtube.com/watch?v=_HSmGph9zrA

Como consecuencia del accidente, se iniciaron diligencias penales. El 30.6.2010, el Juez entonces encargado de la instrucción del caso dictó un auto por el que se acordó el sobreseimiento libre de las diligencias previas. Las acusaciones particulares interpusieron recurso de reforma y apelación contra dicho auto. Un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 10.1.2011, estimó el recurso, revocó el auto recurrido y ordenó la continuación de la instrucción a fin de practicar más diligencias. Las acusaciones particulares presentaron escrito en el que interesaban la imputación de las personas que ocupaban diversos cargos directivos en RENFE y ADIF en la fecha del accidente por 12 presuntos delitos o faltas de homicidio imprudente, así como por 17 delitos o faltas de lesiones imprudentes, a título de comisión por omisión. El Ministerio Fiscal, ADIF y RENFE se opusieron a lo interesado y presentaron escritos de alegación.

El AJPII nº1 Gavà, de 30.5.2012, acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias previas (art. 641.1 LECrim) por "no darse (…) los requisitos que los tipos imprudentes exigen para apreciar su existencia" (FD 2.8) puesto que, "[d]el análisis de las actuaciones obrantes en autos no resulta la existencia de incumplimiento sustancial de la reglamentación y de las normas de cuidado a observar en el ámbito del tráfico ferroviario que permita afirmar la existencia de omisión de un deber de cuidado punible en la esfera penal" (FD 2.1).

En concreto, la Juez consideró probado que

a) "[E]l estado de mantenimiento técnico del tren (…) implicado en el siniestro [era] adecuado" (FD 2.2).

b) [E]l maquinista (…) cumplió en su conducción con todas las exigencias normativas al respecto" (circulación dentro de los límites de velocidad, llevaba encendidas las luces reglamentarias al momento de entrar en la estación, instante en que también accionó el claxon, y el resultado de las pruebas de alcoholemia resultó negativo) (FD 2.2).

c) [E]l apeadero de Castelldefels cumplía "los requisitos de seguridad y accesibilidad exigidos normativamente" (en concreto, había sido reformado en 2009 para adaptarse a las exigencias del RD 1544/2007, de manera que el cruce de pasajeros de un andén al otro mediante una pasarela superior fue sustituido por un paso subterráneo) (FD 2.3). Y,

d) "[L]as condiciones que en particular presentaba el apeadero en el momento de los hechos" eran igualmente adecuadas (iluminación suficiente, paso subterráneo accesible, "sin ningún obstáculo", y –extraordinariamente, por la mayor afluencia de personas en el apeadero con motivo de la noche de San Juan– tornos de salida de la estación abiertos, así como también los portones situados al lado de dichos tornos) (FD 2.3).

Finalmente, la Juez del caso afirmó: "[N]o era previsible (…) que los pasajeros del tren de cercanías, incurriendo en una notoria negligencia y prescindiendo de las más elementales normas de cuidado, incumpliendo con lo previsto en la normativa aplicable, decidieran, sin buscar el paso habilitado al efecto [ya que "desde que el tren de cercanías abandonó la estación hasta que se produjo la entrada en el mismo del tren causante del siniestro transcurrieron únicamente 15 segundos"], pasar al otro andén cruzando directamente las vías, sin prever que por las mismas se podría acercar otro tren (…) (FD 2.6). "Siendo tal decisión de todo punto imprevisible", sus efectos "no [son] imputable[s] a las personas respecto de las cuales se pretende su imputación por las acusaciones particulares" (FD 2.7).

El auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14.5.2013 revocó la anterior interlocutoria al considerar que los peritos que fueron escuchados en sede policial deben ratificarse a presencia de las partes ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Gavà. Sin embargo, en contra del *petitum* de los recurrentes, la AP Barcelona no ordenó practicar nuevas diligencias sobre el accidente ferroviario.

A continuación, se reproducen tres fotografías de la estación de Castelldefells Playa, donde ocurrió el accidente y otras tres de dos estaciones de ferrocarril suizas, Grindelwald e Interlaken-Ost. En las estaciones secundarias de la Confederación Helvética es frecuente que no haya ni pasos elevados ni subterráneos: los pasajeros esperan a que el empleado del ferrocarril que viaja con ellos en cada tren les indique el momento apropiado para cruzar los andenes.

Estación de ferrocarrils de Castelldefels

Der Bahnhof Grindelwald

Der Bahnhof Interlaken-Ost

El contraste entre España y Suiza sugiere una reflexión sobre los comportamientos apropiados en derecho: en ambos países, la gente, las infraestructuras (la arquitectura) y las normas (la cultura) son distintas y, por lo tanto, las reglas de derecho más apropiadas para evitar accidentes, reducir su número y disminuir su gravedad pueden analizarse habida cuenta de su interacción con aquellas.

La modificación de las reglas de derecho o de su interpretación razonablemente posible pueden producir modificaciones en la arquitectura o infraestructura, en el sistema de normas culturales o en el comportamiento de las gentes, o pueden hacer en distinta medida en cada caso.

La decisión infraestructural sobre qué efecto es preferible –estaciones como la española o como las suizas, por ejemplo- no es autoevidente. Así, un factor muy relevante puede ser la velocidad del convoy de largo recorrido que circula por vías que cuentan con estaciones secundarias a más de cien km/h y que, por lo tanto, no puede detenerse si una persona invade indebidamente la vía del tren.

Dos casos recientes:

- El 23 de noviembre de 2012, un hombre de 67 años de edad, que atravesaba las vías del ferrocarril en la estación de Salou, Tarragona y por un paso a nivel que tenía las barreras bajadas, fue arrollado por un tren Euromed que circulaba a 140 km/hora y que no tenía parada en aquella estación. Puede muy bien pensarse que la infraestructura era deficiente. También que el peligro lo era muy manifiestamente y que la manera más sencilla de evitarlo es abstenerse de cruzar la vía cuando las barreras están bajadas.
- La madrugada del sábado 24 de agosto de 2013, una chica de 16 años fue arrollada por un tren de mercancías a su paso por Ascó (Tarragona). Murió en el acto. Las vías del ferrocarril (línea Reus-Zaragoza) se encontraban junto a la plaza donde se desarrolló el festival de música, pintura y agua al que asistía la fallecida durante la fiesta mayor de la población. El Ayuntamiento había instalado un frente de vallas metálicas para impedir el acceso a las vías, aunque aquella noche muchos jóvenes las cruzaron presumiblemente para ahorrarse tener que ir a los servicios instalados en el otro extremo de la plaza que acogía el concierto.

1.3. Accidente de ferrocarril

STS, 1ª, 44/2010, de 18 de febrero:

El 19 de marzo de 1994, dos menores, de 15 y 16 años de edad, circulaban en un ciclomotor de una sola plaza. Su conductor, quien carecía de permiso de conducir, cruzó la vía del tren por un paso a nivel sin barreras ni semáforos en A Rúa (Padrón, A Coruña) y un tren arrolló a ambos muchachos matándoles en el acto. A un lado del paso, había una señal descolorida de paso a nivel. Al otro, un poste de unos dos metros de altura con señales de atención al tren. En ninguno había señal, preceptiva, de stop. Los dos menores eran vecinos del lugar y conocían el paso a nivel. En el momento del accidente el tren circulaba a 98 km/hora, la velocidad máxima permitida era de 100 km/hora y el convoy era visible, aproximadamente, a un kilómetro de distancia del lugar del accidente en línea recta. A unos 600 m. de distancia del paso a nivel existía la señal reglamentaria que ordena "silbar".

Los padres y el hermano, respectivamente, de los dos fallecidos interpusieron sendas demandas contra Renfe y el maquinista del tren. Los padres y hermano de una de las víctimas solicitaron que:

> "[S]e declar[ara] la obligación de [Renfe] de dotar al paso a nivel e inmediaciones… de las medidas de seguridad, protección y advertencia a los usuarios…, necesarias para evitar riesgos en las personas y en las cosas, atendiendo a las circunstancias de la zona y en particular el cercamiento de la vía al paso por la población y dotación de barreras o mecanismos de obligada detención de vehículos y personas …". Y
>
> Se conden[ara] a los demandados a pagar 90.361,45 euros a cada uno de los padres del fallecido y 60.240,96 euros al hermano, así como 553,48 euros por gastos funerarios. Los padres y el hermano de la otra víctima solicitaron una indemnización de 132.530,12 euros por el fallecimiento del menor, de 90.361,45 euros por daño moral y de 1.826,55 euros por gastos funerarios.

El JPI estimó sustancialmente la primera demanda: condenó a Renfe a "dotar el paso a nivel e inmediaciones sito en A Rua de las medidas de seguridad, protección y advertencia que sean necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas" y condenó a ambos demandados a pagar, en concepto de daño moral, 144.821,15 euros a los padres, 18.807,93 euros al hermano, ambas cantidades en concepto de daño moral, así como la cuantía reclamada por gastos funerarios. Asimismo, el JPI estimó sustancialmente la segunda demanda y condenó a ambos demandados a pagar las mismas cantidades en concepto de daño moral y la cuantía reclamada por gastos funerarios.

La Audiencia Provincial (AP) de A Coruña estimó el recurso de apelación de Renfe, revocó la SJPI y desestimó ambas demandas. Extractamos los fundamentos de su resolución (e introducimos algunos cambios en la puntuación para separar los párrafos):

"[L]a causa del accidente fue el grave descuido de las víctimas, que, con infracción de todas las normas de la prudencia y de la circulación viaria, se metieron literalmente debajo del tren; descuido relativamente explicable por la edad juvenil, pero no por ello prescindible e intrascendente cuando de la aplicación del Derecho se trata.

Pero ha sido objeto también de debate otra interesante cuestión: si existe responsabilidad de Renfe por no haber abordado ya la supresión de ese concreto paso a nivel, o, al menos, su reordenación para dotarlo de mejores medios de seguridad, como barreras o semibarreras. Es claro que la actual red viaria, con la existencia de pasos a nivel para cruzar la línea férrea, deriva de razones que en tiempos pretéritos los hicieron necesarios; sin que creasen tan elevado riesgo como en la actualidad, al haber aumentado tanto la circulación de vehículos a motor que se ven obligados a cruzar por ellos. Pero en los tiempos presentes, con medios técnicos muy superiores, se ha impuesto la política conducente a la eliminación de tan peligrosos obstáculos viarios, que por unas u otras razones se han cobrado muchas vidas, como en el caso que nos ocupa.

Responde a tal criterio el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (Real Decreto 1211/90, de 28 setiembre), que en su artículo 235 contempla tanto lo relativo a nuevos pasos a nivel, que solo permite con carácter excepcional y por causas absolutamente justificadas, como la supresión de los actuales o en otro caso, para los subsistentes, la adopción de sistemas de seguridad y señalización más eficaces.

Pero es de advertir que el accidente ocurrió el 19 de marzo de 1994, y que por ello el texto vigente era la primera redacción del artículo 235. A tenor de ella, en su apartado 4, "Los pasos a nivel que resulten subsistentes deberán contar con los sistemas de seguridad y señalización adecuados para garantizar su seguridad que, a tal efecto, se determinen por los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo y de Transportes, Turismo y Comunicaciones".

Pues bien, estos sistemas de seguridad no se determinaron ministerialmente hasta la Orden de 1 de diciembre de 1994 (BOE de 14 del mismo mes), varios meses después de haber ocurrido el accidente objeto de este litigio. En ella se disponen las medidas de seguridad correspondientes a un paso a nivel como el de esta *litis*, que se califica de clase A, en el que ha de procederse a la instalación de la señalización que allí se hace constar (artículos 8 y 9).

No cabría, pues, imputar a RENFE un retraso o dejadez en la aplicación de medidas de seguridad que se anunciaban en el Decreto de 1990, con remisión a lo que dispusiesen los Ministerios competentes, y que no se concretaron hasta después de ocurrido el accidente. Pero ha de tenerse muy en cuenta respecto a las medidas de señalización a instalar en la carretera o camino, que la norma, que se remite a las del Reglamento General de Circulación ya aludidas, al igual que éste, responsabiliza de aquéllas al titular de tales vías (disposición adicional sexta). [E]s lo que ya establecía la Orden de 8 de mayo de 1982, vigente cuando el desdichado accidente ocurrió ... A RENFE solo correspondía entonces y ahora la señalización establecida para la vía férrea" (FD. 4º).

Los actores de la primera demanda interpusieron recurso de casación que el TS desestimó:

"La "defectuosa señalización" del paso a nivel, admitida por la AP, no desempeñó papel relevante alguno en la determinación del nexo de causalidad, sino que, en expresión de la sentencia recurrida, la causa del accidente estuvo en "el grave descuido de las víctimas, que, con infracción de todas las normas de la prudencia y de la circulación viaria, se metieron literalmente debajo del tren" (FD. 3º).

En *"Trenes"*(InDret 1/2000, www.indret.com), un artículo publicado en el año 2000, Carlos Gómez Ligüerre y Pablo Salvador Coderch analizaron la jurisprudencia española de la época sobre responsabilidad civil por accidentes ferroviarios en pasos a nivel y a la luz de la

experiencia histórica norteamericana, es decir, a la de una cultura industrial más antigua y más avanzada tecnológicamente que la española. En el artículo, se rememoraba el intento lúcido, brillante, finalmente fallido, de William Wendell Holmes, Jr., un magistrado legendario, de establecer una única regla para resolver todos los casos de arrollamiento en pasos a nivel sin barreras. A principios del siglo XX, Holmes propuso que, ante un paso a nivel, los conductores de automóviles habían de detener sus vehículos, salir de ellos, mirar a uno y a otro lado de las vías y escuchar si se acercaba algún tren (***"Stop, look and listen"***). De no haber adoptado tales precauciones, opinaba, las víctimas o sus sucesores no podrían reclamar nada por el accidente sufrido. La historia, contada en *Trenes*, enseña que la regla duró pocos años y que, al cabo, los tribunales norteamericanos hubieron de recurrir a criterios mucho más matizados y apegados a las circunstancias de cada caso. Probablemente, lo mismo habrá sucedido con las propuestas sobre precauciones exigibles que Gómez y Salvador formularon hace trece años en su artículo. Los estándares de responsabilidad civil cambian con el tiempo y este solo respeta aquello que ha creado.

2. Fuentes primarias y secundarias/ *Primary and Secondary Sources*

En responsabilidad civil, la ley –desarrollada por los reglamentos- y la jurisprudencia establecen los casos y circunstancias en los cuales el demandado habrá de ser condenado civilmente a reparar los daños derivados de un suceso o acontecimiento dañoso que no debería haber ocurrido, que ha causado el demandado mismo y que el derecho establece que ha de ser puesto a su cargo.

Es muy difícil ofrecer una definición de la responsabilidad civil que sea, a la vez, omnicomprensiva, operativa y fecunda.

Véanse las dos siguientes, tomadas, respectivamente, de un libro clásico español y de otro norteamericano:

"Responsabilidad civil es imputación (...) La responsabilidad civil por daños extracontractuales [refiere a] los presupuestos, condiciones, y circunstancias por las que una persona que ha sufrido un daño jurídicamente tutelable como consecuencia de la conducta o actividad de un tercero tiene derecho a exigir su reparación a ese tercero o a otra persona que se encuentre con él en una determinada relación" (Fernando Reglero Campos, *Tratado de Responsabilidad Civil*, Aranzadi, 2002).

"A tort is a conduct that amounts to a legal wrong and that causes harm for which courts will impose civil liability" (Dan Dobbs, *The Law of Torts,* West, 2000)**.**

2.1. Legislación / *Statutes*

Muchas disposiciones del derecho español (civil, penal, administrativo y laboral) establecen supuestos de responsabilidad civil o, más generalmente, de responsabilidad extracontractual. Las principales están en los artículos de los textos legales que se citan a continuación:

— 1902-1910 del Código Civil de 1889.
— 109-125 del Código Penal de 1995.
— 139-146 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
— 42-54 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
— 128 y ss. RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
— 123 del RDL 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Algunas observaciones preliminares:

En primer lugar y como ya hemos señalado, algunas de las disposiciones citadas se encuentran en leyes civiles aplicadas por tribunales civiles; otras están residenciadas en leyes penales y son aplicadas por tribunales también penales; unas terceras son administrativas y su conocimiento corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa y, por fin, algunas son laborales y los casos que plantean son competencia de la jurisdicción social. La primera característica procesal de la responsabilidad civil es, pues, su naturaleza multijurisdiccional, que trataremos en capítulos posteriores.

En segundo lugar, buena parte de las disposiciones citadas son principios (*standards*), no reglas (*rules*) de derecho. Sobre la distinción entre ambos, véase Ward Farnsworth, *The Legal Analyst. A Toolkit for Thinking About the Law*,The University of Chicago Press, 2007, pp. 163-171: para aplicar una regla, basta con conocer los hechos que describe su supuesto de hecho. En cambio, la apreciación de un principio exige siempre la formulación de un juicio de valor. Así, por ejemplo, conducir un automóvil a más de sesenta kilómetros por hora es una simple cuestión de hecho; conducir negligentemente es, además, una cuestión valorativa, normativa. La primera circunstancia puede integrar una regla; la segunda, un principio.

Luego, en tercer lugar, hoy en día, la ley y los reglamentos, el derecho legislado y regulatorio, ocupan un lugar creciente en la prevención de los accidentes y en la resolución de los conflictos a que su ocurrencia da lugar. Aquí es importante destacar las diferencias básicas entre el derecho regulatorio de los accidentes, establecido por el Parlamento, por el gobierno o por la agencia reguladora con potestad reglamentaria, por una parte, y el derecho de daños creado y desarrollado por los tribunales, por la otra, el *case law*:

> —El derecho regulatorio mira al futuro, se establece *ex ante*. En cambio, el derecho judicial de daños mira al pasado, se decide *ex post*.
> —El derecho regulatorio suele ser detallado –y cada vez lo es más-. Es un conjunto de reglas, no de principios o no solo de ellos. En cambio, la mayor parte del derecho de daños parte de principios o estándares que los tribunales concretan de modo mucho más fluido y, muchas veces, de modo intersticial.

Entonces y en cuarto lugar, una pregunta capital del moderno derecho de daños es si la regulación detallada de un sector de actividad cierra o clausura el sistema de modo tal que excluya toda pretensión adicional por derecho de daños o si, por el contrario, el demandante puede ejercitar una pretensión de responsabilidad civil además de los remedios previstos por la regulación específica del caso: es el tema de la "*preemption*", de la cuestión de si el derecho regulatorio cierra o no el paso a ulteriores reclamaciones por responsabilidad civil.

Un ejemplo: ¿cierra la regulación vigente en España sobre la disolución del matrimonio y sus consecuencias la posibilidad de que uno de los cónyuges ejercite una pretensión de responsabilidad civil contra el otro y en cuyo fundamento alegue los daños morales que, presuntamente, le ha causado la infidelidad del demandado?

2.2. Jurisprudencia / *Case-law*

En España, el derecho de daños es fundamentalmente jurisprudencial, *case-law*. Y lo es, porque, como ya hemos indicado, las disposiciones más importantes sobre la materia del derecho legislado son principios o estándares, no reglas. Así, dos fuentes positivas básicas del derecho español de daños --el art. 1902 del Código Civil de 1889 y el art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común— se formulan como principios. Su concreción y desarrollo se dejan a la jurisprudencia y esta ha venido decidiendo constelaciones de casos que, muy aproximadamente, van delimitando poco a poco grupos de supuestos análogos de responsabilidad civil, las llamadas -mal- "constelaciones de casos".

Tales grupos de supuestos van cambiando con el paso del tiempo y las circunstancias -a diferencia de las auténticas constelaciones, que están fijas en el firmamento- como hemos visto que ocurre en los casos de accidentes de ferrocarril. El jurista que trabaja la interpretación del derecho a partir del estado de los conocimientos científicos y técnicos puede ofrecer criterios razonables sobre el sentido de las resoluciones que propugna. Sin embargo, no existe ninguna teoría que permita predecir y explicar la dinámica del derecho de daños y no existe por la misma razón por la cual no hay una ciencia de la Historia que nos permita predecir y explicar el devenir de una colectividad. Pero la razonabilidad del jurista es crucial a la hora de decidir, de nuevo por ejemplo, casos de accidentes de ferrocarril, si queremos encaminar a la colectividad hacia Castelldefells, o hacia Grindelwald o Interlaken. Siempre es importante que el jurista sepa hacer llegar a los tribunales y la colectividad misma el sentido último, las consecuencias de las decisiones que vayan a adoptar.

En derecho español, la Jurisprudencia en sentido estricto es solo la establecida por el Tribunal Supremo y, más concretamente, por cada una de sus Salas en asuntos de su competencia (*Spanish Supreme Court's Case-law*), pero la denominada jurisprudencia menor, las sentencias de las Audiencias Provinciales (*Spanish Courts of Appeals' Case-law*) son cada vez más importantes: en la actualidad, conocer cómo deciden las Audiencias las distintas constelaciones de casos es imprescindible en la buena práctica de cualquier abogado especializado en responsabilidad civil.

Dos buenas bases de datos de consulta:
— Westlaw Aranzadi (www.upf.edu/bibtic/recursos/bd/bd-a.html)
— CGPJ – CENDOJ (www.poderjudicial.es/jurisprudencia)

El equipo de investigadores que, en 1999, fundó InDret mantiene al día una selección de sentencias del Tribunal Supremo español sobre responsabilidad civil de los últimos años. Su contenido integra las páginas de este curso y ofrece un panorama de la jurisprudencia española reciente:

Pablo SALVADOR CODERCH y Sonia RAMOS GONZÁLEZ (Coords.), Laura ALASCIO CARRASCO, Laura ALLUEVA AZNAR, Luca BIFFARO, Esther FARNÓS AMORÓS, Antonio FERNÁNDEZ CRENDE, Ignacio MARÍN GARCÍA, Rosa MILÀ RAFEL, Sergi MORALES MARTÍNEZ, Magalí RIERA ROCA, Carlos Alb. RUIZ GARCÍA y Antoni TERRA IBÁÑEZ, "120 casos de derecho de daños (2004-2011)", *InDret* 4/2012 (http://www.indret.com/pdf/939.es.pdf).

2.3. Doctrina / *Secondary Literature or Secondary Sources*

Hay muchos buenos tratados, comentarios, monografías y artículos sobre responsabilidad civil. Los autores de este e-libro hemos seleccionado los siguientes, la mayor parte de los cuales versan sobre el derecho español, pero no todos, como los lectores comprobarán:

— Hugo ACCIARRI, *Elementos de Análisis Económico del Derecho de Daños*, 1ª ed., Asociación latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía (ALACDE) & George Mason University, Law & Economics Center, Berkeley, California, 2009. Junto con el libro de Bullard, dos de las más brillantes referencias latinoamericanas, utilísimas y usadas en las mejores universidades del cono sur por quienes ya son estudiantes de excelencia mundial.
— Mario BARCELLONA, *Trattato della Responsabilità Civile*, Ed. Utet, 2011. Tratado italiano de referencia.
— Alfredo BULLARD, *Derecho y Economía. El Análisis Económico de las Instituciones Legales*, 2ª ed., Palestra Editores, Lima, 2006. Síntesis académica y profesional de primer nivel.
— José Manuel BUSTO LAGO/L. Fernando REGLERO CAMPOS (Coords.), *Lecciones de responsabilidad civil*, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2013. La puesta al día de un manual de referencia.
— Ana CAÑIZARES LASO/Pedro DE PABLO CONTRERAS/Javier ORDUÑA MORENO/Rosario VALPUESTA FERNÁNDEZ (Dirs.), *Código civil comentado*, Vol. 4, 1ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur

Menor, 2011 (Javier PLAZA PENADÉS, "Comentario al art. 1902", pp. 1454-1464; y Esther GÓMEZ CALLE, "Comentario al art. 1903", pp. 1464-1476). El otro.

— Robert D. COOTER/Thomas ULEN, *Law and Economics,* 6th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2011. Presentación asequible, muy meditada y muy bien escrita: una excelente introducción para estudiantes que no cursen doble grado.
— DEUTSCH/AHRENS, *Deliktsrecht*, 5. Aufl, Verlag Carl Heymanns Verlag, 2009. Buen libro de introdución.
— Ricardo DE ÁNGEL YÁGÜEZ, *Tratado de responsabilidad civil*, 3ª ed., Universidad de Deusto, Civitas, Bilbao, Madrid, 1993. La visión del abogado.
— Simon DEAKIN, Angus JOHNSTON, Basil MARKESINIS, *Markesinis and Deakins' Tort Law*, 6th ed., Oxford University Press, Oxford, 2007. Obra británica de referencia.
— Luis DÍEZ-PICAZO, *Fundamentos de derecho civil patrimonial*, Tomo V, 1ª ed. Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011. Referencia española: da razón del pensamiento dominante.
— Richard A. EPSTEIN/Catherine M. SHARKEY, *Cases and Materials on Torts*, 10th edition, Aspen Publishers, 2012. La experiencia (Richard Epstein) se encuentra con la juventud (Caty Sharkey) en la universidad actualmente más potente en análisis académico del derecho de daños.
— Michael FAURE, *Tort Law and Economics* (*Encyclopedia of Law and Economics*, Vol. 1, 2nd edition), Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK) – Northampton, Massachussetts (USA), 2009. La enciclopedia.
— Massimo FRANZONI (Dir.), *Trattato della Responsabilità Civile* (Vol. 1: *L'illecito*, Vol 2: *Il danno risarcibile*), 2ª ed., Dott. A. Giuffrè – Editore, Milano, 2010. Otro tratado italiano de referencia.
— James A. HENDERSON/Richard N. PEARSON/Douglas A. KYSAR/John A. SICILIANO, *The Tort Process*, 7th edition, Aspen Publishers, New York, 2007. Tres generaciones de académicos de primer nivel se concitan para producir un *case-book* extraordinario
— Mariano José HERRADOR GUARDIA (Dir.), *Derecho de daños*, Aranzadi, Cizur Menor, 2013. Las actas de un congreso de primeros especialistas en la materia.
— InDret. Revista para el análisis del derecho: www.indret.com. El origen de todo esto. Un producto muy costoso, acaso de algún valor y –para sus lectores- gratis. Editado y escrito por tres generaciones de civilistas.
— Hein KÖTZ/Gerhard WAGNER, *Deliktsrecht*, 11., neu bearbeitete Auflage, Verlag Vahlen, München, 2010. El mejor puente entre el derecho alemán, el *common law* y el moderno análisis del derecho de daños, escrito por dos especialistas de primer nivel y de distintas generaciones, un clásico. Comparte con los *case-books* angloamericanos un lenguaje admirable, pues está muy bien escrito.
— José Luis LACRUZ BERDEJO et. al., *Elementos de Derecho Civil II, Derecho de Obligaciones,* Vol. 2º, Contratos y Cuasicontratos. Delito y cuasidelito. 4ª ed., Dykinson, Madrid, 2009. Manual español de referencia.
— Ángel LÓPEZ LÓPEZ/M. Rosario VALPUESTA FERNÁNDEZ, *Tratado jurisprudencial de responsabilidad por daños*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
— Miquel MARTÍN-CASALS, La "modernización" del Derecho de la responsabilidad extracontractual", XV Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho Civil, http://www.derechocivil.net/jornadas/APDC-2011-PONENCIA-CASALS.pdf, 2011. La visión del primer comparatista español.
— Thomas J. MICELI, *The Economic Approach to Law*, 2nd edition, Stanford University Press, Stanford, 2008 (óptima introducción analítica, indicada para estudiantes de doble grado).
— *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch* (Band 5: *Schuldrecht - Besonderer Teil III §§ 705 – 853, Partnerschaftsgesellschaftsgesetz, Produkthaftungsgesetz*), 5. Auflage, C.H. Beck, 2009. Presentación clásica, panorama para práctica y academia.
— Fernando PANTALEÓN PRIETO, "Comentario al artículo 1902 CC", en Cándido PAZ-ARES, Luis DÍEZ-PICAZO, Rodrigo BERCOVITZ, Pablo SALVADOR, *Comentario del Código Civil*, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, Madrid, 1993, pp. 1971-2003. Los años transcurridos desde su publicación revalidan el comentario como la referencia clásica del derecho español de la negligencia.
— Fernando PEÑA LÓPEZ, "Comentario a los arts. 1902 a 1910 CC", en Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios al Código Civil*, 3ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2009, pp. 2153-2171. Uno de los dos mejores comentarios globales al código civil español.

— L. Fernando REGLERO CAMPOS (Coord.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, 4ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2008. El testamento de un gran profesor, prematuramente desaparecido.
— Encarna ROCA TRÍAS/Mónica NAVARRO MICHEL, *Derecho de daños. Textos y materiales*, 6ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. La voz de profesoras de dos generaciones, una de ellas magistrada del Tribunal Supremo y, desde 2011, del Tribunal Constitucional.
— SCHWARZ/WANDT, *Gesetzliche Schuldverhältnisse – Deliktsrecht, Shadensrecht, Bereicherungsrecht, GoA*, 4. Auflage, Verlag Vahlen, 2011. Imprescindible para la formación de un académico versado en *Civil Law*: el derecho de daños en la primera potencia industrial y exportadora de Europa, un país cuyos sectores de actividad están intensamente regulados y que no se puede permitir inseguridad jurídica ni incertezas de ningún tipo a la hora de delimitar las incumbencias de cada persona u organización en el marco de una división extrema y excelente del trabajo.
— Steven SHAVELL, *Foundations of Economic Analysis of Law*, 1st edition, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2004. Paradigma implacablemente neoclásico del análisis económico del derecho, sin casos.
— Geneviève VINEY, Patrice JOURDAIN, *Introduction a la responsabilité* (2008), *Les conditions de la responsabilité* (2006), *Les effets de la responsabilité* (2011), 3ème éd. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J.), (Collection Jacques GHESTIN [Dir.], *Traité de droit civil*). Manuales franceses de referencia, muy influyentes, como todo lo francés, en nuestra cultura.

3. Análisis económico del derecho / *Law and Economics*

La economía, la ciencia social que estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios (Paul KRUGMAN/Robin WELLS), puede aplicarse con buenos frutos al análisis del derecho –como también pueden serlo la psicología, la ciencia política o la sociología- y, durante el último medio siglo, lo ha sido con mucho éxito y algunos fracasos -notablemente, algunos excesos-.

El análisis económico del derecho puede ser positivo o normativo.

El análisis positivo pregunta sobre las consecuencias económicas del establecimiento y aplicación de una regulación determinada, por ejemplo, ¿qué efectos tendría establecer una regla general de defecto en cuya virtud la velocidad máxima de circulación de vehículos a motor en las vías urbanas no debe superar los treinta kilómetros por hora?

El análisis normativo pregunta sobre cuál es la mejor regla, de entre varias reales o posibles, en términos de eficiencia económica y, por ello, de entre las distintas alternativas razonablemente posibles en términos de limitación de velocidad en vías urbanas, considera preferible aquella que resulte más eficiente en términos de costes y beneficios sociales.

El análisis económico, aplicado al derecho de daños, al derecho de accidentes abordado con las técnicas de la responsabilidad civil, parte de considerar las consecuencias probables, positivas y negativas, de las distintas actividades sociales cuyo desarrollo genera accidentes.

Thomas J. MICELI (*The Economic Approach to Law*, 2nd edition, Stanford University Press, Stanford, 2008), uno de los mejores analistas económicos del derecho, señala que el riesgo de causar algún daño es el subproducto inevitable de muchas –si no de todas- las actividades sociales globalmente beneficiosas. Y aunque, escribe, normalmente no podemos eliminar el riesgo sin suprimir de raíz la actividad de que se trate, deberíamos adoptar todas las medidas, justificadas en términos de costes y beneficios, para minimizar el riesgo: deberíamos, pues, invertir en reducción de riesgos cantidades crecientes de recursos hasta el punto en que un euro adicional empleado en evitar pérdidas derivadas de los accidentes solo consigue impedir accidentes estimados justamente en otro euro.

Toda sociedad avanzada dispone de muchos medios distintos -jurídicos y no jurídicos- para controlar los riesgos derivados de las actividades peligrosas –de casi todas-, pues, además de la

responsabilidad civil, tales actividades pueden estar sujetas a regulaciones de seguridad, a impuestos, al derecho administrativo o, incluso, al derecho penal, además de estarlo a medidas físicas de seguridad o a tradiciones educativas y cívicas que nada tienen que ver con el derecho.

En todo caso, la esencia de la responsabilidad civil es la obligación potencial, asumida por el demandado, de reparar los daños causados a la víctima de un accidente y que esta -o un allegado suyo, si la víctima falleció- reclama ante un tribunal de justicia.

4. Concepto y clases de accidente, y limitaciones del derecho de daños. La minimización de los costes sociales de los accidentes

4.1. Concepto y clases de accidente

Accidente: suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas (DRAE).

Accident: *a mishap, a mischance, especially one causing injury or death* (Collins English Dictionary).

Clases de accidentes: la implosión de la distinción entre accidentes naturales y accidentes causados por conductas humanas

Tradicionalmente los accidentes pueden ser naturales o causados (o cocausados) por una conducta humana, individual o colectiva.

Ejemplos de accidentes naturales (*natural accidents, acts of God*) son los terremotos, como los de Haití y Chile, de 2010, o los maremotos (*tsunami*), como el de Japón en 2011. También los huracanes, ciclones, tormentas, inundaciones, incendios de origen natural. Los accidentes naturales no siempre son acontecimientos discretos, sino que, en ocasiones, son fenómenos que tienen lugar muy lentamente y cuyos efectos se manifiestan a lo largo de periodos muy dilatados de tiempo: así los denominados *Medieval Warm Period (950-1250*) o *The Little Ice Age, 16th-19th centuries.* Pero en estos últimos casos, la noción de accidente se difumina hasta desaparecer. Además, no todos los accidentes naturales son catastróficos (Pablo SALVADOR CODERCH/Sonia RAMOS GONZÁLEZ/Rosa MILÀ RAFEL, "Catastrophic Damages: Liability and Insurance", in Karen B. BROWN/David V. SNYDER [Eds.], *General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law*, 1st edition, Springer, New York, 2012, p. 85-103, esp. 90), sino que muchos de ellos dañan únicamente a una o a muy pocas víctimas, como la caída de un rayo o de un árbol.

Los accidentes causados por una conducta humana (*caused by human agency*) son los causados o agravados por conductas humanas, tales como los de trabajo, los de tráfico, los iatrogénicos, los domésticos.

La distinción entre accidentes naturales y accidentes causados por los seres humanos está en crisis: 2008 fue el año en el cual, por primera vez en la historia de la Humanidad, más habitantes de la Tierra vivían en ciudades que en el campo. Ciertamente, el campo es una idealización que, al menos desde la Revolución Neolítica, desde la última glaciación, hace 10.000 años, cada vez ha tenido menos que ver con la naturaleza, con el mundo silvestre, no humanizado. Tanto es así que, para muchos geólogos –rendidos a la geografía, una ciencia humana-, ya no vivimos en el Holoceno, la fase del Cuaternario posterior a la última Glaciación, sino que hemos entrado en, el Antropoceno, en la Era del Hombre (Paul Crutzen y Eugene Stoermer).

Así, el terremoto de Haití, de 12 de enero de 2010, mató quizás a 200.000 personas, pero el poco posterior de Chile, de 27 de febrero de 2010, de mayor intensidad, a menos de 600: Chile estaba mucho mejor preparado que Haití para soportar la catástrofe.

El Tsunami de Japón, de 11 de marzo de 2011, mató a casi 16.000 personas, pero su consecuencia más destacada culturalmente fue su efecto sobre la central nuclear de Fukushima Daiichi y sobre la política energética mundial de una generación.

Para muchas personas, los accidentes naturales no existen. No es así, pero el jurista hará bien en apuntar a las posibilidades que la ciencia y la técnica ponen a nuestra disposición para prevenir un accidente y los costes de todo tipo de la prevención. Un ejemplo de libro es la susceptibilidad de algunas localidades del Sureste español a un terremoto: sabemos que se producirá, pero no estamos en condiciones de decir cuándo (véase la web del Servicio de Información Sísmica del Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento).

4.2. Algunas limitaciones del derecho privado de daños

Otras distinciones en crisis son las que dividen al mundo en sistemas nacionales de derecho. Desde 2009, se discute sobre el concepto de límites, linderos o fronteras ecológicos del planeta (*environmental boundaries of the world*) que se construye sobre nueve categorías de problemas, algunas de las cuales, al menos, no reconocen fronteras políticas ni, por tanto, sistemas nacionales de derecho (cambio climático, acidificación de los océanos, desaparición de la capa de ozono, intervención en el ciclo del nitrógeno, roturación y urbanización crecientes, extinción, incremento de los polucionantes químicos y su creciente concentración en la atmósfera, difusión de transgénicos, etc.). Algunas de estas fronteras no son globales, pero otras lo son y todas obligan a poner de manifiesto las limitaciones del derecho de daños como derecho de los accidentes: tratados internacionales, políticas mundiales, derecho público y regulatorio, derecho sancionador, impulso del desarrollo tecnológico son instrumentos aparentemente más eficaces para afrontar los retos del Antropoceno que el viejo derecho nacional de daños.

Sin embargo, el derecho de daños juega un rol esencial en tanto en cuanto constituye un instrumento de cambio del derecho mismo de los accidentes, es un motor de su dinámica: típicamente, los nuevos supuestos de responsabilidad civil impulsan cambios de legislación, las iniciativas descentralizadas de los abogados especializados en responsabilidad civil anuncian con frecuencia los cambios que han de llegar.

Así, los derechos de daños son fundamentalmente nacionales, pertenecen a sistemas estatales de derecho –aunque haya macrosistemas regionales armonizados de derecho de daños, como sucede con el derecho europeo de la responsabilidad civil del fabricante--.

Los sistemas de derecho de daños están caracterizados por rasgos comunes: son, como acabamos de señalar, fundamentalmente nacionales, pero las herramientas analíticas utilizadas para su explicación y mejora son globales y por ello permiten realizar una valoración igualmente global y unitaria de cada sistema nacional. En todos ellos, podemos preguntar sobre los costes y beneficios de la responsabilidad civil –que es muy costosa de aplicar-, sobre su contribución a mejorar la eficiencia, en sentido económico, de las conductas humanas, sobre la que puedan tener, psicosociológicamente, a corregir los sentimientos de maltrato, de trato injusto, que la causación de un daño pueda haber generado en sus víctimas o en la sociedad, o sobre los efectos meramente distributivos de su aplicación, sobre sus consecuencias en la seguridad jurídica y en la certeza del derecho, o sobre sus efectos en el desarrollo tecnológico.

Luego, son sistemas basados en la aplicación privada del derecho, en el ejercicio de pretensiones resarcitorias por decisión de las víctimas de un daño o –si estas fallecieron- de sus herederos o allegados. Operan *ex post*, después de que el accidente y, por tanto, el daño hayan tenido lugar.

Y su rasgo más característico consiste en que toda acción de daños en cualquier sistema de derecho consiste en el ejercicio judicial de una pretensión tendente a la reparación del daño o a su indemnización en dinero, dirigida contra el causante del daño, la persona, natural o jurídica, que ha de responder por aquel, o la compañía aseguradora de ambos.

4.3. La minimización de los costes sociales de los accidentes (Guido CALABRESI, 1970; Steven SHAVELL, 2004) y las simplistas pero escasamente realistas asunciones iniciales de los modelos analíticos del moderno derecho de daños

Durante el último medio siglo, la noción de que el derecho de daños puede contribuir, con otras ramas del derecho, a reducir y, específicamente, a minimizar los costes sociales de los accidentes ha ido a más. Aunque los sectores doctrinales más tradicionales del derecho civil español se aferran a la idea de que el derecho de la responsabilidad civil persigue principalmente compensar daños, nadie hasta ahora ha sido capaz de negar fundadamente que la compensación perfecta supone prevención óptima: la prevención de daños es la sombra de su compensación. En efecto, a poco que nos paremos a pensar, un sistema de reglas de responsabilidad civil que consiguiera que todos los casos de accidentes por los cuales alguien ha de responder se transigieran o litigaran con el resultado de que la víctima obtuviera una compensación integral de los daños, prevendría óptimamente la ocurrencia potencial de tales daños: yo no causaré un daño evaluado en 100 si tengo la certeza de que, si lo hago, me condenarán a pagar a mi víctima tal cantidad, pero *ex ante* puedo evitar el accidente invirtiendo 75 en precauciones (75< 100) y los beneficios que obtengo de mi actividad son los mismos en ambos casos.

Al respecto, los modelos más sencillos del análisis económico parten de asunciones simples, escasamente realistas, pero heurísticamente muy fecundas, pues, en términos generales, las personas razonablemente bien informadas y que no estén trastornadas responden a los incentivos. Básicamente, los modelos parten de suponer que, primero, podemos identificar un nivel de precaución que minimiza el coste total de los accidentes para cada tipo de actividad (fabricar objetos, conducir automóviles, prestar servicios médico-sanitarios, etc.). El coste total incluye los costes privados, es decir, los que sufre la víctima, y los costes sociales, los que experimentan terceros.

En segundo lugar, los modelos asumen, también muy drásticamente, que los agentes sociales son neutrales al riesgo, que están perfectamente informados de las consecuencias de sus actos –o de sus omisiones- y que sus conductas individuales son la única causa de cada accidente, es decir, que las víctimas nada pudieron hacer para evitar el daño.

Asumen además que los individuos son económicamente racionales, es decir, que responden a los incentivos de forma tal que su comportamiento se ajusta siempre al que resulta más eficiente, dada una regla de derecho que se les aplicará inexorablemente en todos y cada uno de los casos en que hayan incurrido en una conducta dañosa por la que hayan de responder.

Finalmente, se suele suponer que las reglas de derecho de daños objeto de análisis permiten conseguir una compensación perfecta de los accidentes, de modo tal que sus víctimas son compensadas de forma tan ajustada al daño sufrido que si, antes del accidente, fueran preguntadas sobre qué preferirían, si no sufrir el accidente o sufrirlo y ser indemnizados por ello, responderían que les resultaría indiferente, le daría igual.

A lo largo de este curso, veremos que ninguna de estas asunciones puede mantenerse incólume, pero, como en otros muchos experimentos, conviene comenzar pensando qué ocurrirá si los realizamos en el vacío. Luego, tiempo habrá para complicar las condiciones de partida. Pero, por muchas complicaciones que añadamos, nunca prescindiremos de la idea básica: ***a la larga, los humanos responden a los incentivos*** (aunque el lector escéptico hará bien en recordarnos a Nietzsche cuando dijo que ***la única razón por la cual el hombre no toma el veneno es su mal sabor***).

Frente a las limitaciones del análisis moderno del derecho de daños, el análisis doctrinal tradicional insiste en la de que la responsabilidad civil pretende únicamente compensar íntegra o limitadamente daños causados, corrigiendo en su caso la injusticia generada por el daño mismo. Mas, como ya hemos señalado, si el derecho de daños en acción compensa adecuadamente, es decir, íntegramente, a todas las víctimas en todos los casos de causación de un daño por los que se haya de responder, también minimiza los costes de los accidentes de que

se trate. Últimamente, el análisis tradicional admite la función preventiva del derecho de daños, pero solo como una consecuencia de hecho, no como un efecto normativo del derecho de la responsabilidad civil. Pero la distinción entre efectos de derecho y de hecho roza la metafísica.

Mucho más relevante que la crítica anterior es otra distinta que relaciona el derecho de daños con una función correctiva, catártica, restauradora del orden jurídico y social alterado por el causante y responsable de los daños. Esta es mucho más digna de atención que la anterior y apela a la psicología social, un punto de vista desconsiderado por el análisis económico neoclásico del derecho.

Y finalmente quizás es decisiva la consideración de que el derecho no está únicamente condicionado por la economía, sino que lo está igualmente por todos los saberes científicos y tecnológicos: a largo plazo, el derecho cumple cabalmente sus funciones si trata de realizarlas a partir del estado de los conocimientos, no a su margen ni, mucho menos, en contra de ellos: la ignorancia no es fuente de derecho.

5. La acción de daños de los perjudicados por un ilícito competencial y la Propuesta de Directiva comunitaria de 11.6.2013

— Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (COM(2013) 404 final, 11.6.2013): http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html.

La responsabilidad civil también se llama responsabilidad extracontractual. El nacimiento de una obligación de indemnizar por daños causados al margen de una relación jurídica contractual puede estar asociado a la realización de una conducta penalmente típica, pero también puede estarlo a la infracción de disposiciones puramente administrativas, de derecho público, pero no necesariamente de derecho penal.

Un ejemplo crecientemente importante es el de infracciones del derecho público de la competencia, las cuales, además de violar el derecho europeo, español --o ambos—causan daños a terceros: si las empresas de una misma industria forman un cártel o una sola empresa que ocupa una posición dominante en la industria abusa de tal posición y el resultado final es que los terceros que adquieren bienes o contratan servicios de tales empresas han de pagar un precio más elevado del que habrían de pagar si el mercado funcionara en condiciones de competencia razonable, es obvio que sufren un daño y que, en principio, tal daño es indemnizable: las víctimas del daño, clientes de las empresas en cuestión, tienen una acción civil, cuyo conocimiento corresponde en principio a los tribunales civiles.

Sin embargo, los obstáculos al ejercicio de una acción de responsabilidad civil por daños derivados de la infracción del derecho de la competencia son punto menos que insalvables. Citemos algunos de ellos:

1) En primer lugar, la autoridad competencial, europea o española, habrá de haber declarado la existencia de un ilícito –de la formación de un cártel, de la existencia de un abuso de posición dominante, etc.–. En derecho europeo, el núcleo básico de la regulación relevante se encuentra en los arts. 101 y 102 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea y en el Reglamento del Consejo 1/2003, de 16 de diciembre de 2002. En derecho español, Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
2) Luego, el demandante habrá de probar que ha sufrido un daño y que este deriva precisamente de la infracción cuya existencia ha declarado la autoridad competencial, pero esta podrá, en determinadas circunstancias, negarse a facilitar la información

relevante, por ejemplo, aquella que hubiera obtenido de empresas participantes en el cártel que denunciaron su existencia para librarse de las sanciones legales o moderar su importe. En Europa continental, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, no hay *discovery* y la transparencia de las Administraciones Públicas es también más limitada a esta orilla del Océano Atlántico.

3) El derecho europeo y, por supuesto, el español, tampoco tienen tradición en materia de acciones colectivas o de clase. Miles o cientos de miles de consumidores pueden haber resultado dañados, el daño total puede ser muy elevado, pero al ser muy difuso, ningún consumidor individual tiene incentivos para reclamar y la iniciativa de una firma de abogados para acomunar las acciones individuales de los consumidores perjudicados puede encontrar muchas dificultades en la regulación procesal del Estado Miembro de que se trate.
4) Los distintos derechos nacionales europeos tampoco regulan finamente la llamada *"passing-on defence"*, una excepción en cuya virtud el demandado puede oponer que el demandante o los demandantes no sufrieron el daño que alegan, pues consiguieron repercutir sobre sus clientes y proveedores el exceso de precio cobrado por el demandado mismo al demandante. Si A, B y C constituyen un cártel y acuerdan un precio un tercio superior al que regirían en condiciones de competencia, pero sus clientes consiguen repercutir el sobreprecio en los suyos sin disminución de la demanda --ciertamente, un caso raro--, no habrán sufrido daño alguno y la excepción será oponible con éxito.
5) La ausencia de valor probatorio, en el posterior pleito civil, de las resoluciones de la autoridad competencial de que se trate.
6) La cuantificación del daño causado: el demandado puede haber cometido un ilícito, esta circunstancia puede resultar perfectamente establecida por la autoridad competencial, pero aun y así, probar la existencia y causación del daño puede resultar extraordinariamente complejo: véase Assimakis Komninos (Dir.) (2009), *Quantifiying antitrust damages – Towards non-binding guidance for courts*.

La Propuesta de Directiva trata de abordar estas cuestiones. En particular, intenta establecer un mismo equilibrio entre todos los derechos de los 28 Estados Miembros de la Unión Europea y el derecho europeo mismo, sobre la aplicación del derecho público de la competencia -*public enforcement*, aplicación pública, con técnicas de derecho público- y su aplicación privada -*private enforcement*, con instrumentos de derecho privado, en el caso, con la acción privada de responsabilidad civil, ejercitable ante tribunales civiles-.

En efecto, el ya citado Reglamento 1/2003 desarrolla las reglas de los art. 101 y 102 del Tratado, las cuales prohíben los acuerdos anticompetitivos y los abusos de posición dominante. El Reglamento establece las condiciones bajo las cuales la Comisión Europea y las autoridades competenciales nacionales (y, por supuesto, los tribunales) aplican tales disposiciones.

Además de la aplicación propiamente pública –administrativa (y, en algunos casos, penal)- del derecho de la competencia, el proyecto de Directiva establece los presupuestos de un derecho armonizado de su aplicación privada, es decir, del ejercicio de la acción de responsabilidad civil que corresponde a los perjudicados por el ilícito competencial para reclamar de los infractores una compensación razonable no solo por las pérdidas ocasionadas, sino también por las ganancias dejadas de obtener y, en su caso, los intereses correspondientes.

El proyecto trata de alinear ambos procesos de aplicación del derecho para optimizar el resultado final, intenta armonizar los distintos derechos nacionales y persigue establecer las fronteras entre aplicación pública y privada en búsqueda de un equilibrio razonable –pero en el caso europeo, muy deferente con las atribuciones y competencias de las autoridades--.

Los arts. 1 y 2 de la Directiva en proyecto establecen su alcance, esto es, las reglas necesarias para asegurar que quien haya sufrido un daños como consecuencia de las infracciones competenciales referidas en los arts. 101 y 102 del Tratado o del derecho nacional de la competencia, puedan ejercitar de forma efectiva su derecho a la compensación íntegra (*full compensation*) del caño causado (arts. 1 y 2.1), de modo tal que la víctima del daño, una vez

obtenida la compensación, se encuentre en la misma situación que estaría si la infracción no se hubiera cometido *("Full compensation shall place anyone who has suffered harm in the position in which that person would have been had the infringement not been commited"*, art. 2.2). La propuesta insiste en que los Estados Miembros habrán de asegurar que los perjudicados podrán ejercitar de forma efectiva las acciones correspondientes por responsabilidad civil (art.2.3).

En particular, el proyecto busca proteger a las empresas participantes en un ilícito competencial, pero que han facilitado su persecución pues han denunciado tempranamente la infracción y se han acogido a los programas denominados de clemencia (*leniency programmes*) establecidos por el derecho europeo y los distintos derechos nacionales (véase *Commission Notice on immunity from fines and reduction of fines in cartel cases*. OJ C 298, 08.12.2006, p. 17). El proyecto parte de la asunción, indudablemente correcta, de que, *ex ante*, el infractor y denunciante potencial del ilícito se retraerá si no recibe garantías de que, además de la anulación o moderación de la multa administrativa, no será objeto de una reclamación por responsabilidad civil en cuyo ejercicio, además, el accionante presentará como prueba la denuncia misma y los demás medios de prueba que el demandado hiciera llegar en su momento a las autoridades: todas las policías del mundo trabajan con confidentes, pero saben de sobras que sin confidencia no hay confidentes.

Lo mismo ocurre cuando los infractores o algunos de ellos cooperan activamente con la investigación y llegan a una transacción con las autoridades (*settlement submissions*): difícilmente podría haber una transacción si, luego de acordada y en el procedimiento civil subsiguiente, los demandantes por responsabilidad civil pudieran acceder a la información que está en la base de la transacción misma. En junio de 2008, la Comisión Europea introdujo un nuevo procedimiento para la transacción en casos de cárteles (*Commission Notice on the conduct of settlement procedures in view of the adoption of Decisions pursuant to Article 7 and Article 23 of Council Regulation (EC No 1/2003 in cartel cases (OJ C 167/1, 02.07.2008), and Regulation 622/2008 (OJ L 171/3, 01.07.2008) amending Regulation 773/2004*). La Comisión tiene amplia discrecionalidad y puede comunicar a las partes su predisposición a transigir el caso en el intento de llegar a un entendimiento común (*common understanding*) previo a la transacción misma (*settlement submission*). En el procedimiento, las partes intercambian la información relevante, conducente al esclarecimiento del caso y a su resolución, pero de nuevo es obvio que la transacción sería mucho más difícil de alcanzar si no se ofrecieran garantías de confidencialidad.

Finalmente y al margen de los dos supuestos anteriores, es también lógico que, mientras el procedimiento administrativo incoado para la posible declaración de la comisión de un ilícito competencial no ha sido resuelto (ni, en su caso, revisado jurisdiccionalmente), los perjudicados por el presunto ilícito competencial no pueden acceder a la información que obra en poder de la autoridad competencial de que se trate, pues ello pondría en peligro su buena gestión.

Por ello, el proyecto planea establecer un mismo nivel de protección mínimo a favor de los denunciantes amparados por un programa de clemencia, europeo o nacional:

- El art. 6. 1. establece una regla de protección absoluta en cuya virtud los Estados Miembros habrán de asegurar que, en relación con las acciones de responsabilidad civil, los tribunales nacionales no podrán desvelar en ningún momento –nunca- las manifestaciones relacionadas con los programas de clemencia (*leniency corporate statements*), ni con las transacciones (*settlement submissions*).
- El art. 6.2. establece una regla de protección temporal según la cual los Estados Miembros habrán de asegurar que, con respecto a las acciones de responsabilidad civil, los tribunales nacionales solo podrán exigir el desvelo de información específicamente preparada para un expediente iniciado por una autoridad competencial o generada por esta última, una vez la autoridad en cuestión haya resuelto definitivamente el expediente o adoptado una decisión de acuerdo con el art. 5 del Reglamento 1/2003 o su Capítulo III.

Con estas dos limitaciones, el resto de las reglas propuestas sobre revelación de información a efectos de prueba sigue la tradición europea continental –muy reacia a la *discovery*— y planea exigir a los Estados Miembros asegurar que los tribunales admitan la proposición de prueba de

las partes demandantes por responsabilidad civil con tal que la prueba sea relevante para sustanciar su caso, esté suficientemente especificada, en vista de los hechos alegados, y que resulte proporcionada, a la luz del grado de probabilidad de la comisión de la infracción, del ámbito y coste de la obtención de la información solicitada, de su naturaleza confidencial, así como de su especificidad en relación con una eventual investigación pública anterior (art. 5).

Otras reglas incluidas en la Directiva en proyecto tratan de cuestiones cuyo análisis corresponde a otros capítulos de este e-libro. Así, la muy razonable propuesta de establecer un plazo de cinco años para la prescripción de la acción (art. 10), la que establece la presunción de la causación de daños en el caso de los cárteles (art. 16), las que limitan la –tradicionalmente hipertrofiada– responsabilidad solidaria en el caso de los programas de clemencia (art. 11) y, similarmente, la que hace lo propio en el caso de transacción y a favor de la parte que ha transigido (art. 18). Mención especial merece la regulación de la *passing-on defence* (art. 12), en cuya virtud el demandado podrá siempre oponer como excepción a la demanda de daños que el actor repercutió a terceros todo exceso de su prestación (*overcharges*) derivado del ilícito competencial.

El proyecto de Directiva someramente descrito en estas páginas constituye un ejemplo destacado del nuevo derecho de daños: se trata de una regulación claramente específica de un sector muy especializado del moderno derecho regulatorio, pero que al mismo tiempo participa del conjunto de características del derecho general de daños. Quizás la mayor utilidad de este curso es su transversalidad, su potencial utilidad para integrar el derecho aplicable en una miríada de sectores intensamente regulados en los cuales los árboles han de dejar ver el bosque, la comunidad de criterios normativos y analíticos que mantiene la unidad del derecho de daños a lo largo y a lo ancho de todas las ramas del ordenamiento jurídico.

6. Responsabilidad civil y penal / *Tort and Crime*

En derecho de accidentes y en general, interesa la distinción entre derecho público y derecho privado: el derecho público establece infinidad de regulaciones que establecen, *ex ante*, cuáles son las condiciones de seguridad (precauciones) bajo las cuales puede desarrollarse tal o cual actividad y, *ex post*, las consecuencias de no haber observado las precauciones establecidas, normalmente, una multa pecuniaria, pero también, la suspensión de la actividad, su cese, o, incluso, la imposición de penas en sentido estricto (aplicación del derecho penal). En España, a diferencia de lo que ocurre en los países de nuestra área cultural, los delitos y faltas tipificados en el Código Penal comportan una pena, una sanción específicamente penal, pero además, en el mismo proceso en el cual se ventilan las eventuales responsabilidad penales de los imputados, se resuelve sobre sus responsabilidades estrictamente civiles o aquellas de las personas de quienes dependen.

El derecho penal, el derecho de la responsabilidad penal es primariamente derecho público que tutela intereses públicos: los consistentes en evitar la comisión de delitos y en restablecer la justicia quebrantada por el delincuente. El derecho civil de daños, el derecho de la responsabilidad civil no es incongruente con el anterior, pues también pretende abordar la reducción razonable o la supresión de riesgos que afectan a miembros de la colectividad o a toda ella. Pero ello se consigue, en el caso del derecho civil, con pretensiones puramente civiles ejercitadas normalmente en un proceso civil y queda siempre a la decisión del demandante la relativa al ejercicio de la pretensión de daños. El derecho de daños es privado por dos razones: el demandante elige entre accionar o no hacerlo y la indemnización que, en su caso, obtenga, quedará en su patrimonio, no es ninguna multa que engrose las arcas de la Hacienda Pública.

Sin embargo, ya hemos señalado que un mismo acto puede ser, al mismo tiempo, un delito (o falta) y un supuesto de responsabilidad civil: de derecho, todos los delitos y faltas pueden general una acción de responsabilidad civil por los daños eventualmente causados, acción que, normalmente, se ejercerá en el proceso penal, pero que los afectados pueden reservarse para ejercitarla en un proceso civil independiente (art. 112 LECr), algo que raramente sucede.

7. Responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad (también civil, pero) contractual / *Tort and Contract*

En derecho privado interesa la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual o civil (derecho de daños en sentido estricto). En una primera aproximación, la conducta cuya realización implica el incumplimiento de un contrato conlleva la responsabilidad de la parte incumplidora frente a su contraparte, pero no es considerada un supuesto de responsabilidad civil. Por ejemplo, el incumplimiento de un contrato de transporte de personas no genera responsabilidad civil aunque, claramente, pueda dar lugar a responsabilidad contractual en los términos previstos por el contrato mismo o la ley. Sin embargo, si, con ocasión del transporte, quien lo realiza, hiere o veja al viajero, este dispondrá de una pretensión específica de responsabilidad civil con independencia de las que puedan derivarse del contrato mismo.

En virtud de lo genéricamente establecido por el art. 1255 CC o, menos formalistamente, en virtud del ingenio precisamente humano, los humanos mismos y las organizaciones creadas por ellos pueden entablar relaciones contractuales muy diversas y con un contenido infinitamente diverso: el incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de una de las partes en un contrato válido da derecho a la otra a llevar a la primera ante un Juez para que este establezca las consecuencias de la infracción según el mismo contrato. Así, los deberes y obligaciones contractuales son creados por el ingenio y promesas de las partes del contrato. En cambio, los deberes derivados del derecho de daños dimanan directamente de la legislación y de los reglamentos aplicables o del derecho judicial, al margen de todo pacto o acuerdo entre las partes.

En el *Common Law,* la responsabilidad contractual es fundamentalmente objetiva, mientras que la responsabilidad civil es mayormente por negligencia. Sin embargo, en el *Civil Law* y, concretamente, en derecho español, la responsabilidad contractual parte de un principio general de negligencia, aunque la cuestión es muy discutida.

En la práctica, la dinámica del derecho de contratos es estrictamente privada: los contratos surgen y se desarrollan de abajo arriba –*bottom-up*—a partir de las soluciones ingeniadas por los abogados de las partes, para cada sector del tráfico económico, ante el desarrollo de la tecnología y la comercialización de nuevos productos y servicios cuyo acceso al mercado y distribución exigen nuevas soluciones contractuales. En cambio, la dinámica del derecho de daños, de responsabilidad civil, es regulatoria –*top-down*- o judicial –*bottom-up*, pero pública. Ello genera diferencias estructurales importantes: el derecho de contratos mira a crear o facilitar rutas comerciales, tráfico económico y solo secundariamente litigación. En cambio, el derecho de daños está centrado en la litigación, pues su énfasis está puesto en la reclamación de una indemnización de daños y perjuicios en un proceso judicial. La diferencia es tan marcada que, en algunos países, los abogados de contratos y los abogados de litigación se diferencian claramente los unos de los otros.

La **STS, 1ª, 349/2012, de 11 de junio** resuelve la cuestión relativa a si el propietario de una finca que la contamina en el ejercicio de una actividad industrial lícita y que después vende la finca misma responde extracontractualmente frente al tercer adquirente por los daños económicos sufridos.

En palabras del Tribunal Supremo:

"Se trata de decidir si una sociedad mercantil constituida por entes públicos para la regeneración y consiguiente explotación de un puerto deportivo-pesquero y su zona residencial contigua puede repercutir retrospectivamente los costes de la descontaminación a la sociedad mercantil que en tiempos contaminó la zona, y ello pese a haber tenido que cesar esta en su actividad industrial y haber vendido en su día los terrenos a bajo precio debido precisamente a su contaminación, conocida por todas las entidades que sucesivamente fueron adquiriendo derechos sobre dichos terrenos. Y esta decisión se somete por la actora-recurrente a la jurisdicción civil con base en el Código Civil pero invocando el principio "quien contamina paga"

, presente en diversas normas administrativas de protección medioambiental que se consideran aplicables al caso".

Hechos:

Ercros, S.A. "explotaba desde el primer tercio del siglo XIX una fábrica sita en un terreno de su propiedad ubicado en la fachada marítima de Badalona, y destinada a la fabricación de … productos químicos y abonos en general… siendo su actividad la de gran industria".

El 7.5.1987, la Corporación Metropolitana de Barcelona (luego Consell Comarcal Barcelonés) aprobó el Plan Especial de la Fachada Marítima de Barcelona, que contemplaba la ubicación del futuro puerto de Badalona al norte de los mencionados terrenos, y los calificaba como terrenos para pequeña y mediana industria, con la excepción de una zona destinada a uso residencial.

El 14.5.1987, Ercros, S.A. vendió mediante escritura pública a la Corporación una porción de terreno de unos 71.000 m^2 ubicada en primera línea de mar por 3.906.579 euros (650 millones de ptas.). En ese momento, el precio de mercado del terreno vendido era muy superior, de 5.318.957 euros (885 millones de ptas.). Los terrenos estaban altamente contaminados porque presentaban un elevado contenido de plomo y arsénico.

El 31.7.1987, Ercros cesó su actividad industrial y consta acreditado que, con posterioridad, el lugar fue utilizado como zona de extracción de arenas y vertido incontrolado de residuos de diferentes procedencias

En 1989, Ercros vendió el resto de los terrenos a Prima Inmobiliaria, S.A., que, a su vez, se los vendió mediante escritura pública el 9.5.1990 a Inmobiliaria Industrial Urbana, S.A. y esta, a su vez, se los vendió al ICO en 1994 en pago de deudas.

En 1991, el Ayuntamiento de Badalona decidió ubicar el puerto en los antiguos terrenos de la demanda, pese a ser conocida la contaminación de la zona por los estudios que había iniciado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en 1990, y dividió la zona en dos polígonos: uno destinado a suelo residencial y el otro a sistema portuario. El Gobierno de la Generalitat aprobó el proyecto de construcción del puerto deportivo de Badalona y otorgó a Marina Badalona, S.A., sociedad participada al 50% por el Consell Comarcal Barcelonés y el Ayuntamiento de Badalona, la concesión para la construcción y explotación del puerto, con asunción, entre otras obligaciones, de descontaminar los terrenos.

En 2001, 2002 y 2003 el Consell Comarcal Barcelonés aportó la porción de terreno que había comprador a Ercros a Marina Badalona, S.A. como aportación no dineraria con ocasión de tres sucesivas ampliaciones de capital realizadas en tales años. Del valor de la finca se descontaron en aquel momento 3.432.981 de euros (571 millones de ptas.) en concepto de gastos de descontaminación.

El 19.12.2002 y por escritura pública, ICO vendió a Marina Badalona, S.A. los terrenos que originariamente habían pertenecido a Ercros haciendo constar que tales terrenos iban a verse afectados por las obras de construcción del puerto de Badalona y que como existía un remanente de contaminación del suelo el coste de la contaminación (valorado en 8.005.481 euros) debía descontarse del precio de la venta de los terrenos, que quedaba en 11.419.230 euros.

Procedimiento:

Marina Badalona, S.A. demandó a Ercros, S.A. y le reclamó el pago de 25.444.530,10 euros por daños y perjuicios asociados a la contaminación de las fincas con base en el art. 1902 CC, pero también en haber cumplido con la obligación de descontaminación que incumbía a Ercros, por lo que invocaban la subrogación, el reembolso la repetición y el enriquecimiento injusto, así como la STSJ de Cataluña núm. 308/2004 de 28.4.2004, que habría impuesto a Ercros la obligación de descontaminación.

El 3.6.1997 la Junta de Residuos de la Generalitat de Cataluña había dirigido a Ercros, S.A. un requerimiento para que en el término de dos meses procediese a la retirada de escombros y residuos y a la realización de un estudio sobre el alcance de la contaminación. Requerimiento que fue reiterado el 26.6.1997 y el 28.11.1997. Ercros presentó un recurso administrativo contra el último requerimiento de la Junta, que fue inadmitido el 11.11.1998. Ercros, a su vez, interpuso un recurso ordinario contra la inadmisión, que el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya desestimó mediante resolución de 31.1.2000. Ercros interpuso recurso contencioso-administrativo esta última resolución y el TSJ de Cataluña en Sentencia de 28.4.2004 lo admitió en el sentido de revocar las decisiones administrativas en cuanto a sus pronunciamientos de inadmisibilidad del recurso y, entrando en el fondo del asunto, desestimó el recurso contra la resolución de la Junta de 28.11.1997:

"[E]l apartado a) del ... artículo 15 [de la Ley 6/1993, de 15 de julio, de residuos de Cataluña] considera como responsable directo de la regeneración de los espacios degradados por descargas incontroladas a la persona que ha efectuado la descarga y solidariamente al productor o el poseedor del residuo, siendo responsable únicamente subsidiario de la misma..., según su apartado b), el propietario de la finca ...o en su caso el titular del dominio público afectado, y constituyendo obligación del productor y del poseedor de los residuos, según el art. 17.1.a), la de garantizar su gestión de acuerdo con sus prescripciones desde luego inmediatamente aplicables a un requerimiento de descontaminación producido bajo su vigencia, y ante una contaminación que se mantuvo en el tiempo tras ella, cualesquiera que fuesen los acuerdos, privados o incluso de carácter o alcance urbanístico, que pudieran haberse alcanzado al momento de la venta de los terrenos" (FD. 5º).

La SJPI nº 27 Barcelona (8.1.2008) estimó en parte la demanda y condenó a Ercros al pago de 8.895.785,28 euros. En apelación, la AP (Sección 16ª) de Barcelona (31.3.2009) estimó el recurso de apelación interpuesto por Ercros, S.A., desestimó el de la demandante, y revocó la SJPI, desestimando la demanda:

"El coste de la descontaminación de un suelo contaminado debe ponerse en relación con el uso urbanístico de ese suelo... [en este sentido, art. 15 Ley 6/1993, en su redacción dada por la Ley 9/1998, y actual art. 19 b Decret Legislatiu *1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus*: "Que les persones causants de la contaminació d'un emplaçament resten obligades a sanejar-lo en funció de l'ús urbanístic que tenia quan el van transmetre. No es poden requerir mesures de sanejament complementàries vinculades als nous usos urbanístics del sòl, llevat que hagin estat promoguts per elles mateixes" (…)

"[L]a reclamación fundada en el art. 1902 producía una sensación de perplejidad porque los daños se habrían causado a una finca propia de la demandada cuando ejercía una actividad industrial que cesó en 1987;... descartada cualquier obligación contractual de Ercros para con Marina, ya que ésta no compró directamente los terrenos a aquella ni funda su demanda en acciones derivadas del contrato de compraventa, tampoco cabía la responsabilidad extracontractual por faltar el elemento de alteridad, como consideró la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008 rectificando el criterio de la de 29 de octubre del mismo año...; en último extremo, la acción para exigir responsabilidad civil extracontractual habría prescrito conforme al art. 1968 CC, pues el caso no sería de daños continuados sino permanentes y, además, conocidos desde mucho años antes de la interposición de la demanda, de modo que nada habría impedido... reclamar en su momento por los daños, al margen de una responsabilidad por saneamiento que parece haber sido asumida y resuelta convencionalmente en su momento" (...)

"La demandante no hizo propiamente una regeneración del solar por sustitución de una obligación concreta y exigible a la demandada impuesta por la Administración en interés general, sino que lo que hizo fue urbanizar la zona en propio interés y, ciertamente, ello implicó la descontaminación de la finca" (FD. 2º STS).

Marina Badalona, S.A. interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. El segundo, por infracción de los arts. 1210 y 1158 CC, arts. 33, 43 y 45 CE y art. 1902 CC, así como por infracción del art. 1968 CC. El TS desestimó ambos recursos y confirmó la SAP:

"[E]ntre los dos referidos criterios opuestos de decisión [el de la STS, 1ª, de 29.10.2008 (RJ 5801), en la que el Tribunal Supremo condenó a Ercros con base en la responsabilidad extracontractual y el de la STS, 1ª, núm. 1135/2008 de 22.12.2008, en la que el Tribunal, en

cambio, le absolvió porque los daños fueron causados a una finca propia] esta Sala considera que debe reiterar [el segundo criterio, según el cual] (FD. 4º):

"Cuando se trata de daños originados en la cosa vendida … el daño sufrido por el comprador resulta, en principio, del deficiente cumplimiento o del incumplimiento del contrato de compraventa; la relación de responsabilidad que resulta del cumplimiento o deficiente incumplimiento tiene el mismo alcance subjetivo que el que media, dentro de la órbita contractual, entre el que causa el daño (vendedor) y el que lo recibe (comprador); el ordenamiento jurídico prevé consecuencias específicas para los casos de defectos en la cosa vendida; y, finalmente, los bienes afectados son de carácter patrimonial, en tanto no se demuestre la afectación de bienes o derechos de mayor trascendencia. En suma, los daños originados en la cosa vendida que suponen un menoscabo de su valor o una imposibilidad de dedicarla al uso al que está destinada deben ser reclamados mediante el ejercicio de las acciones contractuales que correspondan, entre las cuales figuran las acciones para pedir el saneamiento de la cosa por vicios o defectos ocultos (acción redhibitoria y *quanti minoris* [de disminución del precio 'en cuanto menos']) o la acción resolutoria dimanante del incumplimiento del contrato cuando la cosa entregada es sustancialmente distinta de aquélla que se pactó como objeto de la compraventa o inhábil para el uso a que se destina (una cosa por otra, o *aliud pro alio*).

Esta reclamación debe ir dirigida contra el vendedor mediante, si procede, la subrogación que a tenor del artículo 1511 CC se opera en favor del comprador respecto de las acciones que corresponden al primero contra los transmisores anteriores…

El hecho de que el comprador no sea el primer adquirente no lo autoriza por sí mismo para el ejercicio de acciones de responsabilidad extracontractual contra los anteriores propietarios por los daños que haya sufrido la cosa vendida" (FD. 4º, véase un análisis de las SSTS de 2008 en Sonia RAMOS GONZÁLEZ y Rosa MILÀ RAFEL, "Responsabilidad civil y daños a los propios bienes", InDret 3/2009).

En último extremo, aunque se admitiera una obligación *ex lege* de Ercros, resultaría que esta ya se habría cumplido frente a la demandante, como razona la sentencia impugnada, mediante los sucesivos descuentos del coste de la descontaminación en los negocios jurídicos privados de transmisión de los terrenos" (FD. 5º).

8. ¿Es el derecho de daños una especialidad bien definida?

Sí, pero quizás sólo por oposición al derecho de la responsabilidad contractual o al derecho sancionador y, desde luego, está mucho menos definido en España que en otros países, señaladamente, que en los Estados Unidos de América.

El derecho de daños tiene una especificidad clara y distinta si se analiza desde el punto de vista del remedio típico que le es paradigmáticamente propio: las acciones de reparación e indemnización de daños. **Los remedios dan unidad al derecho de daños**.

Pero casi nada más lo hace: hoy en día, en un país occidental tecnológicamente avanzado es crecientemente difícil de concebir que una abogada esté especializada, al mismo tiempo, en litigación derivada de difamación, de protección de datos, de daños masivos, de accidentes de circulación, de daños biofarmacéuticos, de prevención de riesgos laborales, de exposición a sustancias tóxicas, etc. La razón es que el derecho de daños descansa sobre regulaciones crecientemente intrincadas y su conocimiento y dominio es, en la práctica, condición necesaria de la viabilidad de un escrito de demanda de reclamación de cantidad por daños y perjuicios. Nadie domina a la vez el acoso sexual, la difamación, la litigación por inhalación de sustancias tóxicas o los accidentes de aviación. Ya no.

Mas queda, anclado bien en el análisis de los remedios, algún otro punto de apoyo a la idea de la unidad positiva del derecho de daños –es decir, a la idea de que este se define por algo más que por su contraposición al derecho de contratos, al derecho penal y al derecho regulatorio---

Así, y en primer lugar, la cuestión de la culpa, de la negligencia del demandado ocupa un lugar central en casi todos los casos de derecho de daños regidos por el estándar de la culpa misma, como es el supuesto general del derecho del art. 1902 del Código Civil español de 1889.

Más aún, en torno a las cuestiones la causalidad en sentido amplio, que abarcan la causalidad empírica o de hecho (*Cause in Fact*) y causalidad, de derecho, normativa o imputación objetiva (*Proximate Causation, Scope of Liability*), comunes a la responsabilidad por negligencia y a la objetiva.

Luego, la naturaleza esencialmente procesal del ejercicio de las acciones y pretensiones de derecho de daños centran a la responsabilidad civil en torno a su litigación y transacción: a diferencia del derecho de contratos, que es extrajudicial y *ex ante*, el derecho de daños es judicial y *ex post*. En los países con juicio de jurado para la responsabilidad civil, la unidad procesal y profesional del derecho de daños aún es más marcada, pero no es el caso de España.

Finalmente, esencial al derecho de daños, es su dinamismo: el cambio forma parte de su naturaleza. El contrato pretende atar el futuro, el derecho de daños reanudar el pasado.

Capítulo 2º
Las cuatro reglas básicas de responsabilidad y los límites del derecho de daños

1. Las cuatro reglas básicas de responsabilidad: ausencia de responsabilidad, dolo, culpa o negligencia y responsabilidad objetiva/*Basis: No Liability, Intentional Torts, Negligent Torts, and Strict Liability.* El límite de la responsabilidad absoluta 28
1.1. La regla de la ausencia de responsabilidad (*No liability*): sobre la libertad de actuar sin miedo a sus consecuencias dañinas para terceros 28
1.2. La causación dolosa, intencional, de daños 30
1.3. La regla de la negligencia 31
1.4. La regla de la responsabilidad objetiva 34

1. Las cuatro reglas básicas de responsabilidad: ausencia de responsabilidad, dolo, culpa o negligencia y responsabilidad objetiva/*Basis: No Liability, Intentional Torts, Negligent Torts, and Strict Liability.* El límite de la responsabilidad absoluta

Como hemos visto en el capítulo 1º, en responsabilidad civil, las circunstancias en las cuales el demandado ha de responder por los daños sufridos por la víctima son muy diversas y dependen de la regulación y la jurisprudencia aplicables al caso. Pero, en términos muy generales, hay cuatro grandes reglas de responsabilidad civil:

1.1. La regla de la ausencia de responsabilidad (*No liability*): sobre la libertad de actuar sin miedo a sus consecuencias dañinas para terceros

El estatuto más básico de una conducta dañina –pero más beneficiosa que dañina—es aquel según el cual su realización no comporta ningún deber de indemnizar a sus víctimas. Contra lo que a menudo se cree, la regla de la no responsabilidad es, afortunadamente, muy frecuente: las pérdidas se quedan donde se han producido; los daños, allí donde han tenido lugar.

Un soldado, jurista y juez norteamericano, Oliver Wendell Holmes, Jr. (1841-1935) expresó muy gráficamente esta idea, en su obra *The Common Law* (1881):

"Sound policy lets the losses lie where they fall except where a special reason can be shown for interference".

Muchos siglos antes, el Derecho romano lo había hecho con laconismo:

"casum sentit dominus".

Y en España lo mismo ha escrito la magistrada Encarna Roca en la Introducción a la 6ª edición de *Derecho de Daños. Textos y Materiales* (en colaboración con Mónica Navarro):

"En este libro se parte de un principio general: la persona que sufre un daño está obligada a asumir sus consecuencias, excepto si existen razones jurídicas para trasladarlas a quien lo ha producido" (p. 15).

Si la regla aplicable es la de ausencia de responsabilidad por los propios actos, no hay indemnización por daños, las víctimas se lamen sus propias heridas –si sobreviven a ellas- y el mundo sigue su curso. La regla incentiva niveles máximos de precaución en las víctimas potenciales (para evitar sufrir el daño), pero también un nivel cero de precaución en los causantes potenciales de daños (pues no habrá de pechar con sus consecuencias). La regla parte de que, para tales o cuales conductas, es preferible un principio de libertad individual sin consideración a los daños que la actividad de que se trate puede causar a terceros:

- Alguno de ustedes estará, sin duda, resfriado, pero sus compañeros no tienen derecho a reclamar indemnización alguna si, por ello, se contagian, mucho menos a exigirle que se quede en su casa, en cuarentena, hasta que cure del resfriado (en cambio, si hubiera contraído la tuberculosis, una enfermedad grave, quizás podrían reclamar por el contagio sufrido si el primer enfermo no adoptó precaución alguna).

- Todos ustedes tienen que soportar que su vecino compre el diario o se conecte a la radio en i-Tunes que ustedes detestan, que se peine, deje de hacerlo o que se atilde como guste o, más opinablemente, que se vista o medio desvista como le plazca.

- En nuestro derecho, nadie tiene derecho a ser amado, es decir, nadie puede ejercitar una pretensión judicial –una pretensión indemnizatoria, en nuestro caso– porque otra persona se niega a quererle, a amarle: no hay derecho al amor aunque ello pueda causar el suicidio del desesperado amante [***The Sorrows of Young Werther*** (*Die Leiden des jungen Werthers*) una novela de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), publicada en 1774]. Más discutiblemente, nadie tiene derecho a seguir siendo amado, aunque algunos juristas defienden que la infidelidad matrimonial y sus consecuencias biológicas deberían dar lugar a una pretensión indemnizatoria a favor del cónyuge afligido por ella.

- Parecidamente, varios aficionados a la práctica del noble deporte del rugby pueden decidir fundar un club deportivo, contratar un seguro de daños y comprometerse a no obligarse a responder recíprocamente por las lesiones causadas en el juego. En general y en derecho de contratos, las partes pueden excluir limitadamente su responsabilidad por accidentes. A cambio de ello, la ley puede exigirles que contraten un seguro obligatorio de accidentes y, en todo, caso prohíbe la exclusión de responsabilidad por daños causados dolosa, intencionadamente, o acaso también los causados por negligencia muy grave, rayana en el dolo.

- Tampoco responden los padres ante un hijo suyo por el hecho de haberle traído al mundo en condiciones tales que el hijo dice luego que preferiría no haber nacido -o alguien lo dice por él, una asociación o una fundación, por ejemplo-. El derecho de familia obliga a los padres a cuidar al hijo precisado de ayuda, pero no concede a éste una pretensión de daños contra aquéllos. El derecho de daños se niega a comparar una vida dura, acaso invivible para muchos, con el vacío absoluto del nihilismo. Pero incluso esto también resulta polémico para algunas personas que se niegan a traer hijos a este mundo, por no tener que convivir con seres temporalmente heterónomos y absolutamente dependientes, al tiempo que defienden que quienes lo hagan, respondan por ello en casos como el presentado aquí.

- La competencia, sumada al desarrollo tecnológico, es, literalmente, destrucción creadora: las tabletas han arrasado las librerías tradicionales del mismo modo que la bombilla de Edison acabó con las cererías y el motor de explosión con las caballerías, o que LED está ahora acabando con las bombillas incandescentes y el motor eléctrico pueda acabar desplazando al de explosión. Pero competencia no es competencia desleal. Es, simplemente, competencia. Causa daños, causa muchos más beneficios que daños, disloca comunidades, acaba con estilos de vida cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, pero, en una sociedad abierta, no impide que una comunidad resuelva libremente vivir al margen del desarrollo tecnológico y de la competencia misma (un claustro monástico, una comunidad de Amish, otra neorrural, etc.), eso también, de modo mucho más sencillo y probablemente menos rico que el del resto de los consociados.

- En general, el ejercicio legítimo de cualesquiera derechos fundamentales puede originar y, de hecho, origina daños, pero son daños por los cuales el causante no habrá de responder. Una madre atea puede llegar a precisar asistencia psicológica, incluso a enfermar después de que su hijo entre en religión y un padre puede pasar por lo mismo o peor porque su hijo deja el oficio paterno, aborrece la ideología de los abuelos o abandona el país que les vio nacer a todos. Pero, afortunadamente, es ley de vida. Igualmente, mis vecinos pueden comprar los diarios, ver las películas o ser socios de los clubes que detesto, practicar la religión, educar a sus hijos, o votar de los modos más alejados a aquellos que considero apropiados para hacer real mi idea del bien común. Y así sucesivamente: no hay responsabilidad.

STS, 1ª, 270/2006, de 9 de marzo. Asunción de riesgo en la práctica deportiva.

El 16.11.1991, Luis Manuel, quien jugaba a golf en el "Club de Golf Terramar" de Sitges, falleció tras recibir el impacto de una pelota lanzada por Ismael, que se encontraba en una calle distinta y separada de la de la víctima por una arboleda que impedía a ambos jugadores verse. El lanzamiento en cuestión había sido técnicamente incorrecto a causa del viento que soplaba en la zona.

Lucía, viuda del fallecido, en su nombre y en el de sus hijos menores, demandó a Ismael, al "Club de Golf Terramar", a "La Estrella S.A. de Seguros" y a "Plus Ultra Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros", y solicitó una indemnización de 281.237 € de las tres primeras y de 1.803 € de la cuarta.

El JPI nº 2 de Vilanova i la Geltrú (22.5.1996) estimó en parte la demanda y condenó al pago de 111.908 €, con el límite de 1.803 € para "Plus Ultra Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros". La AP de Barcelona (Sección 15ª, 12.5.1999) estimó los recursos de "Club de Golf Terramar", "La Estrella S.A. de Seguros" e Ismael, a quienes absolvió.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por Lucía:

"La idea del riesgo, fundada en la explotación de actividades, industrias, instrumentos o materiales peligrosos, y en los beneficios que a través de ello se obtienen, en modo alguno puede trasladarse a la práctica deportiva, no organizativa, para fundamentar un régimen de responsabilidad distinto del de la culpa. Se asume el riesgo desde la idea de que se conoce y se participa de él y de que el jugador es consciente de que no existe en el desarrollo de una buena práctica deportiva, más allá de lo que impone la actividad en concreto, porque confía en la actuación de los demás" (F.D. 3º).

Así, la regla de no responsabilidad consigue básicamente dos cosas: potencia la libertad individual o colectiva por el procedimiento de demarcar o fijar los límites de las actividades por cuyo desarrollo y consecuencias no se habrá de responder, y ahorra de paso los costes de compensar accidentes, caso por caso, por responsabilidad civil, que es una institución jurídica muy cara de gestionar (típicamente por cada euro gastado en un caso litigado y ganado por el demandante, la mitad, cincuenta céntimos, se quedan por el camino).

Su contraria, una regla de responsabilidad absoluta y universal, por todos los daños derivados de la convivencia, del roce social, nos arruinaría a todos, nos paralizaría y la sociedad colapsaría en pocos años. Nadie defiende seriamente semejante totalitarismo del derecho de daños. No existe tal regla en ningún ordenamiento del mundo. Asombrosamente, muchos la piden. Sin pensar.

1.2. La causación dolosa, intencional, de daños

Es el caso más grave y, desde luego, es difícil encontrar un supuesto de causación intencional de daños, sobre todo si tiene como consecuencia la muerte o las lesiones de la víctima, que no constituya un delito o una falta tipificados por el Código Penal, además de ser un ilícito civil. Pero, en todo caso, junto con la responsabilidad penal surgirá la civil, la cual, con independencia

de la anterior, obligará al imputado o a las personas de quienes dependiera a reparar los daños causados.

El dolo es grave en todos los sistemas jurídicos históricos y contemporáneos y es intuitivo que así sea:

- La probabilidad de causar dolosamente un daño suele ser mayor que la de causar el mismo tipo de daño con una conducta similar pero simplemente descuidada o negligente.

- Luego, el causante doloso de daños destruye riqueza dos veces: cuando se hace con el instrumento dañino y cuando lo usa.

- Finalmente, la psicología explica bien por qué los miembros de casi cualquier sociedad reaccionan de manera mucho más intensamente hostil contra quienes les causan daños de intento, a sabiendas y, a menudo, con la precisa voluntad de hacer daño. En el fondo, el principio básico de justicia correctiva, de retribución, en cuya virtud quien ha causado un daño -y sobre todo, quien lo ha causado a ciencia y conciencia-- ha de pagar por ello está presente en todas la culturas históricas y contemporáneas (Neil VIDMAR, "Retribution and Revenge", en Joseph SANDERS/V. Lee HAMILTON [Eds.], *Handbook of Justice Research in Law*, reprint of 1st ed. 2001, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2010). El reto más serio al análisis económico del derecho de daños proviene de la psicología y de la psicología social, que muestran tanto que la conducta humana no siempre es económicamente racional como que la revancha, el rencor y el resentimiento forman parte de la condición humana. Otra cosa es que, paradójicamente, castigar pueda ser mucho más costoso para la víctima que perdonar y olvidar (Kevin M. CARLSMITH/Daniel T. GILBERT/Timothy T. WILSON, "The Paradoxical Consequences of Revenge", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 95, No. 6, 2008, p. 1316–1324).

1.3. La regla de la negligencia

La causación de daños por culpa o negligencia, por descuido más o menos grave, es decir, por no haber puesto en práctica, al desarrollar tal o cual actividad, las precauciones razonablemente exigibles, es el supuesto de partida de nuestro sistema jurídico en derecho privado: todos estamos sujetos a deberes de cuidado, de precaución, y si al llevar a cabo una actividad los infringimos, habremos de responder civilmente por los daños causados, es decir, habremos de repararlos, normalmente, indemnizando al demandante.

Además de definirse como infracción de deberes de cuidado, la negligencia puede caracterizarse como creación o incremento irrazonable de riesgos: toda actividad humana comporta riesgos –si estoy resfriado y salgo de casa puedo contagiar a las personas que se acerquen a mí-, pero la mayor parte de los riesgos normalmente asociados a una conducta son riesgos permitidos –ni la ley ni los tribunales me obligan a quedarme encerrado en casa por un simple resfriado-. Mi responsabilidad comienza allí donde el nivel razonable, socialmente admisible, económicamente sostenible, psicológicamente tolerable, éticamente soportable de riesgos sobrepasa el umbral de los riesgos permitidos –si soy un médico internista y he de trabajar en una unidad de cuidados intensivos, tal vez deba abstenerme de acudir a mi hospital si estoy muy constipado; si soy seropositivo de VIH, habré de abstenerme de tener contactos sexuales sin protección adecuada-.

La regla de la responsabilidad por culpa o negligencia está presupuesta en el art. 1902 del Código Civil, pero no está definida allí.

El análisis doctrinal del *tort* de la *Negligence* en el *Common Law* distingue varios elementos -tres, cuatro o cinco, según los puntos de vista [David G. OWEN, "The Five elements of Negligence" 35 Hofstra L.R. 1671 (2007)]:

1) y 2) Existencia de un deber de precaución o de cuidado, establecido por la ley, los reglamentos o la jurisprudencia, que desarrolla la ley o que concreta estándares sociales de razonabilidad en cada sector de actividad (*Duty of care*); e infracción de tal deber (*Breach of*

duty. En la cultura jurídica alemana se habla parecidamente de *Verkehrspflichten*, "deberes del tráfico" atendidas las circunstancias, de acuerdo con el criterio de un tercero, observador razonable). Si se prefiere, se puede concebir la negligencia como la creación o incrementos irrazonables de un riesgo de causar un daño, pero este punto de vista tiene ventajas (permite cuantificar mejor la gravedad del riesgo generado o incrementado) e inconvenientes (oscurece la doble caracterización del deber y de su infracción).

La idea, escribe Shavell, es "that an injurer is held liable for the accident losses he causes only if he was negligent, that is only if his level of care was less than a level called due care that the courts specify" (*Foundations*, p. 180).

3) Daño, causado a los bienes sobre los cuales el demandante tiene algún derecho de propiedad o similar (*property harm*); o daño causado a su persona: muerte (*wrongful death*, en cuyo caso el demandante no será obviamente la víctima), daño corporal (*bodily injury*), pero también daños morales (*pain and suffering*); también daños puramente económicos (*economic losses*), es decir, no derivados de un daño personal o material, pero solo en algunos casos.

4) y 5) Causalidad naturalística o de hecho (*cause of fact*) y de Derecho o imputación objetiva (*proximate causation, scope of liability*). Relación entre la causa, la conducta precisamente negligente del demandado, y el efecto, el daño sufrido por la víctima. Para la causalidad de hecho, suele seguirse el test de la *condicio sine qua non, But-For test*: de no haber sido por la negligencia del demandado su víctima no habría sufrido el daño causado. Mas, como veremos, el *test* es muy burdo. Los criterios de causalidad jurídica tratan de acotar el alcance infinito de la causalidad de hecho: también muy aproximadamente, requieren que entre la conducta negligente del causante material del daño y el daño mismo la relación de causalidad sea razonablemente próxima: no se condena al bisabuelo por los daños causados por alguno de sus biznietos.

Una buena definición de negligencia se encuentra en el ***§ 3 Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm*** (2010), del *American Law Institute* (ALI):

"A person acts negligently if the person does not exercise reasonable care under all the circumstances. Primary factors to consider in ascertaining whether the person's conduct lacks reasonable care are the foreseeable likelihood that the person's conduct will result in harm, the foreseeable severity of any harm that may ensue, and the burden of precautions to eliminate or reduce the risk of harm".

La regla de la negligencia incentiva precaución adecuada en el agente de la actividad arriesgada, peligrosa, pero ninguna en su víctima potencial (si el daño que puede sufrir es compensable, reparable: muchos no lo son y sus víctimas potenciales tratan por ello de evitar sufrirlos).

La regla de la negligencia simple mira solo al causante potencial de daños, al demandado, no a su víctima potencial, al demandante ni a su conducta. La unilateralidad de la regla de la negligencia, su falta de consideración al comportamiento de la víctima potencial no es, por definición, problema alguno en la causación precisamente unilateral de daños, es decir, en un acontencimiento dañoso tal que la víctima nada pudo hacer por evitar o paliar el daño causado.

Así, un ejemplo posible de negligencia médica (*medical malpractice*) –aunque se discutió en el caso- es el planteado y resuelto por la **STS, 1ª, 1152/2002, de 29 de noviembre**: el cirujano demandado había intervenido quirúrgicamente, en diciembre de 1974, a un hombre de 34 años de edad para extirparle un tumor en su espina dorsal. Durante la operación, el cirujano dejó olvidada una gasa alrededor de la columna lumbar del paciente y, por ello, hubo de intervenirle de nuevo tres meses más tarde para retirarla. Con posteridad a esta segunda operación, el paciente presentó unas secuelas irreversibles que dieron lugar a su incapacidad permanente y demandó al cirujano una indemnización de 240.000 euros.

Otro caso, esta vez, absolutamente claro, de negligencia unilateral es el que resolvió la **STS, 1ª, 813/1997, de 26 de septiembre**, que trataremos al inicio de la sesión 3ª: la víctima, una mujer de edad madura, se había sometido, a principios de año 1984, a una operación de extirpación

de un quiste ovárico en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Un tornillo minúsculo (4x3 mm.) se soltó de uno de los aparatos empleados durante la intervención, pero ni el el cirujano ni sus ayudantes se percataron de ello. Años después, la presencia del tornillo en el abdomen de la víctima fue detectada casualmente con ocasión de unas radiografías practicadas a la paciente con motivo de un accidente doméstico. En junio de 1987, operaron de nuevo a la actora para retirarle el tornillo que había acabado por adherirse a su útero, por lo que fue preciso practicarle una histerectomía. La víctima demandó al cirujano de la primera intervención y al Instituto Nacional de Salud (INSALUD) del que dependía. En la demanda solicitaba una indemnización de 60.000 euros, que le fueron concedidas por la primera instancia. La Audiencia Provincial de Zaragoza y el Tribunal Supremo desestimaron el recurso presentado por el INSALUD.

La **STS, 1ª, 340/2011, de 20 de mayo** recoge la doctrina jurisprudencial según la cual la responsabilidad civil del médico es en todo caso por negligencia: el 30.6.2005, Agustina, de 52 años, fue intervenida en la Clínica Clideba (Badajoz) de artrodesis instrumentalizada lumbar L4-L5 con tornillos pediculares y prótesis espaciadora intersomáticas por presentar espondilolistesis L4-L5 estenosis del canal L4-L5 y hernia foraminal L5-S1. Tras dicha intervención, se detectó la existencia de un sangrado abdominal precisándose el traslado de la paciente al Hospital Infanta Cristina, donde se procedió a ligar la arteria hipogástrica y al lavado de la cavidad. El 11.7.2005, Agustina fue reintervenida quirúrgicamente de sigma, pero falleció el 4.8.2005. La causa de la muerte fue el shock séptico inducido por la ligadura de la arteria mesentérica inferior, que, a su vez, había provocado una falta de riego y consiguiente necrosis isquémica del sigma del paciente y posterior sepsis al perforarse el sigma con desalojo de material fecal de la propia paciente.

Gaspar y sus cinco hijos, Maximino, Vicente, Abelardo, Zaira y Daniela (marido e hijos de Agustina) demandaron a Eugenio (neurocirujano), a la Compañía de Seguros Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) y a la Compañía de Seguros Caser Salud, en reclamación de la suma de 525.000 euros.

El JPI nº1 de Badajoz (28.5.2007) estimó en parte la demanda y condenó a la Compañía de Seguros Caser Salud al pago de 46.583,47€ a Gaspar, 7.763,91€ a Daniela y 3.881,95€ al resto de los demandantes.

La AP de Badajoz (Sección 2ª, 16.11.2007) desestimó sendos recursos de apelación interpuestos por Gaspar y sus cinco hijos y la Compañía de Seguros Caser Salud.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por los actores:

"La obligación del médico es de medios y no de resultados y estos medios que se deben poner a disposición del paciente se deben valorar no sólo en función de la economía del contrato de prestación de servicios médico-sanitarios sino en razón a los que derivan de esta relación y conoce la paciente, sin que sea posible cuestionar la actuación médico-sanitaria fundándose en la evolución posterior de la misma, lo que se conoce como la prohibición de regreso, para responsabilizar al médico de la materialización de un riesgo excepcional del que había sido previamente informada la paciente, que hacía innecesarios más medios de los que se disponían en esos momentos en una previsión lógica y ponderada de la intervención quirúrgica llevada a cabo." (FD 2º). Además, "[…] la responsabilidad fundada en la Ley de Consumidores y Usuarios no afecta a los actos médicos propiamente dichos, dado que es inherente a los mismos la aplicación de criterios de responsabilidad fundados en la negligencia por incumplimiento de la *lex artis ad hoc*. Por consiguiente, la responsabilidad establecida por la legislación de consumidores únicamente es aplicable en relación con los aspectos organizativos o de prestación de servicios sanitarios." (FD 3º)

Adelantemos que la regla de responsabilidad por negligencia permite controlar bien la calidad de la actividad, pero no su cantidad, el nivel de la actividad misma. Baste hoy con dejar dicho que la regla de la negligencia solo funciona bien si su contenido captura todas las dimensiones de la precaución (la calidad exigible de la actividad, pero también su nivel o cantidad, por ejemplo). Dicho sea a modo de ejemplo: un cirujano precavido interviene a sus pacientes, de

acuerdo con las reglas de la profesión médica, la *lex artis*, pero no trabaja 24 horas seguidas sino que descansa entre operación y operación.

Sobre el concepto económico de negligencia en *United States v. Carroll Towing Co.* (159 F2d Cr. 1947), el caso de derecho de daños más famoso del siglo XX, véase el apartado 2.2.3.

1.4. La regla de la responsabilidad objetiva

El tercer gran supuesto de responsabilidad civil es la denominada responsabilidad objetiva o por riesgo, que cubre los casos en los cuales el demandado responde por los daños que ha causado simplemente por haberlo hecho aunque no haya habido ningún género de culpa o negligencia –ningún incremento irrazonable de riesgos o ninguna infracción de deberes de cuidado--.

En el derecho comparado de los países tecnológica y económicamente avanzados, el criterio más común en esta materia es que la responsabilidad objetiva requiere una decisión legal que la establezca o una jurisprudencia que la justifique sostenidamente. En el derecho español, la responsabilidad objetiva no es la regla general de defecto de llegada en derecho privado – lo es la responsabilidad por culpa, art. 1902 CC—, pero, por razones históricas asociadas con la pobreza endémica de nuestro país y la influencia del derecho de la expropiación forzosa, es el principio general del cual partió el legislador administrativo al establecer la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, art. 139 L. 30/1992. Sin embargo, el sistema es impracticable –por ejemplo, no se puede aplicar a los casos de responsabilidad por omisión— y en la vida legal cotidiana, las soluciones a las que llega la Sala 3ª del Tribunal Supremo (que parte de un estándar de responsabilidad objetiva) no son muy distintas de aquellas adoptadas por su Sala 1ª (que lo hace de otro de negligencia): dicho en términos aproximados, sería contrario al buen sentido que el paciente de una clínica privada dispusiera de una pretensión por daños culposos mientras que el de un hospital público tuviera una pretensión por responsabilidad objetiva; o que el alumno de una escuela privada estuviera sujeto a un régimen distinto al de una escuela pública. Tiempo habrá de discutir esta cuestión, pero aquí bastará con dejar apuntado que los regímenes de responsabilidad han de establecerse, en su caso, por sectores o tipos de actividad, no por la condición, pública o privada, de quienes la realizan. Con todas las salvedades que correspondan, el principio general es que una actividad que pueden llevar a cabo tanto agentes públicos como privados ha de estar sujeta a un mismo régimen de responsabilidad por daños. A igualdad de actividad corresponde igualdad de estándar de responsabilidad.

De acuerdo con la regla de la responsabilidad objetiva, los agentes sociales responden por todos los daños que causan aunque no hayan incurrido en culpa o negligencia alguna: es responsabilidad por mera causación de daños, por creación de un riesgo que, en el caso, se concreta en un daño sufrido por un tercero.

La responsabilidad objetiva se llama, en inglés, *strict liability*: "injurers must pay for all accidents losses that they cause" (Shavell, *Foundations*, p. 179).Los alemanes hablan de *Gefährdungshaftung,* responsabilidad por riesgo. Y los italianos de *responsabilità per rischio*. En España, algunos autores escriben "responsabilidad objetiva" y otros "responsabilidad por riesgo". En este e-libro se sigue la primera convención.

La regla de la responsabilidad objetiva incentiva a los causantes potenciales de daños a adoptar los niveles requeridos de precaución, pero no incentiva a sus víctimas potenciales a adoptar ningún género de cuidado (siempre que los daños puedan ser reparados sin demasiados problemas, muchos no pueden serlo: solo se muere una vez, por ejemplo). Asimismo, la responsabilidad objetiva permite controlar no sólo la calidad de la precaución de los agentes de actividad, sino también su nivel mismo de actividad, también la cantidad, por tanto.

En derecho privado español, la responsabilidad objetiva no es la regla general, sino que requiere mandato legal, al menos en principio:

- Accidentes de circulación: Real Decreto Legislativo 8/2004**,** de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

- Administraciones públicas: arts. 139 y ss. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Animales: art. 1905 CC.

- Caza: art. 33.5 Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza

- Cosas que se arrojen o caigan de una casa: art. 1910 CC

- Energía nuclear: art. 45 Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear.

- Medio ambiente: Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

- Navegación aérea: art. 120 Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea

- Productos defectuosos: Art. 1 de la Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por los productos defectuosos; arts. 128 y ss. RDL 1/1007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

- Responsabilidad del propietario por los humos excesivos nocivos para las personas o las propiedades y caída de árboles colocados en sitios de tránsito: art. 1908. 2º y 3º CC.

- Servicios: arts. 147-148 RDL 1/2007

STS, 1ª, 581/2007, de 28 de mayo. Accidente en helicóptero

José Augusto trabajaba como retén de incendios forestales para "TRAGSA", sociedad que había contratado con "HELICSA" los medios aéreos para la campaña 1991-92. El 18.9.1992, a causa de una tormenta, el helicóptero que transportaba a José Augusto se vio afectado por una turbulencia, chocó contra la ladera de una montaña y se incendió. Como consecuencia del accidente, José Augusto resultó herido y sufrió una incapacidad permanente total.

José Augusto demandó a "HELICSA" y a su aseguradora, "Allianz", en solicitud de una indemnización de 135.040,03 €.

El JPI de Purchena (23.9.1998) estimó la demanda. La AP de Almería (Sección 2ª, 31.3.2000) estimó en parte el recurso de apelación de los demandados, condenándoles a pagar 18.030,36 €.

El TS estimó en parte el recurso de casación interpuesto por José Augusto e incrementó el importe de la indemnización a 21.035.42 €. Si bien el accidente aéreo constituyó un caso fortuito, sostuvo el Tribunal, el transportista está sujeto a un régimen de responsabilidad objetiva con limitación del quantum indemnizatorio que no admite moderación alguna por los tribunales (art. 120 Ley de Navegación Aérea).

— Compárese esta resolución con la **STS, 1ª, 595/2012, de 23 de octubre**, en la que el demandante, aprendiz de piloto herido durante un examen de vuelo mientras otro aspirante estaba a los mandos, no obtiene indemnización al no ser considerado pasajero. El tribunal concluye que "la asunción del riesgo de volar tiene mucha más intensidad para los aspirantes a la licencia que para los pasajeros de líneas aéreas o aeronaves autorizadas para el transporte de viajeros, ya que mientras que en el transporte la regla general es evitar maniobras arriesgadas, en cambio la enseñanza del vuelo y los exámenes correspondientes comportan por sí maniobras

que simulen situaciones apuradas (…). Se produce así (…) una asunción de riesgos compartidos por todos los tripulantes de la aeronave que no permite imponer a su propietaria (…) un régimen de responsabilidad objetiva" (FD 3º).

STS, 1ª, 1243/2007, de 4 de diciembre. Caída de una maceta desde el quinto piso de un edificio

El 21.7.1989, una mujer de 65 años de edad, falleció como consecuencia de ser golpeada en la cabeza por una maceta que, durante un fuerte temporal de viento, cayó desde el quinto piso de un inmueble de Madrid. La propietaria había arrendado el inmueble a Carina y tenía contratado un seguro multirriesgo de comunidades de propietarios con "AGF Unión Fénix, S.A.".

Bernardo, viudo de la fallecida, demandó a Romeo, Luis Enrique y Lourdes, viudo e hijos de la propietaria del piso, "AGF Unión Fénix, S.A." y Carina, arrendataria del piso, y solicitó una indemnización de 90.151,82 €.

El JPI núm. 58 de Madrid (11.7.1997) estimó en parte la demanda, condenó a Carina a pagar 48.080,97 € y absolvió al resto de demandados. La AP de Madrid (Sección 13ª, 12.7.2000) desestimó el recurso de apelación interpuesto por Carina y estimó el de Bernardo en el sentido de condenar a todos los demandados a pagar 60.101,21 €.

El TS estimó los recursos de casación interpuestos por Romeo, Luis Enrique, Lourdes y la aseguradora, a quienes absolvió. La propietaria no incurrió en negligencia por no haber advertido a la inquilina del peligro que representaban las macetas, pues ello supone "(...) la imposición al propietario-arrendador de un exacerbado deber de vigilancia o supervisión en la conducta del inquilino" (FD 2º).

Capítulo 3º
Negligencia (I): Circunstancias de la negligencia

1. Infracción de deberes de precaución **37**
2. Circunstancias personales del demandado **42**
3. Riqueza del demandado **49**
4. Conocimientos especiales y habilidades particulares del demandado **49**
5. Circunstancias personales de la víctima **51**
6. Situaciones de peligro que requieren acción inmediata: *Sudden emergency doctrine* **51**

1. Infracción de deberes de precaución

— Encarna ROCA TRIAS/Mónica NAVARO MICHEL, *Derecho de daños*, 6ª ed., 2011, pp. 27-28:

"El retorno a la culpa como criterio de imputación": "el Tribunal Supremo ha vuelto a los criterios de imputación subjetiva" [a la culpa como criterio general por oposición a la responsabilidad objetiva].

La regla de la negligencia es el supuesto de partida del derecho de daños, está presupuesta en el art. 1902 del Código Civil, pero no definida allí. Una explicación tradicional de la culpa o negligencia alude a la idea de infracción de deberes de precaución o cuidado (*breach of a duty of care* en el *Common Law*, o incumplimiento de *Verkehrspflichten* en la cultura jurídica alemana).

La ley, los reglamentos o el juez especifican niveles razonables de precaución o cuidado para tales o cuales actividades humanas, cuya inobservancia por parte del causante de daños llevará a que haya de asumirlos y compensar a la víctima o al perjudicado.

La **STS, 1ª, 679/2010, de 10 de diciembre** resuelve un supuesto de responsabilidad civil médica por error de diagnóstico y, al hacerlo, identifica un deber de precaución del médico general consistente en la remisión del paciente a un facultativo especialista antes determinadas sintomatologías.

El 12.12.1996, Eva se sintió súbitamente enferma, perdió el habla, sintió cosquilleos con adormecimiento y pérdida de la fuerza en el brazo derecho. Acudió al Hospital General de Caranza, donde fue atendida de urgencias por el médico de guardia Pío, quien le diagnosticó una bajada de azúcar, le inyectó glucosa y le dio de alta. Tres días después, Eva volvió a presentar la misma sintomatología y acudió nuevamente al mismo servicio de urgencias, donde fue atendida por el doctor Luis Miguel, quien ordenó su ingreso. En la madrugada del día siguiente, ante la situación de la paciente, el doctor Carlos decidió trasladarla a un nuevo centro hospitalario donde se le pudo realizar un TAC. En el nuevo centro se le diagnosticó un infarto isquémico cerebral. Como consecuencia de ello, Eva quedó con una afasia de tipo motor, problemas en el habla, alexia, agrafía, parálisis espástica de extremidad superior derecha con contractura en flexión de dedos y parálisis espática en la extremidad inferior derecha.

Eva demandó a los médicos Pío, a Luis Miguel, a Carlos, al "Hospital General de Caranza Ferrol" y a las compañías de seguros "Compañía de Seguros Aegon" y "Compañía de Seguros Ama Previsión Sanitaria S.L." y solicitó una indemnización de 780.000 euros por los daños y perjuicios sufridos.

EL JPI núm. 6 de Ferrol (16.2.2004) desestimó la demanda. La AP de La Coruña (Sección 5ª, 4.12.2006) desestimó el recurso de apelación.

El TS estimó en parte el recurso de casación interpuesto por la actora y condenó a Pío y a las compañías de seguros (a estas hasta el límite de los seguros concertados) al pago de 235.112,98 euros. Se deberían "haber agotado los medios que la ciencia médica pone a su alcance para determinar la patología correcta cuando era posible hacerlo, como manifestó el propio perito, bien mediante la realización de las pruebas pertinentes, bien previa consulta de algún especialista en neurología si por razón de la especialización de quien en esos momentos le atendía (medicina general), no estaba en condiciones de detectar y prevenir un ictus en evolución. Faltaron en el caso los conocimientos médicos necesarios para hacer posible el diagnóstico que hubiera prevenido o evitado la obstrucción completa de la arteria carótida a partir de una previa sintomatología neurológica que no fue detectada por el médico de guardia, como "sin duda" lo habría hecho el perito, lo que a la postre no viene sino a indicar que cualquier otro médico con una base mínima de conocimientos para estos supuestos o supliendo sus carencias mediante un consejo médico complementario, habría detectado de inmediato la razón de su ingreso y le hubiera proporcionado con la urgencia y diligencia necesaria todos los medios curativos de que disponía" (FD 2º).

El derecho de daños puede contribuir a reducir los costes de los accidentes por el procedimiento de establecer niveles razonables de precaución y hacer cargar a quienes no los cumplan con las consecuencias (Pablo SALVADOR/Carlos GÓMEZ, "El Derecho de Daños y la Minimización de los Costes de los Accidentes", *InDret* 1/2005 (www.indret.com). Si se asume que el objetivo es minimizar los costes de los accidentes, ello resultará algo sencillo de conseguir en algunos casos, pero de dificultad variable y creciente en otros, como se muestra a continuación:

1. En un primer caso resuelto por la **STS, 1ª, 577/2012, de 17 de octubre**, la empresa Talleres Ballespí SL instaló en 2005 una puerta corredera de hierro –de 6,050 metros de ancho por 4,015 de alto- en el cementerio municipal de Lleida. Cuatro días después de la instalación, a primera hora de la jornada laboral, Simón, trabajador de 48 años empleado por Pintura y Decoración SL, comenzó a pintar la puerta y ésta se salió de la guía superior, le cayó encima y le causó un traumatismo torácico y múltiples fracturas, a resultas de las cuales fue declarada su incapacidad permanente absoluta.

El trabajador demandó a Talleres Ballespí SL y a su aseguradora Reale Seguros Generales SA y solicitó una indemnización de 172.911,84 euros. El JPI núm. 6 de Lleida desestimó la demanda por sentencia de 19.11.2007. La AP de Lleida, Sección 2ª, estimó en sentencia de 26.10.2009 el recurso de apelación, revocó el fallo del JPI y condenó a las sociedades demandadas a indemnizar al actor en 169.220,10 €.

El TS confirmó la sentencia de apelación y argumentó que:

"1ª) La empresa dedicada a la instalación de puertas y que instala en un cementerio municipal una puerta corredera metálica de seis metros de anchura por cuatro de altura debe hacerlo en condiciones de evitar que la puerta caiga no solo sobre los trabajadores de la obra del cementerio sino sobre cualesquiera personas que en el futuro visitaran el cementerio o pasaran por la puerta.

2ª) Entre los riesgos naturales de la vida no se encuentra el de que una puerta de semejantes dimensiones se desplome sobre quien se acerca a ella.

3ª) En el presente litigio no se juzga la responsabilidad de la empresa empleadora del perjudicado, sino la de la empresa que instaló la puerta. El problema no es, por tanto, de medidas de seguridad para el trabajador, sino de instalación de la puerta en las condiciones debidas para que no se desplome sobre persona alguna, trabajador o no de la obra.

4ª) El dato de la instalación de la puerta cuatro días antes del hecho dañoso, que en el motivo se invoca a favor de la empresa que hizo la instalación, justifica en realidad el juicio de imputación de la sentencia recurrida, pues demuestra una evidente proximidad temporal entre la instalación y el desplome de la puerta.

5ª) Es insostenible que la mera existencia de gravilla en la parte inferior de la puerta pueda provocar su desplome. Es más, si así fuera se vendría a demostrar su defectuosa instalación. Y no menos insostenible es que por la mera existencia de una empresa contratista quede exonerada de responsabilidad la empresa subcontratada precisamente para la instalación de la puerta como empresa especializada.

6ª) En definitiva, el hecho también indubitado de que los topes o espárragos se habían salido de la guía superior de la puerta justifica el juicio de imputación del tribunal sentenciador por la posición de garante (SSTS 20-12-11 , 30-10-09 y 5-3-09) que con la instalación de la puerta asumía la empresa instaladora.

7ª) En función de lo anterior, tampoco un mero cierre defectuoso de la puerta el día anterior exoneraría de su responsabilidad a la empresa instaladora, salvo prueba de una maniobra tan negligente o malintencionada que hubiera llegado al extremo de sacar los topes de la puerta de su guía superior, también instalada por la misma empresa" (FD 5º).

Se trata de un caso claro de negligencia unilateral, es decir, de un supuesto en el cual la víctima nada podía haber hecho para evitar el daño que finalmente sufrió, cuando, además, queda bien a las claras que los demandados podían haber adoptado más y mejores precauciones.

El caso siguiente plantea más dificultades tanto a la hora de identificar a los responsables de los daños sufridos por la víctima como a la de concretar los niveles de precaución que podrían haberse adoptado para evitarlos:

2. Una mañana del mes de marzo de 1992, la víctima esperaba la llegada del Metro en la estación de la calle Rocafort de Barcelona. El convoy llegó, abrió las puertas y la abigarrada muchedumbre que esperaba en el andén se abalanzó hacia el interior de los vagones. Empujada por el resto de viajeros, la víctima cayó al suelo y sufrió lesiones de gravedad por las que reclamó un total de 37.743,55 euros a la entidad "Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA" gestora del servicio público de transporte por metro en la ciudad de Barcelona cuando de produjo el accidente. La Audiencia Provincial estimó el recurso de la víctima contra la sentencia desestimatoria de la demanda de la primera instancia y concedió una indemnización de 28.518,02 euros con cargo a la entidad demandada. La **STS, 1ª, 1121/2001, de 3 de diciembre**, que puso fin al proceso, desoyó los argumentos de "Ferrocarril Metropolità" y convalidó la condena decidida por la Audiencia de Barcelona.

El tercer caso que presentamos a continuación manifiesta aún más palmariamente las dificultades de atribuir responsabilidad al titular de una organización por los daños causados por un tercero ajeno al ámbito de influencia de la organización misma:

3. En la madrugada del 6 de mayo de 1990, la Sra. Ángela M.R. entró en una de las oficinas de la entidad bancaria demandada para retirar dinero de un cajero automático. En nuestro país, algunas oficinas de bancos y cajas disponen de cajeros a pie de calle, pero es más frecuente que tras la puerta de entrada de la oficina, haya un primer espacio en el que están instalados uno o varios cajeros automáticos, que pueden ser usados, por lo general, las 24 horas del día. La puerta de acceso a este local puede cerrarse con un pestillo. Durante las horas de oficina, los clientes pueden superar este espacio y entrar donde se encuentran los empleados que ofrecen los servicios bancarios de que se trate. En el asunto, el pestillo de la puerta estaba roto y un atracador, que estaba al acecho, entró en el local cuando la víctima ya había tecleado el número secreto de su tarjeta de crédito. Forcejearon, el atracador sacó una navaja con la que hirió a la actora en su mano izquierda y le robó la cantidad retirada. La víctima reclamó 90.152 euros a la entidad bancaria titular del cajero automático. En primera instancia, su demanda fue estimada en parte, pero la entidad demandada recurrió en apelación y la Audiencia Provincial desestimó íntegramente la demanda. El Tribunal Supremo, en **STS, 1ª, 255/1997, de 1 de abril**, desestimó el recurso de la víctima: "[…] no puede afirmarse que las lesiones sufridas por la recurrente al ser asaltada por un desconocido, sean una consecuencia […] del estado en que se encontraba el cerrojo instalado en la puerta de acceso al cajero automático y que impedía cerrar la puerta desde el interior, sino que tales lesiones son imputables exclusivamente, en una

relación de causa a efecto, a la violencia ejercida sobre la actora por el tercero desconocido que la atacó" (FD 2º).

En ocasiones, quien causa el accidente es su víctima. En otras, el responsable nada tuvo que ver con el accidente que motiva finalmente su responsabilidad. En unas terceras, la víctima carga con las consecuencias del daño que sufre. La imputación de daños no depende siempre del relato causal. Así lo confirman los dos casos siguientes.

4. La **STS, 1ª, 2034/1997, de 31 de diciembre** condenó a la Red Nacional de Ferrocarriles (RENFE) por la muerte de dos menores de edad quienes, durante las fiestas mayores del pueblo de Manzanares (Madrid), jugaban con sus compañeros a ver quién aguantaba más sobre la vía del tren cuando se acercaba la locomotora. RENFE había denunciado varias veces los hechos al Ayuntamiento de Manzanares que había ordenado vigilar la zona durante unas horas al día. Fuera de ellas, grupos de muchachos volvían a la vía para hablar, reír, beber y jugarse la vida. El día 21 de julio de 1990, Miguel Ángel C. y José Gabriel P., ambos de quince años, estaban de pie sobre las vías, con 0,92 gramos de alcohol por litro de sangre el primero, cuando un Tren Expreso que circulaba a 130 km/h., les arrolló. Ambos murieron en el acto. Los padres de las víctimas reclamaron una indemnización de 150.253 euros al Ayuntamiento de Manzanares, a RENFE y al maquinista del tren. Las instancias condenaron únicamente a RENFE y al Ayuntamiento a pagar 36.061 euros a cada uno de los demandantes. El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por la compañía ferroviaria. La actividad de los jóvenes, en absoluto justificable, era conocida y debían haberse adoptado todas las medidas necesarias, incluso la detención del convoy a su paso por el pueblo, para evitar daños como los que sucedieron (cfr. STS, 1ª, 44/2010, de 18 de febrero).

5. El demandante en el proceso que resolvió la **STS, 1ª, de 10 de octubre de 1998** era un trabajador de una empresa de productos congelados a quien una máquina termoselladora le amputó la mano derecha. Inmediatamente después del accidente, la enfermera de la empresa acudió al lugar de los hechos para atender al trabajador, cortó la hemorragia e instruyó a un compañero del trabajador para que envolviera la mano traumáticamente amputada en hielo natural. Mientras esperaban a la ambulancia, el compañero de la víctima metió la mano amputada en una caja de *porexpan* llena de dióxido de carbono sólido, comúnmente conocido como hielo seco, de las que utilizaban para el transporte de productos congelados, pues creía que procuraría una mejor conservación de la mano. Cuando la víctima fue ingresada en el centro sanitario los tejidos de la mano amputada estaban destruidos por congelación y no fue posible practicar el implante. El trabajador quedó manco de por vida y demanda a la empresa y a la enfermera de la misma por no haber comprobado cómo se trasladó la mano amputada al hospital. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial desestimaron la concesión de 120.202 € que el demandante reclama, pero el Tribunal Supremo condenó a la enfermera a pagar una indemnización de 9.015 euros. La enfermera no fue del todo diligente y debía responder por la pérdida de las expectativas de reimplantar el miembro amputado.

6. La **STS, 1ª, 139/2011, de 14 de marzo** resuelve un supuesto de negligencia bilateral o concurrencia de culpas. El 13.8.2000, alrededor de las 12 del mediodía, una embarcación a motor conducida por Máximo atropelló a Fermín cuando practicaba submarinismo a unos 100-150 metros de la costa. En el momento del accidente, Fermín tenía problemas de oído y no iba acompañado de barca ni boya de señalización. La embarcación circulaba a unos 10 nudos de velocidad y había olas de más de un metro de altura. Como consecuencia del atropello, Fermín sufrió lesiones irreversibles que determinaron su incapacidad permanente.

En el procedimiento penal iniciado por estos hechos, el JI núm. 3 de Tortosa condenó al piloto de la embarcación. La AP revocó la SJI y lo absolvió, porque las dudas existentes sobre el lugar exacto en que había ocurrido el accidente impedían imputarle un comportamiento negligente.

Fermín demanda a Máximo, a Otilia (propietaria del barco) y a Zurich España S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros, y solicita una indemnización de daños y perjuicios (no consta la cuantía).

El JPI núm. 49 de Barcelona (23.3.2005) estima en parte la demanda, considera que la conducta negligente del actor contribuyó en un 25% al accidente y que la conducta negligente del

conductor contribuyó en un 75%. El submarinista debió llevar una boya de señalización, como establece el art. 1 Orden del Ministerio de Fomento de 14.10.1997, y el conductor de la embarcación debió reducir la velocidad de la embarcación a unos 3 nudos, como establece el art. 69.2 Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: "En los tramos de costa que no estén balizados como zona de baño se entenderá que ésta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una anchura de 200 metros en las playas y 50 metros en el resto de la costa. Dentro de estas zonas no se podrá navegar a una velocidad superior a tres nudos, debiendo adoptarse las precauciones necesarias para evitar riesgos a la seguridad humana. Estará prohibido cualquier tipo de vertido desde las embarcaciones". En aplicación de la regla de concurrencia de culpas, el JPI condena a los codemandados al pago de 216.374,36 €, límite máximo del seguro de responsabilidad civil, y al propietario y conductor de la embarcación al pago de los restantes 23.197,81 €.

La AP Barcelona (Secc. 14ª, 29.6.2006) estima en parte los recursos de apelación interpuestos por todas las partes. En relación al de Máximo y Otilia, la AP estima en un 50% el porcentaje de culpa de la víctima y del conductor, y condena a estos codemandados solidariamente junto a la compañía de seguros al pago de 167.649,52€ (límite del seguro obligatorio), así como al pago de los 21.075,06 € que completan el total del monto de la indemnización. En relación al del actor, la AP considera indemnizable conforme a baremos el daño moral complementario.

El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el actor porque "(…) ese especial deber de diligencia resulta, asimismo, de las disposiciones administrativas sobre la materia, que obligaban a reducir la velocidad en las zonas próximas a la costa, y especialmente a la playa, en previsión de la presencia de bañistas o nadadores. Pero, contrariamente a lo que se sostiene, no es circunstancia que excluya la posibilidad de imputar el resultado al comportamiento culpable del agente el que la embarcación impactase con la víctima más allá de los límites acotados reglamentariamente para el baño. Consta acreditado que la embarcación circulaba a una velocidad elevada (no menos de diez nudos) y por una zona que, aún fuera de la acotada, seguía encontrándose relativamente próxima a la costa (a una distancia de 100 a 150 metros), donde había calas y playas cercanas, era posible el submarinismo, y en la que, atendiendo al día, hora y época del año (mediodía de un domingo del mes de agosto, época vacacional), resultaba, asimismo, presumible, una notoria afluencia de bañistas. Y en esas circunstancias, y en atención al riesgo generado, el piloto no ha probado la adopción de las especiales medidas de precaución que le eran exigibles para evitar riesgos a la vida e integridad físicas de los bañistas, las cuales no cabe circunscribir a una zona determinada desde el momento que el deber de precaución subsiste desde la puesta en marcha de la embarcación, momento en que el agente desencadena el riesgo, hasta que se detenga, y debe acomodarse en cada momento a las concretas circunstancias que se encuentre durante la conducción." (FD 3º).

7. En el caso resuelto por la **STS, 1ª, 931/2001, de 17 de octubre**, un joven de 21 años practicaba descenso por aguas bravas en el río Gállego al cruzar un desfiladero de especial dificultad, el "Paso del Embudo" en el término municipal de Murillo (Zaragoza), cayó de la balsa neumática, se golpeó la cabeza con una roca y falleció en el acto. Poco después, el padre de la víctima demandó a la asociación organizadora de la actividad deportiva, a la compañía aseguradora y al monitor que había dirigido la actividad. Por el hecho se siguieron diligencias penales posteriormente archivadas. En el pleito civil, las sentencias de las instancias desestimaron la demanda. Igual suerte corrió el demandante en casación. Se trata de un supuesto de culpa exclusiva de la víctima o, en su caso, de concreción de los riesgos asumidos por la propia víctima.

2. Circunstancias personales del demandado

I) Edad y estado de salud

A la hora de determinar los niveles de precaución debidos o estándares de diligencia a cumplir por el causante de los daños, jueces y tribunales toman en consideración las circunstancias personales de aquél.

En cuanto a la edad, el criterio comúnmente adoptado por la mejor doctrina es que los niños de muy corta edad (los menores de 7 años aproximadamente) son inimputables –por ellos responden sus padres o guardadores ex art. 1903 CC-; es más, si el menor carece de capacidad natural –un niño de tres años de edad, por ejemplo-, no hay acción, no hay agencia social. Si el menor tiene capacidad natural –y patrimonio con el que responder-, entonces puede efectivamente ser condenado a indemnizar por los daños causados. Mas, en el derecho positivo, la cuestión solo ha sido regulada por el Código Penal, arts. 19, 118.1 y 120.1 CP y 3 y 61 y ss. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En particular, la LO 5/2000 considera penal y civilmente responsables a los menores de edad desde que cumplen los catorce años (arts. 1.1 y 61.3 LO 5/2000). Además, la doctrina mayoritaria admite la aplicabilidad del art. 1902 CC al menor civilmente imputable (Esther GÓMEZ CALLE (2006), "Los sujetos de la responsabilidad civil. La responsabilidad por hecho ajeno", en L. Fernando Reglero Campos (Coord.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, 3ª ed., Thomson-Aranzadi, Navarra, pp. 461-538, 480).

El derecho comparado de países próximos a nuestra cultura ofrece soluciones similares, pero discrepantes en el detalle de la regulación propuesta.

La jurisprudencia de la Sala 1ª del TS tiende a juzgar la conducta de los menores con edades comprendidas entre 7 y 15 años en términos de negligencia, pero el estándar de diligencia exigible es más leve que el de los adultos. Hay que tener en cuenta también que, si bien los tribunales tienden a excusar travesuras y avatares de los juegos propios de la infancia, no hacen lo mismo con la conducta claramente despreciativa de peligros que todo niño de su edad debería prever, y tampoco la conducta antijurídica: los terceros no tienen por qué anticipar y prevenir el daño conexo a un acto voluntario, arriesgado y a veces incluso ilícito cometido en vísperas de la pubertad (Josep FERRER I RIBA y Covadonga RUISÁNCHEZ CAPELASTEGUI, "Niños y adolescentes", *InDret* 1/2000, pp. 7 y ss.)

STS, 1ª, 205/2002, de 8 de marzo

Patricia G.N., de 16 años, perdió la visión casi total del ojo derecho al sufrir un balonazo en la cara, lanzado por Mariano M.Q., de 17 años, que jugaba al fútbol con unos amigos, mientras estaba sentada en un banco del jardín municipal del Paseo de la Playa de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Georgina N.M., en nombre de su hija Patricia G.N., demandó a Mariano M.Q., a sus padres (Eusebio M.S. y Dulce Nombre Q.Z.) y al Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules y solicitó una indemnización de 90.151,81 euros.

El JPI nº 3 de Chiclana de la Frontera (29.12.1995) desestimó la demanda. La AP de Cádiz (Sección 5ª, 10.7.1996) estimó parcialmente el recurso de casación y condenó a Mariano M.Q. y a sus padres a satisfacer a la actora una indemnización de 60.101,21 euros.

El TS desestimó el recurso de casación y confirmó la SAP. No es necesario acudir a criterios de responsabilidad por riesgo para fundamentar la responsabilidad del menor. Basta analizar la imputación subjetiva del daño: la edad (17 años, 7 meses y 22 días) y los factores psicológicos del menor indican que podía haber previsto que jugando con un balón de cuero ligeramente deshinchado en un lugar inidóneo se podían causar daños a terceros ajenos al juego. La responsabilidad de los padres tiene su fundamento en la presunción de culpa contenida en el art. 1903 CC.

II) Responsabilidad civil de menores e incapaces en derecho español

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Artículo 118.1.1:

1. La exención de la responsabilidad criminal declarada en los números 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 20, no comprende la de la responsabilidad civil, que se hará efectiva conforme a las reglas siguientes:

1. En los casos de los números 1 y 3, son también responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los imputables.

Los Jueces o Tribunales graduarán de forma equitativa la medida en que deba responder con sus bienes cada uno de dichos sujetos.

Artículo 120. Responsables civiles subsidiarios

Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente:
1º Los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos o faltas cometidos por los mayores de dieciocho años sujetos a su patria potestad o tutela y que vivan en su compañía, siempre que haya por su parte culpa o negligencia. (…)

STS, 2ª, 619/2005, de 11 de mayo

El 8.7.2002 en Medina de Pomar (Burgos), sobre las 17:30 horas, Rodrigo, nacido el 31.7.1983 (19 años), con una dotación intelectual inferior al promedio (entre la normalidad y el retraso mental leve) y educado en un contexto familiar desestructurado (abandono de la madre a los cuatro años de edad, y padre alcohólico), tras comprar en una tienda un cuchillo de unos 11 cms. de hoja, entró en la Óptica Medina Centro, sita en la misma calle que el primer establecimiento. Esperó a que la dependienta, Soledad, atendiese a otro cliente y, cuando se encontraban solos en la óptica, le solicitó que le graduase la vista, Rodrigo y Soledad entraron al gabinete habilitado al efecto y, después de realizada tal operación, Soledad se levantó para rellenar el correspondiente impreso, mientras el joven permanecía sentado. Rodrigo, entonces, clavó el cuchillo que portaba consigo en la zona abdominal de Soledad, causándole graves lesiones que tardaron 235 días en sanar y secuelas consistentes en cicatriz queloidea de 17 cms. de longitud y 1 cm. de anchura en la línea media abdominal, cicatriz de 2 cms. en hipocondrio izquierdo y síndrome de estrés postraumático. El día en que ocurrieron los hechos Rodrigo había obtenido una autorización de salida de la Residencia en la que se encontraba ingresado (Residencia Los Robles de Villasante de Montija). No consta que el titular de dicha residencia, Hogadema, S.A. (que tenía contratado el seguro de responsabilidad civil con Mapfre Industrial, S.A.), hubiera adoptado medida alguna para evitar los hechos.

La SAP Burgos, Secc. 1ª, 7.5.2004, condenó al acusado Rodrigo como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasiva durante el tiempo de la condena, y prohibición de aproximación a la víctima a una distancia inferior de 200 metros y de comunicarse en cualquier forma con ella durante cinco años. También condenó a Rodrigo a indemnizar a Soledad con 30.680 € por lesiones y con 20.000 euros por secuelas. De dichas cantidades había de responder directamente Mapfre Industrial, S.A., en solidaridad con Hogadema, S.A.

La STS, 2ª, 11.5.2005, estimó parcialmente el recurso de casación interpuesto por Hogadema, S.A. de manera que redujo la responsabilidad civil de esta entidad de solidaria a subsidiaria, ya que el TS consideró aplicable el art. 120.1 CP "al Organismo que tenía bajo su guarda y tutela a

quien cometió un hecho delictivo por concurrir un cierto nivel de negligencia que guarda con el delito cometido una relación de causa/efecto". Y añadió que "en la sentencia de esta Sala 1527/2001, de 21 de julio, se declara que un requisito esencial de la responsabilidad civil subsidiaria es la existencia de una relación de causalidad –a la que se refiere claramente la expresión legal «siempre que haya mediado»– entre la culpa o negligencia de quienes tengan al exento de responsabilidad criminal –total o parcialmente– bajo su potestad o guarda y la comisión por aquél de un hecho punible (…); exclusión [de la responsabilidad del centro psiquiátrico] que no puede afirmarse en el presente caso (…) ya que no se produjo una cesión temporal de la guarda de hecho a favor de la familia o de tercera persona a quien le incumbiera la responsabilidad civil subsidiaria derivada de la actuación de Rodrigo, sino que se mantuvo la guarda de hecho por parte de Hogadema, S.A. durante las salidas autorizadas por su Dirección" (FD 2º).

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores

Artículo 1. Declaración general

1. Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.

2. Las personas a las que se aplique la presente Ley gozarán de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, particularmente en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y en todas aquellas normas sobre protección de menores contenidas en los Tratados válidamente celebrados por España.

Artículo 3. Régimen de los menores de catorce años.

Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquel conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

Artículo 5. Bases de la responsabilidad de los menores.

1. Los menores serán responsables con arreglo a esta Ley cuando hayan cometido los hechos a los que se refiere el artículo 1 y no concurra en ellos ninguna de las causas de exención o extinción de la responsabilidad criminal previstas en el vigente Código Penal.

2. No obstante lo anterior, a los menores en quienes concurran las circunstancias previstas en los números 1, 2 y 3 del artículo 20 del vigente Código Penal les serán aplicables, en caso necesario, las medidas terapéuticas a las que se refiere el artículo 7.1, letras d) y e), de la presente Ley.

3. Las edades indicadas en el articulado de esta Ley se han de entender siempre referidas al momento de la comisión de los hechos, sin que el haberse rebasado las mismas antes del comienzo del procedimiento o durante la tramitación del mismo tenga incidencia alguna sobre la competencia atribuida por esta misma Ley a los Jueces y Fiscales de Menores.

Título VIII
De la responsabilidad civil

Artículo 61. Reglas generales

1. La acción para exigir la responsabilidad civil en el procedimiento regulado en esta Ley se ejercitará por el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por sí mismo en el plazo de un mes desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil o se la reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil conforme a los preceptos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. Se tramitará una pieza separada de responsabilidad civil por cada uno de los hechos imputados.

3. Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos.

4. En su caso, se aplicará también lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y sus disposiciones complementarias.

Artículo 62. Extensión de la responsabilidad civil

La responsabilidad civil a la que se refiere el artículo anterior se regulará, en cuanto a su extensión, por lo dispuesto en el Capítulo I del Título V del Libro I del Código Penal vigente.

III) Edad, salud y responsabilidad civil en el derecho comparado

Common Law

a) ***Restatement (Third) of Torts:***

§ 10 ***Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm*** (2010): **Children**

"(a) A child´s conduct is negligent if it does not conform to that of a reasonable person of the same age, intelligence, and experience, except as provided by section (b) or (c).

(b) A child less than five years of age is incapable of negligence.

(c) The special rule in Subsection (a) does not apply when the child is engaging in a dangerous activity that is characteristically undertaken by adults."

§ 11 ***Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm*** (2010)**: Disability**

(a) The conduct of an actor with a physical disability is negligent only if the conduct does not conform to that of a reasonable careful person with the same disability.

(b) The conduct of an actor during a period of sudden incapacitation or loss of consciousness resulting form physical illness is negligent only if the sudden incapacitation or loss of consciousness was reasonably foreseeable for the actor.

(c) An actor´s mental or emotional disability is not considered in determining whether conduct is negligent, unless the actor is a child.

b) *Daniels v. Evans* (224 A.2d 63 (N.H. 1966))

[Plaintiff's decedent, a 19-year-old youth, was killed when his motorcycle collided with defendant's automobile. A trial by jury resulted in a verdict for plaintiff, and the only alleged error argued on appeal was the trial court's charge pertaining to the standard of care required of the decedent].

LAMPRON, J. As to the standard of care to be applied to the conduct of the decedent Robert E. Daniels, 19 years of age, the Trial Court charged the jury in part as follows:

"Now, he is considered a minor, being under the age of twenty-one, and a minor child must exercise the care of the average child of his or her age, experience and stage of mental development. In other words, he is not held to the same degree of care as an adult."

Concededly these instructions substantially reflect the rule by which the care of a minor has been judged heretofore in the courts of our state. However an examination of the cases will reveal that in most the minors therein were engaged in activities appropriate to their age, experience and wisdom. These included being a pedestrian, riding a bicycle, riding a horse [and] coasting.

We agree that minors are entitled to be judged by standards commensurate with their age, experience, and wisdom when engaged in activities appropriate to their age, experience, and wisdom. Hence when children are walking, running, playing with toys, throwing balls, operating bicycles, sliding or engaging in other childhood activities their conduct should be judged by the rule of what is reasonable conduct under the circumstances among which are the age, experience, and stage of mental development of the minor involved.

However, the question is raised by the defendant in this case whether the standard of care applied to minors in such cases should prevail when the minor is engaged in activities normally undertaken by adults. In other words, when a minor undertakes an adult activity which can result in grave danger to others and to the minor himself if the care used in the course of the activity drops below that care which the reasonable and prudent adult would use, the defendant maintains that the minor's conduct in that instance, should meet the same standards as that of an adult.

Many recent cases have held that "when a minor assumes responsibility for the operation of so potentially dangerous an instrument as an automobile, he should . . . assume responsibility for its careful and safe operation in the light of adult standards." The rule has been recognized in Restatement (Second), Torts and in Prosser, Torts. In an annotation in [the] A.L.R. it is said that recent decisions "hold that when a minor engages in such activities as the operation of an automobile or similar power driven device, he forfeits his rights to have the reasonableness of his conduct measured by a standard commensurate with his age and is thenceforth held to the same standard as all other persons."

One of the reasons for such a rule has been stated thusly in Dellwo v. Pearson: "To give legal sanction to the operation of automobiles by teen-agers with less than ordinary care for the safety of others is impractical today, to say the least. We may take judicial notice of the hazards of automobile traffic, the frequency of accidents, the often catastrophic results of accidents, and the fact that immature individuals are no less prone to accidents than adults. . . . [I]t would be unfair to the public to permit a minor in the operation of a motor vehicle to observe any other standards of care and conduct than those expected of all others. A person observing children at play . . . may anticipate conduct that does not reach an adult standard of care or prudence. However, one cannot know whether the operator of an approaching automobile . . . is a minor or an adult, and usually cannot protect himself against youthful imprudence even if warned." [...]

RSA 262, which establishes rules of the road for the operation of motor vehicles on our highways, reads as follows: "Required obedience to traffic laws. It is unlawful and . . . a misdemeanor for any person to do any act forbidden or fail to perform any act required in this chapter." (Emphasis supplied). This is some indication of an intent on the part of our Legislature that all drivers must, and have the right to expect that others using the highways, regardless of their age and experience, will, obey the traffic laws and thus exercise the adult standard of ordinary care […].

The rule charged by the Trial Court pertaining to the standard of care to be applied by the jury to the conduct of the minor plaintiff Robert E. Daniels in the operation of the motorcycle was proper in "the bygone days" when children were using relatively innocent contrivances. See A.L.R.. However in the circumstances of today's modern life, where vehicles moved by powerful motors are readily available and used by many minors, we question the propriety of a rule which would allow such vehicles to be operated to the hazard of the public, and to the driver himself, with less than the degree of care required of an adult.

We are of the opinion that to apply to minors a more lenient standard in the operation of motor vehicles, whether an automobile or a motorcycle, than that applied to adults is unrealistic, contrary to the expressed legislative policy, and inimical to public safety. Furthermore when a minor is operating a motor vehicle there is no reason for making a distinction based on whether he is charged with primary negligence, contributory negligence, or a causal violation of a statute and we so hold.

We hold therefore that a minor operating a motor vehicle, whether an automobile or a motorcycle, must be judged by the same standard of care as an adult and the defendant's objection to the Trial Court's charge applying a different standard to the conduct of plaintiff's intestate was valid.

Exception sustained.

c) *Purtle v. Shelton* (474 S.W.2d 123 (Ark. 1971))

GEORGE ROSE SMITH, Justice.

This is an action for personal injuries suffered by Jerry Purtle, a sixteen-year-old minor, in a hunting accident during the 1969 deer hunting season. The defendants are Kenneth Shelton and his son, Kenneth, Jr., who was seventeen at the time of the accident. The jury attributed half the negligence to Jerry Purtle and half to young Shelton; so there was no recovery. For reversal the appellant, Jerry's father and next friend, contends that the trial court erred in its instructions defining the standard of care to be observed by a minor while hunting deer with a high-powered rifle.

There were some conflicts in the testimony, but the salient facts are not really in dispute. Jerry and young Kenneth had spent the night at the home of L. D. McMullen, who owned a deer camp in Union county. Early the next morning, before daylight, McMullen took the two youths (and a third lad not involved in the case) to the area where they were to hunt. Kenneth's deer stand was next to the road, but Jerry had to walk a short distance through the woods to his stand. MaMullen had cautioned both boys to make their presence known when they were walking in the woods and not to shoot at anything without knowing it to be a deer.

Jerry failed to find his stand immediately and actually walked toward Kenneth's stand, without making his presence known. Kenneth thought he saw a deer and fired at it with his 30.06 rifle. The soft projectile apparently hit a tree, broke into shrapnel, and ricocheted toward Jerry, causing serious injuries to both his eyes.

The trial court submitted the case to the jury upon the theory that Kenneth was required to use that degree of care which a 17-year-old minor would use in the same circumstances. […]

We are unable to find any authority holding that a minor should be held to an adult standard of care merely because he engages in a dangerous activity. There is always the parallel requirement that the activity be one that is normally engaged in only by adults. So formulated, the rule is logical and sound, for when a youth is old enough to engage in adult activity there are strong policy reasons for holding him to an adult standard of care. In that situation there should be no magic in the attainment of the twenty-first birthday.

We have no doubt that deer hunting is a dangerous sport. We cannot say, however, either on the basis of the record before us or on the basis of common knowledge, that deer hunting is an activity normally engaged in by adults only. To the contrary, all the indications are the other way. A child may lawfully hunt without a hunting license at any age under sixteen. We know, from common knowledge, that youngsters only six or eight years old frequently use .22 caliber rifles and other lethal firearms to hunt rabbits, birds, and other small game. We cannot conscientiously declare, without proof and on the basis of mere judicial notice, that only adults normally go deer hunting.

In refusing to apply an adult standard of care to a minor engaged in hunting deer, we do not imply that a statute to that effect would be unwise. Indeed, we express no opinion upon that question. As judges, we cannot lay down a rule with the precision and inflexibility of a statute drafted by the legislature. If we should declare that a minor hunting deer with a high-powered rifle must in all instances be held to an adult standard of care, we must be prepared to explain why the same rule should not apply to a minor hunting deer with a shotgun, to a minor hunting rabbits with a high-powered rifle, to a twelve-year-old shooting crows with a .22, and so on down to the six-year-old shooting at tin cans with an air rifle. Not to mention other dangerous activities, such as the swinging of a baseball bat, the explosion of firecrackers, or the operation of an electric train. All we mean to say in this case is that we are unwilling to lay down a brand-new rule of law, without precedent and without any logical or practical means of even surmising where the stopping point of the new rule might ultimately be reached. […]

Affirmed.[…]

BYRD, Justice (dissenting).

"Because a bullet fired from the gun by a minor is just as deadly as a bullet fired by an adult, I'm at a loss to understand why one with 'buck fever' because of his minority is entitled to exercise any less care than any one else deer hunting. One killed by a bullet so fired would be just as dead in one instance as the other and without any more warning.

For the reasons stated, I respectfully dissent".

Civil Law: Francia y Alemania

a) Francia : Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Article 3

"Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi".

b) Código Civil alemán *(Bürgerliches Gesetzbusch (BGB))*

§ 828 Minderjährige

"(1) Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich.

(2) Wer das siebente, aber nicht das zehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für den Schaden, den er bei einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer Schienenbahn oder einer Schwebebahn einem anderen zufügt, nicht verantwortlich. Dies gilt nicht, wenn er die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt hat.

(3) Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist, sofern Seine Verantwortlichkeit nicht nach Absatz 1 oder 2 ausgeschlossen ist, für den Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat".

3. Riqueza del demandado

¿Deben de tenerse en cuenta los medios de que dispone el demandado, su riqueza en términos económicos, culturales, biológicos? La respuesta es negativa en el caso de la riqueza económica, pero como veremos en seguida, hay muchas formas de riqueza que no son estricta y directamente mente económicos, aunque admitan valoración, al menos parcial, en tales términos:

— *Denver & Rio Grande R.R. v. Peterson* (69 P. 578 (Colo. 1902))

"CAMPBELL, C.J. The care required of a warehouseman is the same, whether he is rich or poor. For, if the fact that he is rich requires of him greater care than if he possessed only moderate means or is poor, then, if he were extremely poor, the care required might be such as practically to amount to nothing; and no one would claim that such an uncertain and sliding rule should be the measure of his liability…"

4. Conocimientos especiales y habilidades particulares del demandado

El punto de partida en la responsabilidad profesional es que el demandado responde por el incumplimiento del cuerpo de reglas propias de su profesión, arte u oficio: la *lex artis*. ¿Pero responden más intensamente los mejores, en cada profesión, oficio o práctica o lo hacen de acuerdo con las reglas generales del arte, con la media de su profesión? ¿Está penalizado ser de los mejores? La respuesta suele ser que quien dispone de conocimientos especiales ha de actuar desde luego de acuerdo con las reglas propias del cuerpo de conocimientos correspondientes, es decir, más prudentemente que el lego. En cambio, dentro de la profesión u oficio, la respuesta es que la pericia extraordinaria del demandado es una de las circunstancias de que delimitan sus deberes de cuidado, pero no la única de ellas. En todo caso, quien carece de las habilidades propias de un especialista, no ya porque sea lego, sino porque, siendo profesional, dispone solo de los conocimientos generales de su oficio, ha de abstenerse de ejercer una especialidad para cuyo ejercicio no está preparado suficientemente.

§ 12 ***Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm*** (2010):

"If an actor has skills or knowledge that exceed those possessed by most others, these skills or knowledge are circumstances to be taken into account in determining whether the actor has behaved as a reasonably careful person."

- When the actor is one of a limited number of parties that engage in an activity that poses distinctive and significant dangers [electric-power company].

- When the actor that possesses an above-average knowledge has a pre-existing relationship with the other party. [STS, 1ª, 836/2004, de 22 de julio]

- Substandard judgment is usually ignored. Learners and beginners.

- Intoxication. The foreseeability test: voluntary intoxication is ignored. Iced tea spiked with liquour.

En tal sentido, puede verse la **STS, 1ª, 679/2010, de 10 de diciembre**, ya tratada *supra* (véase epígrafe 3.1): "Faltaron en el caso los conocimientos médicos necesarios para hacer posible el diagnóstico que hubiera prevenido o evitado la obstrucción completa de la arteria carótida a partir de una previa sintomatología neurológica que no fue detectada por el médico de guardia, como "sin duda" lo habría hecho el perito, lo que a la postre no viene sino a indicar que cualquier otro médico con una base mínima de conocimientos para estos supuestos o supliendo sus carencias mediante un consejo médico complementario, habría detectado de inmediato la razón de su ingreso y le hubiera proporcionado con la urgencia y diligencia necesaria todos los medios curativos de que disponía" (FD. 2º).

STS, 1ª, 798/2009, de 9 de octubre (en el mismo sentido, STS, 1ª, 815/2010, de 15 de diciembre). Comentada por Marian GILI SALDAÑA e Ignacio MARÍN GARCÍA (2009), "Sentencia de 9 de octubre de 2008 (RJ 2008, 6042)", *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil,* núm. 80, pp. 751-778. Fin de protección de la norma y ausencia de responsabilidad de auditores.

Desde 1993, "XM Patrimonios Agencia de Valores, S.A." creó la apariencia de que compraba valores por cuenta de clientes cuando, en realidad, desviaba los fondos que recibía a otras sociedades. "Price Waterhouse Auditores, S.A." auditó las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios de 1993 y 1994. Las auditorías, que fueron realizadas efectivamente por Iván, no contenían salvedad alguna y expresaban la opinión de que las cuentas de la sociedad auditada reflejaban la imagen fiel de su patrimonio.

"Lepanto Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.", Luis Enrique, "Penedés, S.A." y "Alto Penedés, S.A." demandan a "Price Waterhouse Auditores, S.A." e Iván, y solicitan una indemnización de 8.961.322,55 € para "Lepanto"; 1.526.244,80 € para Luís Enrique; 846.379,26 € para "Penedés, S.A.", y 65.599,71 € para "Alto Penedés, S.A.".

El JPI nº 24 de Barcelona (21.10.1998) desestimó la demanda. La AP de Barcelona (Sección 16ª, 31.7.2000) estimó íntegramente el recurso de apelación y condenó a los demandados a pagar 8.961.322,55 € a "Lepanto", 1.526.244,80 € a Luís Enrique, 846.379,26 € a "Penedés, S.A." y 65.599,71 € a "Alto Penedés, S.A.".

El TS estimó el recurso de casación interpuesto por "Price Waterhouse Auditores, S.A." e Iván y revoca la SAP y dictó una nueva sentencia. El hecho de que la CNMV no hubiera actuado a tiempo para impedir las inversiones efectuadas por los demandantes es una causa extraña al ámbito de protección de la norma a cuya infracción se vincula la responsabilidad del auditor (art. 11 Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas – ahora art. 22 RDL 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas), pues la finalidad de esta norma es permitir que tanto la sociedad auditada como los terceros pudieran conocer la calidad de la información económico contable sobre la cual versaba la opinión emitida por el auditor de cuentas.

5. Circunstancias personales de la víctima

¿Debe el demandado atender a las circunstancias personales de la víctima que la sitúan en una posición de extrema vulnerabilidad y que, a menudo, no son aparentes? La respuesta es afirmativa en todos aquellos casos o circunstancias en los cuales el demandado había de contar con la posible presencia de víctimas potenciales especialmente frágiles, por ejemplo, en las calles y plazas de la ciudad, en general, en los escenarios habituales de la vida cotidiana. La razón es sencilla de entender: si para medir la intensidad del deber de precaución no se tuviera en cuenta al 5% o al 10% o al 15% de población más frágil, los incentivos para comportarse adecuadamente serían subóptimos.

En cambio, en espacios o, en general, en ocasiones en las cuales el demandado puede contar con que aquellas personas con las cuales va a interactuar son homogéneamente sanas y fuertes, sus deberes de precaución no incluirán la consideración hacia aquellas que precisen de una protección especial salvo que su indefensión resulte aparente a ojos de un observador razonable. El ejemplo clásico es la práctica de un deporte de equipo y de contacto en un espacio cerrado, un estadio o un campo de deporte.

Los casos de la ley suelen seguir esta línea de razonamientos:

"One rule of the tort law … is that the defendant takes his victim as he finds him. In Smith v. Brain Leech & Co. Ltd (1962) 2 Q.B. 405, plaintiff's deceased was burned on his lip by splashing molten metal because defendant negligently failed to provide an adequate guard. Because of prior exposures of another kind in the past, deceased had (according to the court) developed a tendency toward cancer. In any event, the burned lip did develop a cancer from which he died. The court acknowledged that death by cancer was unforeseeable…" (EPSTEIN, Cases and Materials on Torts, 9th ed., p. 542).

6. Situaciones de peligro que requieren acción inmediata: *Sudden emergency doctrine*

Una emergencia es, dice el DRAE, una "situación de peligro que requiere una acción inmediata" (3ª acepción) y la pregunta es si, ante una emergencia, los deberes de precaución son menos intensos que ante una situación de riesgo normalmente esperable. La respuesta es que la emergencia se tiene en cuenta como una de las circunstancias que modulan los deberes de cuidado, pero que, probablemente, no hay necesidad de construir una doctrina específica en la cual quepa encasillar multitud de acontecimientos inesperados, pero muy heterogéneos entre sí.

***Lyons v. Midnight Sun Transportation Services, Inc.* (928 P.2d 1202 (Alaska 1996))** (http://www.onlinelawtutoring.com/Case_Reference/Lyons_v_Midnight_Sun_Transportation_Services_Inc_928_P2d_1202_1996.htm)

PER CURIAM.

I. FACTS AND PROCEEDINGS

Esther Hunter-Lyons was killed when her Volkswagen van was struck broadside by a truck driven by David Jette and owned by Midnight Sun Transportation Services, Inc. When the accident occurred, Jette was driving south in the right-hand lane of Arctic Boulevard in Anchorage. Hunter-Lyons pulled out of a parking lot in front of him. Jette braked and steered to the left, but Hunter-Lyons continued to pull out further into the traffic lane. Jette's truck collided with Hunter-Lyons's vehicle. David Lyons, the deceased's husband, filed suit, asserting that Jette had been speeding and driving negligently.

At trial, conflicting testimony was introduced regarding Jette's speed before the collision. Lyons's expert witness testified that Jette may have been driving as fast as 53 miles per hour. Midnight Sun's expert testified that Jette probably had been driving significantly slower and that the collision could have occurred even if Jette had been driving at the speed limit, 35 miles per hour. Lyons's expert later testified that if Jette had stayed in his own lane, and had not steered to the left, there would have been no collision. Midnight Sun's expert contended that steering to the left when a vehicle pulls out onto the roadway from the right is a normal response and is generally the safest course of action to follow.

Over Lyons's objection, the jury was given an instruction on the sudden emergency doctrine. The jury found that Jette, in fact, had been negligent, but his negligence was not a legal cause of the accident. Lyons appeals, arguing that the court should not have given the jury the sudden emergency instruction.

II. ANALYSIS AND DISCUSSION

The sudden emergency doctrine is a rule of law which states that a person confronted with a sudden and unexpected peril, not resulting from that person's own negligence is not expected to exercise the same 1204 judgment and prudence the law requires of a person in calmer and more deliberate moments. The person confronted with the imminent peril must, however, act as a reasonable person would under the same conditions.

[The Court first held that the use of the sudden emergency instruction count was harmless error since the jury decided in favour of defendant on the ground that his conduct was not the legal cause of plaintiff's injury.]

B. Sudden Emergency Instruction Disapproved

[W]e take this opportunity to disapprove of the instruction's further use. It adds nothing to the established law that the duty of care, which all must exercise, is to act reasonably under the circumstances. The instruction is potentially confusing. Although we cannot say that the instruction is never appropriate, we discourage its employment. In support of this admonition, we offer the following background.

The sudden emergency doctrine arose as a method of ameliorating the, sometimes harsh, "all or nothing" rule in contributory negligence systems. […]

Although the doctrine came out of the contributory negligence regime, there is nothing about it which is inherently incompatible with a comparative fault system. Comparative negligence is a method of apportioning liability for a particular accident among the various parties who have been deemed negligent. The sudden emergency doctrine, in turn, is an expression of the applicable standard of care against which particular actions are judged in order to determine whether they were negligent in character. The fault of one person, determined in the light of a sudden emergency instruction, can be compared to the fault of another person, whose negligence may have created the emergency, with no logical inconsistency. […]

We believe that the sudden emergency instruction is a generally useless appendage to the law of negligence. With or without an emergency, the standard of care a person must exercise is still that of a reasonable person under the circumstances. With or without the instruction, parties are still entitled to present evidence at trial which will establish what the circumstances were, and are also entitled to argue to the jury that they acted as a reasonable person would have in light of those circumstances. Thus, barring circumstances that we cannot at the moment hypothesize, a sudden emergency instruction serves no positive function. Further, the instruction may cause confusion by appearing to imply that one party is less blameworthy than the other. Therefore, we hold that it should not be used unless a court finds that the particular and peculiar facts of a case warrant more explanation of the standard of care than is generally required […].

AFFIRMED.

§ 9 ***Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm*** (2010):

"If an actor is confronted with an unexpected emergency requiring rapid response, this is a circumstance to be taken into account in determining whether the actor's resulting conduct is that of the reasonable careful person".

- This section addresses the situation in which an actor faces two or more choices of conduct, each of which entails its own combination of advantages and disadvantages. In an emergency, the fact of the emergency itself may mean that the response is instinctive rather than deliberative; at the least, it indicates that the opportunities for deliberation have been limited by severe time pressures.

- The emergency can be created by the conduct of another person, or without human action (failure of the brakes).

- Emergency. The kind of event that prevents reasonable people from exercising the kind of good judgment that such people ordinarily exercise.

- Prior negligence of the defendant. A number of courts adopt the rule that the emergency doctrine does not apply when the emergency is due to the defendant's prior negligence, but not all.

Capítulo 4º
Negligencia (II): Estimación del riesgo

1. Cálculo del riesgo. Concepto económico de culpa / *Calculus of risk. The Economic Concept of Negligence* 54
1.1. *Eckert v. Long Island R.R.* (43 N.Y. 502 (1871)) 54
1.2. STS, 1ª, 1186/2004, de 10 de diciembre 56
1.3. *United States v. Carroll Towing Co.* (159 F.2d 169 (2d Cir. 1947)) 56
2. Negligencia como incremento irrazonable de riesgo / *Negligence as non-reasonable increase of risk* 59
2.1. *Helling v. Carey* (83 Wash. 2d 514, 519 P.2d 981 (1974)) 59
2.2. STS, 3ª, de 26 de junio de 2008 61
2.3. STS, 1ª, 64/2011, de 9 de febrero 61
2.4. STS, 1ª, 149/2010, de 25 de marzo 62
3. Costumbre / *Custom* 62
3.1. *The T.J. Hooper* (60 F.2d 737 (2d Cir.), cert. denied, 287 U.S. 662 (1932)) 63
3.2. Pablo SALVADOR CODERCH/Antonio FERNÁNDEZ CRENDE, "Instrumentos de control social y derecho de daños", *InDret* 4/2004 (www.indret.com), pp. 10-12 65

1. Cálculo del riesgo. Concepto económico de culpa / *Calculus of risk. The Economic Concept of Negligence*

La idea de que, en un mundo finito, con recursos limitados, la precaución que hay que aplicar a la realización de una actividad lícita, pero peligrosa, no es infinita es muy antigua:

1.1. *Eckert v. Long Island R.R.* (43 N.Y. 502 (1871))

"[…] The case, as made by the plaintiff, was that the deceased received an injury from a locomotive engine of the defendant, which resulted in his death, on the 26th day of November, 1867, under the following circumstances:

He was standing in the afternoon of the day named, in conversation with another person about fifty feet from the defendant's track in East New York, as a train of cars was coming in from Jamaica at a rate of speed estimated by the plaintiff's witnesses of from twelve to twenty miles an hour. The plaintiff's witnesses heard no signal either, from the whistle or the bell upon the engine. The engine was constructed to run either way without turning and it was then running backward with the cowcatcher next the train it was drawing, and nothing in front to remove obstacles from the track. The claim of the plaintiff was that the evidence authorized the jury to find that the speed of the train was improper and negligent in that particular place, it being a thickly populated neighborhood and one of the stations of the road.

The evidence on the part of the plaintiff also showed that a child three or four years old was sitting or standing upon the track of the defendant's road as the train of cars approached and was liable to be run over, if not removed; and the deceased, seeing the danger of the child, ran to it, and, seizing it, threw it clear of the track on the side opposite to that from which he came, but, continuing across the track himself, was struck by the step or some part of the locomotive or tender, thrown down, and received injuries from which he died the same night.

The evidence on the part of the defendant tended to prove that the cars were being run at a very moderate speed, not over seven or eight miles an hour, that the signals required by law were given, and that the child was not on the track over which the cars were passing, but on a side track near the main track.

So far as there was any conflict of evidence or question of fact, the questions were submitted to the jury. At the close of the plaintiff's case, the counsel for the defendant moved for a nonsuit upon the ground that it appeared that the deceased's negligence contributed to the injury and the motion was denied and an exception taken. After the evidence was all in, the judge was requested by the counsel for the defendant to charge the jury, in different forms, that if the deceased voluntarily placed himself in peril from which he received the injury, to save the child, whether the child was or was not in danger, the plaintiff could not recover and all the requests were refused and exceptions taken, and the question whether the negligence of the intestate contributed to the accident was submitted to the jury. The jury found a verdict for the plaintiff and the judgment entered thereon was affirmed, on appeal, by the Supreme Court and from the latter judgment the defendant has appealed to this court.

GROVER, J. The important question in this case arises upon the exception taken by the defendant's counsel to the denial of his motion for a nonsuit, made upon the ground that the negligence of the plaintiff's intestate contributed to the injury that caused his death. The evidence showed that the train was approaching in plain view of the deceased, and had he for his own purposes attempted to cross the track, or with a view to save property placed himself voluntarily in a position where he might have received an injury from a collision with the train, his conduct would have been grossly negligent, and no recovery could have been had for such injury. But the evidence further showed that there was a small child upon the track, who, if not rescued, must have been inevitably crushed by the rapidly approaching train. This the deceased saw, and he owed a duty of important obligation to this child to rescue it from its extreme peril, if he could do so without incurring great danger to himself. Negligence implies some act of commission or omission wrongful in itself. Under the circumstances in which the deceased was placed, it was not wrongful in him to make every effort in his power to rescue the child, compatible with a reasonable regard for his own safety. It was his duty to exercise his judgment as to whether he could probably save the child without serious injury to himself. If, from the appearances, he believed that he could, it was not negligence to make an attempt so to do, although believing that possibly he might fail and receive an injury himself. He had no time for deliberation. He must act instantly, if at all, as a moment's delay would have been fatal to the child. The law has so high a regard for human life that it will not impute negligence to an effort to preserve it, unless made under such circumstances as to constitute rashness in the judgment of prudent persons. For a person engaged in his ordinary affairs, or in the mere protection of property, knowingly and voluntarily to place himself in a position where he is liable to receive a serious injury, is negligence which will preclude a recovery for an injury so received; but when the exposure is for the purpose of saving life it is not wrongful, and therefore not negligent, unless such as to be regarded either rash or reckless. The jury was warranted in finding the deceased free from negligence under the micas above stated. The motion for a nonsuit was therefore properly denied. That the jury was warranted in finding the defendant guilty of negligence in running the train in the manner it was running requires no discussion. None of the exceptions taken to the charge as given, or to the refusals to charge as requested, affect the right of recovery. Upon the principle above stated, the judgment appealed from must be affirmed, with costs.

CHURCH, C. J., and PECKHAM and RAPALLO, JJ., concur.

ALLEN, J., wrote a dissenting opinion, in which FOLGER, J., concurred.

Judgment affirmed".

En la jurisprudencia española, la idea de que la precaución exigible ha de ser conmensurable con el riesgo aparece en muchas sentencias, pero casi nunca de forma central:

1.2. STS, 1ª, 1186/2004, de 10 de diciembre

El 18.8.1990, José Manuel intentó socorrer a otra persona que se estaba ahogando en la playa de Cullera (Valencia) en una zona alejada de la de uso habitual de los bañistas, sin que existiera en las cercanías miembros del servicio de socorristas municipales y cuando el mar estaba picado. A pesar de que una zódiac de socorristas acudió a rescatarles, ambos fallecieron.

La viuda de José Manuel, en nombre propio y en el de su hijo, demandó al Ayuntamiento de Cullera y solicitó una indemnización de 120.202,42 €.

El JPI nº 1 de Sueca estimó la demanda (2.7.1996) y condenó al Ayuntamiento al pago de 102.172 €, de los cuales 72.121,45 € para la actora y 30.050,60 € para su hijo. La AP de Valencia (Secc. 8ª, 4.5.1998) estimó el recurso de apelación, revocó la SJPI y absolvió al Ayuntamiento.

El TS desestimó el recurso de casación al considerar que la actuación de la víctima fue negligente, pues no tuvo en consideración el mal estado del mar, y que la del equipo de salvamento fue adecuada: "el hecho en cuestión no puede ser reprochado culpabilísticamente al eventual responsable –el Ayuntamiento de Cullera- ya que aparte de la actuación personal del fallecido creadora del riesgo por su comportamiento, que aunque impregnado de un sentimiento solidario de amistad y altruismo, no tuvo en cuenta el mal cariz que presentaba el mar, que en ese momento suponía un peligro serio"(FD 1º).

En el caso debe tenerse en cuenta el criterio de la provocación, según el cual debe afirmarse la imputación objetiva del daño cuando el dañado asume el riesgo del que finalmente resulta víctima en su intento de salvar la vida, integridad física o bienes de un tercero en situación de peligro creada negligentemente por la víctima misma.

Obviando la posible responsabilidad de la persona a quien se intentó salvar–que la actora parece olvidar aferrándose a una entidad más solvente, el Ayuntamiento- , la cuestión radica en determinar si el Ayuntamiento, en concreto, los servicios de salvamento, incumplieron, por omisión, el deber de interrumpir el curso causal anteriormente mencionado.

Puede pensarse que, dada la autopuesta en peligro –o, dicho de otro modo, la asunción del riesgo- por parte de los bañistas, la Administración no incumplió su deber de protección y salvamento, pues no tiene la obligación de prever todo tipo de accidentes ni de proveer servicios de salvamento de forma que se reduzca el número de accidentes hasta cero, incluyendo los gravemente negligentes.

En este sentido, según el TS, la actuación de los servicios de salvamento fue "lógica y correcta", pues "no se puede exigir que haya una abundancia tal de socorristas que puedan actuar de inmediato"(FD 1º).

U.S. v. Carroll, resuelto en 1947, es el caso de derecho de daños más famoso del siglo XX quizás porque acuñó el concepto económico de negligencia en el cénit cultural de un sistema económico. Todavía hoy, es inconcebible un curso de responsabilidad civil impartido en cualquiera de las cincuenta facultades de derecho más prestigiosas según los rankings al uso que no mencione *U.S. v. Carroll*, aunque solo sea para tratar de superarlo. Como ha de ser:

1.3. *United States v. Carroll Towing Co.* (159 F.2d 169 (2d Cir. 1947))

[The incident out of which this admiralty case arose was the sinking of a barge, along with its cargo, allegedly because of the defendant's negligence. A crucial issue in the case involved whether the person in charge of the barge, the bargee, was negligent in being ashore, away from the barge, during the period when it got into difficulties and sank. If the bargee's absence was negligence, and if it contributed substantially to the loss of the barge, then the bargee's employer, the owner of the barge, would not receive full recovery from the other parties whose negligence put the barge into difficulties in the first place].

L. HAND, J.
It appears … that there is no general rule to determine when the absence of a bargee or other attendant will make the owner of the barge liable for injuries to other vessels if she breaks away from her moorings. However, in any cases where he would be so liable for injuries to others obviously he must reduce his damages proportionately, if the injury is to his own barge. It becomes apparent why there can be no such general rule, when we consider the grounds for such a liability. Since there are occasions when every vessel will break from her moorings, and since, if she does, she becomes a menace to those about her; the owner's duty, as in other similar situations, to provide against resulting injuries is a function of three variables:

(1) the probability that she will break away;
(2) the gravity of the resulting injury, if she does;
(3) the burden of adequate precautions.

Possibly it serves to bring this notion into relief to state it in algebraic terms: if the probability be called P; the injury, L; and the burden, B; liability depends upon whether B is less than L multiplied by P: i.e., whether B less than PL. Applied to the situation at bar, the likelihood that a barge will break from its fasts and the damage it will do, vary with the place and time; for example, if a storm threatens, the danger is greater; so it is, if it is in a crowded harbor where moored barges are constantly being shifted about. On the other hand, the barge must not be the bargee's prison, even though he lives aboard; he must go ashore at times. We need not say whether, even in such crowded waters as New York Harbor a bargee must be aboard at night at all; it may be that the custom is otherwise… and that, if so, the situation is one where custom should control. We leave that question open; but we hold that it is not in all cases a sufficient answer to a bargee's absence without excuse, during working hours, that he has properly made fast his barge to a pier, when he leaves it. In the case at bar the bargee left at five o'clock in the afternoon of January 3rd, and the flotilla broke away at about two o'clock in the afternoon of the following day, twenty-one hours afterwards. The bargee had been away all the time, and we hold that his fabricated story was affirmative evidence that he had no excuse for his absence. At the locus in quo -especially during the short January days and in the full tide of war activity- barges were being constantly 'drilled' in and out. Certainly it was not beyond reasonable expectation that, with the inevitable haste and bustle, the work might not be done with adequate care. In such circumstances we hold -and it is all that we do hold- that it was a fair requirement that the Conners Company should have a bargee aboard (unless he had some excuse for his absence), during the working hours of daylight.

El remolcador de la compañía demandada remolcaba una línea de barcazas o gabarras, aguas arriba y aguas abajo, en el río Hudson. La línea incluía la Anna C., propiedad de la Connors Company. La Anna C. rompió sus amarras y, llevada por el viento y la marea, abordó un petrolero cuya hélice rasgó el casco de la barcaza que, a continuación, se hundió.

Una cuestión ante el tribunal era si el armador o dueño de la barraca había incurrido en negligencia, había sido contributivamente negligente, pues podría –se alegaba– haber destacado a un bargee –gabarrero, marinero– en la barcaza.

Juez Hand: No hay regla general, ni legal ni consuetudinaria que establezca cuándo la ausencia de un gabarrero, barquero hará al armador responsable por los daños derivados de la rotura de las amarras de la barcaza. Está claro por qué no puede haber una regla general semejante, pues hay ocasiones en las que cualquier barco se soltaría de sus amarras… El deber de cuidado del dueño es una función de tres variables: B = PxL.

Puede ser que la costumbre sea distinta, en cuyo supuesto, gobernará el caso.

En la literatura: Richard POSNER, *A Theory of Negligence* 1 J. Legal Stud. 29 (1972).

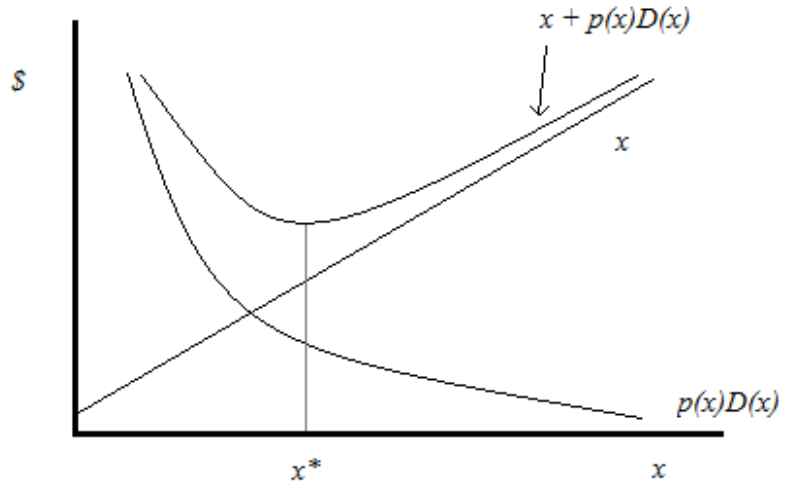


Gráfico de John PRATER BROWN (1983)/Steven SHAVELL (1987).

§ 3 *Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm* (2010): **Negligence**

"A person acts negligently if the person does not exercise reasonable care under all the circumstances."

Primary factors to consider in ascertaining whether the person's conduct lacks reasonable care are:

1) The foreseeable likelihood that the person's conduct will result in harm.
2) The foreseeable severity of any harm that may ensue.
3) And the burden of precautions to eliminate or reduce the risk of harm.

Análisis crítico:

1) Una simple plantilla: *Judex non calculat*, es decir, los tribunales no son consultorías, sino que aplican el derecho a los hechos del caso, tal y como resultan probados en el proceso.
2) La objeción filosófica de la inconmensurabilidad y los problemas empíricos de medición: *Helling v. Carey* (519 P. 22d 981 (Wash. 1974)). Entre los años 1959 y 1968, el demandante acudía a la consulta del oftalmólogo demandado para visitarse y tratarse de una irritación en los ojos causada por lentes de contacto. A finales de 1968, cuando el demandante tenía 32 años de edad, el demandado sospechó que aquel podría sufrir de glaucoma –una enfermedad de los ojos causada por un exceso de presión sobre el nervio óptico- cuando el paciente le dijo que había perdido visión periférica. El oftalmólogo le aplicó entonces un test de presión que confirmó el diagnóstico. El paciente acabó por perder la vista, pero un tratamiento temprano habría evitado el daño. En el pleito que siguió por mala praxis médica, el demandado alegó que el estándar profesional no exigía practicar pruebas de presión a pacientes menores de cuarenta años de edad, pues se trataba de una enfermedad muy poco común que sólo se presentaba en 1/25.000 casos. Suponiendo que el coste de

cada test aplicado a cada niño o persona joven que se visite es de 5 USD, ¿había que haber practicado el test o no? Fíjense que tenemos B = 5, P= 1/25.000, pero que nos falta L, la evaluación de la pérdida de la visión. Si B = PxL, entonces 5 = 125.000/25.000. Mas ¿cuánto vale un ojo de la cara?

3) Un caso similar, apropiado para ser discutido en un seminario, es la STS, 3ª, de 26 de junio de 2008: neuritis óptica de origen tóxico por tratamiento con medicación antituberculosa, Rifinah 300 (principio activo: isoniazida), reacción adversa, muy rara (que se produce en uno de cada diez mil tratamientos) y en caso en el que no existe indicación previa de propensión del paciente a neuritis.
4) Otra cuestión derivada de la presencia masiva de falsos positivos, que encarece mucho la práctica del test: si el test de presión sale positivo en muchos casos, de forma tal que sólo el 4% de los positivos es auténtico, es decir, desarrollarán glaucoma, la cosa se complica. Volveremos sobre la conveniencia o inconveniencia de estar a los estándares profesionales, a la costumbre.
5) Precaución absoluta o precauciones marginales: los primeros 60 euros o dólares USA evitan daños por una evaluación de 120, pero los segundos 40 sólo 30. Entonces, aunque (60 + 40 =) 100 < (120 + 30)= 150, es mejor, menos malo quedarse en 60 de gasto en precauciones, pues los segundos 40 superan en 10 a los 30 que se ahorran con ellos. Si no aprecian contar en unidades económicas, en dinero, pueden hacerlo en cualquier otra unidad que no les repela, por ejemplo, en *quality adjusted years of life, QUALY's.*
6) La fórmula no captura el autorriesgo (PORAT-COOTER, 29 J. Legal, Stud 19 (2000)), la autopuesta en riesgo, es decir, que no tiene en cuenta los daños probables causados por el comportamiento del demandado a sus propios bienes y, que en tal sentido, no incentiva la adopción óptima de precauciones.
7) La neutralidad al riesgo es poco plausible como supuesto general: muchas personas prefieren un 10% de probabilidad de perder 100 al 100% de perder 10. La función de utilidad crece menos proporcionalmente que la renta.
8) ¿Por qué es negligente la gente? Si es racional, no debería serlo.
9) Discontinuidades: pequeños errores en la apreciación del estándar llevan a discontinuidades en la función de responsabilidad: el médico cirujano pasa de ser un prudente profesional a un homicida negligente. Por un pequeño error. Y
10) ¿Sabemos realmente calcular las consecuencias de todas y de cada una de nuestras decisiones arriesgadas para nosotros mismos y para los demás? ¿Lo hacemos así?

2. Negligencia como incremento irrazonable de riesgo / *Negligence as non-reasonable increase of risk*

Tal y como se ha venido señalando en estas Sesiones, la otra cara de la definición de la negligencia concebida como infracción de deberes de cuidado es su concepción como incremento irrazonable de un riesgo. En el contexto del análisis de la regla de Hand, *Helling v. Carey* ilustra muy claramente este enfoque:

2.1. *Helling v. Carey* (83 Wash. 2d 514, 519 P.2d 981 (1974))

HUNTER, ASSOCIATE JUSTICE. This case arises from a malpractice action instituted by the plaintiff (petitioner), Barbara Helling.

The plaintiff suffers from primary open angle glaucoma. Primary open angle glaucoma is essentially a condition of the eye in which there is an interference in the ease with which the nourishing fluids can flow out of the eye. Such a condition results in pressure gradually rising above the normal level to such an extent that damage is produced to the optic nerve and its fibers with resultant loss in vision.... The disease usually has few symptoms and, in the absence of a pressure test, is often undetected until the damage has become extensive and irreversible.

The defendants (respondents), Dr. Thomas F. Carey and Dr. Robert C. Laughlin, are partners who practice the medical specialty of ophthalmology. Ophthalmology involves the diagnosis and treatment of defects and diseases of the eye.

The plaintiff first consulted the defendants for myopia, nearsightedness, in 1959. At that time she was fitted with contact lenses. [She consulted the defendants several times over the next nine years.] Until the October 1968 consultation, the defendants considered the plaintiff's visual problems to be related solely to complications associated with contact lenses. On that occasion, the defendant, Dr. Carey, tested the plaintiff's eye pressure and field of vision for the first time. This test indicated that the plaintiff had glaucoma. The plaintiff ... was then 32 years of age.

Thereafter, in August of 1969, after consulting other physicians, the plaintiff filed a complaint against the defendants alleging, among other things, that she sustained severe and permanent damage to her eyes as a proximate result of the defendants' negligence. During trial, the testimony of the medical experts for both the plaintiff and the defendants established that the standards of the profession for that specialty in the same or similar circumstances do not require routine pressure tests for glaucoma upon patients under 40 years of age. The reason the pressure test for glaucoma is not given as a regular practice to patients under the age of 40 is that the disease rarely occurs in this age group. Testimony indicated, however, that the standards of the profession do require pressure tests if the patient's complaints and symptoms reveal to the physician that glaucoma should be suspected.

The trial court entered judgment for the defendants following a defense verdict. The plaintiff thereupon appealed to the Court of Appeals, which affirmed the judgment of the trial court (...).

We find this to be a unique case. (…) The issue is whether the defendants' compliance with the standard of the profession of ophthalmology, which does not require the giving of a routine pressure test to persons under 40 years of age, should insulate them from liability under the facts in this case where the plaintiff has lost a substantial amount of her vision due to the failure of the defendants to timely give the pressure test to the plaintiff.

The incidence of glaucoma in one out of 25,000 persons under the age of 40 may appear quite minimal. However, that one person, the plaintiff in this instance, is entitled to the same protection as afforded persons over 40, essential for timely detection of the evidence of glaucoma where it can be arrested to avoid the grave and devastating result of this disease. The test is a simple pressure test, relatively inexpensive. There is no judgment factor involved, and there is no doubt that by giving the test the evidence of glaucoma can be detected. The giving of the test is harmless if the physical condition of the eye permits. The testimony indicates that although the condition of the plaintiff's eyes might have at times prevented the defendants from administering the pressure test, there is an absence of evidence in the record that the test could not have been timely given (...).

Under the facts of this case reasonable prudence required the timely giving of the pressure test to this plaintiff. The precaution of giving this test to detect the incidence of glaucoma to patients under 40 years of age is so imperative that irrespective of its disregard by the standards of the ophthalmology profession, it is the duty of the courts to say what is required to protect patients under 40 from the damaging results of glaucoma.

We therefore hold, as a matter of law, that the reasonable standard that should have been followed under the undisputed facts of this case was the timely giving of this simple, harmless pressure test to this plaintiff and that, in failing to do so, the defendants were negligent, which

proximately resulted in the blindness sustained by the plaintiff for which the defendants are liable (...).

The judgment of the trial court and the decision of the Court of Appeals is reversed, and the case is remanded for a new trial on the issue of damages only.

En la jurisprudencia española, la problemática abordada por Helling aparece en numerosas sentencias. Destacamos algunas:

2.2. STS, 3ª, de 26 de junio de 2008

En abril de 1999, el Sr. Octavio acudió a un Centro de Atención Primaria de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) donde el Dr. Millán, médico de cabecera del actor, le diagnosticó tuberculosis, que no fue confirmada por médico especialista, e inició tratamiento farmacológico con Rifinah (F: Sanofi Aventis, S.A.; PA: Isoniazida, Rifampicina; AT: tratamiento de la tuberculosis). En agosto de 1999, se retiró la medicación al Sr. Octavio porque su consumo le había causado una neuritis óptica bilateral, lo que devino en una incapacidad permanente absoluta. Consta acreditado que la neuritis óptica es una reacción poco frecuente (1/10.000 tratamientos) de la isoniazida y que puede paliarse con vitamina B 6, que no se le administró al paciente.

El Sr. Octavio interpuso, primero, reclamación administrativa contra la Administración General del Estado, el Instituto Nacional de la Salud y Mapfre Industrial, S.A. en la que solicitaba 26 millones de ptas. (156.263 euros), que fue desestimada por silencio administrativo y, después, recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, que también fue desestimado (3.3.2004). El actor interpuso finalmente recurso de casación.

El TS estimó dicho recurso de casación, en el que se alegaba infracción del art. 141.1 Ley 30/1992, y condenó a la Administración General del Estado al pago de 30.000 euros porque "debe entenderse que siendo médicamente conocidos los efectos secundarios de la administración de isoniacida y que estos hubieran podido, si no prevenirse, sí minimizarse con la administración conjunta de la vitamina B 6, la no pautación de dicha vitamina al recurrente, a quien como a cualquier paciente, según el informe pericial, se le podían producir dichos efectos secundarios, sin olvidar además que al mismo no se le había realizado prueba que hubiese permitido una mejor confirmación del diagnóstico de presunción, supone una infracción de la "lex artis" que le ha generado una pérdida de oportunidad, en cuanto los resultados hubieran podido ser otros, si se le hubiese administrado conjuntamente la vitamina B 6" (FD 5ª).

2.3. STS, 1ª, 64/2011, de 9 de febrero

El 3.3.2001, Isaac esquiaba en la estación de La Molina (propiedad de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), junto a su familia, cuando cayó y se deslizó hasta impactar contra un cañón de nieve artificial. A raíz del accidente, a Isaac se le rompieron las vértebras D7, D8, D11 y D12, pertenecientes a dos zonas diferentes de la columna, y sufre paraplejia L1, con afectación de esfínteres rectales y urinarios.

Isaac y su mujer África demandaron, en su nombre y en el de sus tres hijas menores de edad –Maite, Melisa y Noemí–, a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y a su aseguradora Winterthur y solicitaron una indemnización por los daños y perjuicios sufridos (no consta cuantía).

El JPI nº 7 de Barcelona (15.12.2004) estimó en parte la demanda y condenó a las demandadas (a Winterthur solamente hasta los 300.005,99€) al pago de 646.803,97€ a Isaac y de 90.000€ por el daño moral causado a la mujer y a las hijas del actor.

La AP de Barcelona (Sección 1ª, 20.9.2006) estimó en parte el recurso de apelación interpuesto por los actores y aumentó la indemnización a pagar por las demandadas a 790.220,60€ y a 110.000 € respectivamente.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por los demandados:

"(…) debe juzgarse como razonable la decisión de calificar como no diligente la conducta de la empresa titular de la estación pues […] el dueño de una estación de esquí se encuentra obligado a poner los medios adecuados para evitar el daño teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad que gestiona, y con mayor motivo, cuando contribuyó a incrementar el riesgo propio de la actividad deportiva colocando en un lugar próximo a la pista un elemento artificial, rígido y duro, como un cañón artificial, que generó un riesgo evidente de lesiones en caso de colisión, incluso si esta se producía por consecuencia de un deslizamiento subsiguiente a una caída. Y siendo todo ello previsible, las caídas, las colisiones y el daño, no podía limitarse a señalar el elemento sino que le incumbía adoptar medidas de seguridad encaminadas a evitar o a disminuir el riesgo de lesiones, lo que no hizo". (FD 4º)

Vídeo de un accidente similar en Vallter 2000 en el año 2008
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/11638/el-terrible-accidente-en-la-nieve-que-costo-la-vida-a-un-joven-colombiano-en-espana/

2.4. STS, 1ª, 149/2010, de 25 de marzo

Una mujer de 65 años de edad y con problemas óseos y articulares, que habían determinado en 1987 el reconocimiento de una situación de invalidez absoluta, no advirtió que, en la entrada de un restaurante había un escalón, por lo que tropezó y se cayó. Como resultado de la caída, sufrió facturas del subcapital de fémur derecho, de la vértebra C1 sin desplazamiento y de la vértebra C2, que agravaron su artrosis previa.

La víctima demandó a la sociedad limitada propietaria del restaurante y a su compañía de seguros. El JPI desestimó la demanda. La AP estimó en parte el recurso de apelación de la actora y condenó a los demandados al pago de 45.076 euros. El TS desestimó el recurso de casación de los demandados y confirmó la SAP:

"[E]l tribunal de apelación no infringió el art. 1902 CC (…) porque en definitiva esta Sala sí comparte el juicio esencial de dicho tribunal sobre la negligencia inherente a la disposición o configuración del acceso del hostal al restaurante, con un escalón intermedio a escasísima distancia del umbral y precisamente en la zona de claroscuro provocado, simultáneamente, por los diferentes colores del pavimento y la luz solar a la entrada y al fondo, quedando en penumbra precisamente el punto en que se encontraba el escalón (…) [L]a causa de la caída no fue sólo esa omisión negligente dado que también contribuyó de forma importante el estado físico de la demandante que afectaba a su capacidad de deambulación. En suma, el problema no es tanto de culpa de la víctima, pues ninguna culpa hay en padecer enfermedades o limitaciones ósea y articulares, cuanto de imputación al demandado de la causa de lo sucedido y de sus consecuencias (FD. 4º).

3. Costumbre / *Custom*

La costumbre, los usos de la profesión, arte u oficio, sus buenas prácticas, son índices de calidad, de conducta adecuada, por diligente, del demandado, pero son solo eso: indicios, pues ni siquiera constituyen una presunción en sentido estricto. Por cierto, ¿conoce el lector la distinción entre presunciones, indicios y sospechas?

En cualquier caso, para valorar el comportamiento del demandado, hay que tener en cuenta, en primerísimo lugar, las disposiciones de la ley o, más frecuentemente, de los reglamentos que la

desarrollan en tema de estándares de precaución. Aquí es importante destacar que, entre la ley (y el reglamento), por un lado, y la costumbre, hay muchas posibilidades alternativas. Véase si no, la lista siguiente:

[First of all, statutory standards of care have to be taken into account:

a. Specific Safety Regulations.
b. Best Available Technology (BAT)
c. As Low As Reasonably Achievable (ALARA)
d. Cost-benefit: Entergy Corp. v. Riverkeeper Inc. et al.
e. The utmost care standard…
f. …

And then, there is:]

g. Custom

The general principles of negligence ("The reasonable person standard"), writes Epstein (p. 221), leave judges a great deal of latitude in deciding cases. This generality introduces a large element of uncertainty even in ostensible routine cases. Using custom to set the standard of care is one way to reduce this uncertainty.

The question is then: Should custom be given the same deference in actions between strangers as in actions arising out of consensual relationships? Does "reasonable safe" mean "safe according to the usages, habits, and ordinary risks of the business"? See *Titus v. Bradford, B & K*. R. Co. 20 A. 517 (Pa. 1890).

El caso de referencia sobre usos, costumbre y tecnología es *The T.J. Hopper*. Resuelto hace ochenta años, su lectura es todavía un magnífico punto de partida para el análisis de la cuestión de si la costumbre induce diligencia:

3.1. *The T.J. Hooper* (60 F.2d 737 (2d Cir.), cert. denied, 287 U.S. 662 (1932))

Petition by the Eastern Transportation Company, as owner of the tugs Montrose and T. J. Hooper, for exoneration from, or limitation of, liability; separate libels by the New England Coal & Coke Company and by H. N. Hartwell & Son, Inc., against the Northern Barge Corporation, as owner of the barge Northern No. 30 and the barge Northern No. 17; and libel by the Northern Barge Corporation against the tugs Montrose and Hooper. The suits were joined and heard together. From the decree rendered [53 F.(2d) 107], the petitioner Eastern Transportation Company and the Northern Barge Corporation, appeal.

[The operator of a tugboat was sued for the value of two barges and their cargoes, which were lost at sea during a coastal storm in March 1928. The basis of the claim was that the tug was negligently unseaworthy in that it was not equipped with a radio receiver, and thus could not receive reports of an impending storm. There was evidence that the master, had he heard the weather reports, would have turned back]

L. HAND,

It is not fair to say that there was a general custom among coastwise carriers so to equip their tugs. One line alone did it; as for the rest, they relied upon their crews, so far as they can be said to have relied at all. An adequate receiving set suitable for a coastwise tug can now be got at small cost and is reasonably reliable if kept up; obviously it is a source of great protection to their tows. Twice every day they can receive these predictions, based upon the widest possible information, available to every vessel within two or three hundred miles and more. Such a set is the ears of the tug to catch the spoken word, just as the master's binoculars are her eyes to see a

storm signal ashore. Whatever may be said as to other vessels, tugs towing heavy coal laden barges, strung out for half a mile, have little power to manoeuvre, and do not, as this case proves, expose themselves to weather which would not turn back stauncher craft. They can have at hand protection against dangers of which they can learn in no other way.

Is it then a final answer that the business had not yet generally adopted receiving sets? There are, no doubt, cases where courts seem to make the general practice of the calling the standard of proper diligence; we have indeed given some currency to the notion ourselves. Indeed in most cases reasonable prudence is in fact common prudence; but strictly it is never its measure; a whole calling may have unduly lagged in the adoption of new and available devices. It never may set its own tests, however persuasive be its usages. Courts must in the end say what is required; there are precautions so imperative that even their universal disregard will not excuse their omission. But here there was no custom at all as to receiving sets; some had them, some did not; the most that can be urged is that they had not yet become general. Certainly in such a case we need not pause; when some have thought a device necessary, at least we may say that they were right, and the others too slack. The statute (section 484, title 46, U. S. Code [46 USCA § 484]) does not bear on this situation at all. It prescribes not a receiving, but a transmitting set, and for a very different purpose; to call for help, not to get news. We hold the tugs therefore because had they been properly equipped, they would have got the Arlington reports. The injury was a direct consequence of this unseaworthiness.

Decree affirmed.

The Restatement (Third) of Torts "downgrades the role of custom" (Epstein) holding that compliance with the custom of the community is evidence that the actor's conduct is not negligence, but does not preclude a finding of negligence".

§ 13 *Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm* (2010)**: Custom**

(a) An actor's compliance with the custom of the community, or of others in like circumstances is evidence that the actor's conduct is not negligent but does not preclude a finding of negligence.

(b) An actor's departure from the custom of the community, or of others in like circumstances, in a way that increases risk is evidence of the actor's negligence but does not require a finding of negligence.

Epstein's dissenting analysis from The T. J. Hooper:

Hand's view has received overwhelming acceptance. Epstein disagrees. First, in cases that arise out of a consensual arrangement, negligence is often the appropriate standard of liability, and where it is so, custom should be regarded as conclusive evidence of due care in absence of any contractual stipulation to the contrary. Second, in stranger cases, negligence should normally not be the appropriate standard of care, so that reliance on custom is as irrelevant as the negligence issue to which custom alone is properly directed (…) because it registers the preferences of the parties to the custom, not those who are victimized by it.

Compare: custom in international law –as a source of legal obligations-; custom in contract law.

Discuss:

- Compliance with the custom of the community. Widespread reliance on custom.
- Private standards ("codes") and public recommendations. Example: National Electric Safety Code, issued by the American National Standards Institute.
- Actor's departure from the custom of the community (typically: a large-scale defendant that has adopted standards applicable to its own operations or its own employees). Departure impugns any claim by the defendant that the risk is unforeseeable or that the safety practice is

unfeasible. What happens when the actor departs from its own standard? The main question is the admissibility of introducing evidence regarding the defendant's violation of its own standard as admissible on the issue of negligence. Divided results. Grounds: if the admission of evidence is to be used against the defendant as an admission of departure, he would naturally find it to his interest NOT to adopt any rules at all. Counterargument: The defendant itself had made these decisions, *facta propria*.

Trimarco v. Klein (N.Y. 1982): plaintiff injured in 1976 when he slipped in his bathroom and received serious lacerations from crashing against a shower door made of ordinary glass estimated to be between 1/16 and ¼ an inch thick. The shower had been installed in the 1950´s, when the use of ordinary glass was standard practice. Since the mid-60´s , the common practice in NYC had been to use safer tempered glass… Must all old shower doors be replaced? Sprinklers and burglar alarms be retrofitted in old buildings?

Why should conformity to the practice protect a physician from liability? One good ground: no other standard is practical. The battle of the experts. The (technical) incompetence of courts.

Local or national standards?: "The time has come when the medical profession should no longer be Balkanized by the application of varying geographic standards" (Brune v. Bellinkoff, Mass 1968). The proper standard is whether the physician has exercised the degree of care and skill of the average qualified practitioner, taking into account the advances in the profession.

Read: Kenneth S. ABRAHAM, *Custom, Non-customary Practice, and Negligence*, 109 Colum , l. Rev. 1784 (2009).

3.2. Pablo SALVADOR CODERCH/Antonio FERNÁNDEZ CRENDE, "Instrumentos de control social y derecho de daños", *InDret* 4/2004 (www.indret.com), pp. 10-12

"*El Derecho de Daños como instrumento de control social: un ejemplo sencillo aplicado a la instalación de dispositivos ABS para vehículos*

Para ilustrar cómo el derecho, y el derecho de daños en particular, contribuye a pasar de peores a mejores situaciones puede servir un ejemplo inspirado en otro que se puede encontrar en SCÄFER/OTT (2000) y que hemos reformulado para adaptarlo al sistema de frenado ABS (***Anti-Block System***) para automóviles. Éste es un dispositivo electrónico antibloqueo que controla la presión de líquido de los frenos y de esta forma evita que las ruedas se bloqueen cuando se ejerce una presión excesiva sobre el pedal, generalmente en situaciones de alto riesgo. En 1978, Mercedes Benz instala el primer sistema ABS en un coche de serie como sistema opcional. Con posterioridad, muchas firmas lo incorporaron a sus vehículos como equipo de serie, aunque todavía no era obligatorio[1].

[1] El sistema de antibloqueo de ruedas al frenar (ABS) se convirtió en un dispositivo de serie obligatorio para todos los turismos nuevos vendidos en la Unión Europea a partir de 2003, en virtud de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión «Protección de los peatones: Compromiso de la industria europea del automóvil» (COM(2001) 389 — C5-0537/2001— 2001/2216(COS)), de 13 de junio de 2002 (P5_TA(2002)0323; DO C 261 E/576, de 30.10.2003). Sin embargo, la normativa se ha visto ya superada en este punto por el Reglamento (CE) nº 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO L 200\1, de 31.7.2009), el cual estableció el ESP (*Electronic Stability Control*, que incluye la función de ABS) como dispositivo de serie obligatorio en todos los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos que se vendan en la Unión Europea desde el 1 de noviembre de 2011.

Es indudable que este dispositivo mejora la capacidad de frenado de un vehículo bajo cualquier circunstancia por lo que evita accidentes individuales y también colectivos. Pero además, si todos disponen del mismo, contribuye a disminuir en gran medida la probabilidad de colisión entre vehículos. Es este segundo efecto el que nos interesa destacar aquí.

En un sencillo ejemplo, dos conductores (C1 y C2) barajan la posibilidad de instalar sendos sistemas de frenado ABS. La utilidad anual que cada conductor obtiene del disfrute de su automóvil es de 1200 €, y sus costes esperados serán de 600 € que resultan de una probabilidad del 6% de sufrir un accidente que le comportará daños por valor de 10.000 € (0,06 x 10.000). La instalación de un dispositivo de ABS tiene un coste de 100 € anuales ya que este sistema requiere de revisiones periódicas. Pero disponer de él reduce la probabilidad de sufrir un accidente de un 6% a un 2%, por lo que los costes esperados bajarán a 200 € (0'02 x 10.000).

Los *pay-offs* de una y otra opción para C1 y C2 figuran en la tabla siguiente:

		C2	
		ABS	NoABS
C1	ABS	900, 900	500, 600
	NoABS	600, 500	600, 600

Supongamos que C2 opta por instalar el ABS. Entonces C1 hará lo propio, pues 900 > 600 como podemos observar en la primera columna. Por el contrario, si C2 resuelve no instalarlo, C1 tampoco lo hará, pues estaremos en la segunda columna, 600 > 500. Si partimos de la decisión de C1 llegaremos a la misma conclusión, resultando las dos situaciones de equilibrio señaladas en la tabla. Se observa que existe un equilibrio eficiente (casilla superior izquierda) y otro ineficiente (casilla inferior derecha) que se corresponden con sendos equilibrios de Nash. A cuál de ellos se llegará, dependerá de circunstancias externas como señalan SCHÄFER y OTT para un ejemplo similar: si C1 sabe que C2 ha instalado el ABS, hará lo propio, pero si sabe que no lo ha hecho, tampoco lo hará él, pues un solo ABS no disminuye suficientemente la frecuencia y gravedad de las colisiones entre vehículos. *A priori*, bajo un sistema de ausencia de responsabilidad *(no liability rule)*, no hay garantías de que ninguna de las dos partes se comportará correctamente tras asumir que la otra lo hará.

Supongamos ahora una situación en la que existe una serie de n conductores C1, C2, C3,... Cn, para $1<n<\infty$ y p es la probabilidad de que un conductor haya instalado el sistema ABS en su vehículos. Entonces los beneficios esperados para C1 serán:

Beneficios en caso de ABS → $B(ABS)= p\cdot 900 + (1-p)\cdot 500= p\cdot 400 + 500$
Beneficios en caso de No ABS → $B(NoABS)= p\cdot 600 + (1-p)\cdot 600= 600$
(donde probabilidad: $p \in [0,1]$)

C1 optará por instalar ABS siempre que:

B(ABS)>B(NoABS), entonces:
$p\cdot 400 + 500 > 600$,
$p> 0'25$

De donde resulta que C1 instalará el ABS en su automóvil siempre que la probabilidad sea superior a 25%, esto es, cuando más de una cuarta parte de los vehículos dispongan de él, pero no lo hará si la proporción es inferior, pues no le saldrá a cuenta. El ejemplo ilustra un caso típico de instalación de dispositivos en los que se produce un efecto de externalidades de red –

network externalities- ya que a mayor número de usuarios de un mismo producto o servicio, mayor será la utilidad que cada uno de ellos obtendrá de él. Pero, a pesar de que todos los interesados coincidan en que la difusión generalizada del producto sería socialmente beneficiosa, la existencia de dos equilibrios puede comportar que los sucesivos intentos de comercializar el uso del producto fracasen debido a que la red no esté lo suficientemente extendida para crear los incentivos privados necesarios para la instalación. Pero un cambio de jurisprudencia o, por supuesto, de legislación podría dar un vuelco a esta situación: por ejemplo, si el Tribunal Supremo, ante un caso de reclamación de daños y perjuicios por colisión entre dos vehículos, resuelve que la falta de instalación de ABS es negligencia y que ésta reduce o anula la indemnización a que tendría derecho el actor, entonces ningún conductor podrá reclamar si no disponía de ABS y, en cambio, deberá pagar los daños resultantes al otro vehículo. Los pagos para C1 se verían modificados de la manera siguiente:

		C2, C3, C4,... Cn	
		ABS	NoABS
C1	ABS	900 900	0 1100
	NoABS	1100 0	600 600

(donde indemnización esperada: I = 0,06 x 10.000= 600)

Si instala ABS, en caso de colisión será indemnizado por aquél que fue negligente porque no lo instaló. En cambio, si no instala el sistema deberá pagar una indemnización a quién lo había instalado, o bien, en caso de que el otro tampoco lo hubiera instalado cada uno asumirá sus propios daños.

Podemos observar cómo independientemente de la decisión de los demás individuos, para C1 resulta más beneficioso instalar ABS ya que los pagos de la fila superior son siempre superiores a los de la inferior. De esta forma, el precedente jurisprudencial habría inducido los incentivos privados necesarios para la generalización del producto, que de otra forma no hubiera podido producirse".

Capítulo 5º
Negligencia (III): Negligencia *per se* y *res ipsa loquitur*

1. Negligencia *per se*. Infracción de normas legales. Presunciones 68
1.1. *Gorris v. Scott* (L.R. 9 Ex. 125 (1874)) 70
1.2. *Martin v. Herzog* (126 N.E. 814 (N.Y. 1920)) 72
1.3. *Tedla v. Ellman* (280 N.Y. 124, 19 N.E.2d 987 (1939)) 72
1.4. *Brown v. Shyne* (151 N.E. 197 (N.Y. 1926)) 74
1.5. SAP de Almería, Secc. 2ª, Penal, 286/2000, de 3 de julio 76
1.6. *Uhr v. East Greenbush Cent. Sch. Dist.* (720 N.E.2d 886 (N.Y. 1999)) 79
1.7. STS, 1ª, 223/2013, de 12 de abril 81
1.8. STS, 1ª, 909/2005, de 9 de noviembre 81
1.9. STS, 1ª, 17/2004, de 3 de febrero 82
1.10. *Preemption* 83
2. *Res ipsa loquitur* 90
2.1. *Byrne v. Boadle* (159 Eng. Rep. 299 (Ex. 1863)) 90
2.2. *Colmenares Vivas v. Sun Alliance Insurance Co.* (807 F.2d 1102 (1st Cir. 1986)) . 91
2.3. *Ybarra v. Spangard* (25 Cal.2d 486, 154 P.2d 687) 93
2.4. STS, 1ª, 1146/1998, de 9 de diciembre 94
2.5. STS, 1ª, 461/2003, de 8 de mayo: fractura de rodilla 95
2.6. Otras sentencias sobre responsabilidad médica por daños desproporcionados 95

1. Negligencia *per se*. Infracción de normas legales. Presunciones

En esta Sesión, tratamos fundamentalmente de tres cuestiones:

En el Common Law, la conducta de quien infringe una ley escrita –o un reglamento—se presume negligente si el fin de protección de la normativa violada es justamente amparar a la víctima de los daños causados: si así es, el demandante no habrá de probar la negligencia del demandado sino únicamente el daño y la causalidad. La presunción admite prueba en contrario (negligencia *per se*). En cambio, si la ley quebrantada no persigue proteger a la víctima de los daños sufridos, su infracción conllevará la aplicación de las consecuencias de derecho previstas por la ley violada, pero será irrelevante a efectos de apreciar la negligencia. Y, finalmente, si el demandado desarrolló su actividad dañina cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios, ello es un indicio de que actuó correctamente, pero, de nuevo, cabe probar que no fue así.

Más allá de la ley escrita o de las regulaciones aplicables a un sector de actividad, una doctrina jurisprudencial común al Common Law y al Civil Law establece que si un accidente tiene lugar en circunstancias tales que su ocurrencia normalmente solo se explica porque su causante ha infringido un deber de cuidado, entonces también se presume su negligencia, siempre con posibilidad de prueba en contrario (res ipsa loquitur).

En tercer lugar, uno de los temas más importantes de los derechos contemporáneos, en entornos intensamente regulados es el relativo a si la regulación legal y reglamentaria de tal o cual actividad, con la consiguiente aplicación de las consecuencias de derecho legalmente previstas que correspondan en caso de infracción, cierran el sistema e impiden el ejercicio de las pretensiones de daños previstas por el derecho común, por ejemplo, por el art. 1902 CC (preemption), o bien y por el contrario, dejan abierta tal posibilidad. En el Common Law angloamericano, la cuestión es muy debatida, pero hay acuerdo en que el legislador puede clausurar el sistema. El problema es doble: si lo hace expresamente, hay que interpretar la delimitación legal del cierre categorial. Y si el cierre es implícito, las dudas interpretativas suelen ser aún mayores.

El derecho español vigente trata de estas cuestiones algo idiosincrásicamente, sobre todo en el caso de la negligencia per se, pues, como veremos, todavía es frecuente encontrar afirmaciones de los tribunales conforme a las cuales la producción del daño permite inferir la negligencia de su causante incluso si cumplió con todas las exigencias legales y reglamentarias.

Comenzaremos analizando los criterios del ***Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm*** (2010) -RTT-, que extractamos del original en inglés y que ofrecen una buena base para una discusión de la negligencia per se en términos de razonabilidad, pero, como acabamos de señalar, no dan razón cabal del derecho español vigente:

§ 14 RTT. Statutory Violations as Negligence Per Se

An actor is negligent if, without excuse, the actor violates a statute that is designed to protect against the type of accident the actor´s conduct causes, and if the accident victim is within the class of persons the statute is designed to protect.

- This section applies to statutes, regulations and ordinances.

- Express and implied statutory causes of action: Some statutes declare conduct unlawful, impose a public-law penalty on the person whose conduct violates the statute, and also specify that the violator is civily liable in damages to the victim of the violation. Certain other statutes simply state that, if certain conduct causes harm, the actor is liable to a victim. Yet large numbers of statutes (…) are silent as to private liability in the event of a statutory violation. Then, the court, relying on ordinary principles of legislative interpretation, may in appropriate cases infer a cause of action for damages.

- Rationales:

a) It would be akward for a court in a tort case to commend as reasonable that behavior that tle legislature has already condemned as unlawful.

b) The judgement of the legislature is the authoritative representative of the community.

c) The negligence standard encounters difficulty in dealing with problems of recurring conduct. (…) statutes address conduct that conspicuously recurs in a way that brings it to the attention of the legislature. Negligence per se hence replaces decision making by juries [career judges].

d) Furthermore, negligence has been settled doctrine in American tort law for many decades, [not under Spanish Law: see infra].

- Negligence per se applies only when the accident that injures the plaintiff is the type of accident that the statute seeks to avert. In some cases, negligence per se does not apply because the statute is not a safety statute at all.

- Licensing statutes: One general purpose of such licensing statutes is to protect the public against physical and emotional harm (…) but in many cases, the immediate reason for the person´s lack of license is unrelated to the state´s general safety purpose. For example, a motorist may lack a license only because of a failure to file for license renewal. If this motorist is involved in an accident, the lack of license has no bearing on the motorist´s negligence. Similarly, a physician may lack a license in a state only because the physician has not yet satisfied the state´s residency requirement. In other cases, however, this general assessment does not pertain. If, for example, a person operates a motorcycle in a way that suggests a lack of skill, and if the evidence shows that the person does not have a license to operate a motorcycle because the person has failed the test that assesses skills, then, depending on the jurisdiction´s rules, the lack of a license may be negligence per se or admissible as tending to show the person´s negligent unskillfulness. Same if a property owner has installed a furnace without securing a permit required by a city ordinance, and the evidence indicates that the inspector would not have issued the permit (…).

- Negligence per se is clearly inappropriate when the actor´s conduct fall below the requirements of a statute enacted **after** the conduct occurred. However, a later-enacted statute can be admissible evidence bearing on the actor´s negligence.

Viceversa, el cumplimiento por el demandado de las regulaciones dictadas para proteger los intereses o la integridad del demandante no excluirá la posibilidad de que este último pruebe la negligencia de aquel, pero será un indicio de que la conducta puesta en cuestión fue correcta, diligente.

Como hemos señalado al inicio de esta Sesión, esta doble construcción no ha sido recibida por el derecho español ni, específicamente, por su jurisprudencia. Esta, como se verá a continuación, a menudo ha sostenido que el cumplimiento de las disposiciones dictadas para prevenir el daño causado no es óbice a la declaración de la existencia de negligencia, pues esta existiría porque el hecho mismo de que se haya producido el accidente implica que las regulaciones eran o habían devenido insuficientes y que alguna negligencia había debido de tener lugar: es una especie de animismo jurídico, acaso propio de un pensamiento primitivo.

Sin embargo y en ocasiones, esta jurisprudencia es contrarrestada por otra según la cual no cabe alegar en casación y ante la Sala 1ª la infracción de normas reglamentarias y puramente administrativas. Tampoco aquí parece que el Tribunal Supremo ande acertado: la mayor parte de las actividades que no pertenecen a los actos más sencillos de la vida cotidiana están intensamente reguladas y la consideración de los estándares establecidos por los agentes reguladores debería de ser un elemento muy importante para evaluar la diligencia o negligencia del demandado. La división jurisdiccional genera así una doctrina oracular e ignora el principio de la unidad del ordenamiento jurídico, de la vieja y buena idea conforme a la cual una tarea básica del intérprete es concordar razonadamente cánones discordantes.

§ 16 RTT Statutory Compliance

(a) An actor´s compliance with a pertinent statute, while evidence of nonnegligence, does not preclude finding that the actor is negligent under § 3 for failing to adopt precautions in addition to those mandated by the statute.

(b) If an actor´s adoption of a precaution would require the actor to violate a statute, the actor cannot be found negligent for failing to adopt that precaution.

- While Subsection (a) states the [U.S.] general common-law rule, this rule can be overcome by a particular statute expressing a contrary understanding.
- In each instance, compliance is evidence of non negligence but it is not conclusive.
- Statutes that merely set minimum standards.
- Unusual circumstances. A finding that additional precautions are called for despite the actor´s compliance with the statute is clearly appropriate if the precaution relates to some unusual situation beyond the generality of situations anticipated by the statute itself.

1.1. *Gorris v. Scott* (L.R. 9 Ex. 125 (1874))

The plaintiffs were entitled to assume that the defendant would perform all the duties cast upon him by the law, including compliance with these orders; and that being so, the defendant has impliedly contracted with the plaintiffs that he would perform them.

Kelly, C.B. This is an action to recover damages for the loss of a number of sheep which the defendant, a shipowner, had contracted to carry, and which were washed overboard and lost by reason (as we must take it to be truly alleged) of the neglect to comply with a certain order made by the Privy Council, in pursuance of the Contagious Diseases (Animals) Act, 18G9. The Act was passed merely for sanitary purposes, in order to prevent animals in a state of infectious disease from communicating it to other animals with which they might come in contact. Under the authority of that Act, certain orders were made; amongst others, an order by which any ship bringing sheep or cattle from any foreign port to ports in Great Britain is to have the place

occupied by such animals divided into pens of certain dimensions, and the floor of such pens furnished with battens or foot-holds. The object of this order is to prevent animals from being overcrowded, and so brought into a condition in which the disease guarded against would be likely to be developed. This regulation has been neglected, and the question is, whether the loss, which we must assume to have been caused by that neglect, entitles the plaintiffs to maintain an action.

The argument of the defendant is, that the Act has imposed penalties to secure the observance of its provisions, and that, according to the general rule, the remedy prescribed by the statute must be pursued ; that although, when penalties are imposed for the violation of a statutory duty, a person aggrieved by its violation may sometimes maintain an action for the damage so caused, that must be in cases where the object of the statute is to confer a benefit on individuals, and to protect them against the evil consequences which the statute was designed to prevent, and which have in fact ensued ; but that if the object is not to protect individuals against the consequences which have in fact ensued, it is otherwise ; that if, therefore, by reason of the precautions in question not having been taken, the plaintiffs had sustained that damage against which it was intended to secure them, an action would lie, but that when the damage is of such a nature as was not contemplated at all by the statute, and as to which it was not intended to confer any benefit on the plaintiffs, they cannot maintain an action founded on the neglect. The principle may be well illustrated by the case put in argument of a breach by a railway company of its duty to erect a gate on a level crossing, and to keep the gate closed except when the crossing is being actually and properly used. The object of the precaution is to prevent injury from being sustained through animals or vehicles being upon the line at unseasonable times; and if by reason of such a breach of duty, either in not erecting the gate, or in not keeping it closed, a person attempts to cross with a carriage at an improper time, and injury ensues to a passenger, no doubt an action would lie against the railway company, because the intention of the legislature was that, by the erection of the gates and by their being kept closed individuals should be protected against accidents of this description. And if we CO see that it was the object, or among the objects of this Act, that the owners of sheep and cattle coming from a foreign port should be protected by the means described against the danger of their property being washed overboard, or lost by the perils of the sea, the present action would be within the principle. But, looking at the Act, it is perfectly clear that its provisions were all enacted with a totally different view ; there was no purpose, direct or indirect, to protect against such damage ; but, as is recited in the preamble, the Act is directed against the possibility of sheep or cattle being exposed to disease on their way to this country. The preamble recites that "it is expedient to confer on Her Majesty's most honourable Privy Council power to take such measures as may appear from time to time necessary to prevent the introduction into Great Britain of contagious or infectious diseases among cattle, sheep, or other animals, by prohibiting or regulating the importation of foreign animals," and also to provide against the " spreading " of such diseases in Great Britain. Then follow numerous sections directed entirely to this object. Then comes s. 75, which enacts that "the Privy Council may from time to time make such orders as they think expedient for all or any of the following purposes." What, then, are these purposes? They are "for securing for animals brought by sea to ports in Great Britain a proper supply of food and water during the passage and on landing," " for protecting such animals from unnecessary suffering during the passage and on landing," and so forth, all the purposes enumerated being calculated and directed to the prevention of disease, and none of them having any relation whatever to the clanger of loss by the perils of the sea. That being so, if by reason of the default in question the plaintiffs' sheep had been overcrowded, or had been caused unnecessary suffering, and so had arrived in this country in a state of disease, I do not say that they might not have maintained this action. But the damage complained of here is something totally apart from the object of the Act of Parliament, and it is in accordance with all the authorities to say that the action is not maintainable.

Judgment for the defendant.

1.2. *Martin v. Herzog* (126 N.E. 814 (N.Y. 1920))

[The decedent was killed in a collision between the buggy he was driving and defendant's automobile. The accident occurred after dark, and decedent was driving the buggy without any lights, in violation of a statute. The defendant requested a ruling that the absence of a light on the plaintiff's vehicle was "prima facie evidence of contributory negligence". This request was refused, and the jury was instructed that it might consider the absence of lights as some evidence of negligence, but not conclusive evidence of negligence. The plaintiff next requested a charge that "the fact that the plaintiff's intestate was driving without a light is not negligence in itself", and to this the court acceded. The jury found the defendant liable and the decedent free from contributory negligence and the plaintiff had judgment. The appellate division reversed for error in the instructions. Affirmed].

CARDOZO, J. [...] We think the unexcused omission of the statutory signals is more than some evidence of negligence. It is negligence in itself. Lights are intended for the guidance and protection of other travelers on the highway. By the very terms of the hypothesis, to omit, willfully or heedlessly, the safeguards prescribed by law for the benefit of another that he may be preserved in life or limb, is to fall short of the standard of diligence to which those who live in organized society are under a duty to conform. [...] In the case at hand, we have an instance of the admitted violation of a statute intended for the protection of travelers on the highway, of whom the defendant at the time was one. Yet the jurors were instructed in effect that they were at liberty in their discretion to treat the omission of lights either as innocent or as culpable. They were allowed to "consider the default as lightly or gravely" as they would (Thomas, J., in the court below). They might as well have been told that they could use a like discretion in holding a master at fault for the omission of a safety appliance prescribed by positive law for the protection of a workman. Jurors have no dispensing power by which they may relax the duty that one traveler on the highway owes under the statute to another. It is error to tell them that they have. The omission of these lights was a wrong, and being wholly unexcused was also a negligent wrong. No license should have been conceded to the triers of the facts to find it anything else.

We must be on our guard, however, against confusing the question of negligence with that of the causal connection between the negligence and the injury. A defendant who travels without lights is not to pay damages for his fault unless the absence of lights is the cause of the disaster. A plaintiff who travels without them is not to forfeit the right to damages unless the absence of lights is at least a contributing cause of the disaster. To say that conduct is negligence is not to say that it is always contributory negligence.

[...] A statute designed for the protection of human life is not to be brushed aside as a form of words, its commands reduced to the level of cautions, and the duty to obey attenuated into an option to conform. [...]

1.3. *Tedla v. Ellman* (280 N.Y. 124, 19 N.E.2d 987 (1939))

LEHMAN, J.

While walking along a highway, Anna Tedla and her brother, John Bachek, were struck by a passing automobile, operated by the defendant Hellman. She was injured and Bachek was killed. Bachek was a deaf-mute. His occupation was collecting and selling junk. His sister, Mrs. Tedla, was engaged in the same occupation. They often picked up junk at the incinerator of the village of Islip. At the time of the accident they were walking along 'Sunrise Highway' and wheeling baby carriages containing junk and wood which they had picked up at the incinerator. It was about six o'clock, or a little earlier, on a Sunday evening in December. Darkness had already set in. Bachek was carrying a lighted lantern, or, at least, there is testimony to that effect. The jury found that the accident was due solely to the negligence of the operator of the automobile. The defendants do not, upon this appeal, challenge the finding of negligence on the part of the operator. They maintain, however, that Mrs. Tedla and her brother were guilty of contributory negligence as matter of law.

Sunrise Highway, at the place of the accident, consists of two roadways, separated by a grass plot. There are no footpaths along the highway and the center grass plot was soft.

It is not unlawful for a pedestrian, wheeling a baby carriage, to use the roadway under such circumstances, but a pedestrian using the roadway is bound to exercise such care for his safety as a reasonably prudent person would use. The Vehicle and Traffic Law (Cons. Laws, ch. 71) provides that 'Pedestrians walking or remaining on the paved portion, or traveled part of a roadway shall be subject to, and comply with, the rules governing vehicles, with respect to meeting and turning out, except that such pedestrians shall keep to the left of the center line thereof, and turn to their left instead of right side thereof, so as to permit all vehicles passing them in either direction to pass on their right. Such pedestrians shall not be subject to the rules governing vehicles as to giving signals.' (§ 85, subd. 6.) **Mrs. Tedla and her brother did not observe the statutory rule and, at the time of the accident, were proceeding in easterly direction on the east-bound or right-hand roadway**. The defendants moved to dismiss the complaint on the ground, among others, that violation of the statutory rule constitutes contributory negligence as matter of law. They did not, in the courts below, urge that any negligence in other respect of Mrs. Tedla or her brother bars a recovery. The trial judge left to the jury the question whether failure to observe the statutory rule was a proximate cause of the accident; he left to the jury no question of other fault or negligence on the part of Mrs. Tedla or her brother, and the defendants did not request that any other question be submitted. Upon this appeal, the only question presented is whether, as matter of law, disregard of the statutory rule that pedestrians shall keep to the left of the center line of a highway constitutes contributory negligence which bars any recovery by the plaintiff […].

The plaintiffs showed by the testimony of a State policeman that 'there were very few cars going east' at the time of the accident, but that going west there was 'very heavy Sunday night traffic. Until the recent adoption of the new statutory rule for pedestrians, ordinary prudence would have dictated that pedestrians should not expose themselves to the danger of walking along the roadway upon which the 'very heavy Sunday night traffic' was proceeding when they could walk in comparative safety along a roadway used by very few cars. It is said that now, by force of the statutory rule, pedestrians are guilty of contributory negligence as matter of law when they use the safer roadway, unless that roadway is left of the center of the road. Disregard of the statutory rule of the road and observance of a rule based on immemorial custom, it is said, is negligence which as matter of law is a proximate cause of the accident, though observance of the statutory rule might, under the circumstances of the particular case, expose a pedestrian to serious danger from which he would be free if he followed the rule that had been established by custom. If that be true, then the Legislature has decreed that pedestrians must observe the general rule of conduct which it has prescribed for their safety even under circumstances where observance would subject them to unusual risk; that pedestrians are to be charged with negligence as matter of law for acting as prudence dictates. It is unreasonable to ascribe to the Legislature an intention that the statute should have so extraordinary a result, and the courts may not give to a statute an effect not intended by the Legislature […].

The statute upon which the defendants rely is of different character. It does not prescribe additional safeguards which pedestrians must provide for the preservation of the life or limb or property of others, or even of themselves, nor does it impose upon pedestrians a higher standard of care. What the statute does provide is rules of the road to be observed by pedestrians and by vehicles, so that all those who use the road may know how they and others should proceed, at least under usual circumstances. A general rule of conduct -- and, specifically, a rule of the road -- may accomplish its intended purpose under usual conditions, but, when the unusual occurs, strict observance may defeat the purpose of the rule and produce catastrophic results.

Negligence is failure to exercise the care required by law. Where a statute defines the standard of care and the safeguards required to meet a recognized danger, then, as we have said, no other measure may be applied in determining whether a person has carried out the duty of care imposed by law. Failure to observe the standard imposed by statute is negligence, as matter of

law. On the other hand, where a statutory general rule of conduct fixes no definite standard of care which would under all circumstances tend to protect life, limb or property but merely codifies or supplements a common-law rule, which has always been subject to limitations and exceptions; or where the statutory rule of conduct regulates conflicting rights and obligations in manner calculated to promote public convenience and safety, then the statute, in the absence of clear language to the contrary, should not be construed as intended to wipe out the limitations and exceptions which judicial decisions have attached to the common-law duty; nor should it be construed as an inflexible command that the general rule of conduct intended to prevent accidents must be followed even under conditions when observance might cause accidents. We may assume reasonably that the Legislature directed pedestrians to keep to the left of the center of the road because that would cause them to face traffic approaching in that lane and would enable them to care for their own safety better than if the traffic approached them from the rear. We cannot assume reasonably that the Legislature intended that a statute enacted for the preservation of the life and limb of pedestrians must be observed when observance would subject them to more imminent danger.

[…] A pedestrian is, of course, at fault if he fails without good reason to observe the statutory rule of conduct. The general duty is established by the statute, and deviation from it without good cause is a wrong and the wrongdoer is responsible for the damages resulting from his wrong.

In each action, the judgment should be affirmed, with costs.

1.4. *Brown v. Shyne* (151 N.E. 197 (N.Y. 1926))

LEHMAN, J. The plaintiff employed the defendant to give chiropractic treatment to her for a disease or physical condition. The **defendant had no license to practice medicine**, yet he held himself out as being able to diagnose and treat disease, and under the provisions of the Public Health Law he was guilty of a misdemeanor. The plaintiff became paralyzed after she had received nine treatments by the defendant. She claims, and upon this appeal we must assume, that the paralysis was caused by the treatment she received. She has recovered judgment in the sum of $ 10,000 for the damages caused by said injury. […]

At the close of the plaintiff's case the plaintiff was permitted to amend the complaint to allege "that in so treating the plaintiff the defendant was engaged in the practice of medicine contrary to and in violation of the provisions of the Public Health Law of the State of New York in such case made and provided, he at the time of so treating plaintiff not being a duly licensed physician or surgeon of the State of New York." Thereafter the trial judge charged the jury that they might bring in a verdict in favor of the plaintiff if they found that the evidence established that the treatment given to the plaintiff was not in accordance with the standards of skill and care which prevail among those treating disease. He then continued: "This is a little different from the ordinary malpractice case, and I am going to allow you, if you think proper under the evidence in the case, to predicate negligence upon another theory. The public health laws of this State prescribe that no person shall practice medicine unless he is licensed so to do by the Board of Regents of this State and registered pursuant to statute. This statute to which I have referred is a general police regulation. Its violation, and it has been violated by the defendant, is some evidence, more or less cogent, of negligence which you may consider for what it is worth, along with all the other evidence in the case. If the defendant attempted to treat the plaintiff and to adjust the vertebrae in her spine when he did not possess the requisite knowledge and skill as prescribed by the statute to know what was proper and necessary to do under the circumstances, or how to do it, even if he did know what to do, you can find him negligent." In so charging the jury that from the violation of the statute the jury might infer negligence which produced injury to the plaintiff, the trial justice in my opinion erred.

The provisions of the Public Health Law prohibiting the practice of medicine without a license granted upon proof of preliminary training and after examination intended to show adequate knowledge, are of course intended for the protection of the general public against injury which unskilled and unlearned practitioners might cause. If violation of the statute by the defendant

was the proximate cause of the plaintiff's injury, then the plaintiff may recover upon proof of violation; if violation of the statute has no direct bearing on the injury, proof of the violation becomes irrelevant. For injury caused by neglect of duty imposed by the penal law there is civil remedy; but of course the injury must follow from the neglect.

Proper formulation of general standards of preliminary education and proper examination of the particular applicant should serve to raise the standards of skill and care generally possessed by members of the profession in this State; but the license to practice medicine confers no additional skill upon the practitioner; nor does it confer immunity from physical injury upon a patient if the practitioner fails to exercise care. Here, injury may have been caused by lack of skill or care; it would not have been obviated if the defendant had possessed a license yet failed to exercise the skill and care required of one practicing medicine. True, if the defendant had not practiced medicine in this State, he could not have injured the plaintiff, but the protection which the statute was intended to provide was against risk of injury by the unskilled or careless practitioner, and unless the plaintiff's injury was caused by carelessness or lack of skill, the defendant's failure to obtain a license was not connected with the injury. The plaintiff's cause of action is for negligence or malpractice. The defendant undertook to treat the plaintiff for a physical condition which seemed to require remedy. Under our law such treatment may be given only by a duly qualified practitioner who has obtained a license. […]

No case has been cited where neglect of a statutory duty has given rise to private cause of action where it has not appeared that private injury has been caused by danger against which the statute was intended to afford protection, and which obedience to the statute would have obviated. […]

It is said that the trial justice did not charge that plaintiff might recover for defendant's failure to obtain a license but only that failure to obtain a license might be considered "some evidence" of defendant's negligence. Argument is made that even if neglect of the statutory duty does not itself create liability, it tends to prove that injury was caused by lack of skill or care. That can be true only if logical inference may be drawn from defendant's failure to obtain or perhaps seek a license that he not only lacks the skill and learning which would enable him to diagnose and treat disease generally, but also that he lacks even the skill and learning necessary for the physical manipulation he gave to this plaintiff. Evidence of defendant's training, learning and skill and the method he used in giving the treatment was produced at the trial and upon such evidence the jury could base finding either of care or negligence, but the absence of a license does not seem to strengthen inference that might be drawn from such evidence, and a fortiori would not alone be a basis for such inference. Breach or neglect of duty imposed by statute or ordinance may be evidence of negligence only if there is logical connection between the proven neglect of statutory duty and the alleged negligence.

Crane, J. (dissenting) […] What is the rule which is to guide us in determining whether a violation of a statute or ordinance is evidence of negligence? It is no answer to say that the statute provides a penalty, and, therefore, no other consequences can follow. Such is not the law. We are to determine it, as I read the authorities, from the purpose and object of the law, and also from the fact whether a violation of the law may be the direct and proximate cause of an injury to an individual. […]

The prohibition against practicing medicine without a license was for the very purpose of protecting the public from just what happened in this case. The violation of this statute has been the direct and proximate cause of the injury. The courts will not determine in face of this statute whether a faith healer, a patent medicine man, a chiropractor, or any other class of practitioner acted according to the standards of his own school, or according to the standards of a duly licensed physician. The law, to insure against ignorance and carelessness, has laid down a rule to be followed, namely, examinations to test qualifications, and a license to practice. If a man, in violation of this statute, takes his chances in trying to cure disease, and his acts result directly in injury, he should not complain if the law, in a suit for damages, says that his violation of the statute is some evidence of his incapacity.

1.5. SAP de Almería, Secc. 2ª, Penal, 286/2000, de 3 de julio

ANTECEDENTES DE HECHO

[…] Hechos probados

«El acusado Antonio N. G, mayor de edad y sin antecedentes penales con título de Licenciado en Medicina y Cirugía, habilitado mediante el oportuno certificado del Ministerio de Sanidad y Consumo para despeñar las funciones de Médico de Medicina General en el Sistema nacional de Sanidad Español, así como en los sistemas Públicos de Seguridad Social de los demás Estados miembros de la Unión Europea, desde fechas no concretadas es el titular de la Clínica "Nueva Andalucía", sita en la calle Blas Infante, ..., de Almería que se anunciaba públicamente al menos hasta 1998 en las páginas amarillas de la guía telefónica dentro del apartado "Médicos: Cirugía Plástica y Reparadora" como clínica de estética pero donde se practican Cirugía Plástica, Liposucciones y Microcirugía, y en la que efectivamente el acusado ha venido realizando ese tipo de intervenciones de cirugía plástica y liposucciones sin estar en posesión del título correspondiente de cirugía Plástica que le habilite para ello, junto a otro tipo de intervenciones quirúrgicas, y sin adoptar las mínimas precauciones exigidas por la "lex artis" de la Medicina.

Así, en fechas próximas a los meses de marzo y abril de 1994 el acusado atendió en dicha Clínica que regenta a doña Carmen Bernardina G. H. y a doña Isabel A. T., que acudieron a su consulta para tratar sus problemas de obesidad, aconsejando el acusado a cada una en su caso que deberían someterse a una intervención de liposucción y, previamente a ello, a un tratamiento que ambas pacientes aceptaron, consistente en una formulación magistral que al principio encargaba al Farmacéutico de Málaga, don Juan M. S., quien la preparaba y encapsulaba y enviaba con su etiqueta, por indicación del acusado, a ambas pacientes a sus respectivos domicilios y que ellas abonaban directamente al citado Farmacéutico, formulación esta que con posterioridad el acusado –pese a no estar en posesión del título de Licenciado en Farmacia– decidió prepararlas y encapsularlas en su clínica, y facilitarlas así a ambas pacientes, alterando la composición de los medicamentos, añadiendo otras sustancias que no figuraban en la etiqueta […].

Posteriormente, en fechas 29 de marzo y 11 de mayo de 1994, fueron sometidas por el acusado a sendas intervenciones, previo pago por parte de cada una de ellas de 200.000 pesetas, quienes decidieron someterse a las mismas voluntariamente, concretamente de liposucción de cadera y rodillas en el caso de doña Carmen, y de caderas, parte interna de los muslos y rodillas en el caso de doña Isabel, sin observar dicho individuo las más mínimas reglas de la práctica de la Medicina, realizando análisis de sangre incontrolados en los resultados, sin disponer del apoyo de profesionales especializados para evitar complicaciones, que eran perfectamente posibles e, incluso, aparecieron, aplicando en ambas mujeres con diversas anomalías estéticas y funcionales en las zonas intervenidas consecuencia del empleo por parte del acusado de una técnica quirúrgica y terapéutica inadecuada, lo que ha producido: En el caso de doña Carmen: secuelas: a nivel de la región femoral anterior y externa una zona de induración producida por el tacto de la fascia lata (incluso con reacción de fibrosis), con desaparición de todo el panículo adiposo a este nivel; dolor a este nivel; falta de fuerza muscular; limitación de la flexión en ambas rodillas de 120º (siendo la anormal de 135º); defecto estético a nivel de región glútea por aspiración insuficiente, no equilibrada, de exceso adiposo y cutáneo a nivel lateral de ambas rodillas y sobrecorrección zona medial, y de asimetría de las regiones femorales anteriores por sobrecorrección mayor nivel de miembro derecho; todo ello con 130 días de incapacidad, de los cuales 30 estuvo impedida para sus ocupaciones habituales. Durante la intervención sufrió un espasmo de glotis, que precisó de sutura.

En el caso de doña Isabel: Secuelas consistentes en zona de induración a nivel de cara posterior de ambas piernas, más acentuada y palpable al tacto en movimientos de fuerza o de extensión completa; este defecto se debe a una sobre corrección durante la liposucción, desapareciendo todo el panículo adiposo y habiendo originado incluso un proceso de fibrosis de la fascia muscular de la masa muscular gemelar; también, abultamientos y depresiones en piel a nivel de regiones femorales producidos por acúmulos de grasa (seromas), originados por una resección irregular; defecto a nivel cara interna de muslo derecho por resección excesiva; defecto a nivel

de ambas rodillas, visible en extensión y flexión, producido por una resección excesiva; cicatriz de rasgos leves en cara posterior de pierna derecha de 3 x 2 cm; defecto estético de la silueta, ya que al tratar la región femoral y no la cresta ilíacas (están por encima), se acentúa la silueta con deformidad en violín; todo ello tardando 131 días en curar, de los que estuvo 30 incapacitada para sus ocupaciones habituales. Tras la intervención, la paciente desarrolla un cuadro de alergia al esparadrapo utilizado, pese a que constaba en la historia su alergia a una clase determinada.

Ambas mujeres necesitaron para la curación, además de la primera asistencia facultativa, tratamiento médico, pero, además, para quedar totalmente restablecidas precisarán además de tratamiento quirúrgico mediante cirugía plástica y reparadora, con un coste estimado para cada intervención de 1.800.000 pesetas».

TERCERO

[La Sentencia del Juzgado Penal] contiene el siguiente fallo: «Que debo condenar y condeno a Antonio N. G., como autor de dos delitos de imprudencia temeraria genérica de los arts. 565,1º y 4º con relación al art. 420-1º CP 1973, a la pena, por cada uno de ellos, de seis meses de arresto mayor, con la accesoria de suspensión del ejercicio de la profesión de Médico durante el tiempo de duración de las respectivas condenas. También, como autor de un delito de intrusismo profesional del art. 403, párrafo primero, inciso segundo, con relación al subtipo agravado del párrafo segundo del CP 1995 (carencia de título oficial referente a la especialidad médica de Cirugía Plástica y Reparadora, con ostentación pública de ello), a la pena de un año de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de médico durante el tiempo de la condena. Igualmente, como autor de otro delito de intrusismo profesional de párrafo primero, inciso primero, del art. 403 CP (falta de título académico de farmacéutico) a la pena de multa de nueve meses, con cuota diaria de 2.000 pesetas, lo que hace un total de 540.000 pesetas, que se pagarán en dos plazos como máximo, y caso de impago de la misma, previa excusión de bienes, a un arresto sustitutorio equivalente a un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas. […].

En cuanto a responsabilidad civil indemnizará:

A doña Carmen Bernardina G. H. en 150.000 pesetas por los 30 días de incapacidad sufridos; por los 130 días de curación 390.000 pesetas; por la intervención quirúrgica que tiene pendiente, la cantidad de 1.800.000 pesetas; por secuela, alzadamente 7.000.000 de pesetas.

A doña Isabel A. T. en 150.000 pesetas por los 30 días de incapacidad sufridos; en 393.000 pesetas por los 131 días de curación; en 1.800.000 pesetas por la intervención quirúrgica de la que pende; en 7.000.000 de pesetas por las secuelas […]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

[…E]s doctrina extensa y pormenorizada respecto de la imprudencia médica la que recuerda:

> a) Que el error de diagnóstico, por regla general no es tipificable, salvo que por su entidad y dimensiones constituya una equivocación inexcusable.
> b) Que queda fuera del ámbito penal, por la misma razón, la falta de pericia cuando ésta sea de naturaleza extraordinaria y excepcional.
> c) Que la determinación de la responsabilidad médica debe hacerse en contemplación de las circunstancias concretas del caso sometido a enjuiciamiento.
> d) Que la imprudencia nace cuando el tratamiento médico y quirúrgico incide en comportamientos descuidados, de abandono y omisión de los cuidados exigibles, atendidas las circunstancias del lugar, tiempo, personas y naturaleza de la lesión o enfermedad que olvidando la "lex artis" conduzca a resultados lesivos».

Aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa resulta que […] existen una serie de datos probatorios que acreditan un proceder negligente en la conducta del facultativo porque el mismo carecía de la titulación suficiente para que llevara a cabo este tipo de operaciones, que por su envergadura y complejidad no debe ser realizado con la titulación de médico de medicina general, ya que la otra titulación aportada consistente en un documento expedido por la denominada Sociedad Española de Medicina Estética, se desconoce en qué consiste el mismo ni la naturaleza de la entidad que lo expide ya que no tiene el carácter de un organismo oficial. […].

Por otra parte no podemos ignorar las circunstancias previas a la operación de las perjudicadas en donde la analítica no resulta debidamente contrastada. […] Por consiguiente no hay constancia de que se hubiese llevado a cabo un preoperatorio adecuado.

Además las operaciones se efectuaron en un quirófano preparado para cirugía menor utilizando anestesia local a pesar de la larga duración de dichas operaciones […].

Finalmente debe tenerse en cuenta el resultado alcanzado consistente en lesiones graves y deformidades en los miembros inferiores de las denunciantes que necesitan de una operación de cirugía plástica para reparar las mismas […].

Con tales presupuestos fácticos no podemos sino considerar […] que el resultado producido ha sido por una culpa o negligencia inexcusable, por pretenderse efectuar unas operaciones de gran complejidad con escasos medios y utilizando técnicas de cirugía menor, sin tener la titulación adecuada para desarrollar dicha actividad, ni siquiera la experiencia que hubiese suplido dicha falta de titulación como lo acredita el resultado producido. […]

Se alega también por la parte recurrente una errónea valoración de la prueba. […] Se fundamenta este recurso en el hecho de que para realizar este tipo de operaciones de liposucción no es necesario tener una titulación específica bastando tener la titulación de médico de medicina general para poder atender problemas como el que motivó la intervención quirúrgica, es decir una obesidad de las denunciantes que fue tratada inicialmente con pastillas hasta que se vio conveniente la necesidad de efectuar la liposucción. En apoyo de su tesis se citan las sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 23 marzo (RJ 1995\2699) y 16 junio de 1995 (RJ 1995\4917), entre otras, que precisan que la profesión de médico es una y sólo una siendo las especialidades variaciones de una única profesión... «en general cualquier médico sea o no especialista puede atender cualquier enfermedad a cualquier enfermo, incluso sobre aspectos de especialidad ajena, ya que el título de médico especialista sólo es necesario para ejercer la profesión con este carácter, es decir, no para ejercer la profesión, sino para ejercerla como especialista» […].

Con independencia de que la argumentación de la sentencia que se invoca debe ser aceptada por este Tribunal, en cuanto que supone una formulación genérica de la obligación y derecho de todo médico de prestar asistencia sanitaria de un modo general para atender cualquier tipo de enfermedad sin necesidad de ser especialista, sin embargo ello no supone que se pueda dar licencia o autorización para que cualquier médico ejercite la medicina desarrollando actividades propias de las especialidades médicas que como tales vienen definidas en el artículo 1 del Real Decreto 127/1984 de 11 de enero por el que se regula la formación médica especializada y la obtención del título de médico especialista. El límite entre la especialidad y la medicina general vendrá determinado en cada caso por las circunstancias concurrentes puesto que frecuentemente desde un médico generalista se llega al médico especialista a través del consejo y dirección de este último, sin perjuicio de que pueda tratarse y curar determinadas dolencias de escasa importancia, o de mayor en caso de urgencia médica, según las circunstancias, siendo el propio médico el que mejor puede trazar esa línea divisoria entre la especialización y la medicina general ya que ha estudiado las distintas asignaturas y ramas de la medicina sobre las que posteriormente se configuran las especialidades médicas. Es precisamente en esta línea divisoria en donde en cada caso concreto habrá que examinar en qué medida el médico que no tiene la especialización, equivalente a título oficial a efectos penales, ha podido incurrir en un delito de intrusismo por carecer de la titulación oficial necesaria sin perjuicio de que tenga la titulación de médico de medicina general.

[…] Este tipo de intervenciones quirúrgicas son propias de la cirugía plástica y reparadora, siendo ésta una especialidad médica para la que se requiere cinco años de preparación tras haber aprobado el correspondiente examen selectivo, lo que unido a los seis años de duración normal de la carrera de medicina determinan una preparación altamente cualificada para llevar a cabo intervenciones encuadrables en este tipo de especialidad […].

FALLAMOS

Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Antonio N. G. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Almería, de fecha 24-2-2000 debemos confirmar y confirmamos el fallo de dicha resolución, con declaración de oficio de las costas procesales de esta alzada.

1.6. *Uhr v. East Greenbush Cent. Sch. Dist.* (720 N.E.2d 886 (N.Y. 1999))

ROSENBLATT, J. Education Law § 905(1) requires school authorities in the State of New York to examine students between eight and sixteen years of age for scoliosis at least once in each schoolyear. The principal issue on this appeal is whether the statute authorizes a private right of action.

During the 1992–1993 school year, the infant plaintiff was a seventh grade student at the Goff Middle School, operated by defendant East Greenbush Central School District. In October 1992, as part of a school program, a nurse screened her for scoliosis. The results were negative. She was examined during the following school year (1993–1994) by a school nurse who checked her height, weight and vision but allegedly did not screen her for scoliosis.

In March 1995, when the infant plaintiff was a ninth grader during the 1994–1995 school year at Columbia High School (also operated by the East Greenbush Central School District), a school nurse screened her for scoliosis and the examination proved positive. Her parents, who are also plaintiffs in this action, then had her examined by an orthopedic doctor who concluded that her scoliosis had progressed to the point that surgery was required instead of the braces that often can be utilized when the condition is diagnosed earlier. The infant plaintiff underwent surgery in July 1995.

Plaintiffs have alleged two causes of action against the East Greenbush Central School District and its Board of Education (collectively "the District"). One is based on a claimed violation of Education Law § 905(1), one on common law negligence. Plaintiffs assert, in essence, that the District was negligent in failing to examine the infant plaintiff for scoliosis during the 1993–1994 school year, as a result of which her ailment was allowed to progress undetected, to her detriment. Supreme Court granted the District's motion for summary judgment, holding that Education Law § 905(1) does not create a private right of action, and that plaintiffs had otherwise failed to state a claim for common law negligence. The Appellate Division affirmed. We granted leave to appeal to this Court and now affirm.

THE RELEVANT STATUTES

[…] Education Law § 905(1) states that "[m]edical inspectors or principals and teachers in charge of schools in this state shall . . . examine all . . . pupils between eight and sixteen years of age for scoliosis, at least once in each school year." Education Law § 905(2) provides that "[n]othwithstanding any other provisions of any general, special or local law, the school authorities charged with the duty of making such tests or examinations of pupils for the presence of scoliosis pursuant to this section shall not suffer any liability to any person as a result of making such test or examination, which liability would not have existed by any provision of law, statutory or otherwise, in the absence of this section." Finally, Education Law § 911 charges the Commissioner of Education with the duty of enforcing the provisions of sections 901 through 910 of the Education Law and authorizes the Commissioner to "adopt rules and regulations" for such purpose.

THE TEST FOR THE AVAILABILITY OF A PRIVATE RIGHT OF ACTION

The District's obligation to examine for scoliosis is, as plaintiffs point out, plain enough. A statutory command, however, does not necessarily carry with it a right of private enforcement by means of tort litigation.

The availability of a private right of action for the violation of a statutory duty –– as opposed to one grounded in common law negligence –– is not a new concept. When a statute itself expressly authorizes a private right of action, there is no need for further analysis. When a statute is silent, as it is here, courts have had to determine whether a private right of action may be fairly implied. […] In making the determination, we ask:

"(1) whether the plaintiff is one of the class for whose particular benefit the statute was enacted;
"(2) whether recognition of a private right of action would promote the legislative purpose; and
"(3) whether creation of such a right would be consistent with the legislative scheme".

[After concluding that the plaintiffs satisfied the first two parts, the court discussed the last requirement]. Plaintiffs argue that a private right of action is not only consistent with Education Law § 905(1) but also necessary for its operation. They assert that the statute offers no other practical means of enforcement and that a private right of action is imperative, in order to give it life. We disagree and conclude that a private right of action would not be consistent with the statutory scheme. To begin with, the statute carries its own potent official enforcement mechanism. The Legislature has expressly charged the Commissioner of Education with the duty to implement Education Law § 905(1) and has equipped the Commissioner with authority to adopt rules and regulations for such purpose (see, Education Law §§ 905[1], 911). Moreover, the Legislature has vested the Commissioner with power to withhold public funding from noncompliant school districts. Thus, the Legislature clearly contemplated administrative enforcement of this statute. The question then becomes whether, in addition to administrative enforcement, an implied private right of action would be consistent with the legislative scheme.

It would not. The evolution of Education Law § 905(2) is compelling evidence of the Legislature's intent to immunize the school districts from any liability that might arise out of the scoliosis screening program. By the language of Education Law § 905(2) the Legislature deemed that the school district "shall not suffer any liability to any person as a result of making such examination" (emphasis added). Plaintiffs contend that by implication, the District is denied immunity for failing to perform the examination. In effect, plaintiffs would interpret the statute as conferring immunity for misfeasance but not nonfeasance. On the other hand, the District contends that it would be incongruous for the Legislature to accord immunity for one circumstance but not the other.

Plaintiffs' reading of the statute might have some appeal if we did not have persuasive evidence as to the Legislature's intent to immunize the school districts for both nonfeasance and misfeasance. […] Revealingly, the Legislature evidently saw no need to amend Education Law § 905 in any other way, although obviously aware of the two Appellate Division decisions on that point. Its failure to otherwise amend the statute is strong evidence of the Legislature's conclusion that the Appellate Divisions had correctly interpreted the statute's immunity provision.

There is also the matter of cost to the school districts, as evidenced by the Legislature's expressed sensitivity in that regard. Orthopedists through the New York State Society of Orthopaedic Surgeons and other professionals from the Scoliosis Association, Inc. agreed to volunteer their time and expertise to train existing school personnel on the relatively simple examination procedure. In forecasting its cost, the Legislature anticipated that the program would have minimal financial impact on school districts (Budget Report on Bills, Bill Jacket, L 1978, ch 202). Allowing a private right of action against the government as opposed to a private entity has direct and obvious financial consequences to the public.

Given the Legislature's concern over the possible costs to the school districts –– as evidenced by the statutory immunity provision and the other legislative statements reflecting those concerns –– we conclude that the Legislature did not intend that the districts bear the potential liability for a program that benefits a far wider population. If we are to imply such a right, we must have clear evidence of the Legislature's willingness to expose the governmental entity to liability that it might not otherwise incur. The case before us reveals no such legislative intent.

In sum, we conclude that a private right of action to enforce Education Law § 905(1) is inconsistent with the statute's legislative scheme and therefore cannot be fairly implied.

COMMON LAW NEGLIGENCE

[The Court then held that the plaintiffs did no state a cause of action for common law negligence]

Affirmed.

La Sala Primera del Tribunal Supremo acoge la figura de la negligencia per se, aunque, normalmente, de acuerdo con la doctrina del fin de protección de la norma, un criterio de imputación objetiva. Sin embargo, el Tribunal, incluso en sentencias recientes, se aferra a la noción según la cual el cumplimiento de la normativa no excusa de la negligencia imputada al demandado si hubo daño, pues la producción del daño implica culpa en cuanto señaliza que el demandado no adoptó precauciones suficientes o las necesarias para evitar la producción del daño: las necesarias y exigibles, pero no todas, habría que matizar: las precauciones necesarias para evitar la producción del daño pueden ser infinitas.

1.7. STS, 1ª, 223/2013, de 12 de abril

Muerte accidental de una persona al electrocutarse con un cable de alta tensión situado a 4,80 metros del suelo –una altura inferior a la mínima establecida en el art. 25.1 Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión–, mientras limpiaba la piscina de su parcela con un barredor de fondos cuyo mástil produjo un arco voltaico con el cable de alta tensión que pasaba por encima de la parcela.

Padres de la víctima c. Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. y a Comunidad de Parcelistas "El Corzo", demandada como propietaria del tendido eléctrico. JPI: estima en parte la demanda y condena a ambos demandados a pagar 91.030,35 euros, según baremos. AP: estima el recurso de apelación de la comunidad de propietarios, a quien absuelve y desestima el de Endesa y el de los demandantes. TS: desestima el recurso de casación de Endesa y el de los demandantes y confirma la SAP: "Cuando lo que se enjuicia es la responsabilidad por una muerte por electrocución a causa del incumplimiento de la distancia de seguridad entre el tendido eléctrico aéreo y el suelo, lo relevante no es la propiedad del tendido eléctrico sino el control de sus condiciones de seguridad" (FD. 2º).

1.8. STS, 1ª, 909/2005, de 9 de noviembre

El 20.8.1992, la U.T.E, formada por "Obras Subterráneas, S.A." y "Auxini, S.A.", encargó al mecánico Miguel Ángel la sustitución de una pieza del sistema de freno de una retroexcavadora en el exterior de una mina situada en Balsareny (Barcelona). Para ello, el conductor de la retroexcavadora hincó una palanca en el suelo a fin de que la presión ejercida por ésta levantara la rueda trasera y, cuando Miguel Ángel se disponía a colocar debajo un taco de madera, uno de los pistones del mecanismo de la palanca cedió provocando la caída brusca de la parte trasera de la máquina que le aprisionó y le causó la muerte.

Luisa, viuda de Miguel Ángel, en nombre propio y en el de su hijo menor Francisco, demandó a "Obras Subterráneas, S.A." y a "Auxini, S.A." y solicitó una indemnización de 120.202,42 €.

El JPI nº 5 de Manresa (23.5.1997) desestimó la demanda. La AP de Barcelona (Sección 16ª, 9.12.1998) estimó el recurso de apelación y condenó a las sociedades demandadas a pagar 120.202,42 €.

El TS desestima el recurso de casación: resuelve que el encargado y el capataz de las sociedades demandadas omitieron negligentemente medidas de precaución, pues consintieron que, como ya había ocurrido en otras ocasiones, se acometiera la reparación de forma arriesgada cuando el resultado finalmente producido era previsible. Señala el Tribunal en el Fundamento 2º de la Sentencia:

"No basta para excluir dicha declaración de culpabilidad la inexistencia de infracción reglamentaria sostenida por las recurrentes en base a ciertos informes incorporados a los autos, ya que, dada la naturaleza de la operación que se estaba realizando, es claro que la misma no era objeto de regulación de tal clase. Además, ha de citarse en este sentido la doctrina de esta Sala expresada, entre otras, en sentencias de 22 de abril de 2003 (RJ 2003, 3545) , 18 de junio (RJ 2004, 4431) y 8 de octubre de 2004 (RJ 2004, 6693), según la cual la imputación subjetiva del acto lesivo, con un fundamento de reproche culpabilístico, se basa en que la producción del daño indica que no se han tomado las precauciones o no se ha actuado con el cuidado necesario para impedirlo, revelando que las garantías adoptadas conforme a las disposiciones vigentes para evitar los daños posibles no han ofrecido resultado positivo, poniéndose de manifiesto la insuficiencia de las mismas y que no se hallaba completa la diligencia, y así precisa la última de las sentencias citadas que «no resulta suficiente la que podría denominarse diligencia reglamentaria, si la realidad fáctica evidencia que las medidas adoptadas para evitar los daños previsibles han resultado ineficaces, pues la diligencia que ha de adoptarse en el cumplimiento de las obligaciones comprende no solo las prevenciones y cuidados reglamentarios sino además todos los que la prudencia imponga para evitar los eventos dañosos".

1.9. STS, 1ª, 17/2004, de 3 de febrero

Un joven de 27 años falleció por inhalación de monóxido de carbono desprendido por un calentador de agua a gas que se hallaba en la cocina del piso que compartía con Daniel.

Los padres del fallecido, Leonardo y Rosa, demandan a "Repsol Butano, SA", a Daniel, y a los propietarios del piso, Luis Pedro y Eva, y solicitan una indemnización de 120.202,42 €.

El JPI nº 3 de León (2.5.1997) estima la demanda en parte: absuelve a Daniel y condena a "Repsol Butano, SA" por deficiencias en la instalación y en el funcionamiento del calentador y a Luis Pedro y Eva por carecer la cocina de rejillas de ventilación al pago de una indemnización de 49.619,56 €, por cuotas del 50 % la primera y 50 % los segundos. La AP de León (Sección 2ª, 27.1.1998) estima el recurso de apelación de "Repsol Butano, SA", revoca la SJPI y condena sólo a Luis Pedro y Eva a abonar a los actores una indemnización de 36.060,73 €.

El TS declara no haber lugar al recurso de casación de los actores. El TS resuelve que la casación no es una tercera instancia en la que pueda modificarse el relato de los hechos probados: "Repsol Butano, SA" sólo era suministradora de las bombonas de butano utilizadas en el calentador y, además, no las entregaba siquiera en el domicilio citado. Señala el Tribunal Supremo:

> "FJ 4º: No se cita [en el motivo de casación sobre posible culpa exclusiva de la víctima] norma ni jurisprudencia alguna como infringida, sin que a tal efecto pueda valer la de un artículo del Decreto de 11 de septiembre de 1992 sobre obligaciones del usuario de una instalación de gas, pues bien sabido es que según reiteradísima jurisprudencia de esta Sala las normas administrativas o reglamentarias carecen de idoneidad para sustentar por sí solas un motivo de casación civil".

1.10. *Preemption*

Como indicábamos al inicio de la Sesión, una de las cuestiones básicas del moderno derecho de daños es si las previsiones del legislador sobre la regulación de tal o cual actividad cierran o no el sistema de remedios al ejercicio de una pretensión civil de reparación o indemnización del daño causado. Así por ejemplo, cabe preguntar:

¿En el caso de que una conducta dañina esté prevista por una legislación específica que establezca las consecuencias de su realización, se aplica además el art. 1902 CC? ¿Si es así, se aplica cumulativamente?, ¿lo hace subsidiariamente?, ¿lo hace solo en la medida en que el daño no haya quedado íntegramente reparado con la aplicación de la ley infringida?

¿Tiene un trabajador accidentado una pretensión civil adicional a aquella o a aquellas que le reconoce el derecho laboral y de la seguridad social?

¿Tiene un cónyuge, excónyuge o persona integrante de una relación de pareja análoga a la matrimonial acciones de daños además de las pretensiones previstas por la legislación matrimonial para el caso de las crisis de pareja?

¿Responde el Estado legislador por la aprobación de una ley cuya aplicación daña al demandante?

Fernando Gómez Pomar, "Responsabilidad extracontractual y otras fuentes de reparación de daños: Collateral Source Rule y afines", InDret 1/1999 (www.indret.com).

- Responsabilidad civil y sistemas de compensación sin culpa

***Bruesewitz v. Wyeth,* 562 U. S. ___ (2011)**

(Slip Opinion) OCTOBER TERM, 2010

Syllabus

BRUESEWITZ ET AL. *v.* WYETH LLC, FKA WYETH, INC., ET AL. CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE THIRD CIRCUIT

No. 09–152. Argued October 12, 2010—Decided February 22, 2011

The National Childhood Vaccine Injury Act of 1986 (NCVIA or Act) created a no-fault compensation program to stabilize a vaccine market adversely affected by an increase in vaccine-related tort litigation and to facilitate compensation to claimants who found pursuing legitimate vaccine-inflicted injuries too costly and difficult. The Act provides that a party alleging a vaccine-related injury may file a petition for compensation in the Court of Federal Claims, naming the Health and Human Services Secretary as the respondent; that the court must resolve the case by a specified deadline; and that the claimant can then decide whether to accept the court's judgment or reject it and seek tort relief from the vaccine manufacturer. Awards are paid out of a fund created by an excise tax on each vaccine dose. As a *quid pro quo,* manufacturers enjoy significant tort-liability protections. Most importantly, the Act eliminates manufacturer liability for a vaccine's unavoidable, adverse side effects.

Hannah Bruesewitz's parents filed a vaccine-injury petition in the Court of Federal Claims, claiming that Hannah became disabled after receiving a diphtheria, tetanus, and pertussis (DTP)

vaccine manufactured by Lederle Laboratories (now owned by respondent Wyeth). After that court denied their claim, they elected to reject the unfavorable judgment and filed suit in Pennsylvania state court, alleging, *inter alia,* that the defective design of Lederle's DTP vaccine caused Hannah's disabilities, and that Lederle was subject to strict liability and liability for negligent design under Pennsylvania common law. Wyeth removed the suit to the Federal District Court. It granted Wyeth summary judgment, holding that the relevant Pennsylvania law was preempted by 42 U. S. C. §300aa–22(b)(1), which provides that "[n]o vaccine manufacturer shall be liable in a civil action for damages arising from a vaccine-related injury or death associated with the administration of a vaccine after October 1, 1988, if the injury or death resulted from side-effects that were unavoidable even though the vaccine was properly prepared and was accompanied by proper directions and warnings." The Third Circuit affirmed.

Held: The NCVIA preempts all design-defect claims against vaccine manufacturers brought by plaintiffs seeking compensation for injury or death caused by a vaccine's side effects. Pp. 7–19.

(a) Section 300aa–22(b)(1)'s text suggests that a vaccine's design is not open to question in a tort action. If a manufacturer could be held liable for failure to use a different design, the "even though" clause would do no work. A vaccine side effect could alway*s* have been avoidable by use of a different vaccine not containing the harmful element. The language of the provision thus suggests the design is not subject to question in a tort action. What the statute establishes as a complete defense must be unavoidability (given safe manufacture and warning) with respect to the particular design. This conclusion is supported by the fact that, although products-liability law establishes three grounds for liability—defective manufacture, inadequate directions or warnings, and defective design—the Act mentions only manufacture and warnings. It thus seems that the Act's failure to mention design-defect liability is "by deliberate choice, not inadvertence." *Barnhart* v. *Peabody Coal Co.*, 537 U. S. 149, 168. Pp. 7–8.

(b) Contrary to petitioners' argument, there is no reason to believe that §300aa–22(b)(1)'s term "unavoidable" is a term of art incorporating Restatement (Second) of Torts §402A, Comment *k,* which exempts from strict liability rules "unavoidably unsafe products." "Unavoidable" is hardly a rarely used word, and cases interpreting comment *k* attach special significance only to the term "unavoidably unsafe products," not the word "unavoidable" standing alone. Moreover, reading the phrase "side effects that were unavoidable" to exempt injuries caused by flawed design would require treating "even though" as a coordinating conjunction linking independent ideas when it is a concessive, subordinating conjunction conveying that one clause weakens or qualifies the other. The canon against superfluity does not undermine this Court's interpretation because petitioners' competing interpretation has superfluity problems of its own. Pp. 8–12.

(c) The structure of the NCVIA and of vaccine regulation in general reinforces what §300aa–22(b)(1)'s text suggests. Design defects do not merit a single mention in the Act or in Food and Drug Administration regulations that pervasively regulate the drug manufacturing process. This lack of guidance for design defects, combined with the extensive guidance for the two liability grounds specifically mentioned in the Act, strongly suggests that design defects were not mentioned because they are not a basis for liability. The Act's mandates lead to the same conclusion. It provides for federal agency improvement of vaccine design and for federally prescribed compensation, which are other means for achieving the two beneficial effects of design-defect torts—prompting the development of improved designs, and providing compensation for inflicted injuries. The Act's structural quid pro quo also leads to the same conclusion. The vaccine manufacturers fund an informal, efficient compensation program for

vaccine injuries in exchange for avoiding costly tort litigation and the occasional disproportionate jury verdict. Taxing their product to fund the compensation program, while leaving their liability for design defect virtually unaltered, would hardly coax them back into the market. Pp. 13–16.

561 F. 3d 233, affirmed.

Scalia, J., delivered the opinion of the Court, in which Roberts, C. J., and Kennedy, Thomas, Breyer, and Alito, JJ., joined. Breyer, J., filed a concurring opinion. Sotomayor, J., filed a dissenting opinion, in which Ginsburg, J., joined. Kagan, J., took no part in the consideration or decision of the case.

- Responsabilidad civil y sistema de regulación de la seguridad de producto

Pliva, Inc., et. al. v. Mensing, 564 U. S. ___ (2011)

(Slip Opinion) OCTOBER TERM, 2010

Syllabus

PLIVA, INC., ET AL. *v.* MENSING

CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE EIGHT CIRCUIT

No. 09–993. Argued March 30, 2011—Decided June 23, 2011[2]

Five years after the Food and Drug Administration (FDA) first approved metoclopramide, a drug commonly used to treat digestive tract problems, under the brand name Reglan, generic manufacturers such as petitioners also began producing the drug. Because of accumulating evidence that long-term metoclopramide use can cause tardive dyskinesia, a severe neurological disorder (a movement disorder which consists in adverse effects including diminished voluntary movements and the presence of involuntary movments similar to tic or chorea, tremor discoordination ---Wikipedia: definition to be improved), warning labels for the drug have been strengthened and clarified several times, most recently in 2009.

Respondents were prescribed Reglan in 2001 and 2002, but both received the generic drug from their pharmacists. After taking the drug as prescribed for several years, both developed tardive dyskinesia. In separate state-court tort actions, they sued petitioners, the generic drug manufacturers that produced the metoclopramide they took (Manufacturers). Each respondent alleged, *inter alia,* that longterm metoclopramide use caused her disorder and that the Manufacturers were liable under state tort law for failing to provide adequate warning labels. In both suits, the Manufacturers urged that federal statutes and FDA regulations pre-empted the state tort claims by requiring the same safety and efficacy labeling for generic metoclopramide

[2] Together with No. 09-1039, *Actavis Elisabeth, LLC v. Mensing*, also on certiorari to the same court, and No. 09-1501, Actavis, Inc. v. Demahy, on certiorari to the United States Court of Appeals for the Fifth Circuit.

as was mandated at the time for Reglan. The Fifth and EighthCircuits rejected these arguments, holding that respondents' claims were not pre-empted.

Held: The judgment is reversed, and the cases are remanded.

588 F. 3d 603 and 593 F. 3d 428, reversed and remanded.

JUSTICE THOMAS delivered the opinion of the Court with respect to all but Part III–B–2, concluding that federal drug regulations applicable to generic drug manufacturers directly conflict with, and thus pre-empt, these state claims. Pp. 4–14, 17–20.

(a) Because pre-emption analysis requires a comparison between federal and state law, the Court begins by identifying the state tort duties and federal labeling requirements applicable to the Manufacturers. Pp. 4–10.

(1) State tort law requires a manufacturer that is, or should be, aware of its drug's danger to label it in a way that renders it reasonably safe. Respondents pleaded that the Manufacturers knew, or should have known, both that the long-term use of their products carried a high risk of tardive dyskinesia and that their labels did not adequately warn of that risk. Taking these allegations as true, the state-law duty required the Manufacturers to use a different, stronger label than the one they actually used. Pp. 4–5.

(2) On the other hand, federal drug regulations, as interpreted by the FDA, prevented the Manufacturers from independently changing their generic drugs' safety labels. A manufacturer seeking federal approval to market a new drug must prove that it is safe and effective and that the proposed label is accurate and adequate. Although the same rules originally applied to all drugs, **the 1984 law commonly called the Hatch-Waxman Amendments allows a generic drug manufacturer to gain FDA approval simply by showing that its drug is equivalent to an already-approved brand-name drug, and that the safety and efficacy labeling proposed for its drug is the same as that approved for the brand-name drug**. Respondents contend that federal law nevertheless provides avenues through which the Manufacturers could have altered their metoclopramide labels in time to prevent the injuries here. These include: (1) the FDA's "changes-being- effected" (CBE) process, which permits drug manufacturers, without preapproval, to add or strengthen a warning label; and (2) sending "Dear Doctor" letters providing additional warnings to prescribing physicians and other healthcare professionals. However, the FDA denies that the Manufacturers could have used either of these processes to unilaterally strengthen their warning labels. The Court defers to the FDA's views because they are not plainly erroneous or inconsistent with the regulations, and there is no other reason to doubt that they reflect the FDA's fair and considered judgment. Auer v. Robbins, 519 U. S. 452, 461, 462. Assuming, without deciding, that the FDA is correct that federal law nevertheless required the Manufacturers to ask for the agency's assistance in convincing the brand- name manufacturer to adopt a stronger label, the Court turns to the pre-emption question. Pp. 5–10.

(b) Where state and federal law directly conflict, state law must give way. See, e.g., Wyeth v. Levine, 555 U. S. 555, 583. Such a conflict exists where it is "impossible for a private party to comply with both state and federal requirements." Freightliner Corp. v. Myrick, 514 U. S. 280, 287. Pp. 11–14, 17–20.

(1) The Court finds impossibility here. If the Manufacturers had independently changed their labels to satisfy their state-law duty to attach a safer label to their generic metoclopramide, they

would have violated the federal requirement that generic drug labels be the same as the corresponding brand-name drug labels. Thus, it was impossible for them to comply with both state and federal law. And even if they had fulfilled their federal duty to ask for FDA help in strengthening the corresponding brand-name label, assuming such a duty exists, they would not have satisfied their state tort-law duty. State law demanded a safer label; it did not require communication with the FDA about the possibility of a safer label. Pp. 11–12.

(2) The Court rejects the argument that the Manufacturers' pre-emption defense fails because they failed to ask the FDA for help in changing the corresponding brand-name label. The proper question for "impossibility" analysis is whether the private party could independently do under federal law what state law requires of it. See Wyeth, supra, at 573. Accepting respondents' argument would render conflict pre-emption largely meaningless by making most conflicts between state and federal law illusory. In these cases, it is possible that, had the Manufacturers asked the FDA for help, they might have eventually been able to strengthen their warning label. But it is also possible that they could have convinced the FDA to reinterpret its regulations in a manner that would have opened the CBE process to them, persuaded the FDA to rewrite its generic drug regulations entirely, or talked Congress into amending the Hatch-Waxman Amendments. If these conjectures sufficed to prevent federal and state law from conflicting, it is unclear when, outside of express pre- emption, the **Supremacy Clause** would have any force. That Clause— which makes federal law "the supreme Law of the Land . . . any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding," U. S. Const., Art. VI, cl. 2— cannot be read to permit an approach to pre-emption that renders conflict pre-emption all but meaningless. Here, it is enough to hold that when a party cannot satisfy its state duties without the Federal Government's special permission and assistance, which is dependent on the exercise of judgment by a federal agency, that party cannot independently satisfy those state duties for pre-emption purposes. Pp. 12–14, 17.

(3) Wyeth is not to the contrary. The Court there held that a state tort action against a brand-name drug manufacturer for failure to provide an adequate warning label was not pre-empted because it was possible for the manufacturer to comply with both state and federal law under the FDA's CBE regulation. 555 U. S., at 572–573. The federal statutes and regulations that apply to brand-name drug manufacturers differ, by Congress' design, from those applicable to generic drug manufacturers. And different federal statutes and regulations may, as here, lead to different pre-emption results. This Court will not distort the Supremacy Clause in order to create similar pre-emption across a dissimilar statutory scheme. Congress and the FDA retain authority to change the law and regulations if they so desire. Pp. 17–20.

THOMAS, J., delivered the opinion of the Court, except as to Part III– B–2. ROBERTS, C. J., and SCALIA and ALITO, JJ., joined that opinion in full, and KENNEDY, J., joined as to all but Part III–B–2. SOTOMAYOR, J., filed a dissenting opinion, in which GINSBURG, BREYER, and KAGAN, JJ., joined.

- Textos relacionados con las cuestiones planteadas:

a) Artículo 123 LGSS. Recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50%, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas

condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla.

3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.

b) Competencia de jurisdicción:

b.1) STS, 1ª, 1217/2008, de 15 de diciembre

La Sala de lo Social es la única competente para conocer de las demandas de responsabilidad civil por accidente de trabajo entre empleado y empleador.

El 27.11.1997, Juan Alberto, quien prestaba servicios para "Colafe Construcciones Extremeñas, S.A.", sufrió un accidente cuando trabajaba en la colocación de un ascensor en una obra, causado por un fallo en la sujeción del chasis en el puntal de aquél. El trabajador no llevaba el cinturón de seguridad. Como consecuencia del accidente, Juan Antonio quedó impedido para la realización de las tareas habituales de su profesión.

Juan Antonio demandó la constructora y solicitó una indemnización de 180.303,63 €. El JPI núm. 6 de Badajoz (3.3.2000) desestima la demanda. La AP de Badajoz (Sección 2ª, 24.11.2000) desestima el recurso de apelación y confirma la SJPI.

El TS se abstuvo de conocer el recurso de casación y declaró la nulidad de todas las actuaciones. Apreció falta de competencia de la jurisdicción civil para conocer la reclamación de responsabilidad planteada, pues es consecuencia del incumplimiento del contrato de trabajo por parte del empresario (FD 3º).

En el mismo sentido: STS, 1ª, 1395/2008, de 15 de enero; STS, 1ª, 267/2008, de 16 de abril; STS, 1ª, 367/2008, de 19 de mayo; STS, 1ª, 513/2008, de 4 de junio; STS, 1ª, 1060/2008, de 17 de noviembre; STS, 1ª, 1061/2008, de 17 de noviembre. *Cfr.* con STS, 1ª, 1118/2008, de 19 de noviembre.

b.2) STS, 1ª, 587/2009, 11 de septiembre

Competencia del orden civil para conocer de demandas por accidentes de trabajo interpuestas con anterioridad a la STS, 1ª, Pleno, 15.1.2008.

El 15.12.1993, a las 16:30 horas, Millán, de 27 años de edad, realizaba tareas de selección de pescado en una embarcación propiedad de Constanza. Iba vestido con impermeable y botas de goma de suela antideslizante, y cargaba unas cajas vacías cuando, a causa de un golpe de mar, perdió el equilibrio y cayó al agua por un hueco que, de haber tendido dimensiones inferiores, hubiera impedido la caída, y falleció ahogado.

La mujer e hijos de la víctima demandaron a Constanza, propietaria del barco, y solicitaron una indemnización de 480.809,68 €.

El JPI núm. 48 de Barcelona (15.6.1999) estimó en parte la demanda y condenó a la demandada al pago de 48.080,97 euros con base en los arts. 1902 y 1903 CC. Ambas partes recurrieron en apelación. La AP de Barcelona (Sección 1ª, 15.4.2000) desestimó el de la demandada y estimó en parte el de la actora en el sentido de aumentar la indemnización a 209.278,72 euros.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por la demandada:

"[L]os usos y costumbres de la mar aceptan determinados riesgos. Ahora bien, estos riesgos están pensados más en la efectividad de la pesca que en la seguridad del trabajador … El golpe de mar es un hecho previsible y previsible era también que un marinero pudiera caer, como cayó, por efecto de este golpe de mar y de la inclinación del barco por un hueco que, de haber tenido unas dimensiones inferiores, nunca se hubiera producido" (FD. 3º).

El Tribunal resolvió, en contra de los precedentes judiciales, a favor de la competencia del orden civil:

"Sin duda la jurisdicción es un presupuesto procesal absoluto para el válido desarrollo de la relación jurídico procesal y como tal de obligada observancia por su naturaleza de orden público … Sin embargo, la aceptación de las anteriores conclusiones, no es suficiente para considerar que la competencia jurisdiccional sobre la pretensión ejercitada en este proceso corresponde al orden social y negar la legitimidad del orden jurisdiccional civil para conocer de un asunto que se inicia con la cobertura que le proporcionaba una reiterada jurisprudencia al respecto. Lo contrario contradice la misma esencia del derecho a la tutela judicial efectiva, pues contrario a esta tutela es que a partir de una interpretación posterior de la normativa, y después de que han pasado más de diez años desde que se interpuso la demanda, se inadmita a trámite en la jurisdicción en la que había sido planteada, pasando absolutamente por alto que este mismo Tribunal, en ocasiones y, precisamente tras ponderar las circunstancias del caso, acuñó la doctrina del peregrinaje enraizando principios procesales con los constitucionalmente protegidos -la tutela judicial efectiva sin indefensión, y la evitación de dilaciones indebidas-".

Con posterioridad, el TS ha mantenido este nuevo criterio en la STS, 1ª, 9.3.2010 (JUR 2010 131735; MP: Juan Antonio Xiol Ríos).

b.3) Art. 2 b) Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

"Artículo 2. Ámbito del orden jurisdiccional social.
Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:
(…)
b. En relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente.

c) STS, 3ª, de 3 de noviembre de 2008

A las 11:30 h. del 29.11.1996, Patricia, celadora en el centro de especialidades del complejo hospitalario "Xeral Calde" (Lugo), dependiente del Servicio Gallego de Salud ("SERGAS"), bajaba en el ascensor de dicho complejo cuando, debido a un fallo mecánico, el ascensor cayo desde la 3ª planta, chocando con el amortiguador situado en el foso del sótano del edificio. Como consecuencia del accidente, Patricia sufrió traumatismos múltiples y precisó de atención psiquiátrica hasta 1998. La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Lugo (29.1.1999) declaró que las secuelas derivadas del accidente de trabajo por Patricia eran constitutivas de invalidez permanente absoluta en grado de gran invalidez y reconoció el derecho de ésta a percibir una pensión mensual de 1.404,84 € con un recargo del 50% por falta de medidas de seguridad.

Patricia demandó al "SERGAS" y a la Xunta de Galicia y solicitó una indemnización de 1.031.171,25 €, que la Consellería denegó por silencio administrativo. El TSJ Galicia (Sección 1ª, 3.3.2004) estimó el recurso contencioso administrativo y condenó a las administraciones codemandadas al pago de 300.500 €

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por el "SERGAS" y la Xunta de Galicia. El TS, tras desestimar los argumentos por los cuales la demandante debería haber llamado al proceso a la empresa fabricante del ascensor y la encargada de su mantenimiento, analizó el motivo central del recurso, a saber, si la existencia de una relación de empleo público entre víctima y Administración anulaba la responsabilidad patrimonial de esta última. El TS resolvió que, por más que el daño se habuiera producido en el desarrollo de una relación de servicio público, el accidente quedaba fuera de los riesgos inherentes al ejercicio de su profesión, de manera que la lesión era antijurídica, máxime cuando la empleada no tuvo la más mínima intervención en el accidente (F. D. 5º).

2. *Res ipsa loquitur*

Los tribunales españoles han recibido la doctrina de denominada *"Res ipsa loquitur"* –"las cosas hablan por sí mismas"–, en virtud de la cual si el accidente ha tenido lugar en circunstancias tales que, normalmente y a ojos de un observador razonable, tales accidentes suelen ocurrir por negligencia del demandado, entonces la existencia de esta última se presume salvo prueba en contrario. Se trata así de conductas que normalmente son dañinas solo porque son negligentes, pues en ausencia de culpa el daño no tiene lugar. La doctrina encuentra su mayor dificultad en aquellos casos, que son legión, en los cuales a la presumible negligencia del demandado se suma la presunta negligencia del demandante. Los casos que se citan a continuación dan razón del alcance de esta doctrina y de sus límites.

2.1. *Byrne v. Boadle* (159 Eng. Rep. 299 (Ex. 1863))

[Plaintiff's complaint stated that he was passing along the highway in front of defendant's premises when he was struck and badly hurt by a barrel of flour that was apparently being lowered from a window above, which was on the premises of the defendant, a dealer in flour. Several witnesses testified that they saw the barrel fall and hit plaintiff. The defendant claimed "that there was no evidence of negligence for the jury". The trial court, agreeing, nonsuited plaintiff after the jury had assessed the damages at £50. On appeal in the Court of Exchequer, the plaintiff argued that the evidence was sufficient to support a verdict in his favor. In response, the defendant's lawyer argued that it was consistent with the evidence that the purchaser of the flour or some complete stranger was supervising the lowering of the barrel of flour and that its fall was not attributable in any way to defendant or his servants. POLLOCK, C.B.: "The presumption is that the defendant's servants were engaged in removing the defendant's flour. If they were not it was competent to the defendant to prove it". Defendant's attorney replied that "Surmise ought not to be substituted for strict proof when it is thought to fix a defendant with serious liability. The plaintiff should establish his case by affirmative defense [...] The plaintiff was bound to give affirmative proof of negligence. But there was not a scintilla of evidence, unless the occurrence is of itself evidence of negligence". POLLOCK, C.B.: "There are certain cases of which it may be said res ipsa loquitur and this seems one of them. In some cases the Court had held that the mere fact of the accident having occurred is evidence of negligence, as, for instance, in the case of railway collisions"].

POLLOCK, C.B. We are all of opinion that the rule must be absolute to enter the verdict for the plaintiff. The learned counsel was quite right in saying that there are many accidents from which no presumption of negligence can arise, but I think it would be wrong to lay down as a rule that in no case can presumption of negligence arise from the fact of an accident. Suppose in this case the barrel had rolled out of the warehouse and fallen on the plaintiff, how could he possibly ascertain from what cause it occurred? It is the duty of persons who keep barrels in a warehouse to take care that they do not roll out, and I think that such a case would, beyond all doubt, afford prima facie evidence of negligence. A barrel could not roll out of a warehouse without some negligence, and to say that a plaintiff who is injured by it must call witnesses from the warehouse to prove negligence seems to me preposterous. So in the building or repairing a house, or putting pots on the chimneys, if a person passing along the road is injured by something falling upon him, I think the accident alone would be prima facie evidence of

negligence. Or if an article calculated to cause damage is put in a wrong place and does mischief, I think that those whose duty it was to put it in the right place are prima facie responsible, and if there is any state of facts to rebut the presumption of negligence, they must prove them. The present case upon the evidence comes to this, a man is passing in front of the premises of a dealer in flour, and there falls down upon him a barrel of flour. I think it apparent that the barrel was in the custody of the defendant who occupied the premises, and who is responsible for the acts of his servants who had the control of it; and in my opinion the fact of its falling is prima facie evidence of negligence, and the plaintiff who was injured by it is not bound to shew that it could not fall without negligence, but if there are any facts inconsistent with negligence it is for the defendant to prove them. [Judgment affirmed].

2.2. *Colmenares Vivas v. Sun Alliance Insurance Co.* (807 F.2d 1102 (1st Cir. 1986))

BOWNES, Circuit Judge.

Appellants are plaintiffs in a diversity action to recover damages for injuries they suffered in an accident while riding an escalator. After the parties had presented their evidence, the defendants moved for and were granted a directed verdict. The court held that there was no evidence of negligence and that the doctrine of res ipsa loquitur, which would raise a presumption of negligence, did not apply. We reverse the directed verdict and remand the case to the district court because we hold that res ipsa loquitur does apply.

I. BACKGROUND

The relevant facts are not in dispute. On February 12, 1984, Jose Domingo Colmenares Vivas and his wife, Dilia Arreaza de Colmenares, arrived at the Luis Muñoz Marin International Airport in Puerto Rico. They took an escalator on their way to the Immigration and Customs checkpoint on the second level. Mrs. Colmenares was riding the escalator on the right-hand side, holding the moving handrail, one step ahead of her husband. When the couple was about halfway up the escalator, the handrail stopped moving, but the steps continued the ascent, causing Mrs. Colmenares to lose her balance. Her husband grabbed her from behind with both hands and prevented her from falling, but in doing so, he lost his balance and tumbled down the stairs. Mr. and Mrs. Colmenares filed a direct action against the Sun Alliance Insurance Company, who is the liability insurance carrier for the airport's owner and operator, the Puerto Rico Ports Authority. Sun Alliance brought a third-party contractual action against Westinghouse Electric Corporation based on a maintenance contract that required Westinghouse to inspect, maintain, adjust, repair, and replace parts as needed for the escalator and handrails, and to keep the escalator in a safe operating condition. […]

The trial was conducted on January 30 and 31, 1986. Appellants called four witnesses. The Ports Authority's contract and maintenance supervisor testified about his daily weekday inspections of the escalator, about the maintenance contract with Westinghouse, about inspection and maintenance procedures, and about the accident report and subsequent repair and maintenance of the escalator. The Ports Authority's assistant chief of operations testified about the accident report. Appellants' testimony concerned the accident and their injuries.

[…] After hearing the parties' arguments, the court ruled that there was no evidence that the Ports Authority had been negligent, and that the case could not go to the jury based on res ipsa loquitur because at least one of the requirements for its application -- that the injury-causing instrumentality was within the exclusive control of the defendant -- was not met […].

II. RES IPSA LOQUITUR

Under Puerto Rico law, three requirements must be met for res ipsa loquitur, ("the thing speaks for itself"), to apply: "(1) the accident must be of a kind which ordinarily does not occur in the absence of someone's negligence; (2) it must be caused by an agency or instrumentality within

the exclusive control of defendant; [and] (3) it must not be due to any voluntary action on the part of plaintiff." Community Partnership v. Presbyterian Hospital.. . If all three requirements are met, the jury may infer that the defendant was negligent even though there is no direct evidence to that effect. […]

A. The First Requirement: Inference of Negligence

The first requirement that must be met for res ipsa loquitur to apply is that "the accident must be such that in the light of ordinary experience it gives rise to an inference that someone has been negligent". It is not clear to us whether the district court decided that this requirement was met, although the court did suggest that it was giving the benefit of the doubt on this question to the appellants. We hold that this requirement was met because an escalator handrail probably would not stop suddenly while the escalator continues moving unless someone had been negligent.

This requirement would not be met if appellants had shown nothing more than that they had been injured on the escalator, because based on this fact alone it would not be likely that someone other than the appellants had been negligent. […]. Here, it was not disputed that the handrail malfunctioned and stopped suddenly, an event that foreseeably could cause riders to lose their balance and get injured. Thus, the evidence gave rise to an inference that someone probably had been negligent in operating or maintaining the escalator, and the first requirement for the application of res ipsa loquitur was met.

B. The Second Requirement: Exclusive Control

The second requirement for res ipsa loquitur to apply is that the injury-causing instrumentality -- in this case, the escalator -- must have been within the exclusive control of the defendant. The district court found that this requisite was not met, despite the parties' stipulation that "the escalator in question is property of and is under the control of the Puerto Rico Ports Authority." We agree that this stipulation was not by itself enough to satisfy the res ipsa loquitur requirement. It did not exclude the possibility that someone else also had control over the escalator; indeed, the stipulation said that Westinghouse maintained the escalator. We hold, however, that the Ports Authority effectively had exclusive control over the escalator because the authority in control of a public area has a nondelegable duty to maintain its facilities in a safe condition.

Few courts have required that control literally be "exclusive." […]. The exclusive control requirement, then, should not be so narrowly construed as to take from the jury the ability to infer that a defendant was negligent when the defendant was responsible for the injury-causing instrumentality, even if someone else might also have been responsible. The purpose of the requirement is not to restrict the application of the res ipsa loquitur inference to cases in which there is only one actor who dealt with the instrumentality, but rather "to eliminate the possibility that the accident was caused by a third party." […] It is not necessary, therefore, for the defendant to have had actual physical control; it is enough that the defendant, and not a third party, was ultimately responsible for the instrumentality. Thus, res ipsa loquitur applies even if the defendant shares responsibility with another, or if the defendant is responsible for the instrumentality even though someone else had physical control over it. […] It follows that a defendant charged with a nondelegable duty of care to maintain an instrumentality in a safe condition effectively has exclusive control over it for the purposes of applying res ipsa loquitur. […] Unless the duty is delegable, the res ipsa loquitur inference is not defeated if the defendant had shifted physical control to an agent or contracted with another to carry out its responsibilities.

We hold that the Ports Authority could not delegate its duty to maintain safe escalators. There are no set criteria for determining whether a duty is nondelegable; the critical question is whether the responsibility is so important to the community that it should not be transferred to another. […]. The Ports Authority was charged with such a responsibility. It was created for a public purpose, which included the operation and management of the airport. ... A concomitant

of this authority is the duty to keep the facilities it operates in a reasonably safe condition. The public is entitled to rely on the Ports Authority -- not its agents or contractors -- to see that this is done. The Ports Authority apparently recognized this responsibility, for its maintenance and contract supervisor conducted daily weekday inspections of the escalators despite the maintenance contract with Westinghouse.

Duties have been seen as nondelegable in several analogous situations. For example, a public authority may not delegate to an independent contractor its responsibility to see that work in a public place is done carefully. […] Also, a government may not delegate its responsibility to maintain safe roads and similar public places. […] Finally, an owner has a nondelegable duty to keep business premises safe for invitees. […] These examples demonstrate a general tort law policy not to allow an entity to shift by contract its responsibility for keeping an area used by the public in a safe condition. It would be contrary to this policy to allow the owner and operator of an airport terminal to delegate its duty to keep its facility safe. We hold, therefore, that the district court erred in ruling that the exclusive control requirement was not met.

C. The Third Requirement: The Plaintiffs' Actions

The third requirement that must be met for res ipsa loquitur to apply is that the accident must not have been due to the plaintiff's voluntary actions. The district court found, and we agree, that there was no evidence that Mr. and Mrs. Colmenares caused the accident. Indeed, there is no indication that they did anything other than attempt to ride the escalator in the ordinary manner. Therefore, we hold that all three requirements were met and that the jury should have been allowed to consider whether the Ports Authority was liable based on the permissible inference of negligence raised by the application of res ipsa loquitur. [...]

TORRUELLA, Circuit Judge dissenting. I must regretfully dissent. […] In my view, solely because the handrail stopped and Mrs. Colmenares fell, without further evidence as to why or how the handrail malfunctioned, does not give rise to an inference of negligence by the Ports Authority. […]

The malfunctioning of an escalator presents an even stronger argument against the raising of an inference of negligence without additional proof as to the cause of the malfunction. Although a court can take notice that an escalator is a complicated piece of machinery, it has no basis of common knowledge for inferring that its malfunction is the result of the operator's negligence.

2.3. *Ybarra v. Spangard* (25 Cal.2d 486, 154 P.2d 687)

GIBSON, C. J. This is an action for damages for personal injuries alleged to have been inflicted on plaintiff by defendants during the course of a surgical operation. The trial court entered judgments of nonsuit as to all defendants and plaintiff appealed.

On October 28, 1939, plaintiff consulted defendant Dr. Tilley, who diagnosed his ailment as appendicitis, and made arrangements for an appendectomy to be performed by defendant Dr. Spangard at a hospital owned and managed by defendant Dr. Swift. Plaintiff entered the hospital, was given a hypodermic injection, slept, and later was awakened by Drs. Tilley and Spangard and wheeled into the operating room by a nurse whom he believed to be defendant Gisler, an employee of Dr. Swift. Defendant Dr. Reser, the anesthetist, also an employee of Dr. Swift, adjusted plaintiff for the operation, pulling his body to the head of the operating table and, according to plaintiff's testimony, laying him back against two hard objects at the top of his shoulders, about an inch below his neck. Dr. Reser then administered the anesthetic and plaintiff lost consciousness. When he awoke early the following morning he was his hospital room attended by defendant Thompson, the special nurse, and another nurse who was not made a defendant.

Plaintiff testified that prior to the operation he had never had any pain in, or injury to, his right arm or shoulder, but that when he awakened he felt a sharp pain about half way between the neck and the point of the right shoulder. He complained to the nurse, and then to Dr. Tilley, who

gave him diathermy treatments while he remained in the hospital. The pain did not cease but spread down to the lower part of his arm, and after his release from the hospital the condition grew worse. He was unable to rotate or lift his arm, and developed paralysis and atrophy of the muscles around the shoulder. He received further treatments from Dr. Tilley until March, 1940, and then returned to work, wearing his arm in a splint on the advice of Dr. Spangard. […]

We have no doubt that in a modern hospital a patient is quite likely to come under the care of a number of persons in different types of contractual and other relationships with each other. For example, in the present case it appears that Drs. Smith, Spangard and Tilley were physicians or surgeons commonly placed in the legal category of independent contractors; and Dr. Reser, the anesthetist, and defendant Thompson, the special nurse, were employees of Dr. Swift and not of the other doctors. But we do not believe that either the number or relationship of the defendants alone determines whether the doctrine of res ipsa loquitur applies. Every defendant in whose custody the plaintiff was placed for any period was bound to exercise ordinary care to see that no unnecessary harm came to him and each would be liable for failure in this regard. Any defendant who negligently injured him, and any defendant charged with his care who so neglected him as to allow injury to occur, would be liable. The defendant employers would be liable for the neglect of their employees; and the doctor in charge of the operation would be liable for the negligence of those who became his temporary servants for the purpose of assisting in the operation. […]

The judgment is reversed.

2.4. STS, 1ª, 1146/1998, de 9 de diciembre

La esposa del actor, de 78 años de edad, fue intervenida satisfactoriamente de halux valgus bilateral, esto es, juanetes. A los pocos días de la intervención, sin embargo, la paciente presentó un cuadro de contractura muscular progresiva a nivel cervical, con dificultad de deglución, por lo que, ante la sospecha de que se tratara de tétanos postquirúrgico se inició el oportuno tratamiento y la enferma fue trasladada a otro hospital donde, confirmado el diagnóstico fue ingresada en la UCI. La paciente falleció a los quince días por tétanos grave postquirúrgico. El actor demandó a la congregación religiosa titular del hospital, al cirujano, al médico que le asistió en la operación y a la Mutua General de Seguros en reclamación de una indemnización 120.202,42 €. El Juzgado desestimó la demanda, mas la Audiencia revocó la sentencia y condenó a la congregación religiosa y a la compañía aseguradora a pagar 90.151,82 € más las costas causadas en primera instancia. El Tribunal Supremo revocó la Sentencia de la Audiencia únicamente en lo referente a la condena en costas, en el sentido de no imponer las de primera instancia a ninguna de las partes. La Sentencia imputóa el resultado dañoso al mal cumplimiento por la entidad titular del centro hospitalario, de la prestación de tener el espacio, el instrumental y el material a utilizar en el estado que sea preciso para evitar infecciones. Y ello porque, aunque se afirma que la obligación médica es de medios, no de resultado, ello no obsta a la presunción desfavorable que nace del daño, cuando éste es desproporcionado en relación con lo que es usual.

Por primera vez el Tribunal Supremo identifico la doctrina del daño desproporcionado con las medidas de facilitación de la prueba existentes en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno:

«[C]onviene recordar la doctrina sobre el daño desproporcionado, del que se desprende la culpabilidad del autor (así, la Sentencia de 13 diciembre 1997 [A.8816]), que corresponde a la regla «res ipsa loquitur» (la cosa habla por sí misma) que se refiere a una evidencia que crea una deducción de negligencia y ha sido tratada profusamente por la doctrina angloamericana y a la regla del *Anscheinsbeweis* (apariencia de prueba) de la doctrina alemana y, asimismo, a la doctrina francesa de la *faute virtuelle* (culpa virtual); lo que requiere que se produzca un evento dañoso de los que normalmente no se producen sino por razón de una conducta negligente, que dicho evento se origine por alguna conducta que entre en la esfera de la acción del demandado aunque no se conozca el detalle exacto y que el mismo no sea causado por una conducta o una acción que corresponda a la esfera de la propia víctima» (FD. 2º).

2.5. STS, 1ª, 461/2003, de 8 de mayo: fractura de rodilla

El 7.1.1991 Marisol sufrió un accidente de esquí en Baqueira Beret que le causó una fractura de espina tibial, de la que fue auxiliada *in situ* y trasladada a Barcelona, donde fue atendida por el doctor Carlos Antonio, que tenía contratado un seguro con Winterthur y pertenecía a "Asistencia Sanitaria Colegial, SA". El tratamiento se prolongó hasta mayo de 1992, en cuyo transcurso la paciente se sometió a tres intervenciones. Finalmente, Marisol acudió a otro doctor para que acabase el tratamiento, pero le quedaron secuelas graves que consisten en limitación de la movilidad de la rodilla derecha, atrofia muscular y una cojera irreversible.

Marisol demanda al doctor Carlos Antonio, a Winterthur y a "Asistencia Sanitaria Colegial, SA" y solicita una indemnización de 120.202,42 €.

El JPI nº 25 de Barcelona (7.4.1995) estima en parte la demanda y condena a Carlos Antonio y a Winterthur al pago de 72.121,45 €. La AP de Barcelona (Sección 11ª, 8.5.1997) estima el recurso de apelación, revoca la SJPI y absuelve a los condenados en la instancia previa.

El TS estima el recurso interpuesto por la actora, revoca la SAP y confirma la SJPI. Considera que el largo periodo de tratamiento, con tres intervenciones de por medio y con el resultado de graves secuelas, es suficiente para deducir la negligencia médica de acuerdo con la regla *res ipsa loquitur*. Así:

"[U]na caída y una lesión que tampoco se dice que fueran especialmente graves, ni complicados, tienen un tratamiento largo y doloroso con un resultado que no puede por menos que considerarse desproporcionado: una cojera irreversible; lo cual crea una deducción de negligencia («res ipsa loquitur»), una apariencia de prueba de ésta ("Anscheisbeweis"), una culpa virtual ("faute virtuelle").No se trata, pues, de una objetivación absoluta de responsabilidad sino de apreciación de culpa, deducida del resultado desproporcionado y no contradichos por hechos considerados acreditados por prueba pericial. Se produce un suceso y un daño: es claro que no consta causa del mismo imputable a la víctima (…), ni se menciona el caso fortuito o la fuerza mayor; la causa fue la actuación médica, de cuyo mal resultado se desprende la culpa y, por ende, la responsabilidad" (FD 3º).

2.6. Otras sentencias sobre responsabilidad médica por daños desproporcionados

STS, 1ª, 417/2007, de 16 de abril

El 9.2.1994, el Dr. Jorge intervino quirúrgicamente a Maite de una hernia discal y le implantó un injerto óseo y una placa de titanio que le produjeron una infección bacteriana. En el postoperatorio, la paciente fue visitada en tres ocasiones por dolores, pero la infección no fue detectada por falta de empleo del medio diagnóstico adecuado. El 3.9.1994, Maite ingresó en el "Hospital Virgen de las Nieves" de Granada, donde fue intervenida en tres ocasiones porque se le encontró un absceso de pus en la zona en la que había sido intervenida. Maite sufrió secuelas consistentes en una tetraparesia con incapacidad del 76%, perjuicio estético derivado de traqueotomía y depresión grave.

Maite demandó a Jorge y a "Neurosan, S.L." *(no consta relación con el caso)*, y solicitó una indemnización de 901.518,6 €.

La SJPI nº 25 de Barcelona, 16.2.1999, estimó en parte la demanda, condenó a Jorge a pagar 540.910,89 € y absolvió al otro demandado. La SAP de Barcelona, Secc. º7ª, 31.1.2000, desestimó el recurso de apelación interpuesto por Jorge y confirmó la SJPI.

El TS desestimó el recurso de casación, pues:

"[A]nte el daño desproporcionado (…) se espera del agente una explicación o una justificación cuya ausencia u omisión puede determinar la imputación por culpa que ya entonces se presume" y en este caso, "no se ha producido por parte del demandado una explicación que excluya la apreciación de negligencia por falta de atención durante el postoperatorio" (FD 2º).

— SSTS, 1ª, 813/1997, de 26 de septiembre; 593/1999, de 29 de junio; 1038/1999, de 9 de diciembre.
— Bibliografía específica: Álvaro LUNA YERGA, *La prueba de la responsabilidad civil médico-sanitaria. Culpa y Causalidad*, Thomson-Civitas, Madrid, 2004, pp. 186 y ss.

Capítulo 6º
Negligencia (IV): Culpa comparativa y culpa contributiva

1. Negligencia bilateral / *Bilateral Care or Joint Care* 97
2. Negligencia contributiva / *Contributory Negligence* 98
2.1. Butterfield v. Forrester (103 Eng. Rep. 926 (K.B. 1809)) 98
2.2. LeRoy Fibre Co. v. Chicago, Milwaukee & St. Paul Ry., 232 US. 340 (1914) 99
2.3. STS, 1ª, 3 de junio de 1901. Colección Legislativa, 91 p. 867 100
2.4. STS, 4ª, 6 de julio de 1990. Inexistencia de error judicial al presentar un documento en idioma extranjero sin acompañar traducción 101
3. *The Last Clear Chance Doctrine* 103
3.1. Davies v. Mann (152 Eng. Rep. 588) 103
3.2. Restatement (Second) of Torts (1965, updated April 2012) 103
4. Negligencia comparativa o concurrencia de culpas / *Comparative Negligence* .. 104
4.1. STS, 1ª, 967/2002, de 21 de octubre. Accidente de tráfico por colisión de una motocicleta con un montón de grava y arena 104
4.2. Antonio FERNÁNDEZ/Víctor M. SÁNCHEZ (2003), "Negligencia Multilateral en Accidente de Motocicleta, ¿cuál es el Estándar Óptimo de Responsabilidad?", *InDret* 3/2003, (www.indret.com), pp. 10-11 105
4.3. STS, 1ª, 139/2011, de 14 de marzo 106
5. Negligencia comparativa modificada 108
5.1. Cuantitativamente 108
5.2. Cualitativamente 109
6. Culpa exclusiva de la víctima 111
7. Negligencia imputada / *Imputed Negligence* 111
8. Seguridad pasiva de automóviles (*Crashworthiness*) 113
8.1. D'Amario v. Ford Motor Co. [806 So. 2d 424 (Fla. 2001)] 114
8.2. STS, 1ª, 1071/2008, de 7 de noviembre (D. Ángel Daniel c. Citröen Hispania, S.A.) 116
8.3. SAP Barcelona, Secc. 16ª, 43/2009, de 29 de enero 119

1. Negligencia bilateral / *Bilateral Care or Joint Care*

Tanto en el modelo normativo del análisis doctrinal tradicional de la negligencia, que en Derecho español arranca del art. 1902 CC de 1889, como en el paradigma analítico del *Law & Economics* neoclásico, se parte siempre de la causación unilateral de daños por la posible negligencia del demandando o demandados, pero sin que el demandante haya contribuido a causar el daño, o habiéndolo hecho, haya infringido también deberes de precaución exigibles, es decir, haya sido, a su vez, negligente: hay, por así decirlo, una sola dirección causal posible que va del demandado al demandante y este no pudo hacer nada para evitar el daño que sufrió. Quizás el ejemplo de referencia sea el del paciente anestesiado y tendido en una mesa de operaciones quien es víctima de una negligencia médica: parece claro que nada pudo hacer por evitar el daño.

En la realidad, sin embargo, son poco frecuentes los casos de causación puramente unilateral de daños. Y ello es así no solo en el sentido trivial de que todos contribuimos al daño, aunque solo sea por el hecho de estar donde y cuando sería mejor que no hubiéramos estado cuando sufrimos el accidente. Es que muchas veces, la víctima contribuye causal y negligentemente a empeorar las cosas: en el ejemplo que acabamos de poner, el abogado del médico y del hospital demandados pueden tratar de probar que el paciente, con anterioridad a ponerse en manos del médico, había descuidado las instrucciones que este le había dado sobre la conducta que debía

observar antes de la intervención. Es decir, si no siempre, casi siempre cabe plantear la cuestión de la contribución del demandado a la producción negligente del daño y, caso de que la pregunta admita respuesta, afirmativa, la relativa a las consecuencias de tal contribución.

Y en la actualidad, es frecuente que la negligencia del demandante, por más que contribuya a la causación del daño –a su cocausación--, no se toma normativamente en consideración si no es suficientemente relevante o --como ocurre, por ejemplo, en el derecho español de los accidentes de trabajo-- si no es crasa, si no constituye negligencia grave. Históricamente se ha pasado de un sistema en el cual la contribución culposa del demandante a la causación del accidente generaba una excepción total a favor del demandado a otro en el cual esta solo puede oponerse si es significativa, cuantitativa o cualitativamente, y, en tales casos, únicamente por la parte en la cual se considera que ha contribuido a causar los daños. Por último, si la causación culpable es imputable sólo al demandante su pretensión será desestimada. Los casos que, a continuación, se resumen trazan el arco de esta evolución (en los derechos de daños de los Estados Unidos de América y en 2011, todos los estados menos cuatro y el Distrito de Columbia tienen un sistema u otro de negligencia comparativa, normalmente modificada, que en España se llama compensación de culpas o concurrencia de causas y que es el comúnmente aplicado por la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo).

2. Negligencia contributiva / *Contributory Negligence*

2.1. Butterfield v. Forrester (103 Eng. Rep. 926 (K.B. 1809))

This was an action on the case for obstructing a highway, by means of which obstruction the plaintiff [Butterfield], who was riding along the road, was thrown down with his horse, and injured, etc. At the trial before Bailey, J. at Derby, it appeared that the defendant [Forrester], for the purpose of making some repairs to his house, which was close by the roadside at one end of the town, had put up a pole across part of the road, a free passage being left by another branch or tree in the same direction. That the plaintiff left a public house not far distant from the place in question at 8 o'clock in the evening in August, when they were just beginning to light candles, but while there still was light enough to discern the obstruction at one hundred yards distance; and the witness who proved this, said that if the plaintiff had not been riding very hard he might have observed and avoided it; the plaintiff, however, who was riding violently, did not observe it, but rode against it, and fell with his horse and was much hurt in consequence of the accident; and there was no evidence of his being intoxicated at the time. On this evidence, Bailey, J., directed the jury, that if a person riding with reasonable and ordinary care could have seen and avoided the obstruction; and if they were satisfied that the plaintiff was riding along the street extremely hard, and without ordinary care, they should find a verdict for the defendant, which they accordingly did.

Lord Ellenbrough, C.J. A party is not to cast himself upon an obstruction, which had been made by the fault of another, and avail himself of it, if he does not himself use common and ordinary caution to be in the right. In case of persons riding upon what is considered to be the wrong side of the road that would not authorize another purposely to ride up against them. One person being in fault will not dispense with another's using ordinary care for himself. Two things must occur to support this action: an obstruction in the road by the fault of the defendant, and no want of ordinary care to avoid it on the part of the plaintiff.

2.2. LeRoy Fibre Co. v. Chicago, Milwaukee & St. Paul Ry., 232 US. 340 (1914)

As part of its business of making flax, plaintiff [appellant] stored about 700 tons of straw units own land. The stacks were lined in two rows. The defendant's right of way ran about 70 feet from the first row and 85 feet from the second. One day a high wind carried sparks from a passing train to one of the stacks of flax located I the row further from the tracks. That fire eventually consumed all the flax. Appellant brought an action against respondent to recover the value of flax straw that was destroyed due to the alleged negligence of the respondent. Respondent alleged that Appellant was guilty of contributory negligence in placing the inflammable stacks of flax straw too near to the railroad track, though the straw was still on Appellant's land.

MCKENNA, J. The questions certified present two facts -- (1) The negligence of the railroad was the immediate cause of the destruction of the property. (2) The property was placed by its owner near the right of way of the railroad, but on the owner's own land. The query is (...) whether one is limited in the use of one's property by its proximity to a railroad; or, to limit the proposition to the case under review, whether one is subject in its use to the careless as well as to the careful operation of the road. (...) That one's uses of his property may be subject to the servitude of the wrongful use by another of his property seems an anomaly. It upsets the presumptions of law and takes from him the assumption and the freedom which comes from the assumption, that the other will obey the law, not violate it. It casts upon him the duty of not only using his own property so as not to injure another, but so to use his own property that it may not be injured by the wrongs of another. How far can this subjection be carried? Or, confining the question to railroads, what limits shall be put upon their immunity from the result of their wrongful operation? In the case at bar, the property destroyed is described as inflammable, but there are degrees of that quality; and how wrongful must be the operation? In this case, large quantities of sparks and "live cinders" were emitted from the passing engine. Houses may be said to be inflammable, and may be, as they have been, set on fire by sparks and cinders from defective or carelessly handled locomotives. Are they to be subject as well as stacks of flax straw, to such lawless operation? And is the use of farms also, the cultivation of which the building of the railroad has preceded? Or is that a use which the railroad must have anticipated and to which it hence owes a duty, which it does not owe to other uses? And why? The question is especially pertinent and immediately shows that the rights of one man in the use of his property cannot be limited by the wrongs of another. The doctrine of contributory negligence is entirely out of place. Depart from the simple requirement of the law, that every one must use his property so as not to injure others, and you pass to refinements and confusing considerations. There is no embarrassment in the principle even to the operation of a railroad. Such operation is a legitimate use of property; other property in its vicinity may suffer inconveniences and be subject to risks by it, but a risk from wrongful operation is not one of them.

MR. JUSTICE HOLMES, partially concurring. If a man stacked his flax so near to a railroad that it obviously was likely to be set fire to by a well-managed train, I should say that he could not throw the loss upon the road by the oscillating result of an inquiry by the jury whether the road had used due care. I should say that although of course he had a right to put his flax where he liked upon his own land, the liability of the railroad for a fire was absolutely conditioned upon the stacks being at a reasonably safe distance from the train. If I am right so far, a very important element in determining the right to recover is whether the plaintiff's flax was so near

to the track as to be in danger from even a prudently managed engine. Here certainly, except in a clear case, we should call in the jury. I do not suppose that any one would call it prudent to stack flax within five feet of the engines or imprudent to do it at a distance of half a mile, and it would not be absurd if the law ultimately should formulate an exact measure, as it has tended to in other instances; ... but at present I take it that if the question I suggest be material we should let the jury decide whether seventy feet was too near by the criterion that I have proposed (...) I do not think we need trouble ourselves with the thought that my view depends upon differences of degree. The whole law does so as soon as it is civilized. See Nash v. United States (. . .) Negligence is all degree -- that of the defendant here degree of the nicest sort; and between the variations according to distance that I suppose to exist and the simple universality of the rules in the Twelve Tables or the Leges Barbarorum, there lies the culture of two thousand years.

I am authorized to say that THE CHIEF JUSTICE concurs in the opinion that I express.

2.3. STS, 1ª, 3 de junio de 1901. Colección Legislativa, 91 p. 867

El *pendant* español del caso americano *LeRoy Fibre Co. v. Chicago* es la STS, 1ª, 3.6.1901. La estación de Málaga destinaba un espacio a almiares de paja, situado junto a uno de los andenes. Una locomotora que se encontraba en ese andén inició la marcha, pero se vio obligada a dar contravapor. Puesto que mientras había estado parada un empleado había alimentado sus calderas para avivar el fuego, de su chimenea comenzaron a saltar chispas que provocaron el incendio del almiar y de unas mercancías almacenadas cerca, propiedad del actor. Éste demandó a la Compañía de ferrocarril. Tanto el JPI de Málaga como la AP de Granada desestimaron la demanda. El TS declaró no haber lugar al recurso: "La sentencia recurrida, en virtud de los hechos que consigna con relación a las pruebas del pleito, declara que no han incurrido en culpa o negligencia los dependientes de la Compañía de, a la cual no afecta en este caso responsabilidad directa, ni indirecta, porque ninguna obligación había contraído y porque los almiares de paja, sin convenio o pacto que limitase el derecho de la empresa a utilizar la vía llamada del Peso, se colocaron en la inmediación de la misma por los dueños de aquella mercancía a sabiendas del uso constante que se podía hacer de la vía, por cuya razón no hay vínculo jurídico ni precepto legal que ampare la indemnización que pide el recurrente" (FJ 2º).

— Pablo SALVADOR/Carlos GÓMEZ, "El Derecho de Daños y la Minimización de los Costes de los Accidentes", *InDret* 1/2005 (www.indret.com), pp. 15-16:

"[...E]n la mayor parte de los casos, las víctimas potenciales *también* pueden influir en la frecuencia y gravedad de los accidentes: los conductores de automóviles, por ej., pueden conducir prudentemente y los peatones pueden caminar también con mayor o menor precaución. En tales casos, se habla de precaución o causación bilateral de daños (*bilateral care, joint care*) y el concepto de precaución óptima se complica un poco, pues depende del cuidado adoptado por ambas partes.

Supongamos, en un ejemplo tomado, con algunas modificaciones, de Richard A. POSNER (*Economic Analysis of Law,* 6ª ed., Aspen Law & Business, New York, 2003, p. 172), a su vez inspirado en un caso *(LeRoy Fibre Co. v. Chicago, Milwaukee & St. Paul Ry. Co., 232 U.S. 340 (1914))* real de principios del siglo XX, un granjero es propietario de una plantación de algodón

que es atravesada por una vía de ferrocarril. El paso de las locomotoras de vapor provoca ocasionalmente chispas, con el consiguiente riesgo de incendio de los campos. Ambas partes pueden adoptar tres niveles distintos de precaución: ninguna, media o alta. Así, el granjero puede plantar algodón junto a las vías del ferrocarril, hacerlo a 75 m. de distancia o alejarlo hasta 200 m. de las vías. Por su parte, la compañía propietaria del ferrocarril puede instalar en las chimeneas de sus locomotoras un artilugio apaga chispas de calidad media o alta, pero también puede resolver no instalar ninguno.

En la **tabla 2**, sus tres columnas recogen los distintos niveles de precaución que pueden adoptar las partes, así como sus costes respectivos. Los beneficios esperados en ahorro de daños son los mismos en los tres primeros casos e importan 150 € (en la cuarta columna, donde ni granjero ni ferrocarril adoptan ningún género de precaución, los daños suben a 300 €). La combinación óptima es aquella en la cual el granjero aleja su plantación a 75 m. de las vías y el ferrocarril instala en sus máquinas un mecanismo de calidad media. De este modo se previene un accidente cuyo daño esperado es de 150 €, con un coste de precaución de 75 €.

	Alta/0 m.	**Media/ 75 m.**	---/200 m.	---/0 m.
Coste precaución ferrocarril (F)	100	**50**	0	0
Coste precaución granjero (G)	0	**25**	110	0
Coste total precauciones (G+F)	100	**75**	110	0
Coste del daño (D)	150	**150**	150	300

Tabla 2.

2.4. STS, 4ª, 6 de julio de 1990. Inexistencia de error judicial al presentar un documento en idioma extranjero sin acompañar traducción

"La demanda sobre la que debemos pronunciarnos llega a la conclusión de que se ha producido error judicial indemnizable con arreglo a los artículos 292 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial-LOPJ en la sentencia del Tribunal Central de Trabajo (TCT) de 2 de octubre de 1987 (RTCT 1987\20512), que denegó el reintegro de gastos médicos por asistencia urgente y de carácter vital, al margen de la Seguridad Social española. A la petición de declaración de error judicial se llega en la demanda mediante la argumentación siguiente: 1) La sentencia adolece de «error en la construcción de la resolución» al aceptar en sus antecedentes los hechos probados de la sentencia de instancia, corrigiéndolos luego en la fundamentación jurídica en el punto relativo a la fecha de la operación quirúrgica que originó el litigio del que procede esta demanda; 2) La referida sentencia del Tribunal Central de Trabajo incurre en «error craso» en la apreciación de la fecha de tal intervención quirúrgica (7-3-81) según la convicción del Tribunal -cuando en realidad el día de la operación fue el 3-7-81; 3) Este error -continúa el argumento de la parte demandante- se ha debido a ignorancia de la «secuencia normal para

indicar las fechas en la documentación mercantil norteamericana», que sigue el orden mes-día-año en lugar del orden día-mes-año convencionalmente establecido en España y en otros muchos países; y 4) La equivocación del juzgador en la interpretación de los guarismos que figuran en las facturas e informes de la clínica en que se practicó la operación reúne -de nuevo según la demanda de la declaración de error judicial- los requisitos exigidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial para la indemnización a que se refiere el artículo 121 de la Constitución Española, al tratarse de un «error craso» «inexplicable» «evidente» y trascendente para la resolución.

En apoyo de esta argumentación se acompaña a la demanda entre otros elementos de convicción, un informe del Consejero Comercial de la Embajada de los Estados Unidos de América, con fecha 12 de noviembre de 1989, en el que se indica que los escritos procedentes de dicho país en los que figuran fechas cifradas, deben ser interpretados atribuyendo la primera cifra al mes, la segunda al día y la tercera al año" (FD 1º).

"Ciertamente, el argumento de más peso de la demanda es el que se refiere al modo de ser leídas las fechas de los documentos acreditativos de la intervención quirúrgica de la demandante. La afirmación de la parte demandante de que la sentencia impugnada incurrió en error en este punto es convincente, y así lo debemos reconocer de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal. Ahora bien, la equivocación imputada no cumple los requisitos del error indemnizable que se deducen de los artículos 292 y 295 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tales requisitos son, entre otros, de acuerdo con la interpretación jurisprudencial, el carácter ostensible o patente del error -T. S. 1.ª, 16-6-88 (RJ 1988\4934); T. S. 4.ª 11-10-89 (RJ 1989\7159); T. S. 1.ª 13-4-88 (RJ 1988\3143)-; su influencia determinante (condición sine qua non) en el fallo -T. S., soc. 24-11-86 (RJ 1986\6716)-, y que no haya sido provocado o producido por la conducta dolosa o culposa de la parte perjudicada (T. S. 2.ª, 24-11-86).

En el presente supuesto es claro que el comportamiento procesal de la parte, que no cumplió con el requisito establecido en el artículo 601 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) de acompañar una traducción de los documentos presentados en lengua extranjera, ha contribuido decisivamente a la equivocación del juzgador, sin que la mera advertencia contenida en el escrito de impugnación del recurso de suplicación fuera bastante para compensar el malentendido provocado por tal carencia.

El error padecido por el Tribunal Central de Trabajo (en el que no hubiera incurrido seguramente de haberse acompañado las traducciones preceptivas, o incluso de haberse aportado en un momento anterior el informe de la Embajada USA que se adjunta como documento nº 4 a la demanda de error judicial) no puede decirse tampoco que sea un error ostensible o patente. En verdad, hoy por hoy, no cabe estimar hecho notorio en España el orden de lectura en las representaciones numéricas de las fechas que se practican en los Estados Unidos de América.

De acuerdo con todo lo anterior no puede accederse a la petición indemnizatoria que se deduce de la demanda" (FD 3º).

3. *The Last Clear Chance Doctrine*

3.1. Davies v. Mann (152 Eng. Rep. 588)

At the trial, before Erskine, J., it appeared that the plaintiff, having fettered the fore-feet of an ass belonging to him, turned it into a public highway, and at the same time in question the ass was grazing on the off side of a road about eight yards wide, when the defendant's wagon, with a team of three horses, coming down a slight descent, at what the witness termed a smartish pace, ran against the ass, knocked it down, and the wheels passing over it, it died soon after. … The learned judge told the jury, that … if they thought that the accident might have been avoided by the exercise of ordinary care on the part of the driver, to find for the plaintiff. The jury found their verdict for the plaintiff…

[The defendant's attorney] moved for a new trial, on the ground of misdirection. The act of the plaintiff in turning the donkey into the public highway was an illegal one, and, as the injury arose principally from that act, the plaintiff is not entitled to compensation for that injury which, but for his own unlawful act would never have occurred. …The principle focus of law ... is, that where an accident is the result of faults on both sides, neither party can maintain an action. Thus, in Butterfield v. Forrester, 11 East 60, it was held that one who is injured by an obstruction on a highway, against which he fell, cannot maintain an action, if it appear that he was riding with great violence and want of ordinary care, without which he might have seen and avoided the obstruction. …

Lord Abinger, C.B. …[A]s the defendant might, by proper care, have avoided injuring the animal, and did not, he is liable for the consequence of his negligence, though the animal may have been improperly there.

Parke, B. … [T]he negligence which is to preclude a plaintiff from recovering in anaction of this nature, must be such as that he could, by ordinary care, have avoided the consequences of the defendant's negligence. … [A]lthough the ass may have been wrongly there, still the defendant was bound to go along the road at such a pace as would be likely to prevent mischief. Were this not so, a man might justify the driving over goods left on a public highway, or even over a man lying asleep there, or the purposely running against a carriage going on the wrong side of the road. …

3.2. Restatement (Second) of Torts (1965, updated April 2012)

§479. Last Clear Chance: Helpless Plaintiff.

A plaintiff who has negligently subjected himself to a risk of harm from the defendant's subsequent negligence may recover for harm caused thereby if, *immediately preceding the harm*,

(a) the plaintiff is unable to avoid it by the exercise of reasonable vigilance and care, and

(b) the defendant is negligent in failing to utilize with reasonable care and competence his then existing opportunity to avoid the harm, when he

(i) knows of the plaintiff's situation and realizes or has reason to realize the peril involved in it or

(ii) would discover the situation and thus have reason to realize the peril, if he were to exercise the vigilance which it is then his duty to the plaintiff to exercise.

§ 480. Last Clear Chance: Inattentive Plaintiff

A plaintiff who, by the exercise of reasonable vigilance, could discover the danger created by the defendant's negligence in time to avoid the harm to him, can recover if, but only if, the defendant

(a) knows of the plaintiff's situation, and

(b) realizes or has reason to realize that the plaintiff is inattentive and therefore unlikely to discover his peril in time to avoid the harm, and

(c) thereafter is negligent in failing to utilize with reasonable care and competence his then existing opportunity to avoid the harm.

4. Negligencia comparativa o concurrencia de culpas / *Comparative Negligence*

4.1. STS, 1ª, 967/2002, de 21 de octubre. Accidente de tráfico por colisión de una motocicleta con un montón de grava y arena

Manuel R.C., propietario de una casa en Gines (Sevilla) situada junto a la carretera a Valencia, estaba realizando obras en su domicilio y había contratado el transporte de grava y arena con "Polvero Manuel Ruiz García, S.A.". El 25.5.1992, sobre las 19:00 h., José G.S., conductor al servicio de la entidad mencionada, descargó un montón de grava y arena de tal forma que ocupaba, sin señalización alguna, 1,25 m de calzada sobre una anchura total de 12,8 m. Cuatro horas después, hacia las 23:00 h., Alberto José L.R., que conducía sin casco una motocicleta a una velocidad superior a la permitida, colisionó con el montón de grava y arena. Como consecuencia del impacto, la motocicleta salió despedida a varios metros y Alberto José L.R. cayó al suelo, lo cual le ocasionó lesiones de gravedad, cuyas secuelas fueron declaradas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social como invalidez permanente en grado de incapacidad permanente.

La víctima demandó a Manuel R.C., a "Polvero Manuel Ruiz García, SA", sociedad encargada del abastecimiento, a José G.S., conductor contratado de la misma, y al Ayuntamiento de Gines y solicitó una indemnización de 362.879,69 € por los daños sufridos.

El JPI nº 18 de Sevilla (27.2.1996) desestimó la demanda y absolvió a todos los demandados por falta de reclamación previa en vía administrativa. El actor interpuso recurso de apelación contra la SJPI, que la SAP Sevilla (Sec. 6ª, 25.11.1996) estimó parcialmente: absolvió a los demandados "Polvero Manuel Ruiz García, S.A." y a José G.S. y condenó solidariamente al Ayuntamiento de

Gines y a Manuel R.C. al pago de una indemnización de 108.863,9 € por los daños sufridos, con fundamento en el art. 1902 CC. Esta cantidad se corresponde con una rebaja del 70% de lo solicitado en la demanda, ponderando el tribunal la concurrencia de culpa del actor. El Ayuntamiento codemandado y el actor, Alberto José L.R., interpusieron sendos recursos de casación contra la SAP.

El TS estimó parcialmente el primero de los recursos y desestimó el segundo. En su sentencia el TS casó el *quantum* indemnizatorio y redujo la indemnización a un 10% de las pretensiones iniciales, es decir, a una cuantía de 38.333,15 €, resultado de ponderar de nuevo la culpa de la víctima en un 90%. Los hechos esenciales que toma el TS a la hora de apreciar la culpa de la víctima en un 90% son (FD B. 2º):

- El montón de grava y arena ocupaba 1,25 m de una calzada de 12,8 m, o lo que es lo mismo, sólo obstaculizaba el 10% del paso.
- El momento de la colisión no circulaba ningún otro vehículo en ninguno de los dos sentidos.
- Había diversas señales que limitaban la velocidad a 30 km/h y que avisaban del peligro de paso de peatones, a las cuales el actor hizo caso omiso circulando a una velocidad superior a la permitida, hecho que viene corroborado porque la motocicleta salió despedida a 29 metros del lugar del accidente.
- El actor no llevaba el casco puesto.

Sin embargo, el TS no exoneró al Ayuntamiento de Gines, pues consideró que éste también incurrió en negligencia por omisión de su deber de cuidado y mantenimiento de las condiciones de seguridad en las carreteras locales por medio de la policía local (art. 10.2 DL 339/1990 y art. 4 de su Reglamento de 7 de enero de 1992). El TS apreció que el tiempo durante el cual el montón de grava y arena estuvo en la carretera había sido más que suficiente para que, en una localidad pequeña, la policía local se percatase del peligro. Por ello establece su culpa en un 10%.

4.2. Antonio FERNÁNDEZ/Víctor M. SÁNCHEZ (2003), "Negligencia Multilateral en Accidente de Motocicleta, ¿cuál es el Estándar Óptimo de Responsabilidad?", *InDret* 3/2003, (www.indret.com), pp. 10-11

"Un mínimo de negligencia es inevitable, ya sea porque la tecnología avanza y el comportamiento antes diligente pasa a ser negligente, porque el agente no es capaz de ajustar su nivel de diligencia al estándar establecido según una persona media o porque el oportunista se aprovecha de su situación.

Además, los jueces tienen serios problemas de información a la hora de precisar los vagos estándares establecidos por la ley. El error judicial se hace patente tanto en la determinación del estándar como en la subsunción de la conducta de cada parte a éste.

Tampoco es del todo cierto que las interacciones sean reiteradas y que los agentes tomen sus decisiones simultáneamente.

> Pongamos un ejemplo: en el ámbito de la ***contributory negligence***, si asumimos que la interacción no es repetida (*one shot game*) y que la víctima ha iniciado el curso causal culposamente, entonces, al no tratarse de acciones simultáneas, el demandado no tendrá

incentivos a evitar el accidente. De ahí la introducción de la cláusula *"last clear chance".* Del mismo modo, con ésta tenemos el problema que la víctima que inicia la acción se puede comportar negligentemente esperando a que el demandado tenga la última oportunidad de evitarla.

Ante todos estos problemas debemos afirmar que los niveles de precaución de cada parte dependen, efectivamente, de la regla que adoptemos. Así, el demandado, bajo una regla de *contributory negligence*, toma niveles más bajos de precaución (Y(CnN)), ya que se verá exonerado de responsabilidad siempre que la víctima haya sido negligente. En el ámbito de la *comparative negligence* su grado de negligencia se verá compensado con el de la víctima, por esto tomará un nivel medio de precaución (Y(CmN)). Y, finalmente, con *simple negligence*, el juez sólo tendrá en cuenta su grado de negligencia, por lo que será más precavido que en los anteriores casos (Y(SN)). Los niveles de precaución del demandado bajo las distintas reglas quedan ordenados de la siguiente manera:

$$Y(CnN) < Y(CmN) < Y(SN)$$

Por contra, la víctima tiene incentivos a comportarse más diligentemente cuando el demandado tiene menos incentivos, debido a que la víctima deberá soportar los costes de los daños no compensados. De esta forma los niveles de precaución de la víctima son:

$$X(SN) < X(CmN) < X(CnN)$$"

4.3. STS, 1ª, 139/2011, de 14 de marzo

El 13 de agosto de 2000 una embarcación a motor conducida por Máximo atropelló a un submarinista, Fermín. El accidente ocurrió en zona rocosa, en línea oblicua al puerto natural y a la playa de l'Estany, a unos 50 metros del espacio de protección de los bañistas establecido por la normativa de aplicación; la velocidad de la embarcación era de 10 nudos (estando el límite de 3 nudos restringido a dicha zona de protección); las condiciones meteorológicas eran de cierta intensidad, con olas de más de un metro de altura; y el submarinista no iba acompañado de la preceptiva embarcación ni llevaba boya de señalización.

El Juzgado de Instrucción n.º 3 de Tortosa condenó al piloto y la AP revocó la SJI y lo absolvió en atención a que las dudas existentes sobre el lugar exacto en que había ocurrido el accidente impedían imputarle un comportamiento negligente.

El perjudicado demandó al piloto de la embarcación, su propietaria (Otilia), y la entidad que aseguraba su responsabilidad civil, Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

El JPI apreció concurrencia de conductas culposas y atribuyó un 25% de responsabilidad a la propia víctima. La AP estimó en parte todos los recursos con revocación de la sentencia recurrida en el sentido de repartir al 50% la responsabilidad.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por la aseguradora y confirmó la SAP:

"Responsabilidad del piloto de la embarcación por omitir la diligencia exigida por las circunstancias.

La jurisprudencia (SSTS de 5 de abril de 2010 (RJ 2010, 4034), RC n.º 449/2005, 11 de septiembre de 2006 (RJ 2006, 8541), 10 de junio de 2006, 6 de septiembre de 2005 (RJ 2005, 6745), 17 de junio de 2003, 10 de diciembre de 2002, 6 de abril de 2000 (RJ 2000, 2508)), no ha llegado al extremo de erigir el riesgo como criterio de responsabilidad con fundamento en el artículo 1902 CC , y ha declarado que la objetivación de la responsabilidad civil no se adecua a los principios que informan su regulación positiva.

Por estas razones la aplicación de la doctrina del riesgo, además de que solo es posible en supuestos de riesgos extraordinarios (riesgo considerablemente anormal en relación a los parámetros medios, SSTS de 18 de julio de 2002 (RJ 2002, 6257), RC n.º 238/1997 y de 21 de mayo de 2009 (RJ 2009, 3030), RC n.º 2005/2004), no implica una responsabilidad objetiva fundada en el resultado o en el propio riesgo creado (que no tiene en encaje en el artículo 1902 CC , como declara, entre otras, la STS de 25 de marzo de 2010 (RJ 2010, 4347), RC n.º 1018/2006), sino que, sin prescindir del elemento esencial de la culpa, a lo más que llega es aceptar la aplicación del principio de la proximidad o facilidad probatoria o una inducción basada en la evidencia a daño desproporcionado o falta de colaboración del causante del daño, cuando éste está especialmente obligado a facilitar la explicación del daño por sus circunstancias profesionales o de otra índole.

De esto se sigue que, al margen de cómo se distribuya la carga de la prueba, la doctrina del riesgo no elimina la necesidad de acreditar la existencia de una acción u omisión culposa a la que se pueda causalmente imputar el resultado lesivo, sin perjuicio, eso sí, de que, en orden a apreciar la concurrencia del elemento subjetivo o culpabilístico, **deba de tenerse en cuenta que un riesgo mayor conlleva un deber de previsión mayor por parte de quien lo crea o aumenta.**

En esta línea se enmarca la STS de 21 de mayo de 2009, RC n.º 2005/2004 . En ella se afirma que ni siquiera la obligatoriedad del aseguramiento determina la presencia de un sistema de responsabilidad civil objetivo puro que permita fundarla exclusivamente en el resultado o en el riesgo creado al margen del elemento culpabilístico, siendo necesario la acreditación de la culpa o negligencia del asegurado, como consecuencia de que el Real Decreto 607/1999 de 16 de abril (RCL 1999, 1091), por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas, reconoce sustentarse en el clásico esquema de responsabilidad civil subjetiva del artículo 1902 CC basado en la concurrencia de culpa o negligencia (el artículo 1 del citado RD dice: "1. El seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria tiene por objeto, en el ámbito y dentro de los límites fijados en el presente Reglamento, de la responsabilidad civil extracontractual en que puedan incurrir los navieros o propietarios de embarcaciones de recreo o deportivas [...] por los daños materiales y personales y por los perjuicios que sean consecuencia de ellos que, mediando culpa o negligencia causen a terceros [...]". Y la "Parte expositiva" del citado RD despeja cualquier duda al respecto al declarar expresamente el acogimiento del sistema tradicional y subjetivo de responsabilidad).

(...)

La AP no se aparta de la doctrina expuesta.

En primer lugar, la sentencia declara probada la relación de causalidad desde el punto de vista físico o fenomenológico, entre la conducta del agente y el resultado, y lo hace a partir de considerar acreditados determinados hechos que ahora no pueden ser desvirtuados (el impacto entre el buceador y el casco de la nave).

En segundo lugar, y desde el punto de vista de la imputación objetiva del resultado lesivo al agente, contrariamente a lo que se sostiene, la responsabilidad del piloto de la embarcación no se hace descansar únicamente en el riesgo creado por la conducción de una embarcación deportiva sino que, con absoluto respeto al sistema tradicional culpabilístico, se asienta en la omisión de la diligencia extrema que cabía exigirle en atención al extraordinario riesgo que

origina quien conduce una embarcación de recreo, superior y completamente ajeno al asumido por la propia víctima con la práctica deportiva…

Ciertamente, quien conduce una embarcación, habida cuenta del específico y extraordinario riesgo creado por su conducción - mayor que el propio de la práctica del submarinismo desde el momento que el deportista asume su propia puesta en peligro mientras que de la conducción de un barco se deriva un peligro para bienes ajenos-, debe agotar la diligencia que le marcan las circunstancias en aras a evitar un accidente con otras embarcaciones o con bañistas.

Por el principio de facilidad probatoria, el cumplimiento de ese deber de diligencia corresponde acreditarlo a quien patronea la embarcación.

En el caso enjuiciado, ese especial deber de diligencia resulta, asimismo, de las disposiciones administrativas sobre la materia, que obligaban a reducir la velocidad en las zonas más próximas a la costa, y especialmente a la playa, en previsión de la presencia de bañistas o nadadores. Pero, contrariamente a lo que se sostiene, no es circunstancia que excluya la posibilidad de imputar el resultado al comportamiento culpable del agente el que la embarcación impactase con la víctima más allá de los límites acotados reglamentariamente para el baño. Consta acreditado que la embarcación circulaba a una velocidad elevada (no menos de diez nudos) y por una zona que, aún fuera de la acotada, seguía encontrándose relativamente próxima a la costa (a una distancia de 100 a 150 metros), donde había calas y playas cercanas, era posible el submarinismo, y en la que, atendiendo al día, hora y época del año (mediodía de un domingo del mes de agosto, época vacacional), resultaba, asimismo, presumible, una notoria afluencia de bañistas. Y en esas circunstancias, y en atención al riesgo generado, el piloto no ha probado la adopción de las especiales medidas de precaución que le eran exigibles para evitar riesgos a la vida e integridad físicas de los bañistas, las cuales no cabe circunscribir a una zona determinada desde el momento que el deber de precaución subsiste desde la puesta en marcha de la embarcación, momento en que el agente desencadena el riesgo, hasta que se detenga, y debe acomodarse en cada momento a las concretas circunstancias que se encuentre durante la conducción" (FD. 3º).

5. Negligencia comparativa modificada

5.1. Cuantitativamente

— **STS, 1ª, 772/2008, de 21 de julio**

La madrugada del 24.2.1996, María Pilar se encontraba en la discoteca "Charlot" de Valladolid cuando el personal estaba realizando las labores de limpieza antes del cierre del local. El camarero Aurelio dejó encima de la barra un envase original de agua mineral, con etiqueta y tapón, que había rellenado de sosa cáustica, y salió del local para tirar la basura. María Pilar bebió del envase y sufrió graves lesiones esofágicas, que precisaron 19 intervenciones quirúrgicas, 1.103 días de incapacidad, gastos por un importe de 6.304,82 €, y de las que derivaron secuelas graves.

María Pilar demanda a Aurelio, a José Luis, propietario de la discoteca, y a su aseguradora, "Seguros A.G.F", y solicita una indemnización de 6.304,82 € por gastos, 53.033,31 € por incapacidad, 300.506,05 € por secuelas físicas, y 90.151,82 € por secuelas psíquicas, con el límite de 150.253,03 € para la aseguradora.

El JPI núm. 2 de Valladolid (9.11.2000) estima en parte la demanda y condena a los demandados al pago de 90.151,82 €. La AP de Valladolid (Sección 1ª, 15.3.2001) estima en parte el recurso de la actora en el sentido de aumentar la indemnización a 209.591,14 €.

El TS desestima el recurso de casación interpuesto por los demandados. El daño fue consecuencia directa y prácticamente exclusiva de la acción de Aurelio. "La mayor entidad de la principal negligencia del demandando Aurelio, absorbe o neutraliza prácticamente, cualquier negligencia levísima que quepa apreciar de la demandante" (FJ 1º).

— **STS, 1ª, 1130/2008, de 12 de diciembre**

La noche del 25.9.1999, Víctor atropelló con su vehículo a un peatón, que se encontraba en la zona de la calzada correspondiente al sentido contrario de circulación al que llevaba el vehículo, y se dio a la fuga. La trayectoria del automóvil era anómala y las circunstancias concurrentes, las fiestas patronales, exigían una circulación prudente. Como consecuencia del atropello, Jaime sufrió lesiones graves que provocaron su hospitalización durante 139 días, secuelas graves determinantes de gran invalidez y perjuicios económicos *(no consta cuantía)*. Con posterioridad, Víctor se suicidó y sus herederos repudiaron la herencia.

Jaime demanda a la aseguradora del vehículo, "Multinacional Aseguradora", y solicita una indemnización *(no consta cuantía).* El JPI núm. 4 de Santiago de Compostela (19.2.2001) condena a la aseguradora a pagar 556.875,27 €. La AP de A Coruña (Sección 6ª, 28.6.2002) estima en parte el recurso interpuesto por la aseguradora y reduce la indemnización a 296.028,03 €, al apreciar la concurrencia de la conducta negligente de la víctima.

El TS estima el recurso de casación interpuesto por Jaime, revoca la SAP y confirma la SJPI. "La negligencia del peatón, consistente en penetrar en la calzada por una parte por la que no era previsible que el vehículo circulase, y en circunstancias que imponían al conductor especiales deberes de precaución, tiene un carácter secundario que impide atribuirle relevancia a los efectos de exonerar al conductor de la imputación del daño producido como ajeno, en todo o en parte, a su responsabilidad objetiva por los riesgos de la circulación" (FD 3º).

5.2. Cualitativamente

— **Art. 21.4 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales**

"Artículo 21. Riesgo grave e inminente.

1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:
a. Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de[l] riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse (…).
b. Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad (…)
c. Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico (…) esté en condiciones (…) de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo (…)
(…)

4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**".

— **Art. 115 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social**

"Artículo 115. Concepto del accidente de trabajo.

1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo (…)

a. Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
b. Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.
c. Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
d. Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
e. Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.
f. Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
g. Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.

3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.

4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la consideración de accidente de trabajo:

a. Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo (…)
b. **Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**".

— Sostienen la imprudencia temeraria del trabajador la STS, 4ª, 22.1.2008 (RJ 2076) -accidente de circulación de trabajador que circulaba en bicicleta en dirección prohibida y colisionó con un vehículo que circulaba correctamente-; y las SSTSJ, Sala de lo Social, País Vasco, Bilbao, 9.2.2010 –la víctima, quien realizaba trabajos en una obra a 8 metros de altura, que no le correspondía realizar, con 2,63 g/l de alcohol en sangre y 0,05 ug/ml de cocaína en sangre, y sin arnés, sufrió un desvanecimiento, cayó al vacío y murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico; Castilla y León, Valladolid, 1274/2010, 21.9.2010 -accidente de circulación de

trabajador por circular con una tasa de alcohol superior en más del doble a la permitida-; Andalucía, Granada, 187/2007, 24.1.2007 -accidente *in itinere* de trabajador que decidió salir de su vivienda por el balcón al encontrarse bloqueada la puerta de entrada; y Andalucía, Málaga, 706/2006, 2.3.2006 -accidente de circulación de trabajador que conducía una motocicleta a velocidad excesiva, haciendo equilibrios en una sola rueda, llevando el casco desabrochado, sin seguro ni permiso de conducir-.

6. Culpa exclusiva de la víctima

Como señalábamos al inicio de esta sesión, los casos en los cuales el tribunal resuelve que los daños fueron imputables sólo al actuar negligente de la víctima cierran el círculo: de la causación bilateral de daños por el demandado y demandante a la auto causación unilateral del daño por el demandante. Véase la STS, 1ª, 44/2010, de 18 de febrero, comentada en la primera de estas sesiones, que resuelve el caso en el que dos menores –de 15 y 16 años respectivamente–viajaban en un ciclomotor de una sola plaza, sin permiso de conducir, y fueron arrollados por un tren en un paso a nivel sin barreras ni semáforos y con una señalización defectuosa.

— Miguel Ángel DE DIOS DE DIOS, *Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación*, La Ley Actualidad, Madrid, 2012.

7. Negligencia imputada / *Imputed Negligence*

¿Puede o, incluso, debe tenerse en cuenta la contribución culposa del padre o guardador del menor a la causación del daño que este sufre para descontarla de la cuota de responsabilidad del demandado? Piénsese en el caso de un conductor que atropella a un niño de cuatro años de edad mientras su padre o madre están distraídamente hablando con un vecino. Muchas jurisdicciones U.S.A. han rechazado tal posibilidad , es decir, se han negado a aplicar la doctrine de la denominada *imputed negligence* (Labier v. Pelletier, 665 A.2d 1013 (Me. 1995) y otros han legislado al efecto, pero surge la pregunta: ¿debe de ser de peor condición el demandado que contribuyó a causar un daño al menor demandante con sus padres o guardadores que aquel que lo hizo con un extraño? ¿Y qué ocurre en un caso en el cual una persona mentalmente discapacitada e internada en un establecimiento psiquiátrico se suicida? ¿Pueden los tribunales imputar parte de la responsabilidad al paciente mismo y reducir en consecuencia la indemnización que hubiera de afrontar el establecimiento por sus fallos de atención (*Limited capacity*)?

Pensemos en dos parejas de casos muy similares. En la primera, una madre descuida por un momento el cuidado de su hijo muy pequeño y este es dañado accidentalmente por un tercero. En tal circunstancia los tribunales acaso podrían dejar de imputar la cuota de contribución materna a la causación del daño y no descontarla de la indemnización que pagará el tercero demandado. Sin embargo, si el niño estaba en una escuela y sus responsables descuidan los cuidados exigibles ningún tribunal dejará de tener en cuenta la responsabilidad de la escuela y del tercero. Parecidamente, en la segunda pareja hipotética de casos. En el primero, el marido de una mujer afectada por una enfermedad neurodegenerativa grave no cierra la puerta de su casa, la enferma sale de ella y sufre un daño causado por un tercero negligentemente. También aquí la negligencia del marido tenderá acaso a ser pasada por alto por los tribunales. Pero

imaginemos que la paciente estaba al cuidado de una residencia especializada, supuesto en el cual la residencia y el tercero responderán claramente por los daños ocasionados. ¿Por qué en el primer grupo de casos la madre y el marido parecen ser de mejor condición que la escuela y la residencia? Una posible respuesta: desde la perspectiva de la disuasión, de la prevención de daños, los familiares suelen ser los interesados en que el hijo y la mujer desvalida no sufran daños, es más, sufren aquello que los penalistas llaman una pena de daño. Y la condena derivada del éxito de la pretensión resarcitoria no les disuade mucho más o sólo lo hace marginalmente. Desde el punto de vista de la compensación, la familia sigue siendo una unidad económica de consumo y las redistribuciones internas de sus miembros no serán realmente compensatorias. Naturalmente, el análisis anterior es perfectamente discutible, pero para esto se han redactado estas sesiones.

Recientemente el Fiscal responsable de seguridad vial ha dado instrucciones a los fiscales para que investiguen en profundidad los accidentes de circulación con resultado de daños a menores que no iban adecuadamente sujetos y ha propuesto que la Fiscalía solicite penas más graves en estos casos (Fiscalía Seguridad Vial, "Seguridad Vial presenta las conclusiones del Proyecto de Investigación sobre accidentes en menores", 5.6.2012; "La Fiscalía de Seguridad Vial plantea que el Fiscal de Menores actúe contra padres multados por no usar 'sillita'", europapress.es**).** ¿Aplicaría sistemáticamente esta directiva a los accidentes domésticos?

— **STS, 1ª, 80/2007, de 26 de enero**

El 30.7.1994, Lucio y Cecilia fueron a visitar el Museo Gaudí anejo al "Templo Expiatorio de la Sagrada Familia" (Barcelona) junto a sus hijos, Lorenzo, de 5 años de edad, y Rocío, también menor de edad. En el museo había expuestas varias esculturas a las que el público podía acercarse e incluso tocar sin que existieran medidas de seguridad o carteles de advertencia que lo impidieran. Una de las obras de la exposición era un conjunto escultórico de varias piezas ensambladas, con estructura asimétrica, de inestabilidad acusada y cuya parte más saliente estaba a una altura de 1,45 m. Lorenzo, de 1,13 m. de altura, se acercó y se colgó de ella. La estatua basculó y las tres piezas superiores del conjunto cedieron y cayeron encima del menor, causándole la muerte por rotura de la base del cráneo.

Lucio y Cecilia, en nombre propio y en representación de Rocío, demandaron a la "Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia" y solicitaron una indemnización a determinar en ejecución de sentencia.

El JPI nº 30 de Barcelona (16.9.1998) estimó la demanda y condenó a la demandada al pago de la indemnización a determinar en ejecución de sentencia. La AP Barcelona (Sección 16ª, 22.10.1999) estimó en parte el recurso de apelación interpuesto por la "Junta Constructora", revocó la sentencia de instancia, apreció concurrencia de culpas de los padres, y condenó a la demandada al pago de 40.067,47 € para cada uno de los padres y 12.020,24 € para la hermana en concepto de daño moral, así como 3.400,27 € en concepto de daños materiales por los gastos del sepelio.

El TS estimó el recurso de casación interpuesto por Lucio y Cecilia, revocó en parte la sentencia de apelación y condenó a la "Junta Constructora" al pago de 60.101,21 € a cada progenitor y 18.030,63 € a la hermana en concepto de daño moral, más 5.100,41 € en concepto de daños materiales:

"[N]o puede admitirse la relevancia causal que la SAP aprecia en la conducta de los padres del menor, pues no contribuyó eficazmente a la producción del daño (…). [A]ún cuando el menor se encontrara sometido a la más estrecha vigilancia de sus padres, no quedaba excluida la causación del accidente" (FD 3º).

— **STS, 1ª, 144/2007, de 7 de febrero**

El 23.10.1991, Jorge, de 9 años, subió a jugar a la azotea del edificio en compañía de otros dos menores, de 4 y 7 años. Jorge, con la intención de coger una pelota, subió por una escalerilla a un tejado en que había placas solares y depósitos de agua. Una vez arriba, perdió el equilibrio y agarró con la mano izquierda un cable eléctrico conductor de baja tensión, lo que provocó una fuerte descarga que le lanzó sobre otra terraza. María Juana, de 16 años, acudió a socorrer a su hermano y recibió otra descarga eléctrica. A consecuencia de las descargas, ambos menores sufrieron lesiones traumáticas y quemaduras, siendo las de Jorge de mayor gravedad. El cable, sin revestimiento aislante, se encontraba a una altura de 1,40 m, 10 cm inferior a la establecida en el Real Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

María Juana, en su nombre, y Claudio y Ángela, en representación de su hijo menor Jorge, demandan a "Iberdrola, S.A.", y solicitaron una indemnización de 81.708,38 €.

El JPI nº 1 de Sueca (10.10.1998) estimó en parte la demanda y condenó a pagar 7.422,5 € a María Juana y 10.553,77 € a los padres, como representantes del menor. La AP de Valencia (Sección 6ª, 1.6.1999) desestimó el recurso de apelación de la demandada y estimó el de los demandantes en el sentido de aumentar la indemnización de Jorge a 13.540,8 €. La AP mantuvo la proporción del 50% de culpa para cada una de las partes.

El TS desestimó el recurso de casación de "Iberdrola, S.A.", en cuyo primer motivo sostenía la culpa exclusiva de los padres de las víctimas:

"[L]a Audiencia en este caso lleg[a] a la conclusión de no considerar acreditado que la puerta de acceso a la terraza del edificio estuviera cerrada con llave y se facilitara por los padres el acceso a la terraza del menor accidentado… [N]o cabe dudar del incumplimiento por la Compañía eléctrica instaladora, responsable del cuidado y mantenimiento de la instalación, de la normativa administrativa en cuanto a la altura del cable conductor de corriente…, que después del accidente fue revestido de protección, sin que hubiera advertencia alguna del peligro que la instalación representaba" (FD. 2º).

8. Seguridad pasiva de automóviles (*Crashworthiness*)

Con frecuencia, se plantea la cuestión sobre si se aplica la regla de la compensación de culpas en los casos en los cuales el demandante, conductor de un vehículo a motor, se causa a sí mismo un daño con su propia negligencia, pero, inmediatamente y a continuación, el daño sufrido se agrava como consecuencia de un defecto en la seguridad del vehículo que conducía. Los tribunales españoles analizan esta cuestión desde el punto de vista de la causalidad y son muy estrictos con la deficiencia de su prueba. En el *Common Law* americano la doctrina dominante permite la aplicación de los criterios generales sobre culpa comparativa pero una doctrina minoritaria aunque influyente niega tal posibilidad y ciñe la cuestión a los daños específicamente causados por el defecto de seguridad del producto en la segunda colisión.

8.1. D'Amario v. Ford Motor Co. [806 So. 2d 424 (Fla. 2001)]

We have for review the decision in *Ford Motor Co. v. D'Amario,* 732 So.2d 1143 (Fla. 2d DCA 1999) (...) on the issue of whether principles of comparative fault apply in a crashworthiness case. We hold that principles of comparative fault concerning apportionment of fault as to the cause of the underlying crash will not ordinarily apply in crashworthiness or enhanced injury cases. Because the manufacturer alleged to be responsible for a defective product that results in a second accident and injury ordinarily may not be held liable for the injuries caused by the initial accident, the fault of the manufacturer may not be compared or apportioned with the fault of the driver of the vehicle who allegedly caused the initial crash.

SECONDARY INJURY CASES

[S]uch cases, which are also often referred to as "secondary collision" or "enhanced injury" cases, involve both an initial accident and a subsequent or secondary collision caused by an alleged defective condition created by a manufacturer, which is unrelated to the cause of the initial accident but which causes additional and distinct injuries beyond those suffered in the primary collision. One court has explained that the damages sought in such cases "are not for injuries sustained in the original collision but for those sustained in the second impact where some design defect caused an exacerbated injury which would not have otherwise occurred as a result of the original collision." *Meekins v. Ford Motor Co.,* 699 A.2d 339, 341 (Del.Super.Ct.1997) (...)

Florida adopted the principle of *Larsen* in *Ford Motor Co. v. Evancho,* 327 So.2d 201, 202 (Fla.1976), wherein we declared: "We hold that a manufacturer of automobiles may be held liable under certain conditions for a design or manufacturing defect which causes injury but is not the cause of the primary collision." (...) However, while the crashworthiness doctrine is now well established in this state, it is not entirely clear whether or how the principles of comparative fault should apply in such cases. That is the issue presented in the two cases before us today (...)

In *D'Amario,* Clifford Harris, a minor, was injured when the car in which he was riding as a passenger collided with a tree and then burst into flames. The car was driven by a friend of Harris who was allegedly intoxicated and speeding at the time of the accident. Harris, and his mother, Karen D'Amario, sued Ford alleging that a defective relay switch in the automobile caused Harris's injuries (...)

Prior to jury selection, the plaintiffs moved to exclude evidence about the driver's alcohol consumption on the day of the accident and the trial court ruled that evidence of the driver's alcohol consumption would be excluded. The court reasoned that the acts leading up to the collision were not at issue, rather, the issue as to Ford's liability concerned events occurring after the initial collision with the tree. However, at trial, Ford moved to amend its affirmative defenses to include an allegation that Harris's injuries were caused by the fault of a third party, and proffered evidence of the driver's intoxication and excessive speed. The trial court granted Ford's request and held that an apportionment defense was available and evidence of the driver's actions in causing the initial accident could be admitted in support of such defense. In the face of such ruling, the parties stipulated to the jury that the negligent and excessive speed

of the driver caused the initial accident and that at the time the driver had a blood alcohol level of .14 percent.

Following deliberations, the jury returned a verdict for the defense, finding that Ford was not a legal cause of the injuries to Harris. Because the jury found for the defense, it did not reach the question on the interrogatory verdict form as to the driver's comparative negligence. D'Amario subsequently moved for a new trial, alleging that the court erred in permitting evidence of the driver's intoxication to go to the jury (...)

ANALYSIS

(...)

Under what has been characterized by *Whitehead v. Toyota Motor Corp.,* 897 S.W.2d 684 (Tenn.1995), as the "majority view," the fault of the plaintiff or a third party in causing the initial accident is recognized as a defense to a crashworthiness case against a product manufacturer (...)

In *Meekins v. Ford Motor Co.,* a Delaware trial judge set out a comprehensive analysis discussing the arguments on both sides of the issue, before ultimately concluding that principles of comparative fault should apply in enhanced injury cases. First, the court reasoned that while some cases may present a clear factual delineation between primary injuries and secondary injuries, whereby the driver's comparative fault should be excluded from consideration, most cases do not (...) Second, the court was concerned that a rule excluding consideration of the plaintiff driver's fault in causing an accident would logically extend to prevent the plaintiff from suing a negligent third party who caused the accident, and thereby run counter to well-established principles of tort law (...)

Another logical hurdle inherent in plaintiff's position is this. If a plaintiff negligently crashes his vehicle into a tree and suffers an enhanced injury because of a design defect in his car, plaintiff says that the manufacturer is liable for the enhanced injury regardless of the plaintiff's negligence in causing the collision. But what if a plaintiff collides with another vehicle and the driver of that vehicle is negligent? (...)

Finally, the court noted that the rule concerning proximate causation should be no different in enhanced injury cases than that applied in ordinary negligence cases

The Minority View

[T]he "minority" view, rejecting the application of comparative fault principles, focuses on the underlying rationale for imposing liability against automobile manufacturers for secondary injuries caused by a design defect. The federal district court in *Jimenez v. Chrysler Corp.,* 74 F.Supp.2d 548 (D.S.C.1999), *reversed in part and vacated,* 269 F.3d 439 (4th Cir. 2001), explained the essential rationale of the minority view:

The crashworthiness doctrine imposes liability on automobile manufacturers for design defects that enhance, rather than cause, injuries (...)The issue for purposes of a crashworthiness case, therefore, is enhancement of injuries, not the precipitating cause of the collision (...) [T]he concept of "enhanced injury" effectively apportions fault and damages on a comparative basis; defendant is liable only for the increased injury caused by its own conduct, not for the injury resulting from the crash itself

[E]vidence of the plaintiff's intoxication and excessive speed is not admissible in a crashworthiness case against a vehicle manufacturer (…)

CONCLUSION

In sum, we hold that principles of comparative fault involving the causes of the first collision do not generally apply in crashworthiness cases. Such a rule, we believe, recognizes the important distinction between fault in causing the accident and fault in causing additional or enhanced injuries as a result of a product defect, a distinction that defines and limits a manufacturer's liability in crashworthiness cases. In such cases, the automobile manufacturer is solely responsible for the enhanced injuries to the extent the plaintiff demonstrates the existence of a defective condition and that the defect proximately caused the enhanced injuries. Thus, an automobile manufacturer who allegedly designed a defective product may not be held liable for damages caused by the initial collision and may not apportion its fault with the fault of the driver of the vehicle who caused the initial accident.

We believe this rule will ensure both fairness in the apportionment of damages and that the jury will not be unduly confused about the issues in the case, especially in cases like those before us today, where both accidents involved drinking and driving. Because the initial collision is presumed in crashworthiness cases, the jury's focus in such cases should be on whether a defect existed and whether such defect proximately caused the enhanced injuries. Unfortunately, in the consolidated cases, the juries' focus was shifted to the conduct of the intoxicated drivers who caused the initial accidents. In light of the confusion caused by the introduction of accident-causing fault and the improper focus placed on the non-party drivers' intoxication in each case, we conclude that both the estate and D'Amario are entitled to a new trial.

Because we are holding that it was error for the trial court to permit evidence of a non-party's fault in causing the accident, D'Amario's related claim that the trial court erred in permitting Ford to amend its pleadings to include a non-party apportionment defense is moot. Accordingly, we offer no opinion on this issue. Similarly, the other issues discussed in the district court opinions are rendered moot by our holding and we decline to address them.

Accordingly, we quash the Second District's decision in *D'Amario* and approve the Third District's decision in *Nash* to the extent it is consistent with this opinion. We further disapprove the opinion in *Kidron* to the extent it is inconsistent with our holding herein.

It is so ordered.

8.2. STS, 1ª, 1071/2008, de 7 de noviembre (D. Ángel Daniel c. Citröen Hispania, S.A.)

En el caso se discutió si la negligencia del demandante podía tenerse en cuenta para compensar parte de los daños sufridos por defecto de producto. El demandado alegaba que el actor había contribuido negligentemente a causar el daño, pero no aportaba prueba concreta alguna sobre la contribución causal de la conducta negligente del actor a la producción del daño. La respuesta –correcta– del Tribunal fue negativa: negligencia y causalidad se diferencian básicamente en que la primera es infracción de un deber de cuidado y la segunda, producción de un resultado material.

D. Ángel Daniel interpuso demanda contra Citroën Hispania, S.A. fundamentada en que el 12 de mayo de 1998 sufrió un accidente de circulación cuando conducía un vehículo marca Citroën ZX, sin que se activara su airbag. El actor, que sufrió lesiones personales en el accidente, reclamaba, entre otras cosas, una indemnización de 181.000 euros.

La SJPI nº 1 de Santa Coloma de Farners (Barcelona) tuvo por probado el defecto de producto, pues, dadas las circunstancias del accidente, el airbag debería haberse accionado y no lo había hecho. "[E]llo determinó que el demandante (…) sufriera las lesiones que padeció o, cuando menos, que éstas fueran más graves que las eventualmente resultantes de haber funcionado adecuadamente el airbag." Mas, la SJPI también afirmó que "el Sr. Ángel Daniel circulaba sin el cinturón de seguridad, con lo que aumentó notablemente su desprotección (…). [L]a imprudente conducta del Sr. Ángel Daniel, que fue la desencadenante del siniestro, y el hecho de que no llevara puesto el cinturón de seguridad, son circunstancias que, unidas a la ausencia de funcionamiento del airbag, contribuyeron a la producción o agravación de las lesiones del Sr. Ángel Daniel. Por ello, estimando parcialmente la demanda, aplicó una disminución del 40% a la indemnización solicitada dejándola en 37.261.660 ptas (223.947,09 euros)" (STS, FD 1º).

La cuestión así planteada es clásica en el análisis de la responsabilidad de producto y, usualmente se formula del modo siguiente: ¿puede el demandado alegar el principio de compensación de culpas o de causas (*comparative fault*) cuando la conducta de la víctima causó inicialmente el accidente, pero los daños se agravaron por la condición defectuosa del producto? Al respecto, el Common Law norteamericano sigue dos orientaciones distintas y contrapuestas:

a) La tendencia mayoritaria reconoce la posibilidad de que el demandado alegue la culpa comparativa o contribución de la culpa del demandante a la causación inicial del accidente, cuyas consecuencias se ven luego agravadas por la colisión o accidente secundarios debidos al defecto probado del producto. Nada impide, en sede de responsabilidad de producto, tener en cuenta la doctrina general de la culpa comparativa y, además, excluir tal posibilidad, suele decirse, impediría lógicamente al mismo demandante accionar contra un tercero cocausante del daño.

b) La tendencia minoritaria rechaza la opinión anterior, y con ella, la posibilidad de alegar con éxito la contribución causal de la negligencia del actor a la producción del daño cuando éste además resultó agravado por el defecto del producto. La razón, de ser tal, consistiría en que la culpa del demandante en la causación del accidente no es relevante en relación con la cuestión de si el demandado fabricó o no un producto defectuoso, y no lo sería por constituir sólo una causa remota del daño finalmente sufrido. Habría falta de previsibilidad (*foreseeability*) y no concurriría la causalidad adecuada (*proximate causation*).

La mayor parte de los casos de seguridad pasiva o *crashworthiness* se relacionan con demandantes que conducían su vehículo bajo la influencia del alcohol o de otras sustancias químicas, que superaban los límites de velocidad permitidos o que no llevaban puesto el cinturón de seguridad. HENDERSON y TWERSKI preguntan entonces retóricamente al lector:

"¿Es acaso previsible para un conductor ebrio que causa un accidente y lesiona a un tercero que el automóvil con el cual colisiona estuviera defectuosamente diseñado? (…) ¿Hay algún tribunal

en el mundo que dejaría a un conductor rico y ebrio libre de toda responsabilidad porque su conducta negligente no fue una causa próxima a las agravadas lesiones de su víctima?" (p. 508).

Retomando el caso, la SAP Girona, Secc. 2ª, 2 de mayo de 2002, estimó parcialmente las apelaciones formuladas por ambas partes fijando la indemnización que Citroën Hispania, S.A. debía abonar al Sr. Ángel Daniel en 21.371.586 ptas. (128.445,82 euros) más intereses, sin expresa imposición de costas. La Audiencia estimó en parte el recurso de apelación de la actora considerando que no resultaba procedente la compensación de culpas del artículo 9 de la Ley 22/1994 (hoy artículo 145 TRLCU), conforme al cual: "La responsabilidad prevista en este capítulo podrá reducirse o suprimirse en función de las circunstancias del caso, si el daño causado fuera debido conjuntamente a un defecto del producto y a culpa del perjudicado o de una persona de la que éste deba responder civilmente." Para la Audiencia "debe valorarse (…) qué daños fueron consecuencia del defectuoso funcionamiento del sistema del airbag y si en ese fallo de funcionamiento tuvo alguna culpa el perjudicado" (STS, FD 1º).

Admitido solo el recurso de casación interpuesto por Citroën Hispania S. A. y basado fundamentalmente en la aplicación indebida del artículo 9 de la ley mencionada, la parte recurrente censuraba que "la sentencia impugnada rechaza valorar (…) que el ocupante del turismo, conductor del mismo, produjo el accidente por su forma de conducir, y conllevó al accidente por los siguientes motivos complementarios: no utilizar la pinza del cinturón de seguridad o no llevar el mismo" (STS, FD 2º).

La STS, 1ª, 1071/2008, de 7 de noviembre, resolvió las cuestiones planteadas sin seguir la antes mencionada orientación mayoritaria de la doctrina de la seguridad pasiva o *crashworthiness doctrine*. Así, se acercó a la tesis minoritaria según la cual hay que rechazar la contribución negligente del demandante a la causación de los daños por lo menos cuando aquella no se proyecta específicamente sobre la anomalía de funcionamiento del producto en que consiste su defecto:

"[H]a de considerarse que la función del airbag es factor moderador del quantum de la responsabilidad. A tal respecto, ha de considerarse que la función del airbag es proteger al ocupante del vehículo para el caso en que se produzca un accidente, con independencia de si éste se debe, o no, a una conducción inadecuada o negligente. La responsabilidad civil radica en el mal funcionamiento, o la falta de funcionamiento, del producto defectuoso, del airbag, llamado a la protección física del sujeto para el caso de accidente, y sólo en el caso de que la anomalía de funcionamiento se debiese a la intervención del sujeto dañado, como si manipula o daña el producto o de algún otro modo resta su eficacia, incide en ella, o la hace desaparecer, debe minorarse o incluso suprimirse la responsabilidad civil del fabricante. En consecuencia es acertado el criterio de la Audiencia" (FD 2º).

La razón por la cual la contribución de la negligencia del demandante a la causación del daño es importante consiste en considerar en cada caso hasta qué punto cada una de las partes estaba en mejores condiciones que la otra de evitar el accidente o reducir su probabilidad o gravedad. Dado lo anterior, resulta opinable la decisión del tribunal, según la cual sólo hay que atender a la negligencia del demandante cuando sus consecuencias se proyectaron exclusivamente sobre el defecto del producto, en el caso la falta de funcionamiento del airbag. En mejor doctrina se trataría, en cambio, de distribuir las cargas sobre quienes estuvieran en mejores condiciones de sobrellevarlas y es notorio que la carga de abrocharse el cinturón de seguridad es muy liviana

así como que las consecuencias de no hacerlo normalmente son muy perjudiciales para las potenciales víctimas.

En todo caso, la STS ofrece una segunda razón por la cual no hay que tener en cuenta la clara negligencia del conductor:

"[E]n la hipótesis que nos ocupa no existe prueba de que ello sea así, es decir, de que determinadas lesiones se hayan producido o agravado por la falta de uso del cinturón de seguridad. Ni siquiera puede hablarse de prueba notoria, pues en ningún momento se informa pericialmente en pos de la notoriedad, siendo por otra parte obvio que el airbag no funcionó, que el actor sufrió determinadas lesiones, y que el airbag pudo disminuirlas en un 40%, lo que no pudo ocurrir dada su injustificada falta de funcionamiento, reveladora de defecto en el mismo. En consecuencia, está probado el defecto del producto, del daño y relación causal, prueba que incumbe al actor (artículo 5 de la Ley 22/1994), sin que se haya probado que la falta de uso del cinturón de seguridad supusiera producción o agravación de las sesiones sufridas, extremos cuya prueba correspondía a la parte demandada. Consecuentemente ha de confirmarse el fallo de la sentencia impugnada" (FD 2º).

A ello sólo cabría objetar que el uso del cinturón de seguridad es obligatorio porque estadísticamente las consecuencias de su utilización están abrumadoramente documentadas, salvo en aquellos casos en los que, por las condiciones del usuario, debe omitirse su utilización. En cualquier caso la diferencia entre actuar negligentemente, causar daños y atribuir la carga de la prueba de la causalidad al reclamante son razones de mucho peso.

8.3. SAP Barcelona, Secc. 16ª, 43/2009, de 29 de enero

Para casos similares, véanse las SSAP Asturias, Secc. 6ª, 205/2007, de 21 de mayo, y León, Secc. 1ª, 203/2008, de 23 de mayo.

El 15 de agosto de 2001 a las 4:00 horas, Pedro Francisco murió a causa de un accidente de circulación en un camino parcelario entre Santa Cecilia y Villar de Maya (término municipal de Bretún, Soria) al salirse de la calzada el todo terreno que conducía.

Sus padres, Fermín y Carolina, interpusieron demanda contra el importador del vehículo, Isuzu Ibérica, S.A., reclamando una indemnización por daño moral derivado del fallecimiento de Pedro Francisco, por entender que la muerte de su hijo derivó del defecto de funcionamiento del airbag de que estaba dotado el vehículo y que no llegó a accionarse en el momento del siniestro.

La SJPI nº 28 de Barcelona de 1 de junio de 2007 desestimó la demanda. Los padres de Pedro Francisco presentaron recurso de apelación manteniendo su pretensión inicial.

La SAP Barcelona, Secc. 16ª, 43/2009, de 29 de enero, desestimó el recurso de apelación basándose en dos argumentos:

En primer lugar, la Audiencia llega "a la conclusión de que es dudosa (no estaría suficientemente acreditada) la relación de causalidad entre el alegado defecto del producto y el resultado, cuando la falta de utilización del cinturón propia y de la pasajera, unido al exceso de velocidad, constituyen causa adecuada y suficiente para explicar lo sucedido con independencia

de que el airbag tuviera, o no, que haberse disparado. Este tema es rehuido expresamente en el recurso y consideramos que tiene relevancia directa en lo enjuiciado, no sólo por la obligada valoración de la culpa del perjudicado prevista en el art. 9 de la Ley de responsabilidad civil por producto defectuoso que permite llegar hasta la exoneración de responsabilidad del fabricante (o importador en este caso), sino que podría representar una causalidad adecuada en la producción del resultado que deshabilitaría la propia aplicación del art. 5 de dicha ley en relación al funcionamiento del airbag" (FD 2º).

Y, por otro lado, la SAP también defiende la desestimación del recurso en base a que "no estamos ante un impacto frontal ni "casi frontal" que indica el manual [relativo al funcionamiento del airbag] sino más bien angular, con un ángulo respecto del eje del vehículo que según un perito debería provocar la activación del mismo para la más efectiva cobertura pero que según otros peritos y lo observado en literatura no es una dirección de fuerza apropiada para la activación del airbag frontal. En tales circunstancias, no cabe sino concluir con el Juzgado de Primera Instancia que no podemos afirmar se haya probado un real defecto en el funcionamiento del airbag objeto del litigio" (FD 3º).

Capítulo 7º
Causalidad de hecho

1. Causalidad / *Causation* **121**
1.1. Causalidad y omisión 122
1.2. Causalidad múltiple 124
1.3. Causalidad indeterminada 125
2. Causalidad genérica y específica / *Generic Causation and Specific Causation* **127**
3. Causalidad alternativa / *Alternative Causation* **127**
3.1. *Summers v. Tice* (33 Cal. 2d 80, 199 P.2d 1 (1948)) 127
3.2. *Ybarra v. Spangard* (*25 Cal.2d 486, 154 P.2d 687*) 129
3.3. STS, 1ª, 708/2011, de 18 de octubre 129
4. Causalidad concurrente / *Concurrent Causation* **130**
4.1. *Kingston v. Chicago Ry.* (191 Wis. 610, 211 N.W. 913 (1927)) 130
4.2. STS, 1ª, 816/2011, de 6 de febrero de 2012 132
4.3. STS, 1ª, 425/2009, de 4 de junio 133
4.4. STS, 1ª, 485/2008, de 28 de mayo 134
4.5. *Dillon v. Twin State* (85 N.H. 449, 163 A. 111 (1932)) 135
5. Causalidad sucesiva / *Succesive Causation* **138**
5.1. BGH NJW 1952, 1010 138
5.2. *Baker v. Willoughby* ([1970] 2 W.L.R. 50) 138
5.3. STS, 1ª, 461/2003, de 8 de mayo: fractura de rodilla en accidente de esquí y responsabilidad civil médico-sanitaria. 138
6. Causalidad probabilística / *Probabilistic Causation* **139**

1. Causalidad / *Causation*

Causa, para los juristas, es *conditio sine qua non*, limitada normativamente por criterios de adecuación social. Es el "But-for Test". Es decir, la "conditio sine qua non", modulada por la apreciación social dominante –pero muy cambiante— sobre cuáles son los roles sociales que determinan, para cada constelación de conductas peligrosas, las personas u organizaciones a cuyo cargo se ponen los riesgos generados.

La causalidad es, primariamente, una cuestión empírica y responde a la pregunta sobre por qué se produjo el daño, cuál fue su explicación científica, técnica o científico social.

La modulación o limitación normativa de la causalidad --en inglés *scope of liability* (antes: *proximate causation*); y en alemán, *objektive Zurechnungslehre*-- trata de evitar hacer responder a los padres por los actos de sus hijos o a los nietos por los de sus abuelos, aunque, como ambos ejemplos sugieren, la respuesta es frecuentemente muy difícil. Intuitivamente, los bomberos y las autoridades que los gobiernan están más directamente incumbidos en la tarea de atajar incendios que los ciudadanos en general; los policías lo están en las de prevenir y evitar delitos; los padres en las de velar por que sus hijos *menores de edad* no causen daños a terceros, etc. Si la pregunta es a quién incumbe prevenir accidentes, el test más fecundo para responderla es filtrar el análisis con la consideración de que si todos hemos de responder por todo, no hay división del trabajo posible, ni por tanto, desarrollo tecnológico.

Así, la causalidad es el territorio de los expertos, de los peritos. La imputación objetiva, de la legislación, la jurisprudencia, las propuestas razonadas de los letrados de las partes que ponen

de manifiesto las razones y consecuencias de poner a cargo de alguien o de alguna organización tales o cuales conductas peligrosas.

El Restatement (Third) of Torts ofrece un buen marco analítico a la doble cuestión de la causalidad y de su acotación por el derecho.

§ 26 RTT Factual cause

Tortious conduct must be a factual cause of harm for liability to be imposed. Conduct is a factual cause of harm when the harm would not have occurred absent the conduct. Tortious conduct may also be a factual cause of harm under § 27.

§ 29. Limitations On Liability For Tortious Conduct

An actor's liability is limited to those harms that result from the risks that made the actor´s conduct tortious.

— Pablo SALVADOR CODERCH/Antonio FERNÁNDEZ CRENDE, "Causalidad y Responsabilidad", 3ª ed., *InDret* 1/2006 (www.indret.com), págs. 3-7:

"En una primera aproximación, la causalidad, entendida como causalidad de hecho, se determina por mediación del criterio de la *conditio sine qua non* (*but-for test*): hay causalidad cuando el daño no hubiera ocurrido de no haberse realizado la conducta, por acción u omisión, del demandado.

> El problema práctico de este test radica en su naturaleza contrafactual. Requiere que el tribunal determine una causalidad hipotética: ¿qué habría ocurrido si el demandado no hubiera actuado como lo hizo? ¿Qué habría ocurrido de no omitir la conducta que se esperaba de él? Estas preguntas plantean serios problemas de prueba *("it is impossible to go back to the moment before the accident, «remove» the negligence of the defendant, and see what would have happened"* (ABRAHAM (2002), p. 101). El concepto de acción supone la causación de efectos y el de omisión, su ausencia, pero siempre que hacemos algo evitamos algo (lo que habría ocurrido si no hubiéramos hecho nada) y omitimos algo (lo que habríamos podido hacer pero no hemos hecho). Véase, MOSTERÍN (1987, p. 141)".

1.1. Causalidad y omisión

La primera cuestión que se plantea es si podemos hablar de causalidad en la omisión. Filosóficamente, hay muchos trucos para rodear el problema de la causalidad en la omisión. Véase el siguiente que tomamos de la obra citada de DÍEZ/MOULINES (1998, p. 253): hay causas "propiciativas" (*contributing*), que contribuyen positivamente a la ocurrencia del efecto, y "resistivas" (*counteracting*), que contribuyen a su no ocurrencia: fumar es causa propiciativa de cáncer de pulmón, mientras que hacer ejercicio es una causa resistiva. Este carácter no es absoluto, pues puede alterarse en presencia de otras causas: la arena es causa propiciativa de accidentes de carretera, pero en presencia de hielo es causa resistiva.

La mayor parte de los casos de responsabilidad civil son pecados de falta de control o de vigilancia de hechos ajenos: la actuación descuidada del dependiente es causa propiciativa de daños; el control o vigilancia por parte del empresario es causa resistiva (véase art. 1903 CC). Por tanto, la omisión de este control o vigilancia remueve una causa resistiva y, en este sentido, podemos afirmar que, en cierto modo, está contribuyendo a la producción del daño.

La idea es que si el patrono y el empleado solvente, en el supuesto arquetípico, pudieran contratar libremente, entonces la existencia o inexistencia de un sistema de responsabilidad por el hecho ajeno no sería relevante. En la práctica lo es y mucho porque: i) la víctima sabe qué empresa le causó daños, pero no cuál de sus empleados; ii) los empleados suelen ser escasamente solventes; iii) en ausencia de responsabilidad, el patrono contrataría a los más insolventes (*judgement proof defendants*); iv) hay muchos costes de negociación entre patronos y obreros. Para un análisis más extenso de este problema, véase SALVADOR/ GÓMEZ (2002).

> En España, la mayor parte de los recursos de casación resueltos por sentencia del Tribunal Supremo son casos de responsabilidad por omisión en la vigilancia o control de los hechos de otro. Así, en el caso Aznalcóllar resuelto por la **STS, 3ª, de 22 de noviembre de 2004**, la rotura de un dique de contención de una balsa de residuos mineros había producido el vertido de su contenido en un afluente del río Guadalquivir, el Guadiamar, cuyo cauce fue invadido por lodos contaminantes que dañaron la flora y la fauna del sistema hídrico. La balsa de residuos mineros era propiedad de Boliden Apirsa, SL, que, en marzo de 1996, había encargado el recrecimiento del dique de la balsa a Geocisa, SA que, a su vez, había asumido el control de la instalación. El Tribunal Supremo confirmó en lo sustancial el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2.8.2002 en cuya virtud, conforme a los arts. 89, 108 f) y g) y 110.1 de la Ley 29/1985, de Aguas, había sancionado a Boliden Apirsa, SL con una multa de 601.012,1 € y le había condenado al pago de 2.870.181,66 € por los daños al dominio público hidráulico y a abonar 41.606.316,75 € por los gastos originados por la reposición del terreno al estado anterior a los hechos. Entre otros argumentos, el Tribunal Supremo fundamenta su decisión en clave de omisión: "*A Boliden Apirsa, S.L., le era exigible, como titular de la explotación minera el deber de mantener la balsa en las adecuadas condiciones de seguridad y la omisión de ese deber comporta ese elemento de culpabilidad que la Administración ha tenido en cuenta al dictar el acuerdo de que trae causa este proceso. [...] A Boliden Apirsa, S.L., le es imputable la culpa en la elección de esa empresa [Geocisa] y la culpa por no haberse implicado más directamente en la vigilancia de unos instrumentos de control creados para mantener la seguridad en una situación de riesgo creada por ella en el ejercicio de su actividad*" (FD 11º).
>
> Carlos GÓMEZ LIGÜERRE, "Quien contamina paga ... si alguna jurisdicción es competente para condenarlo. Conflictos de jurisdicción en el caso Boliden", *InDret 2/2012*, pp. 6-7:
>
> "Boliden demandó ante la jurisdicción civil a las empresas 'Intecsa-Inarsa', diseñadora de la balsa, 'ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S. A.', ejecutora del proyecto de construcción, y 'Geotecnia y Cimientos, S. A.', encargada del mantenimiento de la balsa desde el año 1996 y ejecutora del proyecto de ampliación de la escombrera, así como a 'Banco Vitalicio', compañía aseguradora de 'ACS' y de 'Geotecnia'. La demanda solicitaba la condena solidaria de todos ellos al pago de 115.213.210 euros, por los incumplimientos de los respectivos contratos, para reembolsar a Boliden las cantidades a las que le había condenado el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2002 [sanción de 601.012,1 euros, el importe más elevado que el artículo 109 de la Ley de Aguas vigente en el momento del accidente permitía imponer por la comisión de una infracción muy grave; obligación de pago de una indemnización de 2.870.181,66 euros, por los daños causados al dominio público hidráulico; obligación de abonar 41.606.361,75 euros, por los gastos de reposición de la zona afectada a la situación anterior a la catástrofe]" [y] en previsión del pago [de] otras entidades [que]

en concreto la Junta de Andalucía pudier[a] reclamar de Boliden como consecuencia del accidente".

[La] "**STS, 1ª, [963/2011], 11.1.2012** (…) ha confirmado las sentencias desestimatorias de las instancias y ha declarado no haber lugar al recurso de casación por infracción procesal interpuesto por Boliden. Para la jurisdicción civil (…) de igual modo que para la jurisdicción contencioso-administrativa, no hay otro responsable del desastre que Boliden, empresa explotadora de la mina:

"La [sentencia] de primera instancia tuvo muy en cuenta el informe de los peritos presentado en las diligencias previas penales, si bien interpretándolo en un sentido no totalmente coincidente con el propuesto por la demandante hoy recurrente y, desde luego, poniéndolo en relación, mediante una muy meritoria labor de la magistrada-juez, con todas las demás pruebas practicadas en el proceso civil, llegando así a la conclusión de que no hubo incumplimiento contractual de las demandadas y sí, en cambio, participación relevante de la propia Boliden, por medio de un representante suyo técnicamente cualificado, en el proyecto que ella misma considera defectuoso, así como actuaciones propias de Boliden la balsa que pudieron contribuir a la rotura más relevantemente que cualesquiera cálculos erróneos sobre el comportamiento de las llamadas margas azules del Guadalquivir" (FD. 9º).

La responsabilidad exclusiva de Boliden ha venido confirmada, de hecho, por las decisiones de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que han confirmado la ausencia de responsabilidad de la Administración por el funcionamiento anormal de los servicios de inspección y control de las instalaciones de la mina en los procesos de responsabilidad patrimonial iniciados por diversas empresas y entidades afectadas por los vertidos tóxicos. Así, entre otras, las SSTS, 3ª, 29.9.2012 (RJ 6865), 12.12.2011 (RJ 2012\2672), 6.3.2012 (JUR 101985), 13.3.2012 (JUR 130360) todas ellas confirmatorias de la declaración de ausencia de responsabilidad de la Administración.

Obsérvese que, en la omisión, la ley establece un deber de actuar que el obligado incumplió: no hay causalidad sino incumplimiento de un deber (*breach of duty*), como en la negligencia.

En cualquier caso, la causalidad de hecho, ya sea por acción u omisión, es un mal criterio de imputación de daños, pues plantea una infinidad de problemas en casos de causación múltiple y causación indeterminada. A continuación se plantearán algunos de los más relevantes.

1.2. Causalidad múltiple

Lo normal es que haya demasiadas causas, es decir, que haya muchos eventos sin cuyo acaecimiento tampoco se habría producido el daño. La causalidad es un criterio de imputación demasiado amplio.

Véase si no el siguiente concepto de causa total, que tomamos de uno de los mejores manuales de filosofía de la ciencia escritos en la pasada década: *"[c]ada acontecimiento tiene por lo general múltiples causas. [...] La causa total de un suceso e es la suma [...] de todos los eventos* c_1, c_2, ... c_n *tales que, de cada* c_i *(1…i…n), es cierto que de no haber ocurrido* c_i, *y permaneciendo todo lo demás igual, tampoco habría ocurrido e"* (DÍEZ/MOULINES (1997, p. 146).

Parecidamente, FUMERTON/KRESS (2001, p. 98): *"The problem is that, to get a set of conditions that is genuinely lawfully sufficient for some outcome, the set must contain indefinitely many conditions"*.

Cuando varios agentes contribuyan a causar un daño, su actuación conjunta puede crear un efecto sinérgico: la actuación de uno refuerza el efecto perjudicial de la del otro o viceversa, de forma tal que mientras la probabilidad de que cada conducta, aisladamente considerada, causara el daño es reducida, en cambio, la probabilidad de que la superposición de ambas lo cause es mucho más elevada que la suma de las probabilidades individuales. Parecidamente, KORNHAUSER/ REVESZ ((1998), p. 371 y (2000), p. 626 y ss.): si hay varios agentes potenciales de daños que actúan secuencialmente, el primero en actuar puede no causar ningún daño porque, por ejemplo, la cantidad de vertidos que realiza es por sí sola inocua. Pero los vertidos de quienes le siguen se suman a los anteriores y, entre todos, acaban por causar graves daños. Dicho de otro modo, talar medio bosque no es necesariamente grave, pero cortar los árboles restantes sería una catástrofe. La regla, tradicionalmente aplicada por los tribunales españoles, de la responsabilidad objetiva y solidaria de los cocausantes del daño no tiene en cuenta que el segundo agente es mucho más peligroso que el primero: el veneno está en la dosis.

> La concesión de acciones de regreso a quien ha pagado una indemnización por el todo limita la conclusión anterior, pero únicamente si el sistema judicial funciona razonablemente bien y gradúa la acción de regreso en función del incremento del daño causado en vez de hacerlo – en el ejemplo anterior - proporcionalmente al número de árboles talados. Además, requiere que el demandado en vía de regreso sea solvente.

En los casos de efecto sinérgico es muy discutido si hay o no un único modo lógico de imputar los daños a cada uno de los demandados (véase BEN-SHAHAR (2000), p. 659). Algunas propuestas, con todo, estimulan la reflexión de los jueces y magistrados llamados a decidir: una de ellas, por ejemplo, define el daño marginal de cada demandado, en casos de actuación simultánea de varios dañadores, teniendo en cuenta el promedio de todas las combinaciones posibles de actos dañinos; otra apunta al hecho de que si todos los demandados se comportaron de tal modo que habría bastado la actuación de cualquiera de ellos para causar todo el daño, el régimen de responsabilidad solidaria infraincentiva un comportamiento prudente de todos ellos, pues el daño sólo se causa una vez y la acción de regreso permitirá dividir su estimación proporcionalmente al número de causantes. En casos así resulta justificada una condena por importe superior a los daños causados.

1.3. Causalidad indeterminada

En el *Common Law*, la doctrina procesal civil en materia de prueba propugna que el demandado debe ser condenado si la probabilidad de que haya causado el daño es mayor que al 0'5 (*preponderance evidence rule)*, es decir, si es más probable que haya causado el daño que lo contrario. Esta tesis es polémica.

Para algunos, la regla de la preponderancia de la probabilidad positiva es correcta. Así, supongamos (con BEN- SHAHAR (2000) p. 654, siguiendo a KAYE (1982)) un caso en el que el daño es de 100 €, pero la probabilidad de que el demandado lo haya causado es sólo del 40%. Si se aplica la regla, el demandado será absuelto, pero a costa de un error probable de 40 € (0'4 x 100 = 40). Sin embargo, supóngase ahora que rige una regla de responsabilidad proporcional a la probabilidad de haber causado el daño, es decir, bastará con que la probabilidad sea mayor que cero, pero el importe de la condena se graduará de acuerdo con aquélla. Entonces, en el caso anterior el tribunal condenará al demandado a pagar 40 € al demandante, pero el coste del

error esperado será 48 € en vez de 40 € (hay un 40% de probabilidad de que el demandado fuera el causante del daño; entonces, si causó daños de 100 €, es condenado a pagar 40 y deja de pagar 60: el coste de error esperado es de 0'4 x 60 = 24. Pero también hay un 60% de probabilidad de que el demandado no causara daño alguno, en cuyo caso pagará de más los 40 € a que será condenado: aquí el coste del error esperado es de 0'6 x 40 = 24. La suma de ambos errores, fruto de la aplicación de la regla de la responsabilidad proporcional es de 24 + 24 = 48. Hay una pérdida esperada neta de 8). La regla de la preponderancia de la probabilidad positiva es también defendida por otros (LEVMORE (1990)), que entienden que incentiva a los actores para que traten de reducir la incerteza del juicio aportando más pruebas. Por último, la regla mencionada puede reducir los costes de litigación, aunque sólo sea porque habrá menos casos que litigar.

Otros en cambio critican la tesis de la preponderancia de la probabilidad y favorecen una regla de responsabilidad proporcional. Supóngase un caso de concurrencia de causas (SHAVELL (1998), p. 212), en el que hay i) una infinidad de pequeños productores cuyas cuotas de mercado y probabilidad individual de causar daños son muy bajas; y ii) un gran productor con una cuota de mercado de más del 50%. Dado un daño imputable a alguna empresa de la industria y en ausencia de prueba sobre qué empresa lo causó, la regla tradicional llevará a que los pequeños productores sean infraincentivados a adoptar las precauciones justas, pues fácilmente evadirán toda responsabilidad, dadas las reducidas probabilidades de haberlos causado efectivamente. En cambio, el productor principal será sobreincentivado, pues, como autor de más del 50% de los daños probables, no podrá evitar la condena por la totalidad. Por eso, SHAVELL propone imponer responsabilidad en proporción a la probabilidad de causación de cada cual, por pequeña que resulte (*market share liability*). La tesis apunta a un inconveniente claro de la regla de la preponderancia de la probabilidad: distorsiona los incentivos de quienes sabiendo que es muy poco probable que su comportamiento genere algún daño lo llevan a cabo sistemáticamente, en la suposición de que nunca serán condenados (así, en el ejemplo del apartado anterior el demandado nunca sería condenado, pues la probabilidad de que su conducta causara el daño es sólo del 0'4. La doctrina suele referirse a esta cuestión con la expresión *recurring misses*, fallos repetidos).

Como señala BEN-SHAHAR (2000) las posiciones del debate reflejan dos puntos de partida distintos en materia de causalidad: quienes favorecen la primera tesis privilegian una perspectiva *ex post* del derecho de daños y quienes son partidarios de la segunda ponen el acento en una visión *ex ante*, centrada en la idea de prevención de daños. Una síntesis ha sido intentada por PORAT/STEIN (1997), quienes se pronuncian por una regla de responsabilidad por incerteza *(liability for uncertainty)*: responderá por un daño cuya causa es incierta la parte que originó o tuvo la mejor oportunidad de evitar la incerteza, ello llevaría a las partes a optimizar sus inversiones y despejar *ex ante* la incertidumbre, de forma que *ex post,* la aplicación de las reglas ordinarias de responsabilidad, ya se encargarían de generar los incentivos óptimos para reducir el daño primario. Responde así quien está en mejor condición de preconstruir la prueba *(cheapest evidence providers*)".

2. Causalidad genérica y específica / *Generic Causation and Specific Causation*

La distinción entre causalidad genérica y específica es especialmente relevante en casos en que la víctima ha sido expuesta a una sustancia tóxica, como los medicamentos o los productos químicos. Mientras que la causalidad específica se refiere a la cuestión, común a todo caso de daños, de si la conducta del demandado efectivamente causó el daño al demandante, la causalidad genérica responde a la cuestión de si la conducta del demandado pertenece al tipo de actividad capaz generalmente de causar un daño del tipo sufrido por el demandante. La víctima de daños asociados a medicamentos deberá acreditar, para vencer en juicio, no sólo que ha consumido el concreto medicamento en circunstancias tales que hacen posible la materialización del daño -período de consumo, dosis, circunstancias personales de la víctima tales como la edad, los hábitos o antecedentes médicos y familiares- (causalidad específica), sino además, y de forma previa, que el producto es, conforme al estado de la ciencia y de la técnica disponible, idóneo o capaz en abstracto de producir aquel daño (causalidad genérica). El éxito de la acción de daños dependerá entonces de la validez de la prueba pericial que apoye la alegación de la víctima sobre la causalidad genérica (James A. Henderson Jr., Rucgard N. Pearson, Douglas A Kysar y John A. Siciliano (2007), *The Torts Process*, 7ª ed., Wolters Kluwer, Nueva York, pp. 106, 112-116, 2007). En derecho español, rige la regla de libre apreciación por el juez de la prueba pericial (art. 348 Ley de Enjuiciamiento Civil: "[e]l tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica").

3. Causalidad alternativa / *Alternative Causation*

Remisión: pluralidad de causantes de un mismo daño indivisible y responsabilidad solidaria (*joint and several liability*).

3.1. *Summers v. Tice* (33 Cal. 2d 80, 199 P.2d 1 (1948))

CARTER, J. Each of the two defendants appeals from a judgment against them in an action for personal injuries. Pursuant to stipulation the appeals have been consolidated.

Plaintiff's action was against both defendants for an injury to his right eye and face as the result of being struck by bird shot discharged from a shotgun. The case was tried by the court without a jury and the court found that on November 20, 1945, plaintiff and the two defendants were hunting quail on the open range. Each of the defendants was armed with a 12 gauge shotgun loaded with shells containing 7 1/2 size shot. Prior to going hunting plaintiff discussed the hunting procedure with defendants, indicating that they were to exercise care when shooting and to "keep in line." In the course of hunting plaintiff proceeded up a hill, thus placing the hunters at the points of a triangle. The view of defendants with reference to plaintiff was unobstructed and they knew his location.

Defendant Tice flushed a quail which rose in flight to a 10-foot elevation and flew between plaintiff and defendants. Both defendants shot at the quail, shooting in plaintiff's direction. At that time defendants were 75 yards from plaintiff. One shot struck plaintiff in his eye and another in his upper lip. Finally it was found by the court that as the direct result of the shooting

by defendants the shots struck plaintiff as above mentioned and that defendants were negligent in so shooting and plaintiff was not contributorily negligent. […]

The problem presented in this case is whether the judgment against both defendants may stand. It is argued by defendants that they are not joint tortfeasors, and thus jointly and severally liable, as they were not acting in concert, and that there is not sufficient evidence to show which defendant was guilty of the negligence which caused the injuries -- the shooting by Tice or that by Simonson.

Considering [this argument], we believe it is clear that the court sufficiently found on the issue that defendants were jointly liable and that thus the negligence of both was the cause of the injury or to that legal effect. .... It thus determined that the negligence of both defendants was the legal cause of the injury -- or that both were responsible. Implicit in such finding is the assumption that the court was unable to ascertain whether the shots were from the gun of one defendant or the other or one shot from each of them. The one shot that entered plaintiff's eye was the major factor in assessing damages and that shot could not have come from the gun of both defendants. It was from one or the other only. […]

1. Dean Wigmore has this to say: "When two or more persons by their acts are possibly the sole cause of a harm, or when two or more acts of the same person are possibly the sole cause, and the plaintiff has introduced evidence that the one of the two persons, or the one of the same person's two acts, is culpable, then the defendant has the burden of proving that the other person, or his other act, was the sole cause of the harm. (b) . . . The real reason for the rule that each joint tortfeasor is responsible for the whole damage is the practical unfairness of denying the injured person redress simply because he cannot prove how much damage each did, when it is certain that between them they did all; let them be the ones to apportion it among themselves. Since, then, the difficulty of proof is the reason, the rule should apply whenever the harm has plural causes, and not merely when they acted in conscious concert." (Wigmore, Select Cases on the Law of Torts, § 153.)

2. When we consider the relative position of the parties and the results that would flow if plaintiff was required to pin the injury on one of the defendants only, a requirement that the burden of proof on that subject be shifted to defendants becomes manifest. They are both wrongdoers -- both negligent toward plaintiff. They brought about a situation where the negligence of one of them injured the plaintiff, hence it should rest with them each to absolve himself if he can. The injured party has been placed by defendants in the unfair position of pointing to which defendant caused the harm. If one can escape the other may also and plaintiff is remediless. Ordinarily defendants are in a far better position to offer evidence to determine which one caused the injury. […]

> In addition to that, however, it should be pointed out that the same reasons of policy and justice shift the burden to each of defendants to absolve himself if he can – relieving the wronged person of the duty of apportioning the injury to a particular defendant, apply here where we are concerned with whether plaintiff is required to supply evidence for the apportionment of damages. If defendants are independent tortfeasors and thus each liable for the damage caused by him alone, and, at least, where the matter of apportionment is incapable of proof, the innocent wronged party should not be deprived of his right to redress. The wrongdoers should be left to work out between themselves any apportionment... Some of the cited cases refer to the difficulty of apportioning the burden of damages between the independent tortfeasors, and say that where factually a correct division cannot be made, the trier of fact may make it the best it can, which

> would be more or less a guess, stressing the factor that the wrongdoers are not in a position to complain of uncertainty. [...]

The judgment is affirmed.

3.2. *Ybarra v. Spangard* (*25 Cal.2d 486, 154 P.2d 687*)

GIBSON, C. J. This is an action for damages for personal injuries [paralysis and atrophy of the muscles around the shoulder] alleged to have been inflicted on plaintiff by defendants during the course of a surgical operation [appendectomy]. The trial court entered judgments of nonsuit as to all defendants and plaintiff appealed (...) We have no doubt that in a modern hospital a patient is quite likely to come under the care of a number of persons in different types of contractual and other relationships with each other (...) But we do not believe that either the number or relationship of the defendants alone determines whether the doctrine of res ipsa loquitur applies. The judgment is reversed.

El caso plantea un doble problema de incertidumbre, uno relativo a la causa del daño, porque se desconoce cuál de los distintos profesionales médicos que atendieron a la paciente causó el daño a la paciente, y otro relativo a la negligencia, porque no se sabe qué infracción del deber de cuidado causó el daño a la víctima. La sentencia se centra en este segundo problema y en la aplicación de la doctrina *res ipsa loquitur* como mecanismo para solucionar la falta de prueba sobre la negligencia de los demandados, por lo que nos remitidos al capítulo 5, apartado 2.3.

3.3. STS, 1ª, 708/2011, de 18 de octubre

El 5.3.2000, el vehículo propiedad de la actora, Nicolasa, se salió de la vía, y como consecuencia del accidente su esposo, Pedro José, falleció y sobrevivió el otro ocupante, Eulogio. En el caso no se pudo determinar cuál de los dos conducía el turismo. El atestado de la Guardia Civil indicaba que era más probable que condujese el otro ocupante, pero no lo afirmó incontestablemente.

La viuda y los dos hijos del fallecido demandaron al Consorcio de Compensación de Seguros y a la compañía aseguradora del vehículo, Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija, y solicitan respectivamente 135.417,44 euros, 15.046 euros y 37.615,86 euros.

La SJPI núm. 41 Madrid SAP Madrid (30.6.2008) estimó en parte la demanda, condenó a Mutua Madrileña a pagar a los demandantes las siguientes cantidades respectivamente (67.708,72 euros, 7.523 euros y 18.807,93 euros) y absolvió al Consorcio de Compensación de Seguros. La SAP Madrid, Sección 20ª (30.6.2008) desestimó los recursos de apelación de los demandantes y de la compañía aseguradora. "[L]a sentencia (...) se limita a cargar a la demandada con la prueba de las causas de exoneración que alega [y] entiende que la recurrente no acredita que el fallecido fuese el conductor del turismo" (FD. 3º).

El Tribunal Supremo desestimó los recursos de la compañía aseguradora, extraordinario por infracción procesal (arts. 216, 217 y 218.2 LEC) y de casación por infracción de ley (arts. 1, 73, 75, 76 LCS, arts. 1902 y 1903 CC, arts. 1, 2, 5, 6, 10, 15, anexo primero y segundo Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor,

aprobado por RDL 8/2004, arts. 1.1, 3, 4 y 10 RD 7/2001, de 12 de enero, por el que se aprueba el reglamento sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor):

[E]l seguro obligatorio pretende no solo la protección del asegurado sino también la protección de la víctima, dado que no se trata exclusivamente de un siniestro enfocable aisladamente sino que la circulación vial es, también, un fenómeno con implicaciones sociales en cuanto generador de riesgo y perjuicios de singular gravedad (...)El recurrente pretende fundar su postura en la ignorancia sobre quién conducía y entiende que tal confusión no le puede perjudicar.

Lo incontestable es que la compañía de seguros ha de indemnizar a los perjudicados por el evento circulatorio salvo que acredite una de las causas de exoneración como es, entre otras, la culpa exclusiva de la víctima (art. 9.2 del RD 7/2001 de 12 de enero y disposiciones concordantes).

Es obvio que los dos intervinientes en el siniestro son perjudicados, en cuanto lesionados en su integridad personal, si bien la norma excluye de cobertura al perjudicado-conductor (art. 5 del TRLRCSCVM) y ampara al perjudicado-ocupante.

Para eludir su obligación de pago la aseguradora debió probar la causa de exoneración del art. 1 de la LRCSCVM acreditando que la culpa era imputable exclusivamente a D. Pedro Jesús y ello no lo ha podido hacer, como reconoció, extremo antes mencionado pues su recurso parte del desconocimiento sobre la persona del conductor.

Como refiere el precepto mencionado el conductor del vehículo es responsable y, por ende su aseguradora, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos , de los daños causados a personas y bienes ... solo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor ... (FD 7º).

4. Causalidad concurrente / *Concurrent Causation*

4.1. *Kingston v. Chicago Ry.* (191 Wis. 610, 211 N.W. 913 (1927))

OWEN, J. We therefore have this situation: The northeast fire was set by sparks emitted from defendant's locomotive. This fire, according to the finding of the jury, constituted a proximate cause of the destruction of plaintiff's property. This finding we find to be well supported by the evidence. We have the northwest fire, of unknown origin. This fire, according to the finding of the jury, also constituted a proximate cause of the destruction of the plaintiff's property. This finding we also find to be well supported by the evidence. We have a union of these two fires 940 feet north of plaintiff's property, from which point the united fire bore down upon and destroyed the property. We therefore have two separate, independent, and distinct agencies, each of which constituted the proximate cause of plaintiff's damage, and either of which, in the absence of the other, would have accomplished such result.

It is settled in the law of negligence that any one of two or more joint tortfeasors, or one of two or more wrongdoers whose concurring acts of negligence result in injury, are each individually responsible for the entire damage resulting from their joint or concurrent acts of negligence. This rule also obtains "where two causes, each attributable to the negligence of a responsible

person, concur in producing an injury to another, either of which causes would produce it regardless of the other, . . . because, whether the concurrence be intentional, actual, or constructive, each wrongdoer, in effect, adopts the conduct of his co-actor, and for the further reason that it is impossible to apportion the damage or to say that either perpetrated any distinct injury that can be separated from the whole. The whole loss must necessarily be considered and treated as an entirety […]

It is […]conceivable that a fire so set might unite with a fire of so much greater proportions, such as a raging forest fire, as to be enveloped or swallowed up by the greater holocaust, and its identity destroyed, so that the greater fire could be said to be an intervening or superseding cause. But we have no such situation here. These fires were of comparatively equal rank. If there was any difference in their magnitude or threatening aspect, the record indicates that the northeast fire was the larger fire and was really regarded as the menacing agency. At any rate there is no intimation or suggestion that the northeast fire was enveloped and swallowed up by the northwest fire. We will err on the side of the defendant if we regard the two fires as of equal rank.

According to well settled principles of negligence, it is undoubted that if the proof disclosed the origin of the northwest fire, even though its origin be attributed to a third person, the railroad company, as the originator of the northeast fire, would be liable for the entire damage. There is no reason to believe that the northwest fire originated from any other than human agency. It was a small fire. It had traveled over a limited area. It had been in existence but for a day. For a time it was thought to have been extinguished. It was not in the nature of a raging forest fire. The record discloses nothing of natural phenomena which could have given rise to the fire. It is morally certain that it was set by some human agency.

Now the question is whether the railroad company, which is found to have been responsible for the origin of the northeast fire, escapes liability because the origin of the northwest fire is not identified, although there is no reason to believe that it had any other than human origin. An affirmative answer to that question would certainly make a wrongdoer a favorite of the law at the expense of an innocent sufferer. The injustice of such a doctrine sufficiently impeaches the logic upon which it is founded. Where one who has suffered damage by fire proves the origin of a fire and the course of that fire up to the point of the destruction of his property, one has certainly established liability on the part of the originator of the fire. Granting that the union of that fire with another of natural origin, or with another of much greater proportions, is available as a defense, the burden is on the defendant to show that by reason of such union with a fire of such character the fire set by him was not the proximate cause of the damage. No principle of justice requires that the plaintiff be placed under the burden of specifically identifying the origin of both fires in order to recover the damages for which either or both fires are responsible.[…]

By the Court.--Judgment affirmed.

Daños causados por incendios y doctrina de la Sala 1ª del Tribunal Supremo conforme a la cual al actor, víctima de un incendio, le basta con probar que este tuvo su origen en la esfera de influencia del demandado

4.2. STS, 1ª, 816/2011, de 6 de febrero de 2012

Sobre las 0:15 horas del 1 de julio de 2004, mientras la plataforma remolque frigorífico matrícula AAA se encontraba realizando labores de carga en el establecimiento Supersol sito en la plataforma baja de Mercamadrid, sufrió un incendio, por cortocircuito en el compresor frigorífico, que afectó tanto a la mercancía como al edificio e instalaciones del supermercado. En esa fecha la plataforma remolque era propiedad de Carrocerías Lucas y su uso correspondía a D. Eusebio en virtud de contrato de préstamo de uso celebrado el 11 de febrero de 2004. La responsabilidad civil del remolque (obligatoria y suplementaria hasta 50 millones de euros) estaba asegurada con Mapfre mediante póliza suscrita el 17 de febrero de 2004. Con anterioridad (30 de diciembre de 2003) se había asegurado con la misma entidad la cabeza tractora. Ambas pólizas estaban en vigor al ocurrir el siniestro. Por su parte, la mercantil Dinosol Supermercados. S.L. (antes Ahold Supermercados, S.L.) era arrendataria del establecimiento Supersol al tiempo de ocurrir el incendio. En ese tiempo tenía en vigor la póliza de seguros suscrita bajo su antigua denominación con Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. que, en esencia y en los términos pactados, cubría los daños materiales, la pérdida de beneficios, la avería de maquinaria y el robo. De acuerdo con esta última póliza, Allianz abonó a Dinosol Supermercados la cantidad de 101.390,10 euros en concepto de indemnización por los daños sufridos por el incendio y objeto de cobertura.

Dinosol Supermercados, S.L. y Allianz Seguros, S.A. demandaron a D. Eusebio y a Mapfre. Dinosol Supermercados reclamó la indemnización correspondiente a los daños no cubiertos por la póliza mencionada (82.322,90 euros), y Allianz hizo lo propio con la indemnización que esta aseguradora asumió con cargo a la póliza (101.390,10 euros).

El JPI nº 4 de Majadahonda (Madrid), 6.6.2006, desestimó íntegramente la demanda al considerar que el incendio se había producido por caso fortuito. La AP Madrid, Secc. 13ª, 20.2.2008, desestimó el recurso de los demandantes, estimó la impugnación de Mapfre y confirmó, aunque con distintos razonamientos, el fallo absolutorio de primera instancia.

El TS estimó el recurso de casación interpuesto por Dinosol Supermercados y Allianz en base a que "no existen razones para no calificar como hecho de la circulación [art. 3 RD 7/2001] el incendio que afectó al semirremolque asegurado de responsabilidad civil obligatoria y suplementaria en Mapfre, entidad que, consecuentemente, por tratarse de un siniestro no excluido de cobertura, sí se encuentra pasivamente legitimada frente a la reclamación efectuada de contrario" (…) A esta conclusión se llega valorando que el causante de los daños por los que se reclama es un semirremolque, mencionado expresamente como vehículo a motor en el artículo 2.1 RD 7/2001; que dicho vehículo no se encuentra comprendido en la exclusión del artículo 3.3 RD 7/2001, y que el incendio sobrevino cuando se encontraba estacionado en el lugar destinado a la realización de operaciones de carga y descarga del mismo, consustanciales a su condición de vehículo de transporte de mercancías, situación en que habría de mantenerse, no con vocación de permanencia, sino tan solo por el tiempo necesario para su finalización (lo que, como señaló el Juzgado al aludir a una situación de tránsito, da cuenta de la existencia de una situación de continuidad entre el hecho indudable de la circulación que representa la

conducción del vehículo hasta ese lugar y el constituido por el abandono del mismo hasta el de entrega de la mercancía)" (FD 3º B).

El TS añade que "sentado que se trató de un hecho de la circulación, la responsabilidad del propietario o poseedor debe enjuiciarse desde la óptica del singular riesgo creado por la conducción de un vehículo a motor, que, contrariamente a lo señalado por la AP, sí se trata de una situación de especial riesgo, que comporta una presunción de culpa que corresponde destruir al agente, por encontrarse cercano a la fuente de peligro, y que hace que el problema se contraiga en este caso a valorar, desde el punto de vista de la causalidad, su relevancia causal, es decir, si su actuación negligente pudo ser causalmente determinante del resultado dañoso, entendida esa relación de causalidad, no solo desde el plano fenomenológico (causalidad física) sino también desde el plano jurídico, como posibilidad de que se le pueda imputar objetivamente (causalidad jurídica). [D]e manera que al propietario y al conductor sí les correspondía velar por la seguridad del mismo, incluyendo la de todos sus mecanismos, entre ellos, el sistema de refrigeración, en cuanto estaba íntimamente relacionado con la actividad a la que estaba principalmente destinado el vehículo. No cabe, como hace la AP, desvincular la causa física del incendio (cortocircuito en el grupo frigorífico) con los deberes exigibles de adecuado mantenimiento y conservación del vehículo, pues, por más que este hubiera sido cedido escasamente cinco meses antes y dispusiera de certificado oficial sobre su aptitud para ser usado para la finalidad con que estaba siéndolo en el momento del siniestro, su uso continuado durante este tiempo -y por tanto, con posterioridad a dicha inspección- situaba al agente en una situación de control de la fuente de peligro que le obligaba a extremar su diligencia a fin de detectar posibles incidencias, averías o defectuosos funcionamientos, con objeto de prevenir daños como los ocasionados" (FD 5º B).

Y, en definitiva, el TS "fija la indemnización correspondiente al total de los daños y perjuicios derivados del siniestro en la suma de 173.619,19 euros. De esta cantidad, los demandados deberán indemnizar solidariamente a la demandante Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., con la suma por esta satisfecha a su asegurado, de 101.390,10 euros. Y la diferencia, 72.229,09 euros, deberá ser abonada al perjudicado Dinosol Supermercados S.L." (FD 6º). Estas cantidades se incrementarán con los intereses legales desde la fecha de la reclamación extrajudicial (20.6.2005).

4.3. STS, 1ª, 425/2009, de 4 de junio

El 16 de febrero de 2000 se produjo un incendio en las naves industriales propiedad de Aceites Villanueva S.A. en la zona donde la sociedad demandada, José Molina Tornero, S.L., (con consta su vinculación legal con la propietaria) había almacenado material fácilmente inflamable, de desecho y cajas de madera fina y cartón.

Aceites Villanueva S.A. demandó a Mutua General de Seguros y a la viuda de José Molina Tornero.

El JPI nº 1 de Alciza (30.10.2003) estimó en parte la demanda y condenó a la viuda de José Molina Tornero a pagar 213.839,52 euros, y a Mutua General de Seguros 75.126 euros más 7.544 euros en concepto de desescombros. La AP estimó en parte el recurso de apelación de la actora y modificó la indemnización debida por la Mútua (150.253,03 euros por daños y perjuicios y 5.868,69 euros por gastos de desescombro).

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por la viuda de José Molina con base a la infracción del art. 1902 CC:"En los casos de incendio, la jurisprudencia salva las dificultades de prueba de su causa, basando la imputación objetiva en la generación de un peligro jurídicamente desaprobado y en el control que se ejerce sobre las cosas que lo generan. De modo que admite un grado de razonable probabilidad cualificada, distinta de la certeza absoluta, en la reconstrucción procesal de la relación causal - sentencias de 30 de noviembre de 2.001 (RJ 2001, 9919) ; 29 de abril de 2.002 (RJ 2002, 4971) ; 15 de febrero 2008 (RJ 2008, 2669)…" (FD. 4º).

4.4. STS, 1ª, 485/2008, de 28 de mayo

En la madrugada del 6.3.1997 se originó un incendio en la vivienda de Juan Antonio, lo cual provocó daños (no se especifican) en las zonas comunes del edificio donde se hallaba, así como en las viviendas de Rodolfo, Clemente, Carlos José y Raúl. Juan Antonio tenía sobre una alfombra del salón un alargador, al que se encontraban enchufados dos teléfonos y una lámpara.

La Comunidad de Propietarios y Rodolfo, Clemente, Carlos José y Raúl demandan a Juan Antonio y su aseguradora, y solicitan una indemnización de 1.792 € así como la reparación de los desperfectos ocasionados en las zonas comunes.

El JPI nº 4 de Sueca (19.1.1999) desestima la demanda. La AP de Valencia (Sección 6ª, 15.6.2000) estima en parte el recurso de apelación y condena al demandado a pagar la suma que se determine en ejecución de sentencia.

El TS desestima el recurso de casación interpuesto por la aseguradora del demandado:

> "[H]a de mantenerse el dato de que el incendio se originó en la vivienda del demandado Juan Antonio, y más exactamente, en el enchufe múltiple utilizado por él en el salón comedor del piso… [L]a atribución a éste de la responsabilidad de los daños ocasionados por el fuego responde a la correcta aplicación de la más reciente doctrina de esta Sala, que se resume en la sentencia de 3 de febrero de 2005 (RJ 2005, 1836)… [o] de 23 de noviembre de 2004 (RJ 2004, 7383) , en donde la imputación de la responsabilidad de los daños causados por un incendio se realizó en atención al control o vigilancia que el demandado ejercía sobre el ámbito doméstico, afirmando que "esta Sala viene declarando que no todo incendio es por caso fortuito y que no basta para llegar a tal conclusión que el siniestro se hubiera producido por causas desconocidas (SSTS, entre otras, de 9 de noviembre de 1993 [RJ 1993, 8973] , 29 de enero de 1996 [RJ 1997, 6365] , 13 de junio de 1998 [RJ 1998, 4687] , 11 de febrero de 2000 y 12 de febrero de 2000 [RJ 2001, 850]), de modo que, generado un incendio dentro del ámbito de control del poseedor de la cosa -propietario o quién está en contacto con ella- hay que presumir que le es imputable, salvo que pruebe que obró con toda la diligencia exigible para evitar la producción del evento dañoso (SSTS, entre otras, de 13 de junio de 1998 [RJ 1998, 4687] , 22 de mayo de 1999, 31 de enero y 11 de febrero de 2000, 12 de febrero [RJ 2001, 850] y 27 de abril de 2001, 24 de enero de 2002 [RJ 2002, 28]). [A]creditado el incendio causante del daño, -no importa que no esté probada la causa del mismo- 20 de abril de 2002 -no es suficiente expresar que no se ha acreditado cuál fue la causa del siniestro-, 27 de febrero (RJ 2003, 2152) y 26

de junio de 2003 (RJ 2003, 5960) -debe probarse el incendio, no el hecho, normalmente imposible, que constituye la causa concreta que lo provocó-".

Esta misma orientación jurisprudencial se encuentra también en las Sentencias de 20 de mayo de 2005 (RJ 2005, 6693) [**citada por la STS, 1ª,15.2.2008, RJ 2669]** , 18 de julio de 2006 (RJ 2006, 5345) (FD. 2º):

["La sentencia de 20 de mayo de 2005 (RJ 2005, 6693)... precisa que, cuando se produce un incendio en un inmueble, al perjudicado le corresponde probar la realidad del mismo y que se produjo en el ámbito de operatividad del demandado, mientras que a quien tuvo la disponibilidad -contacto, control o vigilancia- de la cosa en que se originó el incendio le corresponde acreditar la existencia de la actuación intencionada de terceros o de serios y fundados indicios de que la causa hubiera podido provenir de agentes exteriores" (FD. 2º **STS, 1ª, 1ª,15.2.2008, RJ 2669, MP: José Ramón Ferrándiz Gabriel:** Carlos y Ernesto realizaban obras en una vivienda cuando se originó un incendio en ella y dañó las viviendas de Dolores, Lorenzo y María Dolores, que fueron parcialmente indemnizados por la compañía aseguradora "La Unión y el Fénix Español, S.A.")].

4.5. *Dillon v. Twin State* (85 N.H. 449, 163 A. 111 (1932))

The defendant maintained wires to carry electric current over a public bridge in Berlin.

In the construction of the bridge there were two spans of girders on each side between the roadway and footway. In each span the girders at each end sloped upwards towards each other from the floor of the bridge until connected by horizontal girders about nineteen feet above the floor.

The wires were carried above the framework of the bridge between the two rows of girders.

To light the footway of the bridge at its center a lamp was hung from a bracket just outside of one of the horizontal girders and crossing over the end of the girder near its connection with a sloping girder. Wires ran from a post obliquely downward to the lamp and crossed the horizontal girder a foot or more above it. The construction of the wire lines over and upon the bridge is termed aerial. The wires were insulated for weather protection but not against contact.

The decedent and other boys had been accustomed for a number of years to play on the bridge in the daytime, habitually climbing the sloping girders to the horizontal ones, on which they walked and sat and from which they sometimes dived into the river. No current passed through the wires in the daytime except by chance.

The decedent, while sitting on a horizontal girder at a point where the wires from the post to the lamp were in front of him or at his side, and while facing outwards from the side of the bridge, leaned over, lost his balance, instinctively threw out his arm, and took hold of one of the wires with his right hand to save himself from falling. The wires happened to be charged with a high voltage current at the time and he was electrocuted.

The circumstances of the decedent's death give rise to an unusual issue of its cause. In leaning over from the girder and losing his balance he was entitled to no protection from the defendant to keep from falling. Its only liability was in exposing him to the danger of charged wires. If but for the current in the wires he would have fallen down on the floor of the bridge or into the river, he would without doubt have been either killed or seriously injured. Although he died from electrocution, yet, if by reason of his preceding loss of balance he was bound to fall except for the intervention of the current, he either did not have long to live or was to be maimed. In such an outcome of his loss of balance, the defendant deprived him, not of a life of normal expectancy, but of one too short to be given pecuniary allowance, in one alternative, and not of normal, but of limited, earning capacity, in the other.

If it were found that he would have thus fallen with death probably resulting, the defendant would not be liable, unless for conscious suffering found to have been sustained from the shock. In that situation his life or earning capacity had no value. To constitute actionable negligence there must be damage, and damage is limited to those elements the statute prescribes.

If it should be found that but for the current he would have fallen with serious injury, then the loss of life or earning capacity resulting from the electrocution would be measured by its value in such injured condition. Evidence that he would be crippled would be taken into account in the same manner as though he had already been crippled.

His probable future but for the current thus bears on liability as well as damages. Whether the shock from the current threw him back on the girder or whether he would have recovered his balance, with or without the aid of the wire he took hold of, if it had not been charged, are issues of fact, as to which the evidence as it stands may lead to different conclusions.

Exception overruled.

4.6. STS, 1ª, 536/2012, de 10 de septiembre

El 31.3.2003 tuvo lugar un accidente de tráfico debido a la colisión en una curva de dos vehículos que conducían en sentido contrario, a consecuencia del cual uno de los conductores, Dionisio, sufrió lesiones, y ambos vehículos sufrieron daños materiales que fueron reparados por las respectivas aseguradoras. La prueba de alcoholemia practicada al otro conductor, Nicolás, dio positiva, y este admitió que en el momento del accidente circulaba a una velocidad superior a los 50 km/h permitidos. En el caso, no pudo acreditarse cuál de los dos vehículos invadió el carril contrario.

Dionisio denunció a Nicolás y se reservó la acción civil para interponerla en un procedimiento posterior. El Juzgado de lo Penal (7.3.2005) condenó a Nicolás como autor de un delito contra la seguridad del tráfico y de un delito de lesiones por imprudencia. La AP Vizcaya (1.7.2005) revocó la sentencia de instancia y absolvió al acusado: "no se ha probado que efectivamente fuera su vehículo quien invadió el carril contrario y, por lo tanto, incurriera en la infracción del deber objeto de cuidado determinante del siniestro."(A.H. 2º STS).

Dionisio demandó a la compañía de seguros Allianz S.A., aseguradora del vehículo conducido por Nicolás, y reclamó una indemnización por los daños personales sufridos.

El JPI nº 1 de Guernica-Lumo (12.1.2009) desestimó la demanda "al estima[r] que se carecen de elementos concluyentes que permitan conocer con certeza quién invadió el carril contrario, causa del accidente" (A.H. 2º).

La SAP de Vizcaya (Sección 3ª, 11.6.2009) estimó parcialmente el recurso en cuanto a las costas, pero confirmó el resto de pronunciamientos de la SJPI: "ante las versiones contradictorias de los litigantes y atendiendo a la doctrina de las reglas de prueba que en estos supuestos deben ser de aplicación (...) el actor no ha logrado acreditar los hechos que reclama y por tanto [procede] desestimar su demanda" (AH 4º).

El actor interpuso recurso de casación por infracción del art. 1902 CC, del art. 1.1 Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y de la doctrina jurisprudencial sobre este último precepto.

El TS estimó el recurso de casación del actor, declaró al demandado responsable del 100% de los daños personales acreditados por el actor y ordenó reponer las actuaciones a la AP para que dictara sentencia en torno a la cuantía de la indemnización:

"B) (...) [U]na recíproca colisión de vehículos no supone excepción alguna a la aplicación del principio de responsabilidad objetiva por el riesgo de la circulación (...).

El principio de responsabilidad objetiva -en cuya legitimidad constitucional no es necesario entrar aquí-, en efecto, no solo supone el establecimiento de criterios de imputación ajenos a la concurrencia de culpa o negligencia, sino que comporta también establecer una presunción de causalidad entre las actividades de riesgo y la consecuencias dañosas que aparezcan como características de aquellas, como ocurre con los daños derivados de una colisión cuando se trata de la responsabilidad objetiva por el riesgo creado por la conducción de un vehículo de motor. Esta presunción solo puede enervarse demostrando que concurren las causas de exoneración configuradas por la ley como excluyentes del nexo de causalidad entre la acción y el daño (...)

C) La solución apuntada traslada la controversia al tema de si procede o no que cada conductor resarza por completo los daños corporales causados a los ocupantes del otro vehículo implicado en la colisión (...)

[E]n trance de unificar la doctrina existente con efecto de fijación de jurisprudencia, dada la divergencia existente entre las distintas audiencias provinciales, nos inclinamos por entender que la solución del resarcimiento proporcional es procedente solo cuando pueda acreditarse el concreto porcentaje o grado de incidencia causal de cada uno de los vehículos implicados y que, en caso de no ser así, ambos conductores responden del total de los daños personales causados a los ocupantes del otro vehículo con arreglo a la doctrina llamada de las condenas cruzadas. Las razones en que se funda esta conclusión son las siguientes:

(a) Esta es la doctrina seguida por un número considerable de audiencias provinciales.

(b) Constituye una solución aceptada expresamente por alguna de las legislaciones de Derecho comparado, como se ha expuesto.

(c) Es una doctrina próxima, aunque no coincida con ella, a la que inspira la jurisprudencia de esta Sala tendente a proclamar la solidaridad impropia entre los agentes que concurren a causar

el daño cuando no puede establecerse la proporción en que cada uno de ellos ha contribuido a su producción.

(d) Es acorde con la tendencia que se registra en el Derecho comparado a atribuir responsabilidad plena a los causantes simultáneamente de un daño por una pluralidad de actividades (v. gr., PETL, artículo 3:102, según el cual: «En caso de una pluralidad de actividades, si cada una de ellas hubiera causado el daño por sí sola al mismo tiempo, se considerará que cada actividad es causa del daño de la víctima»).

(e) Es la doctrina más acorde con la presunción de causalidad, que rige en el sistema de responsabilidad objetiva por riesgo, en relación con el agente de la actividad peligrosa que interviene en la producción del daño característico de dicha actividad de riesgo. Estimamos que, cuando, por falta de datos, no resulta posible destruir la presunción fundada en el riesgo creado por cada conductor respecto de los daños personales causados a los ocupantes del otro vehículo (supuesto a que se contrae el caso enjuiciado), el principio de responsabilidad objetiva puede resultar dañado si, sin otro fundamento que haber existido otra posible causa concurrente, presuntivamente se restringe la causalidad imputable a cada conductor en la producción de los daños al otro vehículo a una proporción del 50% (esta reducción sí sería procedente si se probase que ambos causaron el accidente en dicha proporción)" (FD. 4º).

5. Causalidad sucesiva / *Succesive Causation*

5.1. BGH NJW 1952, 1010

"[…W]enn der Verletzte durch Verschulden des Schädigers ein Bein verloren hat und es ihm 8 Jahre später infolge dieser Behinderung nicht gelingt, auf der Flucht vor plötzlich einsetzendem Artilleriebeschuß rechtzeitig den schützenden Bunker zu erreichen".

5.2. *Baker v. Willoughby* ([1970] 2 W.L.R. 50)

*"*The defendant negligently struck the plaintiff with his automobile, causing severe injury to the plaintiff's left leg and ankle. Some time later, but before trial, the plaintiff was shot in the already-disabled left leg during a robbery at his place of employment. As a result of the gunshot wound, the already disabled left leg had to be amputated. At trial, the defendant argued that he should be liable for the plaintiff's damages due to his disability only up to the time of the shooting. The trial judge rejected this argument but the court of appeal accepted it. The judgment of the court of appeal was reversed by the House of Lords, which ruled that the plaintiff's recovery for his disability was not affected by the second injury and amputation" (as quoted by HENDERSON et al., *The Torts Process*).

5.3. STS, 1ª, 461/2003, de 8 de mayo: fractura de rodilla en accidente de esquí y responsabilidad civil médico-sanitaria.

El 7.1.1991 Marisol sufrió un accidente de esquí en Baqueira Beret que le causó una fractura de espina tibial, de la que fue auxiliada *in situ* y trasladada a Barcelona, donde fue atendida por el

Dr. Carlos Antonio, que tenía contratado un seguro con Winterthur y pertenecía a "Asistencia Sanitaria Colegial, SA". El tratamiento se prolongó hasta mayo de 1992, en cuyo transcurso la paciente se sometió a tres intervenciones. Finalmente, Marisol acudió a otro doctor para que acabase el tratamiento, pero le quedaron secuelas graves que consisten en limitación de la movilidad de la rodilla derecha, atrofia muscular y una cojera irreversible.

Marisol demandó al doctor Carlos Antonio, a Winterthur y a "Asistencia Sanitaria Colegial, SA" y solicitó una indemnización de 120.202,42 €.

El JPI nº 25 de Barcelona (7.4.1995) estimó en parte la demanda y condena a Carlos Antonio y a Winterthur al pago de 72.121,45 €. La AP de Barcelona (Sección 11ª, 8.5.1997) estimó el recurso de apelación, revoca la SJPI y absolvió a los condenados en la instancia previa.

El TS estimó el recurso interpuesto por la actora, revocó la SAP y confirmó la SJPI. Así, el Tribunal Supremo afirmó en su FD 3º:

"En el presente caso, hubo una actuación médica en un dilatado período de tiempo, con repetidas intervenciones quirúrgicas, con un proceso largo y doloroso y un resultado irreversible: una cojera en persona joven. En la relación fáctica basada esencialmente en las varias pruebas periciales se afirma que no hubo culpa o negligencia, lo cual no es un «factum» sino una «quaestio iuris» revisable en casación; se dice que la prueba pericial dice que no hay nexo causal entre la actuación médica y el resultado dañoso; pero no dice cómo ni porqué se ha producido éste; ni dice en ningún momento que la causa fuera ajena a aquella actuación, ni que fuera causada por fuerza mayor, ni que tuviera su origen en previas condiciones de la propia perjudicada.
En definitiva, una caída y una lesión que tampoco se dice que fueran especialmente graves, ni complicados, tienen un tratamiento largo y doloroso con un resultado que no puede por menos que considerarse desproporcionado: una cojera irreversible; lo cual crea una deducción de negligencia («res ipsa loquitus»), una apariencia de prueba de ésta (*Anscheisbeweis*), una culpa virtual (*faute virtuelle*).

No se trata, pues, de una objetivación absoluta de responsabilidad sino de apreciación de culpa, deducida del resultado desproporcionado y no contradichos por hechos considerados acreditados por prueba pericial. Se produce un suceso y un daño: es claro que no consta causa del mismo imputable a la víctima (no tiene sentido la aberrante frase antes transcrita: "... causa real fue el acto libre y voluntario de la parte actora"), ni se menciona el caso fortuito o la fuerza mayor; la causa fue la actuación médica, de cuyo mal resultado se desprende la culpa y, por ende, la responsabilidad."

6. Causalidad probabilística / *Probabilistic Causation*

Un perro Labrador, LAB, adiestrado por la policía de fronteras para detectar drogas, está entrenado para ladrar cuando huele el rastro o residuo de ellas y acierta nueve de cada diez veces que ladra. Es un buen perro, pues tiene una tasa de un 90% de aciertos.

Si de cada 100 pasajeros de un avión procedente de un país andino, 1 lleva drogas y LAB efectivamente ladra a uno de ellos, MULE, ¿cuál es la probabilidad de que MULE lleve drogas?

Mucha gente, cuenta Ward FARNSWORTH (*The Legal Analyst. A Toolkit for Thinking about the Law*, The University of Chicago Press, 2007, capítulo 30, *The Base Rate*) diría que la probablidad es de un 90%. ¡Incorrecto! No preguntamos sobre la probabilidad de que LAB acierte sino sobre la de que MULE lleve drogas y esta última, de entrada es, como hemos dicho, 1%. Al pie de la escalerilla de un avión que acaba de aterrizar con cien pasajeros a bordo, LAB acertará como máximo una vez (pues sólo un pasajero de cada cien lleva drogas), pero olfateará a los otros 99, acertará con el 90% de los casos, pero se equivocará en el 10% de los restantes, es decir, ladrará equivocadamente a 9,99 pasajeros -redondeando: a 10-. De 11 ladridos, 1 identifica a un viajero con drogas. Una tasa correcta para soportar una legislación que permite registrar a los 11 de cada 100, pero no para aguantar una que permita detenerlos con sola esa información, mucho menos condenarlos.

— *Product Rule*. Es la regla de la probabilidad compuesta: la probabilidad de que salga cara en dos tiradas consecutivas de una misma moneda es 0,5 x 0,5 = ,25, el producto, no la suma de las probabilidades individuales, tratándose de sucesos independientes. En derecho, las cosas no son tan sencillas: en un ejemplo famoso, citado por Ward Farnsworth (capítulo 29), el jurado tenía que decidir sobre si el capitán de un barco era responsable de la desaparición y probable muerte de un marinero que había caído media hora antes a las aguas frías del Atlántico sin que nadie cayera en la cuenta. El capitán decidió no virar la nave y, además, resultaba que no disponía de un cabo para tirárselo al marinero. imaginen que el jurado cree que el demandante tiene razón en afirmar la negligencia del capitán, pues de haber girado la nave a tiempo, habría tenido un 60% de probabilidad de encontrar al marinero vivo y si hubiera dispuesto de un cable o soga, de otro 60% de que el marinero se aferrara a ella y se salvara. A ojos del jurado, quizás el demandante debería ganar, pero si buscamos la probabilidad compuesta: 0,6 x 0,6 = 0,36, podemos concluir que el rescate habría sido poco probable. Podemos cambiar el ejemplo, pero el simple cálculo de probabilidades no resuelve todos los problemas. Así, si la omisión de llevar un cable se considera negligente en un 95% de los casos, pero la probabilidad de que arrojar un cabo en el momento justo inmediatamente posterior al grito de !Hombre al agua!, hace ello una diferencia? Una técnica usada por muchos abogados consiste en descomponer el hecho con probabilidad superior al 50% en varios que la tienen muy inferior.

— Falacia del Fiscal (*Prosecutor's Fallacy*). En un caso de California de finales de los años sesenta, *People v. Colllins*, una mujer había sido robada por el procedimiento del tirón. Un testigo declaró que había visto a la ladrona corriendo calle arriba y le describió como una mujer blanca con una cola de caballo, que conducía un coche amarillo acompañada por un hombre afroamericano con mostacho y barba. Al día siguiente, la policía detuvo a una mujer que respondía a tal descripción. Durante el juicio, el fiscal presentó el peritaje de un profesor de matemáticas para que testificara acerca de la regla de la probabilidad compuesta en el caso:
La probabilidad de que un coche fuera amarillo era de 1/10.
La de que un hombre llevara un mostacho, de 1/4.
La de que la mujer peinara cola de caballo, de 1/10.
La de que ella fuera rubia, 1/10.
La de que el hombre negro tuviera barba, de 1/10.
La de que el coche estuviera ocupado por una pareja interracial, de 1/100.

Fiscal y profesor explicaron al jurado que la probabilidad de que todas estas circunstancias fueran casuales podrían estimarse multiplicando las probabilidades individuales: 1/10 x 1/4 x 1/10, etc., cuyo resultado era de que había una probabilidad por un millón de que hubiera una

pareja de tales características. El jurado dictó un veredicto de culpabilidad, pero el Tribunal Supremo californiano había abusado de su argumentación, pues ninguna de las bases de cálculo tenía ningún género de fundamento sólido. Más fácilmente: muchas probabilidades no eran independientes entre sí (por ejemplo, mucha gente que lleva barba también tiene bigote: llevar la una hace más probable llevar la otra). La falacia del fiscal consiste en presentar el caso como si el jurado hubiera de comparar las probabilidades de que el acusado sea culpable con otra persona escogida al azar. Pero la cuestión legal es cómo las probabilidades de que el acusado sea culpable se comparan con la posibilidad de que cualquier otro realmente lo fuera: si una persona en 100.000 tiene los rasgos incriminadores, pero diez en un millón también los tienen, no deja de ser cierto que la probabilidad de que el primer imputado detenido sea culpable es de una contra diez: hay pues nueve probabilidades de que la detención haya sido equivocada.

The Conjunct Fallacy. Sigue Farnsworth: Linda tiene 32 años, es soltera, extrovertida y muy brillante; se graduó en filosofía, estuvo muy metida en temas de ecología y derechos de los animales, participó en manifestaciones contrarias a la energía nuclear. ¿Qué actividades son más probables que ejerza Linda, (1) cajera de banco o (2) cajera de banco y feminista activa? A Daniel Kahneman le dieron el premio Nobel por mostrar cómo la primera respuesta es mucho más probable que la segunda: (2) es un subconjunto de (1).

Capítulo 8º
Imputación objetiva

1. Imputación objetiva / *Proximate Causation; Scope of Liability* **142**
2. Previsibilidad / *Foreseeability* **145**
2.1. Palsgraf v. Long Island R.R. (N248 N.Y. 339, 162 N.E. 99 (1928)) 145
2.2. STS, 1ª, 597/1996, de 19 de julio 147
3. *Proximate Cause* / Causalidad Adecuada / *Adäquanztheorie* **148**
3.1. Stahlecker v. Ford Motor Company (266 Neb. 601, 667 N.W.2d 244 (2003)) ... 148
3.2. STS, 1ª, 255/1997, de 1 de abril 150
3.3. STS, 1ª, 377/2004, de 12 de mayo 150
3.4. STS, 3ª, de 18 de mayo de 2010 151
4. Riesgos generales de la vida / *General Life Risks* / *Erlaubte Risiken* **152**
4.1. STS, 3ª, 29 de octubre de 1998 152
4.2. STSJ Comunidad Valenciana, Sala C-A, Secc. 1ª, 55/2003, de 2 de enero 153
5. Prohibición de regreso y posición de garante / *Remoteness* / *Regressverbot und Garantenstellung* **154**
6. Ámbito de protección de la norma / *Harm within the Risk* / *Schutzbereich der Norm* **155**
6.1. STS, 1ª, 902/1998, de 8 de octubre 155
6.2. STS, 3ª, 3 de noviembre de 2008 155
7. Provocación / *Provocation* / *Herausforderung* **156**
8. Consentimiento de la víctima y asunción del propio riesgo / *Victim's consent and assumption of risk* / *Einverständigung, Tatbestand-ausschließenden Einwilligung und Handeln auf eigene Gefahr* **157**
8.1. *Knight v. Jewett* (3 Cal. 4th 296, 834 P.2d 696, 11 Cal. Rptr. 2d 2 (1992)) 158
8.2. STS, 1ª, 931/2001, de 17 de octubre 158
8.3. STS, 1ª, 580/2006, de 31 de mayo 159
8.4. STS, 1ª, 26/2012, de 30 de enero 160
8.5. Miller and Another v. Jackson and Others [1977] Q.B. 966 Court of Appeal (Civil Division), 1977-04-06 160

1. Imputación objetiva / *Proximate Causation; Scope of Liability*

La causalidad de hecho de los juristas, "*conditio sine qua non*" (*But-For test*), plantea, como vimos en la anterior Sesión 7ª, entre otros, un problema muy serio: la mayor parte de las leyes científicas –físicas, químicas, biológicas, psicológicas, económicas, sociológicas, etc.- no se formulan en términos de causalidad, pues la *conditio sine qua non* es muy poco excluyente, dice demasiado acerca de la determinación de un fenómeno, de la explicación y predicción de la realidad. Trasladado esto al territorio del derecho, significa que, con la causalidad en la mano, un juez o tribunal pueden imputar cualquier resultado a cualquier persona, por remota que haya sido su participación en la cadena causal. Nos podemos remontar a Adán y Eva, podemos atribuir los males de la patria a quienes nos conquistaron hace dos mil, mil o quinientos años y, desde luego, podemos condenar a los hijos en el vientre de sus madres. William Shakespeare, inventor de la condición humana, lo vio bien en el monólogo de Bruto, en la Escena 2ª, del Acto 2º de su Julio César:

Th' abuse of greatness is when it disjoins
Remorse from power. And, to speak truth of Caesar,
I have not known when his affections swayed
More than his reason. But 'tis a common proof
That lowliness is young ambition's ladder,
Whereto the climber upward turns his face.
But when he once attains the upmost round,
He then unto the ladder turns his back,
Looks in the clouds, scorning the base degrees
By which he did ascend. So Caesar may.
Then, lest he may, prevent. And since the quarrel
Will bear no colour for the thing he is,
Fashion it thus: that what he is, augmented,
Would run to these and these extremities.
And therefore think him as a serpent's egg—
Which, hatched, would as his kind grow mischievous—
And kill him in the shell.

De ahí que los juristas, que los hay y muchos, siempre hayan tratado de acotar o limitar, con criterios normativos, la ciega extensión de la causalidad. Los economistas, por su parte, también han puesto de manifiesto que la división del trabajo, condición del desarrollo tecnológico, resultaría imposible si todo el mundo hubiera de estar a cargo de todas los accidentes que ocurren, mientras que los sociólogos han puesto el acento en que a cada rol social corresponde un círculo de incumbencias: el ciudadano de a pie puede responder por no haber llamado a la policía o a los bomberos, pero no por no haberse comportado como el uno o el otro. En las páginas que siguen, se elencan algunos de los criterios más sensatos, más probados, comenzando por los de la previsiblidad y proximidad: el efecto ha de ser previsible para quien ha de cargar con sus consecuencias y no ha de ser tan remoto que acabemos en un mundo en el cual todos pueden ser condenados por cualquier acontecimiento desagradable o terrible, pues al fin y al cabo todos somos parte de ese todo y nada habría ocurrido en el vacío.

En España la aportación clásica es de Fernando Pantaleón Prieto ("Causalidad e imputación objetiva: Criterios de imputación", en Asociación de Profesores de Derecho civil, *Centenario del Código Civil (1889-1989),* t. II, Madrid (1990), págs. 1561 y ss.):

"El problema de la existencia o no de nexo de causalidad entre la conducta del posible responsable y el resultado dañoso –lo que los anglosajones llaman *causation in fact*- no debe ser en modo alguno confundido con el problema, radicalmente distinto, de si el resultado dañoso causalmente ligado a la conducta en cuestión, puede o no ser 'puesto a cargo' de aquella conducta como 'obra' de su autor, de acuerdo con los criterios establecidos al efecto por el legislador, o deducidos por el operador jurídico de la estructura y función de las normas de responsabilidad correspondientes. No debe ser en modo alguno confundido, en suma, con el problema de si el resultado dañoso es o no *objetivamente imputable* a la conducta del demandado –lo que se ha llamado, en forma muy imprecisa, 'causalidad jurídica' (la *causation in law*, *legal causation* o *remoteness of damage* de los anglosajones) y lo que la doctrina alemana, con más precisión, denomina *objektive Zurechnung"* (págs. 1561 y 1562).

La idea de que los criterios de imputación objetiva del daño al comportamiento del causante reproducen muchos –si no todos- los elementos del deber de precaución ha sido defendida por

Pablo Salvador Coderch, Nuno Garoupa, Carlos Gómez Ligüerre, "El círculo de responsables. La evanescente distinción entre responsabilidad por culpa y objetiva", *InDret* 4/2005:

"La explicación tradicional del derecho de daños asocia la responsabilidad por culpa y la responsabilidad objetiva a la causación de un daño. La responsabilidad por negligencia exige, sin embargo y a diferencia de la denominada responsabilidad objetiva, que el causante haya infringido además un concreto deber de precaución. De acuerdo con esta explicación, los modelos del análisis económico del derecho asumen la distinción entre infracción del deber de precaución y causalidad cuando diferencian la responsabilidad objetiva de la negligencia. En cierto sentido, la distinción es obvia, pues el incumplimiento del deber de precaución crea o aumenta el riesgo de producción del daño mientras que la causalidad, definida con ayuda del (más que dudoso) criterio de la *condicio sine qua non*, evidencia la producción efectiva del perjuicio y, por tanto, la concreción de ese riesgo. Sin embargo, los criterios de imputación objetiva, que reproducen muchos –si no todos- de los elementos del deber de precaución, limitan el ámbito de eficacia tradicionalmente atribuido a la causalidad. Tras la adopción generalizada de los criterios de imputación objetiva, la distinción entre los dos regímenes de responsabilidad deviene poco operativa: la exigencia de imputación objetiva del daño al comportamiento de agente difumina las diferencias entre causación y deber de precaución, que se sitúan en un *continuum* a lo largo del trazado de una misma línea" (pp. 29-30).

Parecidamente, esta idea puede verse en Martín GARCÍA –RIPOLL MONTIJANO, *Imputación objetiva, causa próxima y alcance de los daños indemnizables*, Comares, Granada, 2008:

"Es claro que el legislador del art. 1902 C.c., o de los preceptos del C.p., no tiene en mente un curso causal determinado para considerar a alguien responsable de la muerte. Los cursos causales son infinitos y, evidentemente, no pueden ser previstos por el legislador. Es el jurista el que tiene que descubrir los principios que inspiran el Derecho para determinar si el curso causal es conforme a la norma que prohíbe actuar con riesgo de provocar determinado daño. Y ese principio es, en última instancia, la ilicitud de la conducta del agente (mediante dolo o negligencia): el sujeto será responsable hasta donde alcance su propia actividad ilícita (…). Es decir, las conductas son ilícitas para evitar un determinado resultado, pero no un resultado causado de cualquier manera, sino un resultado causado mediante una cadena de acontecimientos pro la que se estableció el deber de actuar de determinada forma (…) Por tanto, podemos decir que la ilicitud es un concepto de relación, y de una relación bipolar, entre dañante y dañado (…). [L]a atribución de responsabilidad no es un problema de causalidad, cuyo análisis es algo previo y distinto. Se trata de una cuestión de ilicitud de la conducta y esa es su sede propia (…) [E]l problema del límite de los daños indemnizables es exactamente el mismo que el de si el acto es ilícito (…). Por eso, los criterios que se suelen proponer para limitar la extensión de los daños suelen ser los mismos que cuando se trata de averiguar cuándo un acto es negligente. Así, la probabilidad de que se cause el daño, grado de control de la actividad sobre el resultado, la intención y los conocimientos del autor, costes de evitación del accidente, lugar (…), tiempo (…), etc., etc. (…) (pp. 127, 128, 129, 134).

— Pablo SALVADOR/Antonio FERNÁNDEZ, "Causalidad y Responsabilidad", 3ª ed., *InDret* 1/2006 (www.indret.com):

"Las insuficiencias y excesos del principio causal han llevado a los juristas a construir criterios normativos de imputación objetiva que permitan modularlo, es decir, ampliarlo o restringirlo según convenga. En el *Common Law*, la causalidad entendida como *conditio sine qua non (cause*

in fact) se matiza de acuerdo con una miríada de doctrinas sobre *proximate causation* con el objeto de descartar las causas más remotas (*remoteness test*), las más imprevisibles o improbables (*foresight test*) y las causas cuyo riesgo típico no llegó a materializarse efectivamente en el daño en cuestión (*harm-within-the-risk test)*. En el *Civil Law,* sobresale la cultura alemana de la imputación objetiva *(Objektive Zurechnung)*.

> El realismo jurídico intentó depurar el concepto de causa de toda connotación normativa, pero el intento fracasó y el libro más influyente sobre causalidad [HART/HONORÉ (1959) y (1985)] volvió a una concepción de la causalidad concebida como juicio fáctico-normativo que, basada en el sentido común, abarcaba la causalidad de hecho y la imputación objetiva (véase, críticamente, WRIGHT (1985), (1988)).

El problema es que muchos criterios de imputación objetiva se detienen en el nivel de las propuestas doctrinales. Pocas leyes los han hecho suyos, aunque podemos identificar algunos positivados de forma dispersa:

- Los arts. 154, 269, 389, 1596, 1903, 1905 y siguientes del Código Civil, que delimitan los roles sociales básicos a cuyo cargo se ponen los daños causados por personas distintas al demandado: padres, tutores, propietarios, empresarios, maestros.

- Los arts. 118, 120 y 121 del Código Penal de 1995 que, de forma paralela a lo establecido por el art. 1903 del Código Civil, definen roles familiares, sociales y económicos a los que la ley penal asocia el deber de responder civilmente por las consecuencias dañosas de los delitos y faltas cometidos por terceros a cargo o bajo el control o dependencia de quienes ejercen aquellos roles (padres, tutores, guardadores legales, empresarios, propietarios de vehículos, Administraciones públicas).

- En general, las disposiciones que regulan actividades, imponen deberes y delimitan con claridad posiciones de garante: por ejemplo, el art. 33 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza; el art. 1 de la Ley 22/1994; los arts. 139 y siguientes de la LRJAP.

- El art. 141 de la LRJAP según el cual *"sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley"* y que puede ser entendido, como veremos enseguida, en clave de riesgos generales de la vida.

La doctrina jurídica lleva más de un siglo discutiendo los tópicos sobre imputación y algunas propuestas han sido ocasionalmente utilizadas por la jurisprudencia. Las que siguen están tomadas, con algunas modificaciones, de la muy influyente obra del penalista alemán Günther JAKOBS ((1993), pp. 195 y ss., y (1996), pp. 90 y ss)".

2. Previsibilidad / *Foreseeability*

2.1. Palsgraf v. Long Island R.R. (N248 N.Y. 339, 162 N.E. 99 (1928))

APPEAL from a judgment of the Appellate Division of the Supreme Court in the second judicial department, entered December 16, 1927, affirming a judgment in favor of plaintiff entered upon a verdict.

CARDOZO, Ch. J.

Plaintiff was standing on a platform of defendant's railroad after buying a ticket to go to Rockaway Beach. A train stopped at the station, bound for another place. Two men ran forward to catch it. One of the men reached the platform of the car without mishap, though the train was already moving. The other man, carrying a package, jumped aboard the car, but seemed unsteady as if about to fall. A guard on the car, who had held the door open, reached forward to help him in, and another guard on the platform pushed him from behind. In this act, the package was dislodged, and fell upon the rails. It was a package of small size, about fifteen inches long, and was covered by a newspaper. In fact it contained fireworks, but there was nothing in its appearance to give notice of its contents. The fireworks when they fell exploded. The shock of the explosion threw down some scales at the other end of the platform, many feet away. The scales struck the plaintiff, causing injuries for which she sues.

The conduct of the defendant's guard, if a wrong in its relation to the holder of the package, was not a wrong in its relation to the plaintiff, standing far away. Relatively to her it was not negligence at all. Nothing in the situation gave notice that the falling package had in it the potency of peril to persons thus removed. Negligence is not actionable unless it involves the invasion of a legally protected interest, the violation of a right. "Proof of negligence in the air, so to speak, will not do" […]

If no hazard was apparent to the eye of ordinary vigilance, an act innocent and harmless, at least to outward seeming, with reference to her, did not take to itself the quality of a tort because it happened to be a wrong, […]

The risk reasonably to be perceived defines the duty to be obeyed, and risk imports relation; it is risk to another or to others within the range of apprehension[…]

Negligence, like risk, is thus a term of relation. Negligence in the abstract, apart from things related, is surely not a tort, if indeed it is understandable at all […]

The law of causation, remote or proximate, is thus foreign to the case before us. The question of liability is always anterior to the question of the measure of the consequences that go with liability. If there is no tort to be redressed, there is no occasion to consider what damage might be recovered if there were a finding of a tort.

ANDREWS, J. (dissenting).

But we are told that "there is no negligence unless there is in the particular case a legal duty to take care, and this duty must be one which is owed to the plaintiff himself and not merely to others." (Salmond Torts [6th ed.], 24.) This, I think too narrow a conception. Where there is the unreasonable act, and some right that may be affected there is negligence whether damage does or does not result. That is immaterial. Should we drive down Broadway at a reckless speed, we are negligent whether we strike an approaching car or miss it by an inch. The act itself is wrongful. It is a wrong not only to those who happen to be within the radius of danger but to all who might have been there— a wrong to the public at large. Such is the language of the street. Such the language of the courts when speaking of contributory negligence. Such again and again their language in speaking of the duty of some defendant and discussing proximate cause in

cases where such a discussion is wholly irrelevant on any other theory. (Perry v. Rochester Line Co., 219 N. Y. 60.) As was said by Mr. Justice HOLMES many years ago, "the measure of the defendant's duty in determining whether a wrong has been committed is one thing, the measure of liability when a wrong has been committed is another." (Spade v. Lynn & Boston R. R. Co., 172 Mass. 488.) Due care is a duty imposed on each one of us to protect society from unnecessary danger, not to protect A, B or C alone.

The proposition is this. Every one owes to the world at large the duty of refraining from those acts that may unreasonably threaten the safety of others. Such an act occurs. Not only is he wronged to whom harm might reasonably be expected to result, but he also who is in fact injured, even if he be outside what would generally be thought the danger zone. There needs be duty due the one complaining but this is not a duty to a particular individual because as to him harm might be expected. Harm to some one being the natural result of the act, not only that one alone, but all those in fact injured may complain. We have never, I think, held otherwise. Indeed in the *Di Caprio* case we said that a breach of a general ordinance defining the degree of care to be exercised in one's calling is evidence of negligence as to every one. We did not limit this statement to those who might be expected to be exposed to danger. Unreasonable risk being taken, its consequences are not confined to those who might probably be hurt.

Lego Law: Palsgraf v. Long Island Railroad -
http://www.youtube.com/watch?v=mDEbTudkjhc

2.2. STS, 1ª, 597/1996, de 19 de julio

El 12 de septiembre de 1987, hacia el atardecer, un tractor que remolcaba una voluminosa carga de paja subía por la calle de la Amargura de Santa Cristina de Valmadrigal (Valladolid) cuando, al poco de iniciar la cuesta, la paja rozó una línea de baja tensión que cruzaba la calle y cuyos cables habían perdido el aislante. Al contacto, saltó una chispa, la paja prendió, ardió toda la carga, algunas pavesas volaron, llevadas por el calor y el viento, hasta la ventana abierta de una casa vecina, ardió una cortina y con ella toda la casa. Sus propietarios demandaron 105.857 € al conductor del tractor, a su propietario, a la aseguradora con la que el propietario tenía contratado el seguro obligatorio de vehículos, a quien había sido propietario del remolque, así como a "Electromolinera de Valladolid" que explotaba la línea eléctrica y a la aseguradora de la responsabilidad civil de esta última. La Sentencia de primera instancia condenó a los demandados a pagar a los actores una indemnización de 59.748 €. En apelación, la Audiencia mantuvo la condena, especificando que el conductor, el propietario del tractor y la aseguradora debían responder de un 60% de la indemnización, y Electromolinera de Valladolid y su aseguradora, del 40% restante, pero absolvió al propietario del remolque pues entendió *"que era excesivo atribuir una responsabilidad in vigilando al propietario de un vehículo de por sí inmóvil"*. El Tribunal Supremo estimó en parte el recurso de casación de tres de los propietarios demandantes en el único sentido de imponer el pago de los intereses legales desde la sentencia de primera instancia y confirmó el resto de pronunciamientos de la SAP:

"[A]unque esta Sala tiene establecido que puede incluirse en el precepto (art. 1903), ampliado por analogía, a la relación de comodato y por tanto la conducta del dueño de un vehículo que lo cede a persona inexperta para conducir y causa con él un grave accidente (...) [E]n el caso que nos ocupa (...) falta el presupuesto inexcusable de una relación jerárquica para la responsabilidad por hecho ajeno o indirecta (...) máxime si se tiene en cuenta, como hace la Audiencia, que el remolque es de por sí un objeto inmóvil, que solo puede ser arrastrado por

otro, siendo al propietario y conductor de este (del automóvil) a quienes debe abarcar la responsabilidad, al último incluso por la colocación de la carga, sin que aparezca clara la incardinación del supuesto en el no 1o del art. 1908, para exigir tal responsabilidad [al propietario del remolque] (...), pues, repetimos, no aparece acción u omisión achacable (por indemostrada) al mismo, ni se le puede realizar una imputación puramente objetiva".

3. *Proximate Cause* / Causalidad Adecuada / *Adäquanztheorie*

3.1. Stahlecker v. Ford Motor Company (266 Neb. 601, 667 N.W.2d 244 (2003))

This is a civil action for damages resulting from the injury and wrongful death of Amy M. Stahlecker (Amy). Appellants, Susan Stahlecker and Dale Stahlecker, parents of the deceased and special administrators of her estate, alleged that during the early morning hours of April 29, 2000, Amy was driving a 1997 Ford Explorer equipped with Firestone Wilderness AT radial tires in a remote area of western Douglas County, Nebraska, when one of the tires failed, rendering the vehicle inoperable. They further alleged that Richard Cook encountered Amy "alone and stranded" as a direct result of the tire failure and that he assaulted and murdered her. The Stahleckers brought this action against Ford Motor Company (Ford), the manufacturer of the vehicle; Bridgestone/Firestone, Inc. (Firestone), the manufacturer of the tire; and Cook. The district court for Dodge County sustained demurrers filed on behalf of Ford and Firestone and dismissed the action as to those parties. We affirm.

The Stahleckers alleged that "long before April 29, 2000," Ford and Firestone had actual knowledge of "the defective nature of the Ford Explorer's Firestone tires and their propensity to unexpectedly blow out causing wide-ranging results that included stranding and rollovers." The Stahleckers alleged that Ford and Firestone withheld this knowledge from consumers and the general public and advertised the Ford Explorer equipped with Firestone tires as "dependable when used under similar circumstances as Amy was using them during the early morning hours of April 29, 2000."

In order to prevail in a negligence action, a plaintiff must establish the defendant's duty to protect the plaintiff from injury, a failure to discharge that duty, and damages proximately caused by the failure to discharge that duty. […]by alleging that Ford and Firestone failed to exercise reasonable care in designing and manufacturing their tires, and failed to warn users of potential tire defects, the Stahleckers have alleged the existence of a legal duty and a breach thereof by both Ford and Firestone. The remaining issue is whether the breach of this duty was the proximate cause of Amy's harm.

The proximate cause of an injury is "that cause which, in a natural and continuous sequence, without any efficient, intervening cause, produces the injury, and without which the injury would not have occurred." […] Stated another way, a plaintiff must meet three basic requirements in establishing proximate cause: (1) that without the negligent action, the injury would not have occurred, commonly known as the "but for" rule; (2) that the injury was a natural and probable result of the negligence; and (3) that there was no efficient intervening cause[…]

As to the first requirement, a defendant's conduct is the cause of the event if "the event would not have occurred but for that conduct; conversely, the defendant's conduct is not a cause of the event if the event would have occurred without it." Haselhorst v. State, 240 Neb. at 899, 485 N.W.2d at 187. In this case, accepting as true the allegations of the operative amended petition, the first element of proximate causation is established. The petition alleges that Cook "found Amy alone and stranded as a direct result of the failure of the Firestone Wilderness AT Radial Tire and proceeded to abduct, terrorize, rape and murder Amy." Firestone concedes that under the factual allegations of the Stahleckers' petition, that " 'but for' " the failure of its tire, Amy would not have been at the place where she was assaulted and murdered.

The second and third components of proximate causation are somewhat interrelated. Was the criminal assault and murder the "natural and probable" result of the failure to warn of potential tire failure, or did the criminal acts constitute an effective intervening cause which would preclude any causal link between the failure to warn and the injuries and wrongful death for which damages are claimed in this action? An efficient intervening cause is a new, independent force intervening between the defendant's negligent act and the plaintiff's injury. […] This force may be the conduct of a third person who had full control of the situation, whose conduct the defendant could not anticipate or contemplate, and whose conduct resulted directly in the plaintiff's injury […].

This principle requires that we determine whether the duty owed to Amy by Ford and Firestone, as manufacturers and sellers of the allegedly defective tires, included a duty to anticipate and guard against criminal acts perpetrated against the users of such tires. […]

Generally, we have recognized a duty to anticipate and protect another against criminal acts where the party charged with the duty has some right of control over the perpetrator of such acts or the physical premises upon which the crime occurs […].

We have found no authority recognizing a duty on the part of the manufacturer of a product to protect a consumer from criminal activity at the scene of a product failure where no physical harm is caused by the product itself. […] The Stahleckers argue that a duty to anticipate criminal acts associated with product failure arises from their allegations that Ford and Firestone knew or should have known of "the potential for similar dangerous situations arising as a result of a breakdown of a Ford Explorer and/or its tires resulting in danger to its consumers and users from criminal activity, adverse weather conditions, inability to communicate with others or any combination thereof." They also allege that Ford and Firestone had or should have had "knowledge, to include statistical information, regarding the likelihood of criminal conduct and/or sexual assault against auto and tire industry consumers as a result of unexpected auto and/or tire failures in general." Assuming the truth of these allegations, the most that can be inferred is that Ford and Firestone had general knowledge that criminal assaults can occur at the scene of a vehicular product failure. However, it is generally known that violent crime can and does occur in a variety of settings, including the relative safety of a victim's home. The facts alleged do not present the type of knowledge concerning a specific individual's criminal propensity, or right of control over premises known to have been the scene of prior criminal activity, upon which we have recognized a tort duty to protect another from criminal acts. The Stahleckers have not and could not allege any special relationship between Ford and Firestone and the criminal actor (Cook) or the victim of his crime (Amy) which would extend their duty, as manufacturers and sellers of products, to protect a consumer from harm caused by a criminal act perpetrated at the scene of a product failure […].

Although the operative amended petition alleges sufficient facts to establish that Ford and Firestone negligently placed defective products on the market which caused Amy to become stranded at night in a remote location, it alleges no facts upon which either Ford or Firestone would have a legal duty to anticipate and guard against the criminal acts which were committed at that location by another party. Therefore, the criminal acts constitute an efficient intervening cause which necessarily defeats proof of the essential element of proximate cause.

Affirmed.

3.2. STS, 1ª, 255/1997, de 1 de abril

Un atracador forcejeó e hirió con una navaja a la actora, una mujer que, de madrugada, había entrado en un local con cajero automático de la entidad bancaria luego demandada. El pestillo de la puerta estaba roto. La actora reclamó a la demandada una indemnización de 90.152 €. En primera instancia su demanda fue estimada en parte, pero la entidad demandada recurrió en apelación y la Audiencia Provincial desestimó íntegramente la demanda. El TS confirmó la decisión de la Audiencia con razones referidas a la causalidad adecuada:

"(…) para la determinación de la existencia de la relación o enlace preciso y directo entre la comisión u omisión -causa- y el daño o perjuicio resultante -efecto-, la doctrina jurisprudencial aplica el principio de causalidad adecuada, que exige que el resultado sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de la voluntad; (...) una relación de necesidad conforme a los conocimientos normalmente aceptados y debiendo valorarse en cada caso concreto, si el acto antecedente que se presenta como causa, tiene virtualidad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria el efecto lesivo producido (...) [E]s precisa la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo" (F.D. 2º).

Obsérvese el tránsito, sin solución alguna de continuidad, de la causalidad adecuada a la culpabilidad, entendida como infracción de un deber de precaución.

3.3. STS, 1ª, 377/2004, de 12 de mayo

Un perro, de raza doberman y cuyo propietario era Lázaro, se escapó, entró en la finca colindante y vecina, propiedad de Millán y Claudia, y comenzó a pelearse con el perro de éstos. Tras forcejear para separarlos, Millán sufrió una parada cardiaca que le provocó la muerte. Por estos hechos se iniciaron actuaciones penales que fueron archivadas por auto de 20.5.1996. La viuda de Millán viuda demandó a Lázaro y solicitó una indemnización de 55.896,18 €. El JPI nº 3 de Tortosa (17.11.97) estimó íntegramente la demanda en aplicación del art. 1905 CC que establece una responsabilidad objetiva del poseedor de animales: *"[e]l poseedor de un animal, o el que se sirva de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido"*. El demandado apeló y la AP de Tarragona (Sección 3ª, 3.2.1998) estimó en parte su recurso en el sentido de rebajar la cuantía de la indemnización a 27.948,08 € porque consideró la contribución de la propia víctima al daño:

"Respecto de si este infarto fue directamente causado por la pelea del perro del actor o bien fue una circunstancia casual (…) debemos concluir, con el Juez «a quo», que hubo una relación directa entre el hecho de que el perro del demandado penetrase en la finca del señor S. y el hecho de que éste muriese, y ello porque (…) lo cierto es que tenemos a una persona de 66 años con una gravísima dolencia cardíaca (…); tenemos, además, una situación de tensión, como es la pelea del propio perro, provocada por la invasión, por parte del perro del demandado, de su finca, siendo este perro mayor y de raza especialmente agresiva y fuerte; y, finalmente, un especial esfuerzo necesario para separar ambos perros. Del conjunto de estos factores se extrae la conclusión, basada en el informe forense (…) [de que] el esfuerzo exagerado (…) habrí[a] aumentado sus requerimientos de irrigación miocárdica que las válvulas coronarias no podían suplir, colapsando una de ellas (…).

[S]i atendemos a la teoría de la causalidad adecuada, según invoca la sentencia recurrida (…) y esto es que el resultado sea consecuencia virtual y suficiente de la determinación del evento dañoso, resulta que en este caso concurrió otra causa muy relevante, la previa grave enfermedad del fallecido, sin la cual no se podía haber producido el fallecimiento, causa que a su vez concurrió por una cierta imprudencia de la víctima, ya que, conocedor el señor S. como nadie de su grave estado, debería haber dejado que su esposa intentase separarlos o intentarlo con otros métodos (manguerazo de agua) o incluso dejar que se peleasen (…) Por tanto, hubo dos causas relevantes, la invasión por el perro y la intervención del señor S., pese a su enfermedad cardíaca, que por sí no hubieran dado lugar al desenlace, pero que juntas resultaron fatales, al interaccionar ambas entre sí, sin que pueda darse mayor relevancia a una y otra" (FD. 4º).

El TS desestimó el recurso de casación del demandado y confirmó la SAP:

[D]e una manera incuestionable y a través de una hermenéusis lógica y racional en la sentencia recurrida se llega a la conclusión basada en un informe pericial del médico forense que afirma que el "desenlace -muerte- era de preveer debido a estas placas ateromatosas obstructivas en las coronarias", que indican un enlace causal, preciso y directo entre la entrada violenta del perro y la muerte de [Lázaro]" (FD. 2º).

3.4. STS, 3ª, de 18 de mayo de 2010

El 10.11.2000, Salvador, quien cumplía condena de privación de libertad, impuesta por Sentencia de 15.11.2000, por sendos delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas, se fugó del Hospital Carlos de la Haya donde recibía tratamiento médico, tras liberarse de los grilletes que lo esposaban a la cama y aprovechando que el policía encargado de su custodia se encontraba en el aseo como consecuencia de una momentánea indisposición. El 13.4.2001, con ocasión de un altercado al haber varios coches mal aparcados, Salvador disparó a Fructuoso, causándole lesiones en una pierna que determinaron su amputación por encima de la rodilla y su incapacidad permanente total. La SAP de Alicante (Sección 1ª, 13.2.2004) condenó a Salvador como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito de tenencia ilícita de armas con la agravante de reincidencia y a indemnizar a Fructuoso en 4.717,26 euros por gastos y en 300.000 euros por la secuela y daños morales.Fructuoso interpuso reclamación administrativa previa frente al Ministerio del Interior, que la desestimó en resolución de 26.2.2007. La SAN (4.6.2008) estimó en parte el recurso contencioso-administrativo

interpuesto por Fructuoso y, tomando como base la indemnización determinada en la vía penal, imputó a la Administración la mitad de la cantidad concedida por daños personales más los gastos (154.717,26 euros), porque "no puede dejarse de apreciarse una conducta en algún aspecto negligente en la custodia del preso" (FD 4º STS) y "de no haberse producido el funcionamiento anormal de los servicios públicos, la fuga no habría tenido lugar y, en consecuencia, tampoco la agresión… En suma, la intervención del tercero en la causación del daño tuvo gran relevancia pero no la intensidad bastante para romper totalmente el nexo causal" (FD 2º STS). El TS desestimó los recursos de casación interpuestos por ambas partes y confirmó la SAN:

"[E]s preciso que haya algún punto de conexión entre el daño y el servicio público, que puede ser por lo general "directo, inmediato y exclusivo", pero, en ocasiones basta [que sea] "indirecto, sobrevenido y concurrente con hechos dañosos de terceros o de la propia víctima"… Así, en la [STS, 3ª, 4.6.2002, RJ 6292] dijimos: "… que no son admisibles… restricciones derivadas de otras perspectivas tendentes a asociar el nexo de causalidad con el factor eficiente, preponderante o socialmente adecuado o exclusivo para producir el resultado dañoso, puesto que –válidas como son en otros terrenos- irían en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. La consideración de hechos que pueden determinar la ruptura del nexo causal, a su vez, debe reservarse para aquéllos que comportan fuerza mayor… a los cuales importa añadir el comportamiento de la víctima en la producción… del daño, o la gravísima negligencia de ésta…" (FD 3º).

"En supuestos similares… hemos declarado que… los perjudicados no tienen el deber jurídico de soportar los riesgos derivados de los inevitables fracasos penitenciarios, sino que deben ser compartidos en virtud del principio de solidaridad por el conjunto de la sociedad que sufraga el gasto público, ya que la lesión causada al particular se asimilaría a una obligación pública… que… debe repartirse entre todos…" (FD 4º)

"[A]preciamos la existencia de una concurrencia de causas, determinante de una moderación en el quantum indemnizatorio…" (FD 4º).

Véase, en el mismo sentido, la STS, 1ª, 3.3.2010 (RJ 2441), en un caso en el que un preso falleció por agresión con arma blanca en los lavabos de la prisión: "la imprescindible relación de causalidad entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso producido puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes (aunque admitiendo la posibilidad de una moderación de la responsabilidad en el caso de que intervengan otras causas, la cual debe tenerse en cuenta en el momento de fijarse la indemnización)" (FD 6º).

4. Riesgos generales de la vida / *General Life Risks / Erlaubte Risiken*

4.1. STS, 3ª, 29 de octubre de 1998

Un joven que se arrojó al mar desde un rompeolas murió ahogado. Su madre pretendió responsabilizar a la Junta de Cantabria por no haber señalizado el lugar como peligroso. En vano: el mar siempre lo es y no es razonable señalizar toda la costa. Parecidamente, la **STS, 3ª, 8.4.2003** resuelve un caso en el que una viandante sufrió daños en sus rodillas al golpearse

contra un muro a causa de un fuerte golpe de mar que superó el Muro de San Lorenzo del paseo marítimo de Gijón (Asturias). El Tribunal Supremo desestimó las pretensiones de la actora sirviéndose de los criterios del riesgo general de la vida y de la asunción de riesgos por parte de la víctima, pues, debido al temporal, la policía municipal había cortado el tráfico en el paseo marítimo y había advertido a los viandantes de que tuvieran cuidado al transitar por la zona. El Tribunal afirmó:

"De ello se deduce la ruptura del nexo causal conforme a los criterios anteriormente mencionados, toda vez que las lesiones producidas no son imputables al funcionamiento del servicio público y sí al proceder de la accidentada hoy actora, toda vez que como señala la resolución recurrida «quien pese a la evidencia del temporal existente no dudó en circular por la zona donde lo hizo, sin duda convencida de que podía hacerlo sin riesgo alguno para su integridad física».

"Es por ello que pese a la obligación de la Administración demandada del mantenimiento de las condiciones mínimas y elementales de seguridad de las calles y paseos públicos locales, toda vez que las entidades de la Administración local tienen la obligación inexcusable de mantener tales vías públicas abiertas a la circulación peatonal y viaria, en condiciones tales que la seguridad de quienes la utilizan esté normalmente garantizada, en el caso enjuiciado, no puede invocarse imprevisión de la Policía Municipal, al adoptar idénticas medidas que la propia reclamante, por lo que un hecho inesperado conlleva la imposibilidad de procurar medios adecuados para su evitación, toda vez que el golpe de mar que superó el «Muro» de San Lorenzo y alcanzó a la recurrente resultó inesperado, razones todas ellas que llevan a la desestimación del recurso interpuesto, sin que la prueba testifical practicada sea suficiente para desvirtuar lo anteriormente reseñado." (FD 3º).

4.2. STSJ Comunidad Valenciana, Sala C-A, Secc. 1ª, 55/2003, de 2 de enero

La doctrina del riesgo general de la vida no sólo se aplica a riesgos derivados de causas naturales, sino también a riesgos creados por el ingenio humano. En este sentido, la STSJ Comunidad Valenciana, Sala C-A, Secc. 1ª, 55/2003, de 2 de enero resolvióp un caso en el que la víctima falleció al ser arrollada por un tren mientras cruzaba por un paso a nivel en la estación de Benimámet (Valencia). Todas las señales funcionaban correctamente y el conductor no sólo había utilizado las señales acústicas correspondientes sino que, al advertir que alguien cruzaba la vía, disminuyó la velocidad hasta casi detener el tren en el momento de la colisión. El Tribunal desestimó el recurso interpuesto por los familiares de la víctima al afirmar que:

"[a]a causa eficiente del accidente fue la propia conducta de Dña. Marí Luz [...] Podría plantearse la existencia de responsabilidad por la propia existencia del paso a nivel en el ámbito urbano, mas entiende la Sala que los mismos -aun cuando sea deseable su desaparición por la paulatina conversión de las líneas en subterráneas en las zonas urbanas y así parece que se realiza con las de nueva construcción- son necesarios para el normal funcionamiento del servicio público y lo que es exigible a las Administraciones Públicas implicadas es el establecimiento de las medidas de seguridad legalmente previstas. Una vez establecidas éstas, en correcto funcionamiento y desplegada la diligencia exigible por los empleados (como es el caso), no puede imputarse a dichas Administraciones la producción de accidentes por la inobservancia de las medidas por los usuarios" (FD 5º).

5. Prohibición de regreso y posición de garante / *Remoteness* / *Regressverbot und Garantenstellung*

No cabe retroceder en el curso causal e imputar a un agente las consecuencias originadas por la interposición del comportamiento ilícito de un tercero. Así, no cabe responsabilizar al deudor que pagó una deuda al acreedor por el crimen que éste perpetró luego con armas adquiridas gracias al dinero pagado. La doctrina en cuestión sólo puede analizarse con precisión en sede de autoría y participación, materia muy alejada del objeto de estas notas. Aquí bastará con indicar que el demandado no responderá salvo que hubiera estado en posición de garante en el momento en que ocurrieron los hechos. En derecho civil y en materia de responsabilidad por culpa, los deberes de precaución de un agente social para con los demás, o bien se definen institucionalmente por la ley (padres, maestros, empleadores, propietarios, anfitriones, amigos), o bien se establecen primero social y después jurisprudencialmente para cada sector específico del tráfico.

El ejemplo clásico de prohibición del regreso es la interposición de una conducta dolosa de un tercero y sobre todo si es criminal. Así, la jurisprudencia de la Sala Tercera rechazaba históricamente las reclamaciones de las víctimas de delitos, pues consideraba que su comisión derivaba exclusivamente de la actuación voluntaria del delincuente, pero no del funcionamiento de los servicios públicos de seguridad ciudadana. Sin embargo, el criterio de la prohibición del regreso admite muchas modulaciones normativas y la evolución de la jurisprudencia española da razón de alguna muy significativa.

La **STS, 3ª, de 16 de diciembre de 1997** inició un cambio de nota: condenó a la Administración central del Estado a pagar 75.121 € a la viuda de la víctima de un robo con homicidio perpetrado por dos reclusos que disfrutaban de un permiso penitenciario. Otras han seguido después: por ejemplo, las **SSAN, Sala C-A, Secc. 4ª, de 30 de mayo de 2001** y **de 20 de marzo de 2002**: dos casos trágicamente gemelos protagonizados por los mismos delincuentes que cometieron sendos robos con homicidio consecutivos, el mismo día y contra dos taxistas; uno de los autores había sido objeto de una medida cautelar en un centro de internamiento de extranjeros en trámite de expulsión, posteriormente había cumplido una condena de dos semanas en prisión pero, en lugar de ser devuelto al centro de internamiento, había sido puesto en libertad, circunstancia que aprovechó para asaltar a sus víctimas con ayuda de un tercero. La primera sentencia condenó a la Administración a pagar 132.222,66 € y, la segunda, 120.202 €. También conforman esta línea jurisprudencial las SSTS, 3ª, 25.5.2000, 4.6.2002, 14.10.2004 y 18.5.2010 o la más reciente:

STS, 3ª, de 29 de noviembre de 2011

El 17.7.2002 se produjo un atraco en la oficina de Caja Madrid sita en la calle Toledo, número 77, de Madrid. Cesáreo, empleado de dicha entidad, recibió un disparo de Marino, a quien se le había concedido un permiso penitenciario de salida mediante Auto de 11.1.2002 del Juez de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla-León. Como consecuencia del disparo, Cesáreo sufrió una herida penetrante abdominal en hipocondrio izquierdo y quedó en situación de incapacidad permanente absoluta.

Cesáreo reclamó una indemnización de daños y perjuicios al Ministerio del Interior. La Secretaria General Técnica, por delegación del Ministro del Interior, desestimó la reclamación mediante resolución expresa de 16.6.2008.
Acto seguido, la víctima interpuso, contra la resolución de la Secretaria General Técnica del

Ministerio del Interior, recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la AN. El 30.9.2009, la AN dictó sentencia con la cual estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo formulado por Cesáreo y condenó al Ministerio al pago de 250.000 euros, en concepto de daños y perjuicios, sin costas.

La Administración del Estado interpuso recurso de casación contra la sentencia de la AN. El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado y condena en costas a la Administración. En particular, el TS desestima el recurso de casación asumiendo que la Administración ha de responder de los daños derivados del fracaso de los permisos carcelarios. En efecto, la concesión de un permiso carcelario no implica la desaparición de la relación existente entre el interno y la Administración "consecuencia de la denominada relación de 'supremacía especial', de la que dimanan un conjunto de derechos y deberes entre ambos, y que no quedan en suspenso o desaparecen durante los periodos de permiso, sino que continúan, incluso fuera del centro penitenciario" (FJ 1o), sin desconocer que, en casos como los de autos, el hecho causante del resultado dañoso no dimana directamente de la actividad o de los servicios de la Administración.

El TS fundamenta su decisión sobre una doctrina jurisprudencial ya sentada por la Sala 3a (SSTS de 7.10.1997, 25.5.2000, 4.6.2002, 14.10.2004 y 18.5.2010), afirmando que "(...) la obligación de soportar individualmente el daño sufrido no puede imputarse a los perjudicados cuando éstos no tienen el deber jurídico de soportar los riesgos derivados de los inevitables fracasos penitenciarios, sino que deben ser compartidos en virtud del principio de la solidaridad por el conjunto de la sociedad que sufraga el gasto público (...)" (FD 3º).

De la Sala 2ª del Tribunal Supremo, véase la **STS, 2ª, 966/2001, de 29 de mayo**: recluso durante un permiso hirió y violó a una mujer. En este último caso en vía penal, el TS negó la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración *ex* artículo 121 del Código Penal porque los presos no son funcionarios públicos, al tiempo que sugirió reclamar por error judicial vía artículos 292 y ss. LOPJ.

6. Ámbito de protección de la norma / *Harm within the Risk / Schutzbereich der Norm*

6.1. STS, 1ª, 902/1998, de 8 de octubre

Un trabajador había muerto atropellado por un camión cuando, al dirigir la operación de su carga, se situó tras un punto ciego del vehículo y éste le aplastó. En la demanda, su viuda e hijos alegaron que el conductor del camión no poseía el certificado de aptitud de manejo de maquinaria minera exigido por el art. 117 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985, de 2 de abril). El TS confirmó las sentencias desestimatorias de las instancias, pues:

"[l]a ausencia de dicho permiso es irrelevante en este caso" (F.D. 2º).

6.2. STS, 3ª, 3 de noviembre de 2008

A las 11:30 h. del 29.11.1996, Patricia, celadora en el centro de especialidades del complejo hospitalario "Xeral Calde" (Lugo), dependiente del Servicio Gallego de Salud ("SERGAS"), bajaba en el ascensor de dicho complejo cuando, debido a un fallo mecánico, el ascensor cayo desde la

3ª planta, chocando con el amortiguador situado en el foso del sótano del edificio. Como consecuencia del accidente, Patricia sufrió traumatismos múltiples y precisó de atención psiquiátrica hasta 1998. La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Lugo (29.1.1999) declaró que las secuelas derivadas del accidente de trabajo por Patricia eran constitutivas de invalidez permanente absoluta en grado de gran invalidez y reconoció el derecho de ésta a percibir una pensión mensual de 1.404,84 € con un recargo del 50% por falta de medidas de seguridad.

Patricia demandó al "SERGAS" y a la Xunta de Galicia y solicitó una indemnización de 1.031.171,25 €, que la Conselleria denegó por silencio administrativo. El TSJ Galicia (Sección 1ª, 3.3.2004) estimó el recurso contencioso administrativo y condenó a las administraciones codemandadas al pago de 300.500 €

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por el "SERGAS" y la Xunta de Galicia. El TS, tras desestimar los argumentos por los cuales la demandante debería haber llamado al proceso a la empresa fabricante del ascensor y la encargada de su mantenimiento, analizó el motivo central del recurso, a saber, si la existencia de una relación de empleo público entre víctima y Administración anulaba la responsabilidad patrimonial de esta última. El TS resolvió que, por más que el daño se hubiera producido en el desarrollo de una relación de servicio público, el accidente quedaba fuera de los riesgos inherentes al ejercicio de su profesión, de manera que la lesión era antijurídica, máxime cuando la empleada no tuvo la más mínima intervención en el accidente (F. D. 5º).

7. Provocación / *Provocation* / *Herausforderung*

— STS, 2ª, de 26 de septiembre de 2005

La víctima, detenida ilegalmente por Víctor M. y Rafael, sufrió lesiones personales y daños en la ropa al arrojarse por la ventana para huir de sus captores cuando éstos la estaban amenazando con bisturís, cable eléctrico y una pistola para que se quitara la ropa. La SAP Madrid de 4.10.2004 condenó a los acusados, Víctor M. y Rafael, por sendos delitos de robo con intimidación, detención ilegal y delito contra la integridad moral, pero les absolvió de indemnizar a la víctima. El Tribunal Supremo, en cambio, estimó el recurso de casación, revocó la SAP e imputó objetivamente los daños a la conducta de los culpables condenándoles a indemnizar a la víctima con 21.600 € por las lesiones, 3.083,41 € por las secuelas y 81,30 € por los daños en la ropa. El Tribunal resolvió:

"En el caso que se analiza la situación coactiva o la presión ocasionada por el delito contra la integridad moral fue la desencadenante de las lesiones y daños sufridos. El perjudicado no se las produjo por su propia voluntad. Si existía algún resquicio para eludir la acción criminal, no puede impedírsele esa posibilidad, obligándole a soportar aquel delito y no consta que hubiera podido eludir la acción criminal sin tales riesgos, traducidos en daños corporales y materiales, que, por lo tanto, deben considerarse vinculados y objetivamente imputables a la acción delictiva anterior de los acusados, tipificada en el delito contra la integridad moral del art. 173.1 CP".

8. Consentimiento de la víctima y asunción del propio riesgo / *Victim's consent and assumption of risk / Einverständigung, Tatbestand-ausschließenden Einwilligung und Handeln auf eigene Gefahr*

No es imputable al agente el resultado dañoso cuando el bien jurídico lesionado es disponible y la víctima prestó su consentimiento al acto, como tampoco lo es en el caso en que la víctima asumió el riesgo del daño a un bien jurídico indisponible. Este criterio suele ser aplicado para exonerar de responsabilidad al demandado cuando el demandante participó voluntariamente en cualquier tipo de práctica deportiva, realizó una actividad peligrosa a sabiendas del riesgo que conllevaba o invadió una finca ajena sin consentimiento del titular.

En la práctica de diferentes deportes habitualmente se aplica la asunción del riesgo por parte de la víctima (José PIÑEIRO SALGUERO, *Responsabilidad civil, práctica deportiva y asunción de riesgos*, Civitas, Cizur Menor, 2009).

La primera sentencia que reconoció la asunción del riesgo durante la práctica deportiva fue la **STS, 1ª, de 22 de octubre de 1992**: un aficionado a la pelota vasca perdió un ojo al recibir un pelotazo de su contrincante. La víctima demandó a su contrincante y a la "Compañía Nacional Hispánica Aseguradora, SA" y solicitó una indemnización de 60.324,18 €. El Tribunal Supremo declaró haber lugar al recurso interpuesto por la entidad demandada, revocó las sentencias estimatorias de la instancia y desestimó las pretensiones del actor. El Tribunal afirmó que *"en materia de juegos o deportes de este tipo la idea del riesgo que cada uno de ellos pueda implicar —roturas de ligamentos, fracturas óseas, etc.—, va insita en los mismos y consiguientemente quienes a su ejercicio se dedican lo asumen, siempre claro es que las conductas de los partícipes no se salgan de los límites normales ya que de ser así podría incluso entrar en el ámbito de las conductas delictivas dolosas o culposas*" (FD 5º).

Este criterio de imputación de daños ha sido aplicado continuadamente por el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones: **STS, 1ª, 244/1999, de 18 de marzo**: esquiadora murió al chocar contra la caseta de un transformador eléctrico cuando descendía una pista de esquí sobre un plástico; **STS, 1ª, 859/2001, de 27 de septiembre**: alumna de un curso de golf golpeó con el palo a su monitora al errar un golpe; **STS, 1ª, 931/2001, de 17 de octubre**: joven aficionado al rafting murió ahogado tras caer al agua y golpearse con una roca; **STS, 3ª, 1 de julio de 2002**: una participante en un encuentro de fútbol femenino sufrió una fractura compleja distal en el radio izquierdo.

El Tribunal Supremo también recurre a la asunción del riesgo en casos en los que la propia víctima realiza una actividad peligrosa a sabiendas del peligro que conllevaba. La **STS, 1ª, 215/1998, de 12 de marzo** nos muestra un caso de autopuesta en peligro por parte de la víctima: una tarde de julio y para aliviarse del agobiante calor, un joven de 17 años, que no sabía nadar, decidió refrescarse en una charca próxima a la carpintería en la que trabajaba. Al día siguiente, la Guardia Civil lo encontró ahogado. Los actores reclamaron 60.101 € a la empresa de carpintería. Las instancias desestimaron la demanda y el TS no admitió el recurso de los actores.

En último lugar, son relativamente frecuentes los casos de daños sufridos por una persona que se adentró en una finca ajena sin consentimiento de su propietario. En este sentido, véase la

STS, 1ª, 240/2004, de 2 de abril: la víctima se adentró en una fábrica abandonada a través de un agujero de una de las vallas y, ya en el interior, accedió a un transformador de electricidad propiedad de "Fuerzas Eléctricas de Cataluña, SA" (FECSA) y se apoyó en un interruptor, a consecuencia de lo cual sufrió una descarga eléctrica que le provocó la pérdida de ambas manos. El TS estimó el recurso interpuesto por FECSA aplicando criterios de prohibición de regreso y de asunción del riesgo: la conducta ilícita del actor de acceder a una finca ajena y vallada para coger tuberías de cobre interfirió en el curso causal de los hechos y propició el accidente, con independencia del riesgo que entrañaba la actividad de suministro eléctrico. Además, tal conducta suponía la aceptación de un grave riesgo por el sujeto *"habida cuenta de la peligrosidad que entraña el acceso sin control a una edificación [...] por persona desconocedora de las contingencias nocivas inherentes a la misma"* (FD 2º).

8.1. *Knight v. Jewett* (3 Cal. 4th 296, 834 P.2d 696, 11 Cal. Rptr. 2d 2 (1992))

The plaintiff sued the defendant for personal injuries arising out of a touch football game. There was some dispute as to the defendant's conduct which caused the plaintiff's injury. According to the plaintiff, after the plaintiff caught a pass, the defendant ran into her from the rear, knocking her down, and stepping on her hand. The defendant's version was that he collided with the plaintiff in an unsuccessful attempt to intercept the pass. The defendant moved for summary judgment, arguing that the plaintiff assumed the risk of injury by participating in the game. The trial judge granted the motion, and that decision was affirmed by the Court of Appeal.

See Opinion on http://law.justia.com/cases/california/cal4th/3/296.html.

8.2. STS, 1ª, 931/2001, de 17 de octubre

El día 14.5.1994 Luis A.A. concertó con la "Asociación Deportiva Cultural Lur" una excursión para practicar rafting en el río Gállego, en el transcurso de la cual tres participantes cayeron al agua. Dos de ellos fueron recogidos en piraguas de apoyo, pero no fue posible salvar a Luis A.A. a pesar de que el monitor Santiago L.U. intentó subirlo a la balsa agarrándolo del brazo. Luis A.A murió en el acto por parada cardio-respiratoria determinada por traumatismo craneoencefálico con hemorragia subdural.

José A. R., padre de la víctima, demanda a Santiago L. U., "Asociación Deportiva Cultural Lur" y a la "Compañía de Seguros y Reaseguros Hermes, SA Grupo Fortuna" y reclama una indemnización de 60.241 €.

El JPI nº 1 de Ejea de los Caballeros (9.1.1996) y la AP de Zaragoza (sección 2ª, 7.5.1996) desestiman la demanda.

El TS desestima el recurso de casación:

"La ausencia de culpa, incluso en su mínimo grado de levísima, excluye la imputación subjetiva, porque se ha agotado por los demandados la diligencia que las circunstancias exigían.

Pero tampoco se aprecia responsabilidad desde la perspectiva de un exclusivo criterio de imputación objetivo, pues si la generación de determinados riesgos puede acarrear la responsabilidad civil por daño, en el sistema de culpa extracontractual del art. 1902 CC no cabe erigir el riesgo en factor único de la responsabilidad y es preciso que se dé una conducta

adecuada para producir el resultado dañoso. En el caso es cierto que existía una situación de riesgo (como dice la Sentencia recurrida el «rafting» es una actividad deportiva consistente en el deslizamiento mediante bote neumático por aguas bravas que debe calificarse de peligrosa, porque tiene para los participantes un indudable riesgo de vuelco o caída al agua por el propio recorrido turbulento de las aguas), pero se trataba de una actividad voluntaria, cuyo peligro era conocido por el solicitante, y el accidente se produjo dentro del ámbito del riesgo asumido y aceptado. Hubo asunción de riesgo, y no concurrió por parte de los demandados ningún incremento o agravación del riesgo asumido. Esta conclusión responde al criterio que viene siguiendo en concreto esta Sala en relación con supuestos similares. Y aunque no son muchas las resoluciones en materia de accidentes con ocasión de prácticas deportivas, cabe señalar por su semejanza casuística las Sentencias de 22 de octubre de 1992 (RJ 1992, 8399) (lesiones sufridas con ocasión de juego de pelota a pala), 20 de marzo de 1996 (RJ 1996, 2244) (accidente practicando el esquí), 20 de mayo de 1996 (RJ 1996, 3879) (colisión de lancha a motor con escollo sumergido a escasa profundidad en pantano) y 14 de abril de 1999 (RJ 1999, 3140) (accidente en curso de aprendizaje de parapente)" (FD. 4º).

8.3. STS, 1ª, 580/2006, de 31 de mayo

El 6.5.1989 y durante la 13ª etapa de la 44ª edición de la Vuelta Ciclista a España, que partía de Benasque con dirección a Jaca, uno de los participantes de un grupo de 180 ciclistas sufrió lesiones muy graves como consecuencia de la caída sufrida en el interior de un túnel insuficientemente iluminado con dos focos halógenos situados a unos 50 metros de la boca norte del túnel y diversas bombillas en el resto del recorrido. Antes de la carrera, su Director había indicado al Comisario de la misma que se habían tomado las medidas oportunas y que se cumplían todas las disposiciones. "Unipublic, S.A.", encargada de la organización y control de la carrera, había advertido del peligro al Jefe de la Unidad de Huesca de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, quien, a su vez, había encargado de forma verbal la iluminación a una empresa de Sabiñánigo.

Bruno demandó a "Unipublic, S.A." y "Caja de Seguros Reunidos, S.A." y solicitó una indemnización de 480.810 €.

El JPI de Boltaña (31.7.1998) estimó en parte la demanda y condenó a los demandados al pago de 360.607,26 € más el interés anual del 20% desde la fecha del siniestro. La AP de Huesca (15.7.1999) desestimó los recursos de apelación de los demandados, estimó el del actor y revocó la SJPI en el sentido de fijar la indemnización en 480.809,68 €.

El TS desestimó el recurso de casación de "Unipublic, S.A." y confirmó la SAP: "[f]unciones inherentes a la organización son (…) la de adoptar las medidas necesarias para evitar los riesgos propios de esta práctica deportiva, riesgos que son distintos de los que la propia competición genera y que, a diferencia de aquellos, los profesionales conocen y asumen voluntariamente como parte de su actividad (…) Es [la] falta de medidas de seguridad la que aparece como causa próxima y adecuada para producir el daño (…) [E]l daño aparecía como probable y lógico para quien organizaba la carrera y éste no se hubiera materializado de haberse celebrado en un escenario más favorable para la integridad y salud del ciclista" (F.D. 3º).

8.4. STS, 1ª, 26/2012, de 30 de enero

Rodolfo trabajaba en la empresa Ferpi, Transportes y Obras Sociedad Anónima (subcontratada por ACS, Proyectos, Obras y Construcciones Sociedad Anónima) cuando se produjo una explosión en las obras de construcción de un tramo de autovía A-6 (Tamón-Villalegre, Asturias), mientras procedía a la destrucción de los restos de cordón detonante sobrante de las voladuras.

Rodolfo demanda a Ferpi, Transportes y Obras Sociedad Anónima y a ACS, Proyectos, Obras y Construcciones Sociedad Anónima y solicita una indemnización de 859.942,34 euros.

El JPI núm. 10 de Gijón (29.9.2006) estima en parte la demanda y condena a Ferpi, Transportes y Obras Sociedad Anónima al pago de 237.079, 63 euros. La AP de Gijón (Sec. 7ª, 22.9.2008) estima el recurso interpuesto por la condenada y la absuelve.

El TS desestima el recurso de casación interpuesto por el demandante, porque entiende que "Es cierto que en casos de actividades especialmente peligrosas […] no es suficiente el cumplimiento de las normas y reglamentos, debiendo el empresario extremar su diligencia, Ahora bien, el riesgo que deriva de la manipulación de explosivos lo creó el propio lesionado, que lo conocía como parte de su actividad, pues no hubo ningún incremento o agravación imprevisible, desproporcionado o distinto del que figuraba en el manual de empleo de explosivos editado por la Unión Española de Explosivos, ni en particular en la ficha de seguridad del fabricante. […] Rodolfo, en la condición de ingeniero técnico de minas, con la especialidad de laboreo y explosivos, fue contratado para llevar la dirección facultativa de la obra. Siendo responsable de que se cumplieran las medidas de seguridad en el manejo de explosivos, tanto en su activación como destrucción lo que llevo a cabo a partir de un plan de voladuras que tenía a su disposición y que era suficiente para el desarrollo de dicha actividad en la forma que figuraba en aquella documentación. Asumió como tal el riesgo que finalmente se materializó al no alejarse a la distancia mínima de seguridad del lugar donde se había prendido fuego a los trozos de cordón detonante". (FD 4º).

8.5. Miller and Another v. Jackson and Others [1977] Q.B. 966 Court of Appeal (Civil Division), 1977-04-06

Injunction--Jurisdiction to grant--Nuisance--Houses built adjoining village cricket ground--Damage to property and potential danger to occupants--Action by householder for damages for negligence and nuisance and injunction against playing cricket--Liability established--Whether equitable remedy of injunction appropriate where public interest outweighing interest of private individuals.

Members of a village club played cricket in the evenings and at week-ends in the summer months on a small ground where cricket had been played since about 1905, when it was surrounded by agricultural fields. The ground was leased to the club by the owners, the National Coal Board, which in, 1965 sold part of the adjacent pasture land to the local council who in 1970 sold it to developers. A line of houses was built so sited that it was inevitable that so long as cricket was played on the ground some balls hit beyond the boundary would fall into the rear gardens or on to or against the houses, despite a six-foot concrete boundary fence.

In 1972 the plaintiffs bought one of the houses the rear garden of which had a boundary with the cricket ground. Soon after taking possession they began to complain of incidents causing actual damage to their house and apprehension of personal injury which interfered with their enjoyment of their house and garden whenever cricket was being played; and though in 1975 the club increased the height of the boundary fence to 15 feet, some balls continued to land in adjacent properties.

In 1975 the plaintiffs brought an action claiming damages for negligence and alternatively for nuisance, and an injunction to restrain the club from playing cricket on the ground without first taking adequate steps to prevent balls being struck out of the ground on to their house or garden. The defendants denied negligence and nuisance and also claimed that the plaintiffs had contributed to any injury, loss, or damage they might prove by refusing offers to fit shutters and unbreakable glass at the rear of their premises. Reeve J. awarded the plaintiffs damages for personal inconvenience and interference with their past enjoyment of their property at £30 a year for five years, and granted them the injunction in the terms asked for.

On appeal by the defendants:

Held:
(1) (Lord Denning M.R. dissenting) that the defendants, so long as they played cricket on that ground, were guilty of negligence every time a ball came over the fence and caused damage, for the risk of injury to person and property was continuous and no reasonable method of eliminating that risk had been produced; they were also guilty of nuisance since their use of their land involved an unreasonable interference with their neighbours' use and enjoyment of their house and garden; and the neighbours were under no duty to mitigate that risk.

Per Geoffrey Lane L.J. The court is bound by the rule in Sturges v. Bridgman (1879) 11 Ch.D. 852, which has never been questioned, that it is no answer to a claim in nuisance for the defendant to show that the plaintiff brought the trouble on his own head by coming to live so close to the defendant's premises that he would inevitably be affected by the defendant's activities where no one had been affected before. It is not for this court to alter a rule which has stood for so long (post, pp. 986H - 987B).

Sturges v. Bridgman (1879) 11 Ch.D. 852, C.A., considered.

Per Lord Denning M.R. The use of the ground for cricket was a most reasonable use; and it does not suddenly become a nuisance because a neighbour chooses to come to a house in a position where it might occasionally be hit by a cricket ball (post, pp. 980G - 981A). Nor is it negligence so as to give rise to a claim for damages (post, p. 982C-D).

But (2) (*per* Lord Denning M.R. and Cumming-Bruce L.J.) that the court in exercising its equitable jurisdiction to grant or refuse an injunction was under a duty to have regard to the public interest; and where the effect of an injunction would prevent cricket being played on a ground where it had been played for over 70 years, the special circumstances were such that the greater interest of the public should prevail over the hardship to the individual householders by being deprived of their enjoyment of their house and garden while cricket was being played; and for that reason the injunction should be discharged and damages of £400 substituted for past and future inconvenience.

Decision of Reeve J. reversed.

Capítulo 9º
Responsabilidad objetiva

1. Concepto general de responsabilidad objetiva. Distinciones con responsabilidad por culpa y responsabilidad absoluta 162
1.1 Relación con la responsabilidad por negligencia 162
1.2. Relación con la responsabilidad absoluta 163
1.3. El análisis económico de la responsabilidad objetiva 163
2. Actividades anormalmente peligrosas 166
2.1. La regla en el Restatement (Third) of Torts 166
2.2. La doble justificación de la responsabilidad objetiva: *Rylands v. Fletcher* ([1868] UKHL 1). 167
2.3. Rasgos de las actividades anormalmente peligrosas 169
3. Responsabilidad objetiva y relaciones de vecindad 171
4. La noción de responsabilidad objetiva por mera causación de daños 171
5. Ámbito de la responsabilidad objetiva 171
6. Regímenes legales de responsabilidad objetiva en derecho español 172
6.1. Accidentes de circulación 172
6.2. Administraciones públicas 174
6.3. Animales 178
6.4. Caza 181
6.5. Cosas que se arrojen o caigan de una casa 181
6.6. Energía nuclear 182
6.7. Medio ambiente 182
6.8. Navegación aérea 183
6.9. Productos defectuosos 184
6.10. Responsabilidad del propietario por los humos excesivos nocivos para las personas o las propiedades y caída de árboles colocados en sitios de tránsito 185
6.11. Servicios 186

1. Concepto general de responsabilidad objetiva. Distinciones con responsabilidad por culpa y responsabilidad absoluta

- En responsabilidad objetiva (RO), en *Strict Liability*, el demandado responde por haber causado un daño a la víctima aunque no haya incurrido en ningún género de culpa o negligencia.

1.1 Relación con la responsabilidad por negligencia

La regla de RO concierne actividades que entrañan un riesgo muy significativo de causar daños. A) Probabilidad de daño; B) gravedad del daño; y C) riesgos residuales, esto es, riesgos muy significativos que subsisten con la actividad a pesar de que todos los agentes implicados despliegan niveles razonables de cuidado. En los casos de actividades calificadas como anormalmente peligrosas, hay razones para recurrir a una regla de RO y proporcionar al demandado/causante los incentivos necesarios para que adopte decisiones socialmente deseables acerca de qué actividades llevar a cabo y de y qué volúmenes de actividad adoptar.

1.2. Relación con la responsabilidad absoluta

En aplicación de una regla de responsabilidad objetiva, resulta irrelevante examinar el estándar de cuidado adoptado por el demandado: si víctima o perjudicado prueban la relación de causalidad y no concurre ninguna causa de exoneración, aquél responderá civilmente con independencia de que hubiera sido diligente o negligente.

En los sistemas de compensación de daños basados en la responsabilidad absoluta, la responsabilidad se desliga, también, de toda conexión causal. Así pues, la causalidad – además del nivel de cuidado– resulta irrelevante para imputar las consecuencias previstas en la ley al demandado: la mera acreditación de un resultado puede bastar como fundamento de la responsabilidad en cuestión.

Los regímenes de responsabilidad absoluta sustituyen la labor judicial de identificación tanto de la relación causal como de la existencia e infracción de un deber de precaución: los responsables potenciales están identificados por la ley y, *ex post*, sólo resta comprobar la existencia, gravedad, tiempo y lugar del daño.

Es con todo discutible si son auténticos supuestos de responsabilidad absoluta aquellos en los cuales la causalidad solo se presume, por ejemplo, por concreción de riesgo en realización de conductas con riesgo característico. En dichos regímenes, la causalidad no deja de carecer de relevancia, sino que se presume y deberá ser el demandado quien, con mayor o menor laxitud, tendrá la carga de probar la falta de causalidad o imputación objetiva.

En el ámbito de la responsabilidad civil, la responsabilidad absoluta aparece en los sistemas de compensación de daños causados por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

1.3. El análisis económico de la responsabilidad objetiva

- Fernando GÓMEZ POMAR, "Carga de la prueba y responsabilidad objetiva", *InDret* 1/2001, pp. 2-4:

> "La distinción entre la regla de responsabilidad por culpa y la regla de responsabilidad objetiva es una de las […] básicas del Derecho de daños. Una y otra regla constituyen igualmente la dualidad esencial a la que se enfrentan el legislador y el juez a la hora de regular con normas de responsabilidad los comportamientos potencialmente dañosos.
>
> Los efectos de una y otra sobre las conductas de cuidado del causante (si el accidente es unilateral, esto es, su probabilidad de acaecimiento depende del comportamiento del dañante y no del de la víctima) o de causante y víctima (si el accidente es bilateral, esto es, su probabilidad de acaecimiento depende del comportamiento de ambos) han sido ampliamente estudiados por el análisis económico del Derecho de daños y no es necesario reproducirlos aquí. El lector interesado puede encontrar el tratamiento canónico de la materia en Steven Shavell, *Economic Analysis of Accident Law*, Cambridge (Mass.) (1987), p. 6 y ss.
>
> Lo que sí resulta oportuno recordar es el conjunto de resultados de la teoría económica de los accidentes por lo que respecta a las posibles ventajas comparativas de la responsabilidad objetiva sobre la responsabilidad por culpa.

1) Simplificación y menor propensión al error en los procesos

En la medida en que la regla de responsabilidad objetiva permite a los jueces y tribunales decidir la responsabilidad del demandado sin consideración hacia el nivel de diligencia exigible, y sin detenerse a determinar si el cuidado realmente observado por el demandado se ha atenido a tal nivel, los procedimientos judiciales en la materia serán, en buena lógica, más simples y menos costosos.

Al ser igualmente más predecible el resultado (ya que una posible fuente de incertidumbre, que es la decisión de si el demandado ha sido o no negligente, queda por definición obviada) se incrementará la tasa de transacción extrajudicial de las reclamaciones de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual.

Por añadidura, si se supone, como parece realista hacer, que los jueces y tribunales pueden cometer errores en la determinación del estándar de la diligencia exigible y/o en la valoración del ajuste de la conducta del demandado a tal estándar, el atractivo de la regla de responsabilidad objetiva, que elimina de raíz toda posibilidad de error al respecto, se acrecienta.

Esta ventaja "procesal" de la responsabilidad objetiva frente a la culpa es, en buena medida, más teórica que real. Y no sólo porque bajo un régimen de responsabilidad objetiva es esperable que se produzcan más reclamaciones indemnizatorias y, por tanto, mayor número de litigios y de costes procesales globales que bajo un régimen de culpa. La razón es más sutil y procede del hecho de que, con regla de la culpa o sin ella, siempre será necesario examinar en el proceso, además de la causalidad material, la imputación objetiva del daño causado a la conducta del causante. Y como este juicio de imputación objetiva no es conceptualmente distinguible del análisis coste-beneficio de la conducta del causante a la vista de sus costes de precaución, de la probabilidad del accidente y de la magnitud del daño, el proceso no resultará significativamente menos costoso bajo una regla de responsabilidad objetiva.

Esto deja como única motivo relevante de preferencia a favor de esta última regla el que se examina a continuación.

2) La peligrosidad de la actividad dañosa

Si el volumen de actividad potencialmente dañosa del causante (cuántos km. se conducen, cuántas horas vuela la compañía aérea, cuánto produce la empresa posiblemente contaminadora), y no sólo su inversión en cuidado o precaución, es un factor influyente sobre la probabilidad de acaecimiento del daño, la regla de responsabilidad por culpa se ve incapaz de inducir en el causante los niveles de actividad socialmente más deseables.

Al causante, a fin de eludir el pago de la indemnización, le basta con alcanzar el nivel de cuidado exigible, esto es, ser diligente. Siendo diligente, pues, no se enfrenta al riesgo de abonar indemnización alguna por los daños resultantes de su actividad, de modo que la regla de la culpa no le incentivará a adoptar el volumen de actividad más adecuado desde el punto de vista de la reducción eficiente de los daños derivados de

aquélla. Escogerá, en cambio, el nivel de actividad que le resulta personalmente más ventajoso, y que será superior al más conveniente desde el punto de vista del bienestar social.

La regla de responsabilidad objetiva, por el contrario, sí fuerza al causante a internalizar el coste externo de su actividad: como, con independencia de su mayor o menor cuidado, tendrá que pagar por todo el daño causado, le conviene, por propio interés, elegir el nivel de actividad que hace máxima la diferencia entre la utilidad resultante de la actividad y el daño producido, y éste es precisamente el nivel que dicta la maximización del bienestar social.

Esta ventaja frente a la de la culpa no resulta demasiado relevante cuando la actividad potencialmente generadora de daños no es en sí peligrosa, es decir, cuando se trata de una actividad que, si se realiza con la precaución requerida por el estándar de la diligencia exigible, presenta un riesgo reducido de producir daños (más técnicamente: la probabilidad del daño evaluada en el punto de la diligencia exigible es baja). Aunque el volumen de la actividad del causante supere lo deseable socialmente, el daño resultante no es significativo.

Por contra, la comentada deficiencia de la regla de la culpa sí se convierte en preocupante en relación con actividades que se pueden calificar de intrínsecamente peligrosas: en ellas, el daño esperado es importante aun cuando el agente actúe con toda la diligencia exigible. Este daño esperado puede ser alto tanto como consecuencia de la elevada probabilidad de que ocurra el daño como por la elevada magnitud de éste, aun siendo reducida la probabilidad del mismo (piénsese, por ejemplo, en una central nuclear: la probabilidad de escape puede ser pequeña si se opera con diligencia, pero si un tal evento de baja probabilidad tiene lugar, el resultado dañoso es verdaderamente catastrófico).

Tratándose de actividades inherentemente peligrosas redunda, pues, con claridad, en interés de la sociedad que quien desarrolla la actividad no exceda los niveles de ésta que son socialmente óptimos. La consecuencia es, en principio, la preferencia de la responsabilidad objetiva como regla de responsabilidad para una actividad de esa naturaleza.

En puridad, en los ámbitos de accidente bilateral es preciso tomar en consideración también el volumen de actividad de la potencial víctima. La incidencia sobre éste de ambas reglas de responsabilidad es, bajo ciertos supuestos, precisamente el opuesto al que se acaba de exponer. Se puede soslayar esta objeción, sin embargo, suponiendo simplemente que el análisis se limita a los accidentes unilaterales (aéreos, medioambientales) y a aquellos bilaterales en los que en relación con el daño esperado el nivel de actividad del causante es más trascendente que el de la víctima.

En términos más técnicos de probabilidad, sean:

X = “falta de cuidado del causante” (en otros términos, “negligencia”)
~X = “no X”, (por tanto, “diligencia del causante”)
Y = “acaecimiento del daño”
Prob (Y/X) = probabilidad de Y condicionada a que haya ocurrido X
Prob (Y/~X) = probabilidad de Y condicionada a que no haya ocurrido X.

Una actividad se puede definir como intrínsecamente peligrosa si el cociente

$$\frac{\text{Prob (Y/X)}}{\text{Prob (Y/}\sim\text{X)}}$$

es sólo ligeramente superior a 1.

Este resultado del cociente indica que la observación o constatación de que ha ocurrido Y, esto es, el daño, no es una buena señal o indicio de si X ha ocurrido o no, es decir, de si el causante actuó con negligencia. Y, recuérdese, precisamente es en casos como éstos en los que la regla de responsabilidad objetiva aparece como preferible a la regla de responsabilidad por culpa".

2. Actividades anormalmente peligrosas

2.1. La regla en el Restatement (Third) of Torts

§ 20 RTT. Abnormally Dangerous Activities

(a) An actor who carries on an abnormally dangerous activity is subject to strict liability for physical harm resulting from the activity.
(b) An activity is abnormally dangerous if:
  (1) the activity creates a foreseeable and highly significant risk of physical harm even when reasonable care is exercised by all actors and
  (2) the activity is not one of common usage.

Elementos de la regla:

(a) Cuidado razonable desplegado por todos los agentes (*reasonable care is exercised by all actors*). Con frecuencia será el agente que desarrolle una actividad el que estará mejor situado para controlar los riesgos que aquélla genere. Con todo, no deberá considerarse únicamente la diligencia desplegada por el causante potencial, sino también la de otros agentes implicados en la actividad, ya sean terceros o las propias víctimas potenciales de daños. La regla de RO persigue proteger a "personas inocentes que sufren un daño" ("the innocent person who suffers harm") a resultas de un "riesgo inevitable de daño inherente a la actividad del causante" ("unavoidable risk of harm that is inherent in the defendant´s activity"). Una actividad no debería reputarse como inherentemente e inevitablemente peligrosa si los cuidados razonables que pueden adoptar sus víctimas potenciales sirven habitualmente para reducir o evitar la producción de accidentes. Tampoco debería aplicarse sin más una regla de RO en una clase de víctimas será enteramente inocente si los daños que sufren se deben con frecuencia a su propia omisión en desplegar medidas de precaución razonables. En general, cuando la tasa de accidentes en una constelación de casos se debe a la combinación de decisiones de conducta por parte de causantes y víctimas potenciales, se debilitan los argumentos a favor de una regla de RO, fundados en la prevención o en una visión ética de la regla.

(b) Previsibilidad (*forseeability*). En general, el favorecimiento de reglas de RO se incrementa cuando el causante conoce efectivamente los riesgos propios de la actividad en cuestión. Con relación a la mayoría de actividades anormalmente

peligrosas, los causantes potenciales conocen de hecho los riesgos inherentes a su conducta [la responsabilidad por riesgos no previsibles es referida en ocasiones como "responsabilidad absoluta"].

(c) Riesgo altamente significativo (*highly significant risk*): véase apartado 1.

(d) Uso común (*common usage*). Una actividad que es normal o habitual no puede reputarse como anormalmente peligrosa. En este sentido, las jurisdicciones del *common law* norteamericano recurren a un estándar de "uso no natural" (*non-natural use*). El estándar de "uso no natural" es ambiguo y presenta, al menos, tres significados diferentes. En primer lugar, puede referir a un uso que se aleja del estado de naturaleza; en segundo lugar, significar un uso que no es común o usual; y, por último, describir un uso que es irrazonable o inapropiado a la luz de las circunstancias en una comunidad.

Una actividad será claramente de uso común si es llevada a cabo por una parte sustancial de la población en una comunidad. Cuando una mayoría significativa de la población desarrolla una determinada actividad, la ausencia de RO puede explicarse por principios de reciprocidad. Sin embargo, otras actividades también pueden ser de uso común aunque sean desarrolladas únicamente por un número limitado de actores (por ejemplo, el suministro de energía eléctrica o de gas llevado a cabo por una o pocas compañías mercantiles en una determinada comunidad). El concepto de uso común puede, por último, incluir además actividades que, aunque no muy frecuentes, resulten familiares en el marco de una comunidad. En estos casos, actitudes básicas del público tienden a la aceptación de riesgos familiares y tradicionales, a pesar de la general aversión frente a riesgos poco habituales o noveles.

Ejemplo: responsabilidad objetiva por daños causados en voladuras de edificios (residuos y escombros proyectados que dañan a propiedades colindantes o a personas que estuvieren en ellas).

2.2. La doble justificación de la responsabilidad objetiva: *Rylands v. Fletcher* ([1868] UKHL 1).

[The defendant retained and independent contractor to construct a pond in Lancaster, England. Beneath the land were old mine shafts that had long since been filled and covered. Neither the contractor nor the landlord discovered any reason for concern. The ponded water eventually broke through the debris in the shafts and flowed into them, then thorough horizontal shafts to flood the plaintiff´s mine.] a) "the person who for his own purposes brings on his land and collects and keeps there anything likely to do mischief if it escapes, must keep it at his peril" (Justice Blackbourn and Lord Cransworth); b) the defendant bears SL for harms caused by a "non-natural use" in the defendant´s land (Lord Chancellor Cairns). Ambiguity: "non-natural use" yields at least three possible meanings; it might be one that departs from a state of nature; it might be one that is uncommon or unusual, or it might be one that is unreasonable or inappropriate in light of the local circumstances.

[T]he Plaintiff (…) is the occupier of a mine and works under a close of land. The Defendants are the owners of a mill in his neighbourhood, and they proposed to make a reservoir for the purpose of keeping and storing water to be used about their mill upon another close of land, which, for the purposes of this case, may be taken as being adjoining to the close of the Plaintiff, although, in point of fact, some intervening land lay between the two. Underneath the close of land of the Defendants on which they proposed to construct their reservoir there were certain old and disused mining passages and works. There were five vertical shafts, and some horizontal shafts communicating with them. The vertical shafts had been filled up with soil and rubbish, and it does not appear that any person was aware of the existence either of the vertical shafts or of the horizontal works communicating with them. In the course of the working by the Plaintiff of his mine, he had gradually worked through the seams of coal underneath the close, and had come into contact with the old and disused works underneath the close of the Defendants.

In that state of things the reservoir of the Defendants was constructed. It was constructed by them through the agency and inspection of an engineer and contractor. Personally, the Defendants appear to have taken no part in the works, or to have been aware of any want of security connected with them. As regards the engineer and the contractor, we must take it from the case that they did not exercise, as far as they were concerned, that reasonable care and caution which they might have exercised, taking notice, as they appear to have taken notice, of the vertical shafts filled up in the manner which I have mentioned. However, my Lords, when the reservoir was constructed, and filled, or partly filled, with water, the weight of the water bearing upon the disused and imperfectly filled-up vertical shafts, broke through those shafts. The water passed down them and into the horizontal workings, and from the horizontal workings under the close of the Defendants it passed on into the workings under the close of the Plaintiff, and flooded his mine, causing considerable damage, for which this action was brought.

LORD CAIRNS:

My Lords, the principles on which this case must be determined appear to me to be extremely simple. The Defendants, treating them as the owners or occupiers of the close on which the reservoir was constructed, might lawfully have used that close for any purpose for which it might in the ordinary course of the enjoyment of land be used; and if, in what I may term the natural user of that land, there had been any accumulation of water, either on the surface or underground, and if, by the operation of the laws of nature, that accumulation of water had passed off into the close occupied by the Plaintiff, the Plaintiff could not have complained that that result had taken place. If he had desired to guard himself against it, it would have lain upon him to have done so, by leaving, or by interposing, some barrier between his close and the close of the Defendants in order to have prevented that operation of the laws of nature […].

[I]f the Defendants, not stopping at the natural use of their close, had desired to use it for any purpose which I may term a non-natural use, for the purpose of introducing into the close that which in its natural condition was not in or upon it, for the purpose of introducing water either above or below ground in quantities and in a manner not the result of any work or operation on or under the land, - and if in consequence of their doing so, or in consequence of any imperfection in the mode of their doing so, the water came to escape and to pass off into the close of the Plaintiff, then it appears to me that that which the Defendants were doing they were doing at their own peril; and, if in the course of their doing it, the evil arose to which I have

referred, the evil, namely, of the escape of the water and its passing away to the close of the Plaintiff and injuring the Plaintiff, then for the consequence of that, in my opinion, the Defendants would be liable. […]

LORD CRANWORTH:

My Lords, I concur with my noble and learned friend in thinking that the rule of law was correctly stated by Mr. **JUSTICE BLACKBURN** in delivering the opinion of the Exchequer Chamber. If a person brings, or accumulates, on his land anything which, if it should escape, may cause damage to his neighbour, he does so at his peril. If it does escape, and cause damage, he is responsible, however careful he may have been, and whatever precautions he may have taken to prevent the damage.

In considering whether a Defendant is liable to a Plaintiff for damage which the Plaintiff may have sustained, the question in general is not whether the Defendant has acted with due care and caution, but whether his acts have occasioned the damage. […]. And the doctrine is founded on good sense. For when one person, in managing his own affairs, causes, however innocently, damage to another, it is obviously only just that he should be the party to suffer. He is bound sic uti suo ut non laedat alienum. This is the principle of law applicable to cases like the present, and I do not discover in the authorities which were cited anything conflicting with it.

[…] I come without hesitation to the conclusion that the judgment of the Exchequer Chamber was right. […]. The Defendants, in order to effect an object of their own, brought on to their land, or on to land which for this purpose may be treated as being theirs, a large accumulated mass of water, and stored it up in a reservoir. The consequence of this was damage to the Plaintiff, and for that damage, however skilfully and carefully the accumulation was made, the Defendants, according to the principles and authorities to which I have adverted, were certainly responsible.

2.3. Rasgos de las actividades anormalmente peligrosas

Restatement (Second) of Torts (1977)

§ 520 RST. Abnormally Dangerous Activities

In determining whether an activity is abnormally dangerous, the following factors are to be considered:

> (a) existence of a high degree of risk of some harm to the person, land or chattels of others;
> (b) likelihood that the harm that results from it will be great;
> (c) inability to eliminate the risk by the exercise of reasonable care;
> (d) extent to which the activity is not a matter of common usage;
> (e) inappropriateness of the activity to the place where it is carried on; and
> (f) extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes.

Extracto de la ponencia del Juez Richard A. Posner en el asunto *Indiana Harbor Belt Railroad Co. v. American Cyanamid Co*., 916 F.2d 1174 (7th Cir. 1990):

"The roots of section 520 are in nineteenth-century cases. The most famous one is *Rylands v. Fletcher*, 1 Ex. 265, aff'd, L.R. 3 H.L. 300 (1868), but a more illuminating one in the present context is *Guille v. Swan*, 19 Johns. (N.Y.) 381 (1822). A man took off in a hot-air balloon and landed, without intending to, in a vegetable garden in New York City. A crowd that had been anxiously watching his involuntary descent trampled the vegetables in their endeavor to rescue him when he landed. The owner of the garden sued the balloonist for the resulting damage, and won. Yet the balloonist had not been careless. In the then state of ballooning it was impossible to make a pinpoint landing.

Guille is a paradigmatic case for strict liability. (a) The risk (probability) of harm was great, and (b) the harm that would ensue if the risk materialized could be, although luckily was not, great (the balloonist could have crashed into the crowd rather than into the vegetables). The confluence of these two factors established the urgency of seeking to prevent such accidents. (c) Yet such accidents could not be prevented by the exercise of due care; the technology of care in ballooning was insufficiently developed. (d) The activity was not a matter of common usage, so there was no presumption that it was a highly valuable activity despite its unavoidable riskiness. (e) The activity was inappropriate to the place in which it took place--densely populated New York City. The risk of serious harm to others (other than the balloonist himself, that is) could have been reduced by shifting the activity to the sparsely inhabited areas that surrounded the city in those days. (f) Reinforcing (d), the value to the community of the activity of recreational ballooning did not appear to be great enough to offset its unavoidable risks.

These are, of course, the six factors in section 520. They are related to each other in that each is a different facet of a common quest for a proper legal regime to govern accidents that negligence liability cannot adequately control [...]; Shavell, Strict Liability versus Negligence, 9 J. Legal Stud. 1 (1980). By making the actor strictly liable--by denying him in other words an excuse based on his inability to avoid accidents by being more careful--we give him an incentive, missing in a negligence regime, to experiment with methods of preventing accidents that involve not greater exertions of care, assumed to be futile, but instead relocating, changing, or reducing (perhaps to the vanishing point) the activity giving rise to the accident. [...]. The greater the risk of an accident ((a)) and the costs of an accident if one occurs ((b)), the more we want the actor to consider the possibility of making accident-reducing activity changes; the stronger, therefore, is the case for strict liability. Finally, if an activity is extremely common ((d)), like driving an automobile, it is unlikely either that its hazards are perceived as great or that there is no technology of care available to minimize them; so the case for strict liability is weakened.

The largest class of cases in which strict liability has been imposed under the standard codified in the Second Restatement of Torts involves the use of dynamite and other explosives for demolition in residential or urban areas. Restatement, supra, Sec. 519, comment d. Explosives are dangerous even when handled carefully, and we therefore want blasters to choose the location of the activity with care and also to explore the feasibility of using safer substitutes (such as a wrecking ball), as well as to be careful in the blasting itself. Blasting is not a commonplace activity like driving a car, or so superior to substitute methods of demolition that the imposition of liability is unlikely to have any effect except to raise the activity's costs".

3. Responsabilidad objetiva y relaciones de vecindad

Véanse artículos 389-391 Código Civil, en relación con los artículos 1907-1908.

RO y relaciones de vecindad (*private nuisance*): el régimen legal de RO por actividades anormalmente peligrosa parece tener su origen en problemas surgidos entre vecinos causados por usos incompatibles de sus fincas respectivas. La responsabilidad por un uso incompatible o inmisión puede fundarse en la conducta del demando consistente en el desarrollo de actividades inusuales o la creación de condiciones poco habituales en su finca que interfieren con el uso y disfrute de sus bienes por parte del actor. En el *common law*, una actividad del demandado que afecta al uso y disfrute privados de una finca es ilícita si se lleva a cabo negligentemente, si resulta anormalmente peligrosa o si la actividad es irrazonable y causa daños de forma intencional.

4. La noción de responsabilidad objetiva por mera causación de daños

Algunos académicos han abogado por universalizar el principio de RO, es decir, una regla de responsabilidad por todos los daños que pueda causar una persona en sus interacciones sociales. Se trata de una visión arraigada en el sentir de las gentes: con una alta probabilidad, el común de los ciudadanos responderá afirmativamente a la pregunta acerca de si una persona ha de responder por los daños que cause a un tercero. Cuando una persona actúa voluntariamente y al hacerlo obtiene los beneficios esperados de tal acción, resulta de justicia que haya de arrostrar con las consecuencias negativas derivadas de su acción. Con todo, una crítica a esta visión apunta que la mayoría de accidentes ocurren en la intersección literal o figurada de dos o más actividades. Por ello, la mera causalidad de hecho resulta un criterio indeterminado e insuficiente para la atribución de responsabilidad. Por ejemplo, cuando un tren arrolla un vehículo en un paso a nivel, el accidente tiene su origen tanto en el funcionamiento del tren como en la conducción del automóvil.

5. Ámbito de la responsabilidad objetiva

§ 24 RTT Scope of Strict Liability

Strict liability under §§ 20-23 does not apply

(a) if the person suffers physical or emotional harm as a result of making contact with or coming into proximity to the defendant´s animal or abnormally dangerous activity for the purposes of securing some benefit from the contact or that proximity.
(b) If the defendant maintains ownership or possession of the animal or carries on the abnormally dangerous activity in pursuance of an obligation imposed by law.

§ 25 RTT Comparative Responsibility

If the plaintiff has been contributorily negligent in failing to take reasonable precautions, the plaintiff´s recovery in a strict liability claim under §§ 20-23 for physical or emotional harm is reduced in accordance with the share of comparative responsibility assigned to the plaintiff.

6. Regímenes legales de responsabilidad objetiva en derecho español

6.1. Accidentes de circulación

1. **Artículo 1 del *Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre*:**

1. El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación.

En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos.

En el caso de daños en los bienes, el conductor responderá frente a terceros cuando resulte civilmente responsable según lo establecido en los artículos 1.902 y siguientes del Código Civil, artículos 109 y siguientes del Código Penal, y según lo dispuesto en esta Ley.

Si concurrieran la negligencia del conductor y la del perjudicado, se procederá a la equitativa moderación de la responsabilidad y al reparto en la cuantía de la indemnización, atendida la respectiva entidad de las culpas concurrentes.

El propietario no conductor responderá de los daños a las personas y en los bienes ocasionados por el conductor cuando esté vinculado con este por alguna de las relaciones que regulan los artículos 1.903 del Código Civil y 120.5 del Código Penal. Esta responsabilidad cesará cuando el mencionado propietario pruebe que empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.

El propietario no conductor de un vehículo sin el seguro de suscripción obligatoria responderá civilmente con el conductor del mismo de los daños a las personas y en los bienes ocasionados por éste, salvo que pruebe que el vehículo le hubiera sido sustraído.

2. Los daños y perjuicios causados a las personas, comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales, se

cuantificarán en todo caso con arreglo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de esta Ley.

3. Las indemnizaciones pagadas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 tendrán la consideración de indemnizaciones en la cuantía legalmente reconocida, a los efectos del artículo 7.d del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, en tanto sean abonadas por una entidad aseguradora como consecuencia de la responsabilidad civil de su asegurado.

4. Reglamentariamente, se definirán los conceptos de vehículos a motor y hecho de la circulación, a los efectos de esta Ley. En todo caso, no se considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes.

El artículo 1 del Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (RDL 8/2004) establece un régimen de responsabilidad objetiva para los daños a las personas, aunque conserva el régimen general de la responsabilidad por culpa en el caso de daños a los bienes. La STS, 1ª, Pleno, 536/2012, 10.9.2012 (MP: Juan Antonio Xiol Ríos), en un caso de causación de daños recíprocos y ausencia de prueba del grado de contribución causal de cada conductor, ha establecido un criterio de presunción de causalidad:

"[E]n trance de unificar la doctrina existente con efecto de fijación de jurisprudencia, dada la divergencia existente entre las distintas audiencias provinciales, nos inclinamos por entender que la solución del resarcimiento proporcional es procedente solo cuando pueda acreditarse el concreto porcentaje o grado de incidencia causal de cada uno de los vehículos implicados y que, en caso de no ser así, ambos conductores responden del total de los daños personales causados a los ocupantes del otro vehículo con arreglo a la doctrina llamada de las condenas cruzadas. Las razones en que se funda esta conclusión son las siguientes:

(a) Esta es la doctrina seguida por un número considerable de audiencias provinciales.

(b) Constituye una solución aceptada expresamente por alguna de las legislaciones de Derecho comparado…

(c) Es una doctrina próxima, aunque no coincida con ella, a la que inspira la jurisprudencia de esta Sala tendente a proclamar la solidaridad impropia entre los agentes que concurren a causar el daño cuando no puede establecerse la proporción en que cada uno de ellos ha contribuido a su producción.

(d) Es acorde con la tendencia que se registra en el Derecho comparado a atribuir responsabilidad plena a los causantes simultáneamente de un daño por una pluralidad de actividades (v. gr., PETL, artículo 3:102, según el cual: «En caso de una pluralidad de actividades, si cada una de ellas hubiera causado el daño por sí sola al mismo tiempo, se considerará que cada actividad es causa del daño de la víctima»).

(e) Es la doctrina más acorde con la presunción de causalidad, que rige en el sistema de responsabilidad objetiva por riesgo, en relación con el agente de la actividad peligrosa que interviene en la producción del daño característico de dicha actividad de riesgo (…)

En consecuencia, encontrándonos ahora en este último caso de incertidumbre causal, en que no se ha podido acreditar el concreto porcentaje en que ha contribuido el riesgo de cada vehículo al resultado producido, procede declarar a cada uno de sus conductores plenamente responsable de los daños sufridos por los ocupantes del otro vehículo implicado en la colisión, de tal manera que corresponde al demandado abonar el 100% de los daños personales reclamados por el recurrente que resulten acreditados" (FD. 4º).

6.2. Administraciones públicas

a) Reglas: arts. 139 y ss. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 139.1

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Artículo 141.1

Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

b) Casos

- **Infecciones nosocomiales: STS, 3ª, 5.10.2010 (RJ 6994). MP: *Luís María Díez-Picazo Giménez***

El 27.7.1999, un hombre de 77 años de edad, ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de Sagunt (Valencia) con molestias en el pecho y con sensación de ahogo. Le diagnosticaron un fallo ventricular izquierdo que conllevó una caterización vesical y en vena sin protección antibiótica. El 7.8.1999, su crítica situación aconsejó el traslado del paciente a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde falleció como consecuencia de un shock cardiogénico desencadenado por una infección renal.

Sonia y Saturnino, viuda e hijo del fallecido, reclamaron a la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana una indemnización de 450.759,08 euros por la pérdida, que fue desestimada por la Consellería en fecha 5.4.2004.

EL TSJ de la Comunidad Valenciana (19.5.2006) desestimó el recurso contencioso-administrativo.

El TS declara no haber lugar al recurso de casación por entender que la infección renal contraída no fue la causa exclusiva del fallecimiento, a pesar de que tuviese alguna incidencia en el mismo. El tribunal señala que:

> "[E]l mero hecho de haber contraído una infección en un hospital no puede dar derecho a una indemnización, ni siquiera cuando la infección tiene resultados tan graves como en este caso. Hay que destacar que, en el estado actual de la ciencia y de la técnica, el riesgo de infecciones es frecuente en los hospitales, sin que a menudo sea posible adoptar medidas eficaces para eliminarlo o paliarlo. Ello significa que contraer una infección en un hospital puede muy bien deberse a una fuerza mayor en el sentido del art. 139.1 LRJPAC y, por tanto, constituir una circunstancia excluyente de la responsabilidad patrimonial de la Administración" (FD 4º).

- **Biondas peligrosas: STS, 3ª, 1.12.2009 (RJ 8129).** ***MP: Luis María Díez-Picazo Giménez***

El 19.9.1999, Modesto circulaba en una motocicleta Ducati 750 por el carril izquierdo de la carretera nacional 340 en sentido Cádiz, a más velocidad de la permitida, patinó en un lugar mojado, cayó de la moto e impactó contra la valla de la mediana, que consistía en una bionda de carácter cortante, que le seccionó la pierna izquierda por encima de la rodilla y le produjo desgarros en la pierna derecha, erosiones y traumatismos.

Modesto reclamó al Ministerio de Fomento y solicitó una indemnización 440.588,73 €, por considerar que había actuado negligentemente al mantener ese tipo de vallas de carácter cortante, que el Ministerio denegó por silencio administrativo.

La SAN, Sección 8ª, 1.2.2005 (JUR 2005\222099) desestimó el recurso contencioso administrativo presentado por la actora, puesto que: "(…) la causa principal determinante del accidente fue la velocidad inadecuada para las condiciones existentes por parte del conductor de la motocicleta (…) [lo que] (…) permite concluir que no existe relación de causalidad entre el evento lesivo y el funcionamiento del servicio "(FD 2º).

El TS declaró haber lugar al recurso de casación y condenó a la Administración General del Estado a pagar la 120.000 € a la actora: "La velocidad inadecuada (…) fue la causa del accidente; pero la concreta y específica lesión padecida no se habría producido si la valla de la mediana hubiera sido de un tipo distinto (…) mientras que la velocidad inadecuada es imputable al recurrente, la existencia de la bionda lo es de la Administración. Ello implica la existencia de un nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño (…)" (FD 4º).

En particular, el Tribunal consideró que la Administración contribuyó en un 50% en la causación de los daños sufridos por la víctima: "[E]n el presente caso hay una concurrencia de culpas del recurrente y de la Administración (…) [y] lo cierto es que no hay razones de peso para calificar más negativamente el comportamiento del recurrente (…) que el riesgo asumido por la Administración al mantener las biondas. De ahí que la culpa deba repartirse por mitades." (FD 5º).

- **STS, 3ª, 9.10.2012. MP: Santiago Martínez-Vares García.**

FUNDAMENTOS DE DERECHO
(…)
SEGUNDO

La sentencia recurrida tiene como premisa los siguientes hechos que considera acreditados en su Fundamento Sexto: "1.- El actor, que contaba con 37 años de edad en octubre de 2002, y trabaja como camarero, acude al Centro de Asistencia Primaria del Temple de Tortosa, a los efectos de que se le administre por la ATS la vacuna antigripal del año 2002- 2003. No consta documento escrito de información respecto a las consecuencias y riesgos de la vacuna.

2.- La vacuna suministrada fue CHIROFLU [fabricada por "Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L"](…) 3.- A los diez días aproximadamente, de la inyección de dicha vacuna, comienza a tener sensación de cansancio en los miembros inferiores y superiores. Es ingresado en el Hospital de Tortosa. 4.- Al agravarse su estado clínico (…) es trasladado a [un] Hospital (…) de Tarragona, a la UCI, siendo diagnosticado de Síndrome de Guillain-Barré (…) [P]ersiste la grave disminución funcional sobre un 85 %, por lo que en junio de 2004 se le concede la invalidez absoluta."

[La sentencia recurrida declara no concurrir] "un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración (…)

En el presente caso, nos encontramos ante la administración de una vacuna antigripal con una finalidad de salud pública, previamente determinada en planes anuales, controlada internacionalmente, a los efectos de poder reducir el impacto de una epidemia de gripe en determinados colectivos considerados de riesgo (…) Las vacunas tienen pocas contraindicaciones ya que están especialmente estudiadas y controladas por la OMS (..) Las consecuencias y efectos secundarios de la vacunación son considerados poco importantes (…) Cuestión distinta, es lo que en el presente caso ha ocurrido y que determina lo que ya la Jurisprudencia del Tribunal Supremo - STS 20.4.2007 (RJ 2007, 4294) y algunos Tribunales Superiores de Justicia , como la reciente de Madrid de 19.7.2010 (JUR 2010, 309864), Sección 8 ª han dado en llamar "efectos adversos de una vacunación" o "reacciones impredecibles", que no permiten determinar la infracción de un deber de información que se revelaría desproporcionado absolutamente y que impediría el ejercicio de la función médica de curar puesto que todo medicamento y toda actuación en el ámbito de la salud, conlleva un riesgo. Es decir, si bien es cierto que puede ocurrir un resultado totalmente adverso, es tan impredecible o remotamente considerable, que no permite ofrecer información sobre ello (…)

QUINTO

El recurrente [en casación, el actor] sostiene que (…) el padecimiento de tetraparesia flácida y un grado de disminución funcional del 85%, (…) es un daño que no tiene el deber jurídico de soportar, al tratarse de un riesgo previsible según el estado del conocimiento de la ciencia, sin que concurra ningún supuesto de fuerza mayor (…)

[La sentencia] afirm[a] que de la prueba practicada se desprende que aquella reacción cabe ser considerada como rara, pero no como muy rara o excepcional, por ser su frecuencia de 1-9 casos cada 10.000 pacientes, en lugar de 0,5-1 cada millón de vacunados, como concluyen los peritos Don. Jesús Ángel Don. Vidal , y que es en cuyo conocimiento en el que el recurso dice que sustenta la sentencia la excepcionalidad de aquella reacción.

[E]n supuestos como [la] presente vacunación en todo caso voluntaria si bien aconsejada y promovida por la Administración por los beneficios sociales que de la misma derivan, es bastante con que en el acto de la inoculación del virus se advierta verbalmente a la persona que lo recibe de aquellas consecuencias leves que pueden presentarse y que desaparecerán en breve tiempo y se indique los medios para paliar sus efectos.

SEXTO

(…)

[E]l daño causado no dimana de la aplicación de las técnicas sanitarias conocidas por el estado de la ciencia y razonablemente disponibles en el momento; y que, igualmente, se acomodó a la "lex artis" en lo que demandaba el derecho de información del paciente. Ahora bien, es igualmente cierto que la obligación de soportar el daño sufrido no puede imputarse al perjudicado cuando éste no tiene el deber jurídico de soportar el riesgo que objetivamente debe asumir la sociedad en virtud del principio de solidaridad, como sucede en el particular y concreto supuesto que nos ocupa, difícilmente repetible fuera de su excepcionalidad, en el que se ha concretado en el reclamante un riesgo altamente infrecuente, pero de previsible aparición en el amplio ámbito de las campañas generales de vacunación, considerando además, según nos recuerda el informe del doctor Jesús Ángel , que éstas persiguen objetivos no solo particulares, sino también generales de salud pública, para la disminución de la incidencia o erradicación de enfermedades que, como la gripe, puede ser una enfermedad muy grave cuando se extiende de forma genérica a una población numerosa, con complicaciones también muy graves y fuerte absentismo laboral, y que una información excesiva de los riesgos de la vacunación sería un factor disuasorio a la adhesión de la campaña, cuyo éxito requiere de la máxima cobertura de la población por la vacuna; factores estos que justifican que los perjuicios de la programación anual de vacunación, previsibles y conocidos por el estado de la ciencia en el momento de la implantación de esta política de salud pública, sean soportados por toda la sociedad, porque así lo impone el principio de solidaridad y socialización de riesgos, con el fin de lograr un mejor reparto de beneficios y cargas (…)

SÉPTIMO

Reclama el recurrente ante la Administración de la Generalidad de Cataluña una indemnización de 468.699,42 euros, como resultado de las sumas que corresponden al periodo de estabilización de las lesiones, secuelas e incapacidad permanente absoluta, obtenidas a título orientativo de la aplicación del Baremo establecido para la valoración del daño corporal en el ámbito de los accidentes de automóviles, que apreciamos en su consideración global adecuada a la fecha de la reclamación judicial (…)

a) Bibliografía específica

- Oriol Mir Puigpelat, «Propuestas para una reforma legislativa del sistema español de responsabilidad patrimonial de la Administración», en Joaquín Ortiz Blasco/Petra Mahillo García (Coords.), *La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Crisis y propuestas para el siglo XXI*, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2009, pp. 33-60. Disponible en: http://www.ub.edu/dadmin/OriolMir/Publicacions/Mir_Propuestas_reforma_responsabilidad.pdf

6.3. Animales

a) Reglas en el Código Civil

Artículo 1905

El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa de que lo hubiese sufrido.

Artículo 1906

El propietario de una heredad de caza responderá del daño causado por ésta en fincas vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación o cuando haya dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla.

b) Artículo 33.1 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza

Los titulares de aprovechamientos cinegéticos, definidos en el artículo 6 de esta Ley, serán responsables de los daños originados por las piezas de caza procedentes de los terrenos acotados. Subsidiariamente, serán responsables los propietarios de los terrenos.

c) Accidentes de tráfico por atropellos de animales de caza

Disposición adicional novena de la **Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial**, aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (incorporada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial):

"En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación.
Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización".

d) Reglas administrativas

Un ejemplo: *Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos* (DOGC núm. 2948, de 9.8.1999).

e) Reglas en el *common law*

En el *common law*, los propietarios de ganado han respondido tradicionalmente de forma objetiva por los daños causados por la entrada de sus animales en fincas ajenas (*cattle trespass*). En cambio, los animales domésticos, como perros y gatos, han sido tratados jurídicamente de forma diferente: sus dueños o poseedores no responden objetivamente en ningún caso por daños causados por entradas en propiedades de terceros y únicamente se recurre a una regla de RO si el dueño conocía o debía conocer que su animal era anormalmente peligroso y el daño producido derivaba de tal peligro.

Por otra parte, la regla tradicional en el derecho inglés recurría a una regla de RO por daños causados por animales salvajes. ¿Qué pasa con los daños causados por elefantes y abejas?: los primeros eran considerados animales domésticos en algunas partes del antiguo Imperio Británico; no se aplicaba una regla de RO por picaduras de abejas a pesar de los usos productivos tradicionales de estos insectos.

§ 21 RTT Intrusion by Livestock or Other Animals

An owner or possessor of livestock or other animals, except for dogs and cats, that intrude upon the land of another is subject to strict liability for physical harm caused by the intrusion.

§ 22 RTT Wild Animals

(a) An owner or possessor of a wild animal is subject to strict liability for physical harm caused by the wild animal.
(b) A wild animal is an animal that belongs to a category of animals that have not been generally domesticated and that are likely, unless restrained, to cause personal injury.

§ 23 RTT Abnormally Dangerous Animals

An owner or possessor of an animal that the owner or possessor knows or has reasons to know has dangerous tendencies abnormal for the animal´s category is subject to strict liability for physical harm caused by the animal if the harm ensues from that dangerous tendency.

f) Casos

- **STS, 1ª, 20.12.2007 (Ar. 9054).** *MP: Ignacio Sierra Gil de la Cuesta*

Hechos: En las instalaciones de un circo, Braulio, sin autorización alguna y actuando a su riesgo, sorteó las vallas que delimitaban la jaula de los tigres, abrió el pestillo de seguridad que cerraba la trampilla a través de la cual se alimentaba a los animales, metió el brazo izquierdo en la jaula para introducir el recipiente utilizado para dar de beber a los tigres, y uno de ellos le arrancó el brazo de cuajo. Braulio, quien trabajaba en el circo, no era el cuidador habitual de los tigres y era plenamente consciente de la agresividad de los mismos.

Disposiciones estudiadas: artículo 1905 CC

Demanda: Braulio demandó a Bárbara, dueña de los animales, a su aseguradora y al Ayuntamiento de Vall d'Uxó, que había concedido la licencia de actividad, y solicitó una indemnización 420.708,47 € en concepto de lesiones permanentes.

Procedimiento: El JPI núm. 2 de Nules (12.2.1998) desestimó la demanda al apreciar culpa exclusiva de la víctima. La AP de Castellón (Sección 3ª, 1.9.2000) desestimó el recurso de apelación y confirmó la SJPI.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por Braulio fundado en la infracción del artículo 1905 CC. "La causa eficiente y adecuada de las lesiones sufridas por el actor se encuentra (...) en la propia conducta de aquél, quien, consciente y deliberadamente, asumió el riesgo que entrañaba una acción que se revela carente de toda prudencia, de tal forma que fue él quien voluntaria y conscientemente se situó en la posición de riesgo, y asumió y aceptó sus consecuencias, con lo que interfirió en el nexo causal entre el riesgo inherente a la tenencia y utilización de los animales y el resultado lesivo producido" (FD 2º).

- **STS, 1ª, 5.7.2011 (RJ 2011\5004).** *MP:* Francisco Marín Castán.

La mañana del 11 de octubre de 2002, Francisco circulaba en su bicicleta por una carretera local cerca de Ponte (Asturias) cuando fue atacado por un perro labrador suelto, sin correa ni bozal, cayó y se golpeó contra los escombros en la calzada procedentes de unas obras que ejecutaba por aquellas fechas la compañía Ferrovial Agromán S.A. A resultas de la caída, Francisco sufrió lesiones con secuelas invalidantes.

Francisco demandó a Inés, la propietaria del perro, a Artemio, quien lo había sacado a pasear y lo dejó suelto de la correa, y a Ferrovial Agromán S.A, y solicitó una indemnización de 182.554,46 €.

El JPI núm. 1 de Pravia (1.2.2007) estimó parcialmente la demanda: condenó a Ferrovial Agromán S.A. al pago de 43.331,55 € y estimó la excepción de prescripción alegada por los otros dos codemandados, a quienes absolvió. Interpuesto recurso de apelación por el actor, la AP de Asturias (Sección 4ª, 28.9.2007) lo estimó en parte, revocó la SJPI, y resolvió que la acción no se hallaba prescrita en relación con Inés y Artemio, a quienes condenó junto a Ferrovial Agromán S.A a indemnizar al actor los daños por un importe

que elevó hasta 151.663,1 € (a satisfacer una mitad por Ferrovial Agromán y la otra por Inés y Artemio). Según la AP, no resultaba relevante que el perjudicado hubiera reclamado extrajudicialmente –y, en efecto, hubiera interrumpido la prescripción– sólo contra Ferrovial Agromán S.A y no contra Inés y Artemio, sino que debía estarse como *dies a quo* a la fecha de consolidación de las secuelas del accidente y, contado el plazo así, la demanda contra aquellos se había interpuesto antes de transcurrido un año.

El TS desestima el recurso de casación interpuesto por Inés y Artemio y confirma la SAP. En caso de daños continuados, el plazo de prescripción empieza a contar a partir de la "definición del resultado o del conocimiento definitivo del quebranto padecido" (FJ 4º). Una declaración administrativa anterior declarando una incapacidad no tiene relevancia a efectos de la prescripción.

6.4. Caza

a) Art. 33.5 Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza

Todo cazador estará obligado a indemnizar los daños que causare con motivo del ejercicio de la caza, excepto cuando el hecho fuera debido únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor. En la caza con armas, si no consta el autor del daño causado a las personas, responderán solidariamente todos los miembros de la partida de caza.

6.5. Cosas que se arrojen o caigan de una casa

a) Artículo 1910 CC

El cabeza de familia que habita una casa o parte de ella, es responsable de los daños causados por las cosas que se arrojaren o cayeren de la misma.

b) STS, 1ª, 4.12.2007 (Ar. 2008\39). *MP: Francisco Marín Castán*

Hechos: El 21.7.1989, una maceta, que había sido colgada por la arrendataria con un aro de hierro en el balcón de un quinto piso de un inmueble de Madrid, se descolgó y cayó sobre la cabeza de la conserje de 65 años causándole la muerte en el acto. El día del accidente soplaba un fuerte viento. La propietaria, quien vivía en Barcelona, había arrendado el inmueble a Carina y tenía contratado un seguro multiriesgo de comunidades de propietarios con "AGF Unión Fénix, S.A.", cuya cobertura se limitaba a la responsabilidad civil del propietario del inmueble asegurado.

Disposiciones estudiadas: artículos 1902, 1907 y 1907 CC y 9 LPH reglas 2ª y 6ª.

Demanda: Bernardo, viudo de la fallecida, demanda a Romeo, Luis Enrique y Lourdes, viudo e hijos de la propietaria del piso, a "AGF Unión Fénix, S.A." y Carina, arrendataria del piso, y solicita una indemnización de 90.151,82 € por los daños y perjuicios sufridos por la muerte de su esposa con base en los artículos 1902 y 1903 CC.

Procedimiento: El JPI núm. 58 de Madrid (11.7.1997) estimó en parte la demanda, condenó a la arrendataria a pagar 48.080,97 € y absolvió al resto de demandados con base en el artículo 1910 CC, pues la primera y no la propietaria es la "cabeza de familia" a efectos del artículo citado. La AP de Madrid (Sección 13ª, 12.7.2000) desestimó el recurso de apelación interpuesto por la arrendataria y estimó el del demandante en el sentido de condenar a todos los demandados a pagar solidariamente 60.101,21 € con base en los artículos 1902, 1907 y 1910 CC y 9 LPH reglas 2ª y 6ª, pues la propietaria omitió la diligencia debida al no advertir a la arrendataria sobre el peligro que representaban las macetas.

El TS estimó los recursos de casación interpuestos por el viudo e hijos de la propietaria y la aseguradora, a quienes absolvió. La SAP infringió: a) el artículo 1907 CC, porque no se probaron las malas condiciones del aro que sujetaba la maceta; b) el artículo 1910 CC, que excluye de su ámbito al "propietario-arrendador de la vivienda"; y b) las reglas 2ª y 6ª del artículo 9 LPH al no estar el edificio sometido al régimen de propiedad horizontal. Finalmente, también infringió el artículo 1902 CC, porque la propietaria no incurrió en negligencia por no haber advertido a la inquilina del peligro que representaban las macetas, pues ello supondría "extender el ámbito del artículo 1910 CC a sujetos distintos del habitante de la casa (…) mediante la imposición al propietario-arrendador de un exacerbado deber de vigilancia o supervisión en la conducta del inquilino" (FD 2º).

6.6. Energía nuclear

a) Art. 45 Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear.

El explotador de una instalación nuclear o de cualquier otra instalación que produzca o trabaje con materiales radiactivos o que cuente con dispositivos que puedan producir radiaciones ionizantes, será responsable de los daños nucleares. Esta responsabilidad será objetiva y estará limitada en su cuantía hasta el límite de cobertura que se señala en la presente Ley.

Si el explotador prueba que la persona que sufrió los daños nucleares los produjo o contribuyó a ellos por culpa o negligencia, el tribunal competente podrá exonerar total o parcialmente al explotador de su obligación de abonar una indemnización por los daños sufridos por dicha persona.

No producirán responsabilidad para el explotador los daños nucleares causados por un accidente nuclear que se deba directamente a conflicto armado, hostilidades, guerra civil o insurrección o catástrofe natural de carácter excepcional.

6.7. Medio ambiente

a) Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

6.8. Navegación aérea

a) Arts. 120-121 Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea

Artículo 120.

La razón de indemnizar tiene su base objetiva en el accidente o daño y procederá, hasta los límites de responsabilidad que en este capítulo se establecen, en cualquier supuesto, incluso en el de accidente fortuito y aun cuando el transportista, operador o sus empleados justifiquen que obraron con la debida diligencia.

Artículo 121.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el transportista u operador responderá de sus propios actos y de los de sus empleados, y no podrán ampararse en los límites de responsabilidad que en este capítulo se establecen si se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión suya o de sus dependientes, en la que exista dolo o culpa grave. En el caso de los empleados habrá de probarse, además, que éstos obraban en el ejercicio de sus funciones.

b) STS, 1ª, 15.4.2009 (RJ 2009\1764). MP: Antonio Salas Carceller

Alumno de una escuela de vuelo fallece al caer en picado el ultraligero que pilotaba y estrellarse contra el suelo a gran velocidad.

El JPI núm. 3 de León, en sentencia de 8.10.2003, desestimó la demanda interpuesta por la viuda, actuando para sí y en representación de sus dos hijos menores, en reclamación de una indemnización de daños morales por importe de 170.000 €, contra "Aeroservicios León, S.L.", prestadora de los servicios de formación en vuelo, el instructor empleado de esta última, su compañía asegurada y el Consorcio de Compensación de Seguros.

Recurrida la SJPI por la viuda, la AP de León, Sección 2ª, estimó parcialmente el recurso en sentencia de 2.2.2004 y condenó a la sociedad "Aeroservicios León, S.L." y a su aseguradora, hasta el límite cubierto por la póliza suscrita, a satisfacer una indemnización de 140.776 €.

El TS desestima el recurso de casación interpuesto por "Aeroservicios León, S.L." y estima el de su compañía aseguradora, a quien absuelve de la condena indemnizatoria. El seguro suscrito por "Aeroservicios León, S.L." no fue el previsto en la normativa sobre navegación aérea, sino una general de responsabilidad civil que no cubría los accidentes producidos durante el vuelo de los ultraligeros.
En cuanto a la compañía prestadora de los servicios, el TS confirma la sentencia *a quo* y señala su responsabilidad objetiva en aplicación de la Ley 48/1960 sobre navegación aérea y del artículo 2 del Real Decreto 37/2001, que extiende el régimen de responsabilidad objetiva a las actividades de formación de pilotos y a las entidades que realizan vuelos de iniciación o panorámicos: "precisamente el desconocimiento de las causas del accidente es lo que fundamenta la aplicación del principio de responsabilidad objetiva -sin culpa- del empresario de la navegación que está presente en las normas que

se han indicado, las cuales imponen para tal caso la suscripción de un seguro de carácter obligatorio y fijan las cuantías indemnizatorias que resultan de aplicación" (FD 5º).

Resulta irrelevante, por quedar fuera del ámbito de protección de la norma infringida, el hecho de que en el momento del accidente la tarjeta de alumno-piloto de la víctima expedida por la Dirección General de Aviación Civil estuviera caducada (FD 2º).

6.9. Productos defectuosos

a) Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por los productos defectuosos.

b) Arts. 128 y ss. del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

c) Origen de la responsabilidad de producto como responsabilidad objetiva: *Escola v. Coca Cola* (150 P.2d 436 (Cal. 1944)).

En 1944, el Tribunal Supremo de California decidió *Escola v. Coca Cola Bottling Co. of Fresno* (150 P.2d 436 (Cal. 1944)). La demandante, camarera de profesión, reclamaba una indemnización por los daños corporales que había sufrido cuando le explotó en las manos una botella de Coca Cola que trataba de meter en un refrigerador. Alegaba que la compañía demandada había sido negligente por haber llenado la botella a presión excesiva o porque el recipiente era defectuoso. El jurado dictó un veredicto favorable a la demandante que fue confirmado en apelación, pero no hubo unanimidad en las razones de la sentencia: la mayoría aplicó al caso la doctrina de la *Res Ipsa Loquitur*, conforme a la cual la negligencia puede presumirse cuando, dadas las circunstancias, el accidente no se habría producido de no haber mediado culpa por parte del demandado – la idea de fondo es que las botellas no deben explotar por el simple hecho de ser manipuladas-. En su voto particular, el Juez Roger J. Traynor (1900-1983), quien llegaría a presidente del Tribunal, propuso de forma razonada el establecimiento de un régimen de responsabilidad objetiva por defectos de producto:

> "Concuerdo con el fallo pero no con su fundamentación, pues creo que la negligencia del fabricante debe dejar de ser la base del derecho del demandante a resarcirse en casos como el presente. En mi opinión, debería ahora reconocerse que el fabricante responde de forma absoluta cuando resulta probado que un producto que puso en circulación, consciente de que iba a usarse sin inspección previa, tiene un defecto que causa un daño a las personas. *MacPherson v. Buick* estableció el principio, reconocido por este tribunal, según el cual, con independencia de la eficacia relativa de los contratos, el fabricante responde por las lesiones causadas por un artículo a cualquier persona que lo manipule de forma correcta. En tales casos, la fuente de la responsabilidad del fabricante era su negligencia en el proceso de fabricación o en el de inspección de los componentes

suministrados por terceros. Incluso en ausencia de negligencia, el interés público exige que la responsabilidad se fije de la forma más efectiva para reducir los riesgos a la vida y a la salud inherentes a los defectos de productos que se ponen en circulación. Es evidente que el fabricante puede anticipar algunos riesgos y evitar la producción de otros, algo que no está al alcance del público en general. Quienes sufren un daño derivado de un producto defectuoso no tienen medios para asumir sus consecuencias. El coste de una lesión, así como la pérdida de tiempo o de salud, pueden ser una desgracia grande para la víctima que es fácilmente evitable, pues el riesgo del daño puede ser asegurado por el fabricante y su coste distribuido entre sus clientes. Es de interés público desincentivar la comercialización de productos con defectos que amenacen a los consumidores. No obstante, si tales productos entran en el mercado es también de interés público imputar responsabilidad por cualquier daño que se pueda originar al fabricante, quien, pese a no haber sido negligente en la fabricación del producto, es responsable por haberlo llevado al mercado. Por más que estos daños se produzcan de forma intermitente u ocasional, el riesgo de que ocurran es constante y general. Contra él, ha de haber una protección general y constante y quien mejor está situado para ofrecerla es el fabricante".

Con el tiempo, la opinión de Traynor pasó de ser un voto particular histórico a la *ratio decidendi* de la mayor parte de las jurisdicciones estatales norteamericanas. Los casos más significativos fueron *Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc.* (161 A.2d 69 (N.J. 1960)) y *Greenman v. Yuba Power Products*. Inc. (377 P.2d 897 (Cal. 1963)).

d) Bibliografía específica:

- Pablo Salvador/Fernando Gómez (Eds.), *Tratado de Responsabilidad Civil del Fabricante*, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008.

- Pablo Salvador/Fernando Gómez/Sonia Ramos (Eds.), *Apéndice 2009 al Tratado de Responsabilidad Civil del Fabricante*, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2010.

6.10. Responsabilidad del propietario por los humos excesivos nocivos para las personas o las propiedades y caída de árboles colocados en sitios de tránsito

a) Art. 1908. 2º y 3º CC.

Igualmente responderán los propietarios de los daños causados:

1. […]
2. Por los humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a las propiedades.
3. Por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor.
4. […]

6.11. Servicios

a) **Arts. 147-148 del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.**

Capítulo 10º
Daño

1. Daño y daño indemnizable / *Harm and Actionable or Recoverable Damage*... 187
2. Tipos de daño ... 189
2.1. Daños personales: muerte, daños corporales y daño moral ... 189
2.2. Consecuencias patrimoniales derivadas del daño corporal ... 189
2.3. Pérdida de oportunidad (*Loss of chance*) ... 190
2.4. Daños discretos y daños masivos ... 190
2.5. Daños concentrados y daños difusos ... 191
2.6 El (discutido y recurrente) concepto de daños exclusivamente económicos (*pure economic loss*) ... 192
3. Análisis económico del derecho / *Economic Analysis of Law* ... 192
4. Daño moral ... 193
4.1. Daño patrimonial y moral: las razones de la diferencia, en Fernando Gómez Pomar, "Daño moral", InDret 1/2000, www.indret.com, pp. 1-3 ... 193
4.2. STSJ, 3ª, Galicia, 626/2004 de 21 julio: la angustia y la ansiedad provocadas por la posibilidad de desarrollar una enfermedad no son indemnizables ... 194
4.3. SAN, 3ª, Secc. 3ª, 16.2.2012: daño moral por prisión indebida ... 195
4.4. Presunción de daño moral ... 197
4.5. *Walters v. Hitchcock* (237 Kan. 31, 697 P.2d 847 (1985)) ... 197
5. Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación ... 199
5.1. Aplicación orientativa en accidentes distintos a los de circulación ... 203
5.2. Anexo Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el RDL 8/2004, de 29 de octubre ... 206
5.3. Caso práctico ... 208
6. Pérdida de ingresos y de la capacidad de generarlos / *Lost earning, Impairment of Earning Capacity* ... 211
6.1. Sistema de baremos y pérdida de ingresos ... 211
6.2. Lucro cesante y menores de edad ... 214
7. Infracción de deberes de información ... 214
8. Nacimiento indebido / *Wrongful Conception, Wrongful Birth, Wrongful Life* ... 217
8.1. *Wrongful Conception* ... 217
8.2. *Wrongful Birth* ... 218
8.3. *Wrongful Life* ... 220
9. Daño exclusivamente económico / *Pure Economic Loss* ... 222
10. Pérdida de oportunidad / *Loss of a chance* ... 225
11. Lesiones personales y mitigación / *Compensatory damages: personal injury and mitigation* ... 227
11.1. *Williams v. Bright* (632 N.Y.S.2d 760 N.Y.Sup.,1995) ... 227
11.2. STC 154/2002, de 18 de julio ... 229
12. Compatibilidad de fuentes indemnizatorias / *Collateral Source Rule* ... 234

1. Daño y daño indemnizable / *Harm and Actionable or Recoverable Damage*

Daño (*Harm*) es cualquier detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia (definición extraída de la definición de "dañar" en el DRAE), mientras que daño indemnizable (*Actionable or recoverable damage*) es un concepto normativo, que incluye aquellas lesiones causadas por

conductas que reúnen los requisitos de los dos sistemas básicos de responsabilidad, por culpa y responsabilidad objetiva. Negligencia es fundamentalmente infracción de deberes de cuidado, previstos legal o jurisprudencialmente, como vimos en el capítulo 3º de estos materiales. Y responsabilidad objetiva, analizada en el capítulo 9º, que ha de estar prevista por ley o muy bien fundamentada por una jurisprudencia consolidada. Qué consecuencias se consideran dañinas es una cuestión de política jurídica –y económica, social, cultural- cuyo alcance depende de la intensidad de los deberes de precaución que se resuelva establecer, de los riesgos que se quieran prevenir.

En términos de daño, la responsabilidad contractual y extracontractual suelen distinguirse porque mientras que la pretensión que deriva del incumplimiento contractual debería ser suficiente para situar al acreedor en la posición en la que se encontraría de haberse cumplido el contrato, la pretensión extracontractual persigue –literalmente- indemnizar a la víctima, esto es, dejarla indemne, tal y como se encontraría si el accidente nunca hubiera tenido lugar, un instante antes de sufrir el daño.

La existencia de un daño cierto causado por la conducta del demandado es un presupuesto esencial de la responsabilidad civil. Sin daño no hay responsabilidad. Así, en la STS, 3ª, 10.2.2009, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia desestimatoria de la demanda de una paciente, a quien los servicios médicos había informado tardíamente de que era portadora del virus del VIH: la actora no había probado "en el proceso (…), siquiera sea de forma indiciaria, cuáles son los perjuicios concretos, singulares, tangibles (…) que le ha causado la tardanza en la toma de conocimiento de la tenencia del virus del SIDA".

Las consecuencias dañosas de la conducta del demandado son indemnizables si son actuales. Los daños futuros lo serán una vez producidos y mediante una nueva reclamación de responsabilidad civil (art. 220 LEC). La STS, 1ª, 580/2009, de 20 de julio, que resuelve un caso de cesárea practicada tardíamente, circunstancia que causó daños graves al niño, negó la indemnización por "gastos de fisioterapeuta, clases de natación [y otros], teniendo en cuenta que se trata de unos daños, perjuicios y gastos futuros hipotéticos, que por tal circunstancia no pueden ser objeto de una condena de futuro".

El paciente expuesto a una sustancia tóxica o radioactiva que, estadísticamente, sabe que la probabilidad de contraer tal o cual enfermedad ha pasado del 0,0001% al 0,001% no tiene una acción por el 0,001 % de los daños probables. En ausencia de daños actuales, pero ante la probabilidad de causarlos, el demandante puede disponer de acciones negatorias, de cesación y abstención de la actividad que amenaza causar daños (*Injunction*), incluso de acciones tendentes a indemnizar al afectado por los costes de los chequeos y pruebas analíticas, periódicas para descartar la contracción de la enfermedad, pero no de una acción de daños en sentido estricto.

A diferencia del art. 1902 del Código Civil español, algunos sistemas jurídicos, como el alemán, tipifican genéricos tipos de daño en función de los bienes jurídicos afectados: la vida, la intyegridad corporal, la salud, la libertad, la propiedad u otro derecho similar (§ 823 del Código civil alemán). También optan por este concepto de daño los Principios de Derecho Europeo de Responsabilidad Civil, un proyecto académico del *European Group on Tort Law* (2005) y muy influido por el derecho alemán:

§ 823 Schadensersatzpflicht:
"(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet".

Art. 2:102 *Principles of European Tort Law*. Protected interests*:*
(1) The scope of protection of an interest depends on its nature; the higher its value, the precision of its definition and its obviousness, the more extensive is its protection.
(2) Life, bodily or mental integrity, human dignity and liberty enjoy the most extensive protection.
(3) Extensive protection is granted to property rights, including those in intangible property.
(4) Protection of pure economic interests or contractual relationships may be more limited in scope (...)"

2. Tipos de daño

En el análisis doctrinal del daño, se suelen distinguir los daños materiales, causados a bienes sobre los cuales el demandante tiene un derecho de propiedad en sentido amplio, es decir, un *property right* (*Property Damages or Injury to Personal Property*) de los daños personales (*Personal Injury*) y, dentro de estos últimos, entre daños corporales, morales y los perjuicios económicos que derivan de los daños corporales –por ejemplo, las pérdidas resultantes de los días de baja laboral de la víctima).

Un buen punto de partida para abordar esta cuestión es tener en cuenta un núcleo claro de daños sencillos de identificar y, solo luego, el halo de posibles daños que rodea a los primeros, pero que son mucho más difíciles de estimar y probar.

2.1. Daños personales: muerte, daños corporales y daño moral

Dentro de la categoría de daños personales, los derivados de la muerte (*Wrongful Death*) o los daños corporales causados por un trauma externo (*Danno biologico* en derecho italiano, *Bodily Injury* en el *Common Law*) son partidas que hoy suelen estar incluidas sin más en el ámbito de los daños resarcibles --pero no fue así con la indemnización por causa de muerte en el pasado. En cambio, los daños morales, que los angloamericanos denominan "*Pain and Suffering"* y los alemanes "*Schmerzengeld",* los originados por el dolor físico, por la pérdida de un ser querido o por la destrucción de un bien irrecuperable son mucho más difíciles de determinar y, consecuentemente, mucho más fáciles de exagerar. Es normal, pues, que el carácter indemnizable de los segundos sea menos fácil de admitir que el de los primeros.

2.2. Consecuencias patrimoniales derivadas del daño corporal

Como ya hemos señalado, las consecuencias patrimoniales derivadas de un daño corporal también constituyen un daño indemnizable. El art. 1106 CC distingue entre daño emergente (la disminución de los valores patrimoniales que el perjudicado tenía en su haber) y lucro cesante (*Loss of Profits*, los beneficios o ganancias que ha dejado de obtener). La partida más común del

daño emergente es la de gastos médicos (*Medical Expenses*) asociados al tratamiento del daño físico. El lucro cesante cubre tanto las pérdidas de ingresos por trabajo personal (*Lost Earnings*) acumuladas durante el tiempo de incapacidad temporal de la víctima y también aquellas generadas por la imposibilidad de desarrollar, en caso de secuelas permanentes, la actividad profesional habitual de la víctima o, si las secuelas son muy invalidantes, cualquier actividad laboral. Si se trata de una víctima en edad no laboral, su lucro cesante se concreta en la pérdida o disminución de la capacidad de ganancia (*Impairment of Earning Capacity*).

2.3. Pérdida de oportunidad (*Loss of chance*)

En ocasiones, la negligencia del demandado reduce la probabilidad de que el demandante preserve su salud, conserve sus bienes, obtenga un beneficio o no experimente una pérdida (pérdida de oportunidad, *Loss of a Chance*): un diagnóstico tardío o un error de diagnóstico pueden reducir o incluso privar al paciente de posibilidades de tratamiento médico; el paciente que, como consecuencia de una intervención quirúrgica, sufre un daño grave sobre el cual el médico no le había informado quizás alegará que de haber obtenido dicha información habría rechazado el tratamiento; la mala praxis del abogado consistente en interponer una reclamación fuera de plazo priva a la víctima de la posibilidad, por reducida que resulte, de obtener una sentencia favorable a sus derechos e intereses. [Joseph H. King, "Causation, valuation and chance in personal injury torts involving preexisting conditions and future consequences", 90 *Yale L. J.* 1353, 1363-1368 (1981)].

Los tribunales españoles consideran indemnizable la pérdida de oportunidad y sostienen que el importe de la indemnización en estos casos ha de ser distinto al que correspondería a la dolencia del paciente, a la secuela derivada del tratamiento médico o al beneficio que el demandante habría obtenido de ganar el pleito. Así, en la reciente STS, 3ª, 3.12.2013, RJ 2013\582, que resuelve un caso de diagnóstico tardío de un cáncer en el abdomen que se diseminó y causó la muerte de la esposa y madre de los actores, el TS casa la SAP porque "ha errado al considerar que en este caso el importe de la indemnización debe calcularse teniendo en cuenta el importe total del daño producido".

2.4. Daños discretos y daños masivos

El análisis doctrinal tradicional del derecho de daños se adecua razonablemente a los accidentes discretos, casuales o negligentes, que afectan a una persona o a un número reducido de ellas y que provocan un resultado instantáneo o evaluable al cabo de algún –poco tiempo-: la destrucción de un bien mueble o inmueble, la causación de la muerte de un peatón, la causación de heridas que sanan al cabo de algún tiempo o que dejan secuelas que pueden evaluarse sin demasiada complejidad.

Pero el análisis tradicional y el derecho mismo de daños funcionan muy limitadamente en los casos de accidentes masivos (*Mass Torts*), en aquellos en los cuales los daños se manifiestan al cabo de muchos años, acaso de décadas, de exposición de las víctimas a sustancias tóxicas (*Toxic Torts*) o de la realización de actividades que causan enfermedades óseas, cardiovasculares o de otro tipo (*Working Place Accidents*): en estos casos y en otros semejantes, el derecho regulatorio, el establecimiento de fondos de compensación específicos o, aún mejor, la asunción de los costes de los accidentes y enfermedades por los sistemas generales de la seguridad social

pueden constituir una alternativa al derecho de daños, cuyo lugar debe ceñirse al tratamiento de los casos más graves, de los residuales o –nótese bien- de los emergentes, pues la responsabilidad civil cumple una función esencial en la dinámica del derecho. Al respecto, puede verse Alberto AZAGRA MALO, *La tragedia del amianto y el derecho español*, 1ª ed., Atelier, Barcelona, 2007 y *Daños del amianto: litigación, aseguramiento de riesgos y fondos de compensación*, 1ª ed., Fundación Mapfre – Instituto de Ciencias del Seguro, Madrid, 2011.

Dan B. Dobbs resume bien el estado de la cuestión para el *common law* norteamericano:

"Actual damage or injury is a necessary element of tort liability (for negligence). What qualifies as actionable damage is a question of policy largely defined by the duty rules considered in the 5th chapter:

- While bodily injury from external trauma is categorically included, liability for mental distress is more hedged, depending on whether it results from an external injury or mere mental processes.

- Property damage is widely conceived, embracing any interference which diminishes the value of the object. Purely economic loss, -or loss not resulting neither from propoerty damage,nor from personal injury- however, is actionable only under limited controlled conditions.

  For merely threatened harm, an injunction but no claim for damages will lie. In other words, merely creating a risk of injury is not actionable; injury must have become actual. And, consequently, no cause of action accrues until damage has occurred.

  But what precisely qualifies as damage in cases of bodily injury or property damage, and when does it occur as to start the limitation period running? Asbestosis often remains undiagnosed for many years after exposure, yet the injury is evidently deemed to occur as soon as a lesion would have been discoverable by x-ray (...)" (Dan B. Dobbs, *The Law of Torts*, West Group, St. Paul, Minn., 2000).

2.5. Daños concentrados y daños difusos

A veces es relevante no tanto la naturaleza del daño como el grado de su concentración o difusión: no solo se trata de que la gravedad de un daño se incrementa más que proporcionalmente cuanto mayor es su grado de concentración –dada la función de utilidad de la mayor parte de los humanos--, es que, además, los daños muy difusos, son mucho más costosos de gestionar que los daños concentrados: un sujeto que sufre un accidente que le cuesta 100.000€ tiene muchos más incentivos para reclamar una compensación que cien mil afectados que han sufrido un daño de 1 € y el coste de la suma de las reclamaciones en este segundo caso haría inviable la reclamación por vía judicial. Aunque el derecho de daños cuenta con instrumentos para gestionar reclamaciones colectivas por daños difusos, como las acciones de clase, no es la herramienta primaria para su contención y compensación.

2.6 El (discutido y recurrente) concepto de daños exclusivamente económicos (*pure economic loss*)

Daño o pérdida exclusivamente económica suele definirse como el daño pecuniario que no resulta de un daño personal causado al demandante o de un daño material causado a un bien que es propiedad del demandante mismo. (un buen análisis puede verse en el *Restatement of the Law Third Torts: Liability for Economic Harm (Tentative Draft No 1, April 4th, 2012; Preliminary Draft No 2, September 3rd, 2013).*

En el *Common Law* norteamericano, en materia de daños puramente económicos, rige una regla de ausencia de responsabilidad (*No Liability rule*): no hay un deber general de abstenerse de causar involuntariamente daños puramente económicos, sino que estos solo son indemnizables cuando concurren buenas razones para ello, como pueden ser, por ejemplo, la negligencia de un profesional o la confianza suscitada razonablemente por el causante de los daños en una víctima o en un grupo definido de víctimas. La exclusión de un deber general se fundamenta en la doble consideración de que una responsabilidad universal por daños exclusivamente económicos generaría una responsabilidad indeterminada y desproporcionada –impracticable—y, sobre todo, en que la herramienta ideal para gestionar contingencias puramente económicas –cuestiones que, por definición, versan exclusivamente sobre dinero— es el contrato y no el derecho de la responsabilidad extracontractual-.

En la jurisprudencia española, los casos de daños puramente económicos suelen resolverse con base en consideraciones relacionadas con el carácter puramente especulativo, incierto o insuficientemente probado de los daños alegadamente sufridos por el demandante. En la STS, 3ª, 23.3.2009 (RJ 2009 2502), descrita en el apartado 9 de este capítulo, el Tribunal Supremo concedió al hotel Miguel Ángel de Madrid una indemnización por la caída de ingresos que había experimentado durante el período en el que tuvieron lugar unas obras del metro muy próximas a su entrada principal. En el caso resuelto por la STS, 1ª, 187/2012, 29.3..2012, el Hotel Hilton de Barcelona contrató a "Rentokil Initial España, S.A." para que desinfectara algunas plantas del hotel y varias trabajadoras de la limpieza sufrieron una intoxicación debido a que su acceso a la zona desinfectada se produjo antes de las 48 horas recomendadas por Rentokil. El hotel demandó a esta empresa y solicitó que le compensara "por los recargos de prestaciones satisfechos a las Seguridad Social en relación a las declaraciones de invalidez de las trabajadoras intoxicadas, la cantidad de 637.136,84 euros, [y] por los gastos de defensa letrada en los diversos expedientes administrativos y procedimientos judiciales la cantidad de 576.302,99 euros".

3. Análisis económico del derecho / *Economic Analysis of Law*

El análisis económico del derecho *reduce* las categorías de daño a dos:

- Daños patrimoniales o pecuniarios, es decir, aquellos que afectan a bienes o servicios que pueden ser objeto de tráfico y, por tanto, de valoración en un mercado legal. Por ejemplo: daños causados a un automóvil, a un edificio, o daños que imposibilitan a un profesional desarrollar su actividad profesional durante unos días, semanas, meses o años.

- Daños no patrimoniales o morales. Son los que se causan a bienes únicos, insustituibles, o, por decirlo de otro modo, a personas o a bienes que no son objeto de tráfico, ni por tanto de

apreciación, en ningún mercado, sea ya porque no existe, sea ya porque la ley no admite su existencia o funcionamiento: hay, efectivamente y como escribe Michael Sandel, bienes que no se pueden comprar (Michael J. SANDEL, *What Money Can't Buy: The Moral Limits of Market*, 1st ed., Farrar, Straus and Giroux, 2012): no está bien comprar un esclavo, no se puede vender un amigo a los amigos, no es fácil comprar amor, ni suele parecer razonable comerciar hijos, la lista es potencialmente muy larga pero solo su contenido básico no es polémico, pues hay mucha controversia en sus márgenes, una cuestión, esta última, que solo se puede analizar cumplidamente con conocimiento de causa, más adelante. En todo caso, hace más de un siglo que los ordenamientos de los países de nuestra cultura reconocen que los daños causados a objetos únicos, irremplazables, imposibles de comprar o vender, o muchos de los daños personales –y paradigmáticamente, la muerte en muchos casos (no en todos)—son indemnizables de alguna manera. El problema suele ser cómo, pues ¿cómo valorar la pérdida de un hijo?, ¿cómo indemnizar un daño cuya ocurrencia futura nadie o casi nadie aseguraría?, ¿cómo valorar la destrucción de la única fotografía del padre?, ¿el atropello mortal de nuestra vieja perra de trece años de edad, atrítica, sorda y casi ciega?, ¿cómo el insulto vulgar de quien, disparándose un tiro en el zapato, le chilla a otro ---"¡Eres un auténtico hijo de puta"!—o el del cínico bien leído y exquisitamente educado, que, sonriendo, susurra ---¡"Huérfano, que eres como Jon Snow"! ?

4. Daño moral

4.1. Daño patrimonial y moral: las razones de la diferencia, en Fernando Gómez Pomar, "Daño moral", InDret 1/2000, www.indret.com, pp. 1-3

"En economía, dañar es hacer disminuir la utilidad del individuo dañado. En derecho, se distingue entre daños patrimoniales y daños morales, una dualidad básica y que tiene importantes consecuencias legales. El análisis económico del derecho integra entonces los discursos de la economía y del derecho para elaborar una teoría fecunda y elegante de los daños morales que se expone a continuación.

En el marco de esta teoría, los daños patrimoniales se diferencian de los daños morales en función de la muy distinta aptitud que el dinero tiene, en uno y en otro caso, para restaurar la utilidad perdida:
a) El daño patrimonial provoca una disminución de utilidad que es compensable con dinero o con bienes intercambiables por dinero.
b) El daño no patrimonial o moral, por el contrario, implica una reducción del nivel de utilidad que ni el dinero, ni bienes intercambiables por éste, pueden llegar a compensar: todo el oro del mundo no basta para reemplazar el sufrimiento experimentado por el velocista que queda tetrapléjico como consecuencia de un accidente.

Una representación gráfica y muy sencilla de ambas nociones puede obtenerse mediante la función de utilidad del dinero. Las consecuencias de un daño patrimonial se dibujan en la figura 1, que muestra un movimiento hacia la izquierda a lo largo de la propia curva: el individuo dañado sufre un daño patrimonial de importe D, pero el abono de una cantidad de dinero D puede restablecer la utilidad perdida y volver a llevarle de B a A.

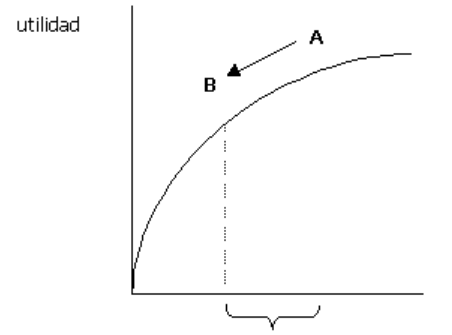


FIGURA 1

Los efectos de un daño moral se representan en la figura 2 como un desplazamiento que se produce no a lo largo de la misma curva sino de una a otra que se sitúa más abajo. Obsérvese que el cambio no afecta a la cantidad de dinero disponible por el dañado, que sigue siendo la misma. Sucede, sin embargo, que la misma cantidad le vale menos, le rinde menos utilidad: en el ejemplo utilizado para ilustrar el concepto de daños moral, nuestro velocista inválido ya no puede disfrutar con la misma intensidad del dinero que no ha perdido. Así, en la figura 1 la diferencia entre la utilidad A y la B es monetaria, de dinero. En cambio, en la figura 2 es de utilidad "pura".

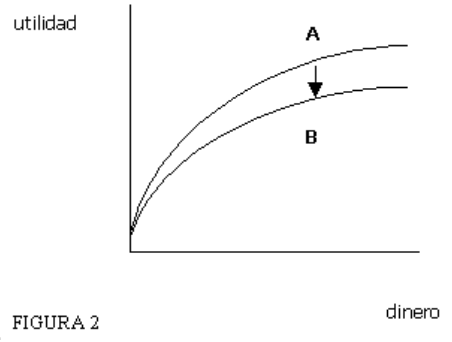


FIGURA 2

4.2. STSJ, 3ª, Galicia, 626/2004 de 21 julio: la angustia y la ansiedad provocadas por la posibilidad de desarrollar una enfermedad no son indemnizables

Entre mayo y noviembre de 1997, varios hospitales gallegos, públicos y privados, inyectaron a 450 pacientes con cuadros de posible tromboembolismo pulmonar el medicamento radiofármaco *Amerscan Pulmonate II Technetium Lung Agent* (en adelante, *Amerscan Pulmonate II*) para la realización de gammagrafías pulmonares de ventilación-perfusión. Dicho radiofármaco, un contraste inyectable compuesto de tecnecio (^{99m}Tc) y de microesferas de albúmina elaboradas con plasma humano, había sido fabricado por el laboratorio británico "Nycomed Amersham" para el diagnóstico de embolias pulmonares.

> La gammagrafía pulmonar es una prueba diagnóstica basada en la imagen que producen las radiaciones generadas tras la inyección o inhalación en el organismo de sustancias que contienen isótopos radiactivos. Esta prueba se utiliza para medir la

respiración (ventilación) y la circulación (perfusión) en todas las áreas de los pulmones.

El 18.11.1997, el Ministerio de Sanidad del Reino Unido retiró del mercado británico los lotes A-548, A-554 y A-556 de *Amerscan Pulmonate II*, tras haber detectado que uno de los donantes de la partida de plasma, de quien se había obtenido uno de los componentes del radiofármaco, la albúmina *Zenalb 20*, había desarrollado una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (en adelante, nvECJ) con posterioridad a la donación. Esta enfermedad, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, es una enfermedad mortal que afecta al sistema nervioso central y daña la función cerebral, si bien aparece en edades más tempranas.

Ese mismo día, el Ministerio de Sanidad británico comunicó dicha retirada al Ministerio de Sanidad y Consumo español. La Subdirección General de Control Farmacéutico, tras comprobar la presencia en el mercado español de dos de los lotes potencialmente contaminados con la nvECJ (lotes A-548 y A-554) ordenó, como medida precautoria, la inmovilización del producto. Asimismo, advirtió de que no existían evidencias de que el producto fuera defectuoso o estuviese contaminado con la nvECJ, de que el donante sufriera aquella enfermedad o hubiere desarrollado el agente infeccioso en el momento de la donación, y de que la nvECJ fuera transmisible por vía sanguínea.

Entre el 26.11.2003 y el 21.7.2004, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó 28 sentencias en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria por los posibles daños físicos y morales derivados de contagios por tales hechos. En concreto, en el caso que dio lugar a la STSJ de Galicia de 21.7.2004, la paciente y actora había reclamado en la vía contencioso-administrativa 300.506,05 € en concepto de daños morales, así como la creación de áreas multidisciplinares en las que se ofreciera asistencia a los pacientes. El TSJ de Galicia desestimó el recurso:

"[N]i se ha probado científicamente el riesgo de llegar a contraer dicha enfermedad por el hecho de haber recibido el mencionado radiofármaco integrado por un componente de una partida de plasma, en concreto la albúmina, donada por quien contrajo con posterioridad a la donación la nueva variante de dicha enfermedad, ni se ha demostrado que la actora haya resultado infectada, lo cual elimina uno de los presupuestos imprescindibles para la concurrencia de responsabilidad patrimonial de la Administración cual es la existencia del daño o lesión indemnizable (…) Pese a que la ausencia de daño efectivo y antijurídico así como de relación causal entre el funcionamiento normal o anormal de la Administración sanitaria y el invocado perjuicio, han de dar lugar a la desestimación de la presente reclamación, conviene significar que se comprende la preocupación creciente de la actora ante la posibilidad de desarrollar en el futuro la enfermedad" (FD. 4º).

[Marian Gili Saldaña, "Responsabilidad de la Administración por el posible contagio de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob", *Indret 1/2006*]

4.3. SAN, 3ª, Secc. 3ª, 16.2.2012: daño moral por prisión indebida

"En el presente recurso se impugna la resolución del Secretario de Estado de Justicia, por delegación del Ministro del ramo, de 17-12-2010 estimatoria en parte de la reclamación por

responsabilidad patrimonial del estado por error judicial formulada por el recurrente el 20-11-2009.

En dicha resolución se contempla una indemnización de 555.600 € por los 4.630 días de prisión [12 años, 8 meses y 8 días], a razón de 120 €/día.

Ante esta Jurisdicción se reclaman 10.000.000 € minorados en la cantidad ya reconocida e incrementados en el interés legal desde la fecha de la reclamación administrativa.

La cuestión debatida, una vez que el error judicial resulta de la sentencia de revisión penal, queda limitada a determinar la cuantía a indemnizar por los daños y perjuicios, reales que no meramente hipotéticos, que resulten acreditados y que aparezcan causalmente vinculados con la condena que fue objeto de revisión.

[E]l recurrente fue condenado por sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz (…) como autor de dos delitos de violación imponiéndosele una pena de 18 años de prisión por cada uno de ellos con el límite de 30 años. Dicha sentencia fue revisada por el TS en sentencia de 16-7-2009 (…) con base a que nuevas pruebas de ADN, por el avance de la técnica, habían permitido concluir que los restos biológicos de tales violaciones no pertenecían al Sr. Juan (…).

La parte actora entiende que la indemnización reconocida en vía administrativa no tiene en cuenta las circunstancias especiales concurrentes en el caso (…) Por ello entiende que ha de partirse de un módulo diario de 133,33 €/día y aplicando un ponderado criterio de progresividad la cantidad a indemnizar por este concepto sería de 8.000.000 de €. Igualmente se solicitan 2.000.000 € por las secuelas físicas y psíquicas que sufre tras tantos años de encarcelamiento.

En cuanto a la indemnización por los daños morales y de diversa índole que implican la prisión en si misma considerada y la posterior situación de provisionalidad en la libertad hasta que se resolvió la revisión penal, teniendo en cuenta su duración, la naturaleza infamante de los delitos objeto de condena, el que el Sr. Juan cuando ingresa en prisión tiene unas relaciones familiares claramente desestructuradas (...) el que la prisión no influyó en su arraigo laboral ya que partimos de que la prisión no le supuso la pérdida de ingresos económicos (al ingresar en prisión vivía de una pequeña pensión y de lo que obtenía de "gorrilla" y de mendigar), en el caso de autos la Sala considera ponderada al caso una indemnización de 896.000 € de los cuales 280.000 corresponden a una principio de progresividad para atender a compensar el mantenimiento en el tiempo de la privación de libertad, aspecto no contemplado en la resolución recurrida (...)

[E]stamos ante una persona que de partida, antes de su ingreso en prisión, presenta graves déficits intelectivos (analfabeto y "border line"), que por diversos factores posteriores, entre ellos la hepatopatología, su depresión y su larga adicción a alcohol y drogas, hoy en día, su estado psiquiátrico responde a una edad mental de 8 años, prácticamente una demencia.

[G]ran parte de la patología psicológica/psiquiátrica que presenta en la actualidad el recurrente tiene su origen en causas extrañas al hecho mismo de la prisión y de la condena errónea, pero no puede desconocerse la existencia de una influencia negativa (...) resultante de la traumática situación que supone el verse cumpliendo una pena por delito no cometido. Por ello entiende la

Sala que la indemnización debe ser incrementada por este concepto en 104.000 € [resultando un total de 1 millón de euros]".

4.4. Presunción de daño moral

- **Artículo 9 Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.**

"(…) Tres. La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido".

- **SAP Cádiz (Secc. 2ª), Civil, 336/2009, de 17 de noviembre**

El 15 de noviembre de 2008, el diario "El País" publicó un reportaje sobre el problema del narcotráfico en Sanlúcar de Barrameda, en el que tildaba a Alberto de narcotraficante: "Apodos como Orejas, su hijo Perico , Pulpo o Palillo son narcos conocidos que invierten sus beneficios en negocios lucrativos". En el año 2002 el mismo periódico había sido condenado civilmente por publicar un reportaje sobre el mismo tema: "Esa realidad es que el narcotráfico forma parte de la vida cotidiana del pueblo. Todo se sabe. ¿No hizo " Pulpo " de Rey Mago en la cabalgata? Y " Pulpo " es un narco".

Alberto demandó al periodista autor del reportaje y al diario, y solicitó la condena solidaria de ambos al pago de 150.000 euros en concepto de daños morales.

El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Sanlúcar de Barrameda estimó en parte la demanda y condenó a los codemandados al pago de 10.000 euros. La Audiencia Provincial de Cádiz estimó en parte el recurso de apelación y aumentó la indemnización a 30.000 euros:

"[E]s claro que atribuir a alguien la condición delictiva de narcotraficante es expresión que desacredita, menosprecia y afrenta al actor (…) Convendrá también indicar que la reiteración en la conducta, la hace más grave. No es cierto que la rectificación provocada en el litigio anterior y la indemnización concedida al Sr. Andrés salde para siempre cualquier otra vulneración a su derecho al honor. Lejos de convertirse aquella condena en una patente de corso para el periódico y para sus periodistas, les coloca en una posición de garantía respecto de futuros tratamientos periodísticos de la misma noticia. Se alega que todo se ha debido a un error, y efectivamente así ha de haber sido. Pero creemos que tal error es inexcusable a la vista de la condena previa, de tal forma que lo único que provoca es la exigencia de un plus de responsabilidad ante la reiteración en el ilícito dos veces cometido" (FD. 2º).

4.5. *Walters v. Hitchcock* (237 Kan. 31, 697 P.2d 847 (1985))

McFARLAND, Justice. This is a medical malpractice action wherein plaintiff Lillian K. Walters received a $2,000,000 damage award against defendant C. Thomas Hitchcock, M.D. The

defendant physician appeals from the jury's verdict and certain pretrial and post-trial rulings of the district court.

The facts may be summarized as follows. In December 1979, a lump on the neck of Lillian Walters was discovered by her family physician. Mrs. Walters was, at the time, approximately 32 years of age, married, with four minor children. She was not employed outside the home. The family physician conducted a number of tests and advised her to consult with a surgeon. Mrs. Walters was seen by defendant Hitchcock, a surgeon, on January 7, 1980. As a result of the prior testing and his physical examination of her, Dr. Hitchcock recommended surgical removal of diseased areas of the thyroid gland. There were indications of a possibly malignant condition. Surgery was scheduled for January 22, 1980. Mrs. Walters was advised the operation was a relatively low risk procedure with an anticipated three-day hospital stay and a small residual scar.

The operation proceeded in what appeared at the time to be a routine manner. Specimens were sent to the pathology laboratory and no malignancy was detected. The patient was sutured and sent to the recovery room. One day later Mrs. Walters' condition rapidly deteriorated. Her head ballooned in size, she became blind and suffered extreme respiratory distress. She was taken to the intensive care unit where a breathing tube was inserted. Shortly thereafter, Dr. Hitchcock was advised by the hospital pathology department that a one inch by one and one-half inch piece of esophagus tissue was connected to the thyroid specimen sent to the laboratory during surgery. Mrs. Walters' wound was now badly infected. She was taken to surgery. Dr. Hitchcock reopened the wound and observed a significant hole in the left front portion of her esophagus. He concluded that repair was not possible and sewed the esophagus shut-thereby closing it permanently.

At this point feeding was possible only through a tube inserted directly into Mrs. Walters' stomach (...) Ultimately, colon interposition surgery was performed which involved making a sort of bypass esophagus from a portion of Mrs. Walters' colon (...)

Mrs. Walters brought this action against Dr. Hitchcock based upon negligence in cutting into the esophagus and in failing to make prompt repair thereof. She sought $4,000,000 in damages. Dr. Hitchcock denied negligence and blamed the injury to the esophagus on the abnormal physiology of Mrs. Walters. The jury awarded Mrs. Walters $2,000,000 in damages and Dr. Hitchcock appeals therefrom […].

The evidence herein bears out that medical science has done all that it can do to alleviate plaintiff's condition and no further surgery is contemplated, although the same is not ruled out. This does not mean the damage done to Mrs. Walters has been undone and that she has been restored to her previous condition. It simply means her condition cannot be helped by further surgery or treatment. The substitute esophagus fashioned from a part of Mrs. Walters' colon is, apparently, functioning as well as can be expected but that level of function is a source of permanent problems for Mrs. Walters. When she swallows, food does not automatically go to her stomach. It piles up in grotesque bulges in her throat and upper chest. It is necessary for her to manually massage the bulges downward to force the food to her stomach. The process is physically painful. As there is no valve to keep the contents of her stomach from traveling back up the makeshift esophagus, she cannot lie flat and must remain in a position where gravity will keep the contents of her stomach in place. Her condition is embarrassing, distasteful to persons around her, and a major obstacle to leading a normal life. She has serious ongoing digestive

problems. At the time of trial her life expectancy was 41.9 years. The years between Mrs. Walters' injury and attainment of her present level of functioning were a nightmare of pain, disability, hospitalizations and surgical procedures. She has severe disfiguring scars on her neck and torso. Many activities, such as eating and sitting, continue to be painful.

After having reviewed the record, we conclude our collective conscience are not shocked by the size of the verdict herein. The judgment is affirmed.

SCHROEDER, Chief Justice, dissenting. The magnitude of the verdict in this case is the result of trial error and what purports to be misconduct of the jurors (...)

By reason of the (...) trial court errors and speculation on the part of the jurors, the magnitude of the verdict in this case demonstrates *prejudice on its face*. In light of evidence, it shocks my conscience.

The plaintiff, Lillian K. Walters, at the time of trial had a life expectancy of 41.9 years. Her medical bills at the time of trial were approximately $59,000. She made no claim for lost-earning capacity, or diminished earning capacity; no evidence of future surgery or medical expenses was presented. The $2 million verdict included $1,940,000 in the general damage categories.

On an annual basis this gives the plaintiff the principal sum of $47,733 per year for the rest of her life. Assuming one-half of the damage award is paid on expenses and attorney fees, the remaining $1 million invested at 10% simple interest (present interest rates compounded quarterly on money invested in C.D.'s will exceed 10%), payable annually, will provide an annual income of $100,000 without invading the principal sum invested (...).

In my opinion, courts of last resort must exercise a degree of economic judgment to provide stability in our free enterprise system if justice is to be administered fairly and within reason (...).

It is respectfully submitted this court should reverse the trial court and grant a new trial on the ground of misconduct of counsel for the plaintiff in closing argument and, failing this, that the court should remand the case for a hearing on the motion for new trial concerning the charge of misconduct on the part of the jury in fixing the damage award".

5. Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación

En el derecho español de daños, la indemnización de los daños personales causados en accidentes de circulación está tasada legalmente mediante un sistema de baremos y de aplicación obligatoria (Anexo del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre -en adelante, Texto Refundido-). En cambio, es puramente orientativa para los casos de daños causados por accidentes distintos a los de circulación. Hoy, los jueces y tribunales españoles suelen aplicar de manera orientativa este sistema a accidentes distintos a los de circulación (véanse, por ejemplo, las SSTS, 5ª (Penal), 16.5.2002 –cadete de la guardia civil

dispara su arma olvidando que estaba cargada y el proyectil impacta en el pómulo derecho de un compañero-; 3ª, 2.11.2011 –suicidio de preso en celda de aislamiento-; 1ª, 27.11.2011 –lesión de derechos fundamentales a la dignidad e integridad moral como consecuencia de despido laboral improcedente-). Con todo, hay excepciones muy notables:

- **STS, 3ª, 18.9.2009 (JUR 428240). MP: Juan Carlos Trillo Alonso**

El 2 de septiembre de 2005, el actor, de 32 años de edad, estaba trabajando en el campo cuando vio que una avioneta del Ejército del Aire, que había despegado de Murcia para realizar un vuelo de entrenamiento, se estrellaba en el casco urbano de Baeza, Jaén, y caía sobre su casa, causando su derrumbe e incendio. Al día siguiente, los equipos de rescate encontraron el cuerpo descuartizado y completamente quemado de su mujer, pero ningún rastro de su hija de nueve meses de edad.

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de septiembre de 2007 se declaró la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado y se acordó indemnizar al actor con 742.963,19 euros.

El actor interpuso recurso contencioso administrativo solicitando que se aumentara la cuantía concedida en el citado Acuerdo a 184.699,51 euros más en concepto de secuelas psicológicas (103.093,89 euros), gastos de tratamiento psicológico (360 euros), días de incapacidad (6.392,10 euros) y daño moral derivado de la pérdida de objetos de valor (63.640 euros).

El TS estimó en parte el recurso del actor y aumentó la indemnización concedida por el Acuerdo del Consejo de Ministros en 120.535,77 euros, por los mismos conceptos alegados por el recurrente:

"Previsto para determinar la responsabilidad civil derivada de accidentes de circulación de vehículos a motor, mal cabe [la] aplicación [del baremo] o al menos sin correcciones al caso … Y es que las circunstancias con las que se presentan los acontecimientos, se revelan como especialmente trágicas … y por ello acreedoras de un resarcimiento que, si bien es de muy difícil valoración, lo que está claro es que no se consigue con la aplicación de un baremo previsto para acontecimientos menos dramáticos…" (FD. 3º).

Véase también, recientemente, la ya citada **STS, 3ª, 3.12.2012 (RJ 2013\582)**, que resuelve un caso sobre pérdida de oportunidad de paciente de 50 años de edad a quien diagnosticaron tardíamente un cáncer en el abdomen cuando ya se había hecho metástasis en el peritoneo: "[L]os baremos (…) han sido utilizados por la jurisprudencia para valorar (…) daños [personales] producidos dentro del ámbito de la Administración sanitaria (…) con carácter orientativo, sin que esa aplicación excluya la necesidad de valorar todas las circunstancias que concurran en cada caso para lograr la total indemnidad del daño ocasionado (…) [N]o pueden aplicarse sin matices cuando se trata de la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria (…) En el caso (…) la suma fijada por el baremo aplicado resulta claramente insuficiente. Se trata del fallecimiento de la esposa y madre de los recurrentes, persona de 50 años de edad con una menor a su cargo, por lo que la suma de 108.846,51 euros que el baremo reconoce al cónyuge y 18.141,08 euros a la hija no es adecuada para comenzar el cálculo de la indemnización" (FD. 4º).

- **Auto AP Sevilla (Secc. 7ª), 224/2005, de 30 de diciembre**

[Miguel Ángel Roig Davison, "Indemnización por la privación indebida de la compañía de los hijos. Comentario al AAP Sevilla, Civil Sec. 6ª, 30.12.2005 (MP: Ruperto Molina Vázquez)", InDret 2/2006, www.indret.

"En 1996, la policía halló a la Sra. Carmen F. en situación de pérdida de autocontrol debido a una ingesta alcohólica. Por ello, el 12.11.1996 la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía declaró la existencia de situación legal de desamparo de sus hijos, Sara e Iván, de 5 y 4 años de edad respectivamente, y retiró la guarda y custodia de la madre. Los menores quedaron bajo la tutela de la Junta de Andalucía.

El 2.6.1997 los menores fueron entregados por la mencionada Administración en acogimiento preadoptivo al matrimonio constituido por Juan y Josefa. En este proceso recayó sentencia del JPI nº 7 de Sevilla, 8.9.1998, en la que se desestimó la oposición planteada por la madre de los menores. Sin embargo, la sentencia fue revocada por la SAP Sevilla, Civil Sec. 6ª, 12.6.2000, al considerar que no existía situación legal de desamparo.

No obstante, el AJPI nº 7 de Sevilla, 11.7.2001, de ejecución de la SAP Sevilla, Civil Sec. 6ª, 12.6.2000 declaró que, en interés de los menores, éstos debían permanecer con sus padres de acogida.

Mientras tanto, Juan y Josefa recurrieron en amparo al Tribunal Constitucional, alegando vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por habérseles negado su participación en el proceso como parte. La STC, Sala 2ª, 20.5.2002, estimó el recurso y procedió a la anulación de todo lo actuado desde la SAP Sevilla, Civil Sec. 6ª, 12.6.2000, que declaraba la inexistencia de situación legal de desamparo.

Por ello, la AP de Sevilla dictó nueva sentencia (SAP Sevilla, Civil Sec. 6ª, 26.12.2002) en la que declaró la inexistencia de situación legal de desamparo, denegó el acogimiento preadoptivo y ordenó el retorno de los niños con su madre biológica. No obstante, en dicha sentencia se admitió la imposible ejecución del fallo, debido al largo periodo de tiempo que los menores habían convivido con su nueva familia. De esta manera, el JPI nº 7 de Sevilla incoó incidente para la determinación de la indemnización sustitutoria que debía hacer frente la Junta de Andalucía con base en el Art. 18.2 de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE nº 157, de 2.6.1985).

En el año 2003, Sara, con 13 años de edad, volvió por su propia voluntad a convivir con su madre biológica.

Durante todo este proceso, el sufrimiento padecido por Carmen se tradujo en dos enfermedades: una depresión reactiva, que tuvo manifestaciones tan graves como el intento de suicidio, y otro de naturaleza física u orgánica a resultas de la cual tuvo que someterse a tratamiento oncológico, presentando plena afectación de un pulmón.

En el mencionado incidente de ejecución, la madre solicitó algo más de 1 millón de euros. La SJPI nº 7 de Sevilla, 28.3.2005, estableció una indemnización de 72.670 €. El AAP Sevilla, Civil Sec. 6ª, 30.12.2005, resolvió el recurso de apelación, y aumentó la cuantía indemnizatoria a 1.400.000 €":

[S]in que un supuesto tan específico y humano como el presente guarde relación alguna con los supuestos de accidentes de tráfico, [el juez a quo] decide, para cuantificar la indemnización, acudir al baremo indemnizatorio establecido para las compañías aseguradoras en la Ley 30/1995 de 8 de noviembre (RCL 1995, 3046), decisión que sólo tiene de acierto el eliminar en algún porcentaje una discrecionalidad que fácilmente podría desembocar en arbitrariedad. En efecto, por donde quiera que se mire, ningún parangón es posible establecer entre unas lesiones o un fallecimiento por accidente de tráfico con la ilegítima privación de unos hijos a su madre desde hace casi diez años, con numerosas y muy graves circunstancias que rodearon tal privación y que agravaron hasta extremos de difícil narración el sufrimiento, podemos ya avanzar que muy superior al de la muerte. Por tanto no vale como referente el indicado baremo, que, por otra parte, también se ha aplicado con criterios sumamente restrictivos en un ejercicio irracional de la prudencia y ponderación debidas… (FD. 3º).

[P]arece de todo punto correcto en términos de razonabilidad, prudencia y ponderación, la utilización del referente indemnizatorio empleado por la solicitante respecto de las indemnizaciones otorgadas por el Tribunal Supremo en los supuestos de personas indebidamente privadas de libertad, debiéndose tener presente que el criterio utilizado por el Alto Tribual es progresivamente creciente (…).

Con tales parámetros, procede aceptar íntegramente, por este concepto, e incluso calificarlo de moderado, el importe de algo más de un millón de euros pedido (…) [D]ebe tenerse en cuenta que todas las cifras han de multiplicarse por dos, pues dos han sido las privaciones de la solicitante (…) y que, finalmente, el hecho no es del todo equiparable, pues parece mucho más grave la privación de unos hijos que la que pueda sufrir uno mismo (…)

[H]a de ser objeto de indemnización diferenciado el sufrimiento asimilable a la muerte física que representa el fin de aquella expectativa [de recuperación de los hijos], la pérdida definitiva de los hijos, y por tal concepto acordamos una suma de 250.000 euros, en lugar de los 500.000 solicitados por la recurrente porque computa dos hijos, en tanto que es aquí donde hemos de hacer cierto trato diferenciador en atención a la singularidad de la situación producida con respecto a la menor Marcelina, porque para ésta no puede predicarse una situación equivalente a la muerte física dado que voluntariamente ha vuelto a convivir con su madre (…)

El último concepto de indemnización que procede acordar (…) es el relativo a la enfermedad actual de la solicitante, situación que sí que puede ser conceptuada como de secuelas a consecuencia de un daño o lesión sufrido de manera ilegítima, y aquí, desprovistos ya de todos los antecedentes, ya considerados, y atendiendo en exclusiva a las secuelas, podría establecerse cierto parangón con las secuelas producidas en accidente de circulación, y tomando como referente el baremo indemnizatorio de la Ley 30/1995 de 8 de noviembre (RCL 1995, 3046), pero en su máximo exponente en atención a la particularidad del caso, parece ponderada la determinación por este concepto de una suma de 200.000 euros, dado que los padecimientos son irreversibles e incurables. Sumados los conceptos referidos en las cuantías señaladas, nos pone en presencia de una indemnización ascendente a 1.450.000 euros, la que devengará el interés legal" (FD. 5º).

La Junta de Andalucía recurrió en amparo el Auto de la AP Sevilla y el TC desestimó el recurso por STC 11/2008, de 21 de enero.

5.1. Aplicación orientativa en accidentes distintos a los de circulación

- **Sala civil: STS, 1ª, 858/2010, 15.12.2010 -accidente de trabajo-. La aplicación orientativa no permite salirse del baremo**

"Don Mariano sufrió un accidente cuando se derrumbó la parte inferior de un tabique en el que trabajaba y le cayó en la mano izquierda, a resultas del cual sufrió lesiones y secuelas, que reclama de los demandados Zamakoa S.A, y Seguros FIATC, a los que la sentencia del Juzgado condena a pagar, conjunta y solidariamente, la suma de 150.253,03 euros, y además a Zamakoa, la cantidad de 5.913,22 euros (…) Recurrida en apelación, la sentencia de la Audiencia Provincial mantiene la del Juzgado salvo en lo relativo al pago de los intereses (…) Don Mariano formula un doble recurso, extraordinario por infracción procesal y de casación (…).

El segundo motivo formulado se sustenta en la aplicación indebida del artículo 1902 del CC, al minusvalorar los daños por errónea utilización del anexo (sistema, baremos y tablas) de la Ley 30/1995, condenando a la demandada Zamakoa a pagar cantidades inferiores a las procedentes conforme a derecho, al no haberse pronunciado sobre los factores de corrección inherentes en lo que se refiere a dos aspectos: incapacidad total del actor y perjuicios económicos/ingresos netos por trabajo personal.

Se estima.

La función de cuantificar los daños a indemnizar es propia y soberana de los órganos jurisdiccionales, atendidos los hechos probados y el principio de indemnidad de la víctima, al amparo de los artículos 1106 y 1902 del Código Civil , y esta función es el resultado de una actividad de apreciación para lo que goza de amplia libertad que abarca la posibilidad de servirse a efectos orientativos de sistemas objetivos, como el del baremo anexo a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, con el que se dota al sistema de criterios técnicos de valoración, así como de una seguridad y garantía para las partes mayor de la que deriva del simple arbitrio judicial, con la consecuencia de que solo pueda ser revisada en casación si la determinación por el Tribunal "a quo" resulta manifiestamente errónea o ilógica (…)

Ahora bien, esta regla tiene también dos limitaciones. Una, que el Tribunal no puede alterar los términos en que el debate fue planteado, y deberá resolver en atención a las circunstancias concurrentes, determinando la indemnización que corresponda con arreglo a dicho sistema, sin salirse del baremo para procurar indemnizaciones distintas, puesto que lo contrario haría incongruente la resolución y supondría un evidente desajuste en la determinación y cuantificaron del daño en un sistema en el que los valores de días y puntos están directamente calculados en previsión y ponderación a sus inherentes factores de corrección (…).

En el caso, la Sala se ha pronunciado expresamente tanto sobre el factor de corrección como de la pérdida de emolumentos para negarlos, posiblemente porque entiende correctamente indemnizado el daño con la indemnización que establece al margen de los factores. De esa forma ignora el factor de corrección derivado de la incapacidad total del actor que en el baremo utilizado en la sentencia para lesiones y secuelas oscila de 14.101 a 70.505 euros, lo que permite incrementar la indemnización [en] 50.000 euros, teniendo en cuenta la edad del lesionado (nacido el día 3 de marzo de 1976), la fecha del siniestro (13 de junio 2002) y las oportunidades perdidas de vida laboral, en un mercado que admite como general el trabajo

hasta los 65 años. Tampoco se indemnizan los perjuicios económicos/ ingresos por trabajo personal, lo que deberá corregirse mediante una indemnización del 5% sobre los 122.400 euros concedido por secuelas, lo que supone un incremento de 6.120 euros" (FD. 5º).

En el mismo sentido, véase la STS, 1ª, 321/2009, 7 de mayo –ingesta de sosa cáustica por negligencia de la dueña de un bar-.

- **Sala contencioso-administrativa: STS, 3ª, 9.2.2010, RJ 2010\3307 –responsabilidad civil médica-. La aplicación incorrecta de un baremo orientativo no es revisable en casación**

En el Hospital 12 de Octubre de Madrid el hijo de la actora, María Inés, había sido diagnosticado de esclerosis tuberosa a los ocho meses de edad y fue tratado hasta los cuatro años de edad con medicamentos sin que dejaran de producirse ataques epilépticos constantes y agresivos asociados a la enfermedad. En el Hospital San Carlos se le aplicó también durante otros tres años y medio tratamiento farmacológico y se desaconsejó la cirugía. Finalmente y a iniciativa propia, la actora acudió a la clínica Teknon de Barcelona, donde, tras las pruebas pertinentes, operaron al menor y, desde entonces, dejó de manifestar crisis epilépticas. El menor quedó con una minusvalía del 67%.

El 13 de agosto de 2002, María Inés interpuso, en nombre de su hijo, una reclamación patrimonial contra la Comunidad de Madrid, que fue desestimada por silencio administrativo, aunque, consta en la sentencia que la Administración reconoció a la actora los gastos de 45.445,90 euros derivados de la intervención quirúrgica. María Inés interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de la reclamación administrativa, siendo partes demandadas la Comunidad de Madrid y Zurich España Cía de Seguros y Reaseguros, y solicitó una indemnización de 450.759 euros por los daños físicos y morales del menor.

El TSJ Madrid (Sección 9ª) en Sentencia de 27.11.2006 estimó en parte el recurso de la actora y condenó a los demandados al pago de 418.553,66 euros, por considerar "probada la concurrencia de los requisitos legales de la responsabilidad patrimonial" (FD 4º STSJ Madrid). La cantidad concedida incluía los 45.445,90 euros por gastos de la operación y 373.107,76 euros en concepto de daños físicos y morales del menor, cantidad esta última que resultaba de aplicar el sistema de baremos. En particular, el Tribunal otorgó la máxima puntuación a los daños físicos del menor y le aplicó la partida de daño moral complementario.

El TS inadmitió el recurso de casación de la compañía aseguradora y desestimó el único motivo del recurso de la Administración demandada basado en el carácter desproporcionado y arbitrario de la indemnización, pues, alegaba el recurrente, la sentencia impugnada no se atenía a los criterios de aplicación del baremo en lo relativo a la minusvalía y el daño moral:

"[E]l baremo recogido en la resolución de la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones de 24 de enero de 2006, que rige para el sector de los seguros privados, no era vinculante para el tribunal a quo. Este acudió a dicho documento para orientarse a la hora de calcular la cuantía de la indemnización, del mismo modo que habría podido inspirarse en algún otro documento similar o en el criterio jurisprudencial predominante en casos análogos. En todo caso, la aplicación incorrecta de un baremo no vinculante -suponiendo que efectivamente tuviera lugar- no constituye una infracción de la legalidad y, por consiguiente, no sirve de fundamento para casar la sentencia impugnada. Por lo demás, teniendo en cuenta la experiencia de esta Sala en

materia de indemnizaciones, la cifra finalmente establecida por el tribunal a quo no resulta desproporcionada ni arbitraria" (FD 4º).

- **Sala penal: STS, 2ª, 375/2008, 25.6.2008 –delito doloso de lesiones-. El tribunal de instancia puede salirse del baremo para aumentar la indemnización en casos de delitos dolosos**

"El acusado Jesús Ángel, mayor de edad y sin antecedentes penales, jugaba un partido de fútbol-sala en el campo de "Ses Paises", de Sant Antoni (Ibiza), cuando, en sus minutos finales y encontrándose en la zona del centro del campo, propinó a Fermín, jugador del equipo rival, un codazo, tras lo cual se dirigió inmediatamente hacia su área, saliendo tras él el referido Fermín. Al llegar a su posición este le propinó un empujón recriminándole su comportamiento, empujón que le hizo retroceder, sin perder el equilibrio y caer al suelo, respondiendo el acusado, con intención de menoscabar su integridad física, con un puñetazo dirigido directamente al rostro, golpeándole así en la zona de la nariz, frente y ojo derecho (…)

La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: "Condenamos a Jesús Ángel como autor responsable de un delito de lesiones (…) a las penas de un año y seis meses de prisión (…) En el orden civil, Jesús Ángel abonará a Fermín, en concepto de indemnización, la suma de 50.589,58 euros (…)

[S]e preparó recurso de casación por el condenado (…) La sala de instancia desglosa los conceptos indemnizatorios de forma suficiente y que permite entender el criterio de valoración del que ha hecho uso. En efecto, de una parte compensa los 100 días de baja e incapacidad (10 de ellos de hospitalización) con 5.016,10 euros; las secuelas, sin considerar el perjuicio estético, con 21,141,20 euros; con 19.027 euros este último. Sobre el total resultante por las secuelas la sala giró un factor de corrección del 10%; y, en fin, añadió 1.388,20 euros en concepto de lucro cesante por la pérdida de días de trabajo (…) Por lo demás, la circunstancia de que la adecuación a las prescripciones del baremo, tomado como referencia, no haya sido plena, es una objeción aquí inatendible, pues sus previsiones tienen que ver con acciones de muy distinto tenor de la enjuiciada. Y es que, en efecto, desde el punto de vista de la afección moral no es lo mismo resultar víctima de un accidente propio de los del tráfico rodado que de una acción dolosa, reflexivamente orientada a causar daño. En este caso en una región anatómica como la del impacto. Así, es razonable que ese plus de gravedad y de gravamen se traduzca en un incremento del monto de la indemnización".

En el mismo sentido, véase la STS, 2ª, 366/2011, de 11.5.2011 –delito doloso de lesiones-.

Cuatro referencias bibliográficas específicas:

- Miquel Martín-Casals, "Por una puesta al día del sistema de valoración del daño corporal ("baremo"). Líneas generales de los trabajos de la "Comisión de expertos"", InDret 4/2012, www.indret.com
- Miquel Martín-Casals, "Conceptos perjudiciales (*heads of damage*) en la indemnización por muerte y por lesiones personales en Europa", InDret 2/2013, www.indret.com.
- Javier López García de la Serrana (Dir.), *Manual de Valoración del Daño Corporal, Guía de aplicación del Sistema de Baremación para accidentes de circulación*, Aranzadi, 2007.

- Álvaro Luna Yerga, Sonia Ramos González, Ignacio Marín, Guía de Baremos, Valoración de daños causados por accidentes de circulación, de navegación aérea y por prisión indebida, InDret , InDret /2006, www.indret.com

5.2. Anexo Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el RDL 8/2004, de 29 de octubre

"Primero. Criterios para la determinación de la responsabilidad y la indemnización.
1. Este sistema se aplicará a la valoración de todos los daños y perjuicios a las personas ocasionados en accidente de circulación, salvo que sean consecuencia de delito doloso (…)
3. A los efectos de la aplicación de las tablas, la edad de la víctima y de los perjudicados y beneficiarios será la referida a la fecha del accidente (...)"

Según las SSTS 1ª, 429/2007, 430/200, de 17.4.2007 (MP: Encarna Roca Trías), los criterios de aplicación de las tablas y los puntos que correspondan a la secuela se fijarán de acuerdo con el régimen jurídico vigente en el momento del accidente y la valoración de los daños se llevará a cabo según las tablas de baremos actualizadas y vigentes en el momento del alta médica definitiva del perjudicado, esto es, en el momento de la consolidación de las secuelas. El Texto Refundido fue objeto de una reforma importante en materia de cálculo del perjuicio estético, entre otras cuestiones, por la Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados.

"5. Darán lugar a indemnización la muerte, las lesiones permanentes, invalidantes o no, y las incapacidades temporales.
6. Además de las indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas, se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en la cuantía necesaria hasta la sanación o consolidación de secuelas, siempre que el gasto esté debidamente justificado atendiendo a la naturaleza de la asistencia prestada.
En las indemnizaciones por fallecimiento se satisfarán los gastos de entierro y funeral según los usos y costumbres del lugar donde se preste el servicio, en la cuantía que se justifique.
7. La cuantía de la indemnización por daños morales es igual para todas las víctimas, y la indemnización por los daños psicofísicos se entiende en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud. Para asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios causados, se tienen en cuenta, además, las circunstancias económicas, incluidas las que afectan a la capacidad de trabajo y pérdida de ingresos de la víctima, las circunstancias familiares y personales y la posible existencia de circunstancias excepcionales que puedan servir para la exacta valoración del daño causado. Son elementos correctores de disminución en todas las indemnizaciones, incluso en los gastos de asistencia médica y hospitalaria y de entierro y funeral, la concurrencia de la propia víctima en la producción del accidente o en la agravación de sus consecuencias y, además, en las indemnizaciones por lesiones permanentes, la subsistencia de incapacidades preexistentes o ajenas al accidente que hayan influido en el resultado lesivo final; y son elementos correctores de agravación en las indemnizaciones por lesiones permanentes la producción de invalideces concurrentes y, en su caso, la subsistencia de incapacidades preexistentes".

El Tribunal Supremo español ha admitido la posibilidad de salirse del baremo en casos de accidentes de circulación y aumentar la indemnización básica hasta en un 75% en dos situaciones:
a) Si el lucro cesante acreditado la víctima es muy superior al que resulta de aplicar el factor de corrección por perjuicios económicos y por incapacidad permanente (STS, 1ª, 25.3.2010, RJ 2010\1987, MP: Juan Antonio Xiol Ríos)
b) Si la concurrencia de varias lesiones supone "por sí misma una agravación de la entidad fisiológica del conjunto de las secuelas no prevista en las tablas al valorar las invalideces o establecer los factores de corrección" (SSTS, 1ª, 383/2011, de 8 de junio, FD. 5º, MP: Juan Antonio Xiol Ríos y 648/2011, de 27 de septiembre, FD. 9º, MP: José Antonio Seijas Quintana).

"8. En cualquier momento podrá convenirse o acordarse judicialmente la sustitución total o parcial de la indemnización fijada por la constitución de una renta vitalicia en favor del perjudicado (...).
10. Anualmente, con efectos de 1 de enero de cada año y a partir del año siguiente a la entrada en vigor de este texto refundido, deberán actualizarse las cuantías indemnizatorias fijadas en este anexo (…) En este último caso y para facilitar su conocimiento y aplicación, se harán públicas dichas actualizaciones por resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
[Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2013 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación].

Segundo. **Explicación del sistema**.
a. Indemnizaciones por muerte (tablas I y II).
Tabla I. Comprende la cuantificación de los daños morales, de los daños patrimoniales básicos y la determinación legal de los perjudicados, y fijará los criterios de exclusión y concurrencia entre ellos (…)
Tabla II. Describe los criterios que deben ponderarse para fijar los restantes daños y perjuicios ocasionados, así como los elementos correctores de estos. A dichos efectos, debe tenerse en cuenta que tales daños y perjuicios son fijados mediante porcentajes de aumento o disminución sobre las cuantías fijadas en la tabla I y que son satisfechos separadamente y además de los gastos correspondientes al daño emergente, esto es, los de asistencia médica y hospitalaria y los de entierro y funeral.
Los factores de corrección fijados en esta tabla no son excluyentes entre sí, sino que pueden concurrir conjuntamente en un mismo siniestro.
b. Indemnizaciones por lesiones permanentes (tablas III, IV y VI). La cuantía de estas indemnizaciones se fija partiendo del tipo de lesión permanente ocasionado al perjudicado desde el punto de vista físico o funcional, mediante puntos asignados a cada lesión (tabla VI); a tal puntuación se aplica el valor del punto en euros en función inversamente proporcional a la edad del perjudicado e incrementado el valor del punto a medida que aumenta la puntuación (tabla III); y, finalmente, sobre tal cuantía se aplican los factores de corrección en forma de porcentajes de aumento o reducción (tabla IV), con el fin de fijar concretamente la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados que deberá ser satisfecha, además de los gastos de asistencia médica y hospitalaria.
Tablas III y VI. Se corresponden, para las lesiones permanentes, con la tabla I para la muerte (…)
En concreto, para **la tabla VI** ha de tenerse en cuenta:

1. Sistema de puntuación. Tiene una doble perspectiva. Por una parte, la puntuación de 0 a 100 que contiene el sistema, donde 100 es el valor máximo asignable a la mayor lesión resultante; por otra, las lesiones contienen una puntuación mínima y otra máxima.
La puntuación adecuada al caso concreto se establecerá teniendo en cuenta las características específicas de la lesión en relación con el grado de limitación o pérdida de la función que haya sufrido el miembro u órgano afectado (...)
2. Incapacidades concurrentes. Cuando el perjudicado resulte con diferentes lesiones derivadas del mismo accidente, se otorgará una puntuación conjunta, que se obtendrá aplicando la fórmula siguiente: [[(100 - M) x m] / 100] + M, donde M = puntuación de mayor valor y m= puntuación de menor valor. Si en las operaciones aritméticas se obtuvieran fracciones decimales, se redondeará a la unidad más alta. Si son más de dos las lesiones concurrentes, se continuará aplicando esta fórmula, y el término *M* se corresponderá con el valor del resultado de la primera operación realizada. En cualquier caso, la última puntuación no podrá ser superior a 100 puntos. Si, además de las secuelas permanentes, se valora el perjuicio estético, los puntos por este concepto se sumarán aritméticamente a los resultantes de las incapacidades permanentes, sin aplicar respecto a aquellos la indicada fórmula.
Tabla IV. Se corresponde con la tabla II de las indemnizaciones por muerte y le son aplicables las mismas reglas, singularmente la de posible concurrencia de los factores de corrección.
c. Indemnizaciones por incapacidades temporales (tabla V). Estas indemnizaciones serán compatibles con cualesquiera otras y se determinan por un importe diario (variable según se precise, o no, una estancia hospitalaria) multiplicado por los días que tarda en sanar la lesión y corregido conforme a los factores que expresa la propia tabla, salvo que se apreciara en la conducta del causante del daño culpa relevante y, en su caso, judicialmente declarada".

5.3. Caso práctico

Mujer de 30 años de edad es víctima de un accidente de circulación el 15 de noviembre de 2012 cuando viajaba como ocupante en uno de los dos turismos implicados en el accidente. No se pudo acreditar la causa del accidente. Como consecuencia del mismo, la mujer sufrió una grave lesión medular que requirió tratamiento quirúrgico con material de osteosíntesis. La lesión resultó en una paraparesia grave de los miembros inferiores. Permaneció 193 días ingresada en el hospital y, tras el alta hospitalaria, la víctima hubo de seguir un tratamiento de fisioterapia durante 87 días más hasta que le confirmaron las secuelas descritas. A pesar de las limitaciones físicas, la víctima puede desarrollar autónomamente su vida personal. La víctima era profesora y bailarina de ballet y contaba con unos ingresos anuales de 32.000 euros, después de impuestos.

Propuesta de solución:
La víctima tendrá derecho a una indemnización básica tanto por lesiones permanentes (tabla III), como por incapacidad temporal (tabla V), corregidas al alza por dos factores de corrección: perjuicios económicos, aplicables a ambas indemnizaciones básicas, y el relativo a la incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima, aplicable sólo a la indemnización básica por lesiones permanentes. Considerando las explicaciones que se verán a continuación, la indemnización máxima aproximada que podría recibir, conforme al sistema legal de baremos, es de **361.821,5 euros.**

I. Normativa aplicable: tablas de baremos vigentes en el momento del alta médica o de estabilización de las secuelas

Conforme a la jurisprudencia del TS, establecida en las SSTS, 1ª, de 17 de abril de 2007, las cuantías aplicables serán las vigentes en el momento de estabilización de las secuelas (**Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones**). Las restantes cuestiones, distintas a la cuantías (criterios de responsabilidad, explicación del sistema, tabla VI relativa a los puntos por secuela) están reguladas en el Anexo Texto Refundido aprobado por RDL 8/2004, vigente en el momento de producción del accidente. Conviene recordar que el Anexo, apartado primero, 3 establece que la edad de la víctima relevante a los efectos de aplicar las tablas será la referida a la fecha del accidente.

II. Lesiones permanentes

1. Indemnización básica

En el caso, concurren varias **secuelas físicas** independientes a las que la Tabla VI asigna las siguientes puntuaciones:

- paraparesia grave de los miembros inferiores: 65 puntos
- material de osteosíntesis en la columna vertebral: 15 puntos

Además, concurre un **perjuicio estético**, que podría calificarse de importante y al que la tabla VI asigna de entre 19 y 24 puntos. Escogemos para el cálculo la máxima puntuación posible:

- perjuicio estético: 24 puntos

Respecto a las dos secuelas físicas, procede aplicar la **fórmula** prevista en el apartado segundo, b) 2º del Anexo del Texto Refundido, en lugar de sumar las puntuaciones. En cambio, respecto al perjuicio estético, el mismo apartado establece que deberá valorarse por separado de acuerdo con la tabla III y la cantidad obtenida deberá sumarse a la indemnización básica por los perjuicios físicos. En ningún caso, podrán sumarse los puntos asociados al perjuicio estético con los puntos asociados a los perjuicios físicos (método de cálculo aplicable antes de la reforma del sistema de baremos por la Ley 34/2003).

Fórmula de lesiones concurrentes:

(100-65) x 15/100 + 65 = 70,25 = **71** (el sistema prevé que se redondee a la unidad más alta)

2. Factores de corrección

La indemnización básica que resulte deberá incrementarse con los siguientes factores de corrección previstos en la tabla IV:

a) **perjuicios económicos (hasta un 25% más sobre la indemnización básica, dados los ingresos netos de la víctima)**

b) **incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima, sólo aplicable a la indemnización básica por lesiones permanentes.** La jurisprudencia del TS ha considerado que este factor de corrección tiene un doble objeto: reparar los perjuicios patrimoniales derivados de la disminución de ingresos de la víctima, pero también el daño moral ligado a la situación de incapacidad para desarrollar las actividades ordinarias de la vida. Consta que la víctima puede desarrollar, por sí sola, después del accidente, su vida ordinaria; sin embargo la secuela impide que pueda dedicarse a su profesión como profesora y bailarina de ballet. Parece razonable colocar a la víctima en una situación de **incapacidad permanente total para el desarrollo de su ocupación laboral habitual**.

Sin embargo, como la lesión le permite desarrollar autónomamente sus actividades ordinarias, el aumento de la indemnización básica por este factor de corrección no podrá ser el máximo posible según la tabla IV. Teniendo en cuenta que la tabla IV concede por este concepto una indemnización que oscila entre 19.115,20 a 95.575,94 euros, un 75% de la indemnización máxima (71.681,95 euros) podría dar razón de la situación real en la que se encuentra la víctima.

La circunstancia de que la víctima pueda desarrollar autónomamente su vida ordinaria es un factor, de nuevo, relevante para negar la aplicación de otros factores de corrección, asociados a lesiones más incapacitantes que la de la víctima, tales como la necesidad de ayuda de otra persona, la adecuación de la vivienda, la adecuación del propio vehículo, o los perjuicios morales de familiares. Aunque en la tabla IV no consta de manera clara, la jurisprudencia del TS ha asociado estos factores de corrección a situaciones de gran invalidez (tetraplejías, paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas, ceguera completa, etc.).

III. Incapacidad temporal

A la indemnización básica resultante de multiplicar el número de días de hospitalización y de días de baja (en este caso impeditivos) por el valor asignado en la tabla V, habrá que añadir el factor de corrección por perjuicios económicos, que supondrá hasta un 25% más sobre la indemnización básica. Dado que no se ha podido acreditar cómo ocurrió el accidente no será posible aplicar la doctrina de la STC 181/2000 según la cual en caso de culpa relevante del causante del daño la cuantía del lucro cesante derivado de la pérdida de ingresos por razón del trabajo estará sujeta a la prueba que logre aportar la víctima en juicio. Esta circunstancia no es aplicable al caso, por lo que podremos valorar el perjuicio económico conforme a baremos.

IV. Importe desglosado de la indemnización y cuantía total de la indemnización

Mujer, 29 años, 32.000 euros netos anules	
CONCEPTOS	**CUANTÍAS (€)**
Lesiones permanentes	
Indemnización básica	
▪ **Secuelas concurrentes (nº puntos x €/punto)**	
71 puntos x 2.578,93 €/punto	**183.104,03**
▪ **Perjuicio estético (nº puntos x €/punto)**	**30.116,16**
24 puntos x 1.254,84€/punto	
Factores de corrección	
▪ **Perjuicio económico (+ 25% sobre la indemnización básica)**	**53.305,05**
▪ **Incapacidad permanente total (De 19.115,20 a 95.575,94 euros)**	**71.681,95**
Incapacidad temporal	
Indemnización básica (nº de días x €/día)	
▪ **Estancia hospitalaria**	
193 días x 71,63 €/día	**13.824,59**
▪ **Sin estancia hospitalaria impeditivo***	
87 días x 58,24 €/día	**5.066,88**
Factores de corrección	
▪ **Perjuicio económico (+ 25% sobre la indemnización básica por incapacidad temporal)**	**4.722,87**
TOTAL	**361.821,5**

* Impeditivo, porque fuera del hospital, la víctima no puede desarrollar su ocupación habitual

6. Pérdida de ingresos y de la capacidad de generarlos / *Lost earning, Impairment of Earning Capacity*

Antes de la aplicación generalizada del sistema de baremos a los casos de daños distintos a accidentes de circulación, era una práctica habitual de los tribunales conceder una indemnización a tanto alzado, sin detallar la cantidad asignada a cada partida de daño: la STS, 1ª, 983/2005, de 30 de noviembre, confirmó la indemnización de 180.304 euros a una menor de 9 años de edad, que había sufrido lesiones neurológicas por asfixia debido a inmersión en una piscina pública, con base en las "lesiones, secuelas, y lucro cesante y gastos sobrevenidos".

- STS, 1ª, 842/2009, de 5 de enero de 2010:

La actriz española, Loles León, entró con su acompañante, el actor británico Jeremy Irons, en la suite en la que éste último se hospedaba en el hotel de lujo Santo Mauro de Madrid y se cayó por las escaleras. La habitación estaba a oscuras porque el alumbrado de emergencia no funcionaba. Como consecuencia de la caída, la actora sufrió fractura de pelvis y de la muñeca derecha.

La actora reclamó a la propietaria del hotel, Anca Hoteles, S.L., y al director del hotel Santo Mauro 551.377 euros.

JPI núm. 11 de Madrid (11.7.2002) desestimó la demanda. La AP estimó en parte el recurso de apelación de la actora, estimó en parte la demanda, condenó a Anca Hoteles, S.L. a pagar 41.226,852 euros y absolvió al director del hotel. La AP apreció concurrencia de culpas, en un 75% para la actora y en un 25% para la entidad demandada.

La actora interpuso recurso de casación contra la SAP y alegó, entre otros motivos, infracción del art. 1902 y 1106 CC porque la SAP no había incluido en la indemnización la ganancia dejada de obtener por la actora, valorada en 12.260,64 euros, al no poder cumplir su contrato con una productora de cine australiana. El Tribunal Supremo estimó este motivo del recurso y aumentó la indemnización debida por el demandado en 3.065,16 euros, equivalente al 25% de la ganancia alegada por la actora:

"[U]na interpretación de los arts. 1902 y 1106 CC acorde con la realidad social no autoriza un criterio tan rígido que por la mera coincidencia temporal parcial de dos contratos de una misma actriz para aparecer en dos películas diferentes, aunque una se ruede en España y la otra en Australia, quede descartado su trabajo en una de ellas, pues no sólo el tiempo requerido por la productora australiana se limitaba a dos semanas de rodaje y una de ensayo sino que, además, la experiencia enseña que los actores suelen esforzarse al máximo por aprovechar las épocas en que les ofrecen papeles, dado su siempre incierto futuro profesional, y en la actualidad es habitual la participación simultánea en películas y series de televisión, incluso en lugares distantes entre sí, gracias a la facilidad y rapidez de desplazamiento que brindan los modernos medios de transporte" (FD. 10º).

6.1. Sistema de baremos y pérdida de ingresos

La indemnización por pérdida de ingresos (*Loss of profits*) está contemplada en diversos apartados del sistema de baremos legales:

Con carácter general, el art. 1.2 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre -en adelante, Texto Refundido- incluye en los " daños y perjuicios causados a las personas", (...) "[e]l valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales" y el apartado Primero, 7º del Anexo especifica que "[p]ara asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios causados, se tienen en cuenta, además, las circunstancias económicas, incluidas las que afectan a la capacidad de trabajo y pérdida de ingresos de la víctima".

En particular, las Tablas del sistema que bareman la indemnización por muerte, por lesiones permanentes y por incapacidad temporal contemplan, para el caso de víctimas en edad laboral, el lucro cesante consistente en la pérdida de ingresos económicos como un factor de corrección de aumento de la indemnización básica por muerte o lesiones permanentes, que puede oscilar entre el 1 y el 75%, en función de los ingresos netos de la víctima por trabajo personal. Este modo de cálculo de las pérdidas de ingresos de trabajo ha sido criticado por la doctrina porque supone una valoración en abstracto arbitraria al aplicar el porcentaje de aumento sobre una indemnización que repara el daño corporal y el daño moral, conceptos que nada tienen que ver con la entidad del lucro cesante de la víctima concreta (Miquel Martín, "La «modernización» del Derecho de la responsabilidad extracontractual", p. 93).

La víctima en edad laboral que no acredite ingresos tiene derecho a que se le aplique el factor de corrección por perjuicios económicos en su grado mínimo (hasta el 10%) - STS, 1ª, 18.6.2009 (RJ 4318)- (estudiantes, amas de casa, trabajadores que en el momento del accidente habían perdido su trabajo).

Además, la víctima con lesiones permanentes que la incapacitan para su ocupación o actividad habitual tiene derecho a obtener hasta 191.151,88 euros, cantidad prevista para los casos más graves que determinen una incapacidad permanente absoluta de la víctima (**Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones**), cantidad que pretende reparar el perjuicio patrimonial vinculado a la imposibilidad de desarrollar la ocupación habitual, además del daño moral asociado a la pérdida de calidad de vida.

- STS, 1ª, 25.3.2010, RJ 2010\1987 (MP: Juan Antonio Xiol Ríos):

El 2 de mayo de 2000 se produjo una colisión entre el vehículo conducido por Íñigo y por Raimundo, el primero sufrió secuelas determinantes de una incapacidad permanente total.

Íñigo demandó a los herederos del Raimundo y a Seguros Zurich, S.A., compañía aseguradora del vehículo de Raimundo, y reclamó la diferencia entre la suma consignada por la aseguradora (161.445 euros: 114.017 euros por incapacidad temporal y secuelas; 41.176,98 euros por incapacidad permanente total, y 6.251,03 euros por perjuicios económicos) y la indemnización que le correspondería, esto es, 103.573,03 euros, según el sistema de baremos, y 143.516 euros, en concepto del lucro cesante acreditado mediante informe actuarial.

El JPI de Pravia (4.12.2003) estimó en parte la demanda, consideró que la indemnización resultante de baremos era de 190.268,17 euros y sustrajo los 161.445 euros pagados por la aseguradora, por lo que condenó a los demandados a pagar 28.823,17 euros. Respecto a la

indemnización solicitada por lucro cesante, el JPI consideró que esta partida está incluida, por imperativo legal ex art. 1.2 RDL 8/2004, en la indemnización por incapacidad permanente.

La SAP de Oviedo (Sección 5a, 9.6.2004) desestimó el recurso de apelación del actor al negar la indemnización del lucro cesante más allá del baremo, estimó el de la aseguradora al considerar que la cantidad que había abonado al actor en concepto de incapacidad permanente total era correcta al hallarse dentro de la horquilla del baremo y desestimó la demanda por "apreciar la Sala dudas de hecho en cuanto a la cantidad a reclamar, en atención a la estrecha, pero en definitiva discrecionalidad que concede el baremo al juzgador" (FD 6º SAP).

El TS estimó el recurso de casación interpuesto por el actor en lo relativo a la indemnización por lucro cesante, revocó la SAP sólo en este extremo y estimó la demanda en el sentido de indemnizar al actor con 33.338,80 euros en concepto de lucro cesante:

"La Tabla IV ... se remite a los "elementos correctores" del apartado primero, número 7, del Anexo, y establece un porcentaje de aumento o de reducción "según circunstancias"... [L]os elementos correctores a los que se refiere el citado apartado no pueden ser solo los expresamente calificados como de aumento o disminución, sino... también los [criterios] fundados en circunstancias excepcionales relacionadas con las circunstancias personales y económicas de la víctima" (FD 3º G).

"[E]l lucro cesante por disminución de ingresos de la víctima en caso de incapacidad permanente... es susceptible... de ser compensado proporcionalmente... por encima de lo que pueda resultar de la aplicación de los factores de corrección por perjuicios económicos y por incapacidad permanente cuando concurran circunstancias que puedan calificarse de excepcionales, sin necesidad, en este caso, de limitarlo a los supuestos de prueba de la culpa relevante por parte del conductor" (FD 3o G, d). "[En concreto, cuando exista] un grave desajuste entre el factor de corrección por perjuicios económicos [y el factor de corrección por incapacidad permanente] y el lucro cesante realmente padecido"... [L]a corrección debe hacerse en proporción al grado de desajuste probado, con un límite máximo admisible... del 75% de incremento de la indemnización básica, pues éste es el porcentaje máximo que se fija en el factor de corrección por perjuicios económicos" (FD 4º).

"[En el caso] 1) Se ha probado mediante informes actuariales la existencia de un grave desajuste entre el factor de corrección por perjuicios económicos, que la Sala aplica en un 7,5% de la indemnización básica por lesiones permanentes (que arroja un total de 6.251,03 euros), y el lucro cesante realmente padecido [según el informe actuarial presentado por el actor el lucro cesante sería de 148.516,48 euros y la aseguradora demandada lo cifra en 64.117,20 euros] ... 2) Este lucro cesante no resulta compensado de forma suficiente ... por el factor de corrección por incapacidad permanente ... [P]odría aceptarse como razonable que la indemnización concedida por la aseguradora por incapacidad permanente total (41.176,98 euros) puede imputarse en un 50% al lucro cesante, y el resto a daño no patrimonial... [L]a proporción en que resultaría resarcido el lucro cesante por disminución de ingresos de la víctima apenas alcanzaría el 20%... 3) La Sala estima que ... debe aplicarse ponderadamente como factor de corrección por concurrencia de la circunstancia excepcional de existencia de lucro cesante no compensado un porcentaje intermedio de un 40% de incremento sobre la indemnización básica (de 33.338,80 euros)" (FD. 5º).

6.2. Lucro cesante y menores de edad

STS, 1ª, 237/2011, de 13 de abril

La actora, una escolar de 15 años de edad resultó gravemente herida cuando un árbol cayó sobre ella en el recinto de su colegio. La actora demandó a Residencia Hispano Alemana para Alumnos S.A., la Asociación Patronato del Colegio Alemán y la entidad aseguradora Liberty Seguros, y solicita una indemnización de 3.758.989,40 €.

El JPI núm. 1 de Marbella (10.10.2006) estimó en parte la demanda y condenó a Residencia Hispano Alemana para Alumnos S.A. y Asociación Patronato del Colegio Alemán al pago de 626.035,22 €. La AP de Málaga (Sección 6ª, 6.6.2007) estima en parte el recurso de apelación presentado por las demandadas y redujo la indemnización a 230.419,49 €.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por Rita:

"Sin embargo el planteamiento global del motivo impide aplicar [la doctrina de esta Sala desde la STS, 1ª, 25.3.2010], en favor de la recurrente, pues su fundamento principal parece ser la "notoria desproporción" entre la cantidad de 68.651'45 euros establecida por la sentencia impugnada como factor de corrección por la incapacidad por invalidez permanente y la "renta vitalicia" de 1.842.517'40 euros pedida en la demanda por lucro cesante, siendo así que lo determinante para la referida doctrina de esta Sala no es, desde luego, la diferencia entre lo pedido en la demanda y la cantidad resultante de una aplicación del sistema en su interpretación estrictamente literal. De ahí que tampoco en el motivo se aluda a informe actuarial alguno, elemento probatorio normalmente tenido en cuenta para poder aplicar la referida doctrina al caso concreto, y sí únicamente, solo al final del alegato del motivo, a informes del Instituto Nacional de Estadística sobre ingresos familiares medios y esperanza de vida de la mujer en Andalucía de todo punto insuficientes para la aplicación de los elementos correctores de que se trata, toda vez que han de fundarse en circunstancias excepcionales".

7. Infracción de deberes de información

- STS, 1ª, 948/2011, de 16 de enero

"El día 3 de febrero de 2005 Don Pedro Enrique fue intervenido quirúrgicamente por el Dr. Adriano para efectuar una disectomía cervical. El Dr. Adriano tiene asegurada la responsabilidad civil en la compañía Zurich (póliza colectiva del Colegio de Médicos) y pertenece al cuadro médico de la compañía Aresa, con quien el paciente tenía concertado seguro de enfermedad en la modalidad de asistencia sanitaria. A consecuencia de la operación, el Sr. Pedro Enrique , entonces de 48 años, quedó afectado de una tetraplejia con paresia severa de ambas extremidades inferiores, tronco y parte de las extremidades superiores (...).

El Sr. Pedro Enrique y su familia formularon demanda contra el Dr. Adriano, contra la aseguradora de éste, ZURICH, y contra ARESA, compañía aseguradora de salud. Reclamaban 1.387.519 euros de indemnización más el importe de las mensualidades de la residencia asistencial en la que se encontraba ingresado, así como 57.518,94 euros para sus hijos y esposa en concepto de perjuicios morales a familiares como consecuencia de las secuelas postoperatorias sufridas.

Conviene señalar que no se discute en este pleito la eventual existencia de mala praxis en la actuación propiamente quirúrgica (...) Lo que se cuestiona con carácter principal es si la falta de información ha producido al paciente algún perjuicio (...) [L]a sentencia de la Audiencia Provincial revocó en parte la del juzgado, que había desvinculado la responsabilidad por deficiente información de las consecuencias materiales resultantes de la intervención, indemnizando exclusivamente un daño moral estimado en 118.253,79 euros y en 10.000 euros a familiares, para indemnizarle la totalidad de los daños sufridos mediante la aplicación del baremo establecido para la responsabilidad civil de la circulación de vehículos de motor (RCL 1995, 3046), que las partes utilizaron como referente, cifrando el importe de la condena en 509.954,99 euros a favor del Sr. Pedro Enrique y en 19.172,98 euros a cada uno de los restantes demandados, esposa y dos hijos.

Formularon recurso de casación Don Pedro Enrique, Don Adriano, las compañías Zurich y Aresa. Además, el Dr. Adriano ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal (...)

[E]xiste una evidente incertidumbre causal en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haber sido informado el paciente, en base a lo cual y dentro del ámbito de la causalidad material o física que resulta de la sentencia, es posible hacer efectivo un régimen especial de imputación probabilística que permite reparar en parte el daño, como es la pérdida de oportunidad, que toma como referencia, de un lado, el daño a la salud sufrido a resultas de la intervención y, de otro, la capacidad de decisión de un paciente razonable que valora su situación personal y decide libremente sustraerse o no a la intervención quirúrgica sin el beneficio de conocer las consecuencias para su salud una vez que estas ya se han producido. Ello exige una previa ponderación de aquellas circunstancias más relevantes desde el punto de vista de la responsabilidad médica, que en el caso se concretan en una intervención clínicamente aconsejable, en la relación de confianza existente entre paciente- médico, en su estado previo de salud, el fracaso del tratamiento conservador, las complicaciones de escasa incidencia estadística y en las consecuencias que se derivaron de la misma; todo lo cual permite cuantificar la indemnización en 254.977,45 euros a favor del Sr. Pedro Enrique y en la cantidad de 9.586,49 euros a favor de cada uno de los restantes codemandantes, es decir, un 50% de lo que hubiera correspondido por una mala praxis médica acreditada, tomando como referencia la misma que recoge la sentencia de la Audiencia, mediante la aplicación del baremo, que no ha sido cuestionada (...)"

- STS, 1ª, 323/2011, de 13 de mayo

En fecha indeterminada, Celia consintió someterse a una intervención quirúrgica consistente en una menisectomía artroscópica para la que solicitó y obtuvo autorización de su compañía aseguradora, ASISA. No obstante, en quirófano, el cirujano comprobó que la operación programada era innecesaria porque el menisco no estaba afectado, decidió cambiar el tratamiento quirúrgico en quirófano, seccionó y extrajo la plica medial, y liberó el alerón o retináculo rotuliano externo, operación para la cual la paciente no había prestado ningún consentimiento.

Celia demanda a Felicísimo y a Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A), y solicita una indemnización de 180.000 €

El JPI núm. 2 de Madrid (21.10.2005) desestima la demanda. La AP de Madrid (Sección 12ª, 7.11.2007) desestima el recurso de apelación.

El Tribunal Supremo revocó la SAP desestimatoria de la demanda porque consideró que, aun cuando la intervención que se llevó a cabo fue correcta y no resultó ninguna secuela física, existía un daño indemnizable derivado del incumplimiento del profesional: "[e]l consentimiento previo de la paciente lo había dado para una intervención clínica distinta… de la que no derivaba ningún riesgo inmediato y grave para la integridad física o psíquica del enfermo que pudiera justificarla. No es el daño que resulta de la intervención programada puesto que no se produjo, sino el daño que resulta de la que sí se llevó a cabo con la que no solo no logró mejorar sus dolencias en la rodilla, sino que se le privó de conocer los riesgos y beneficios posibles para su salud, puesto que ninguna información hubo respecto de una actuación médica que desconocía. La falta de información configura en este caso un daño moral grave... Un daño que fundamenta la responsabilidad por lesión del derecho de autonomía del paciente respecto de los bienes básicos de su persona, como presupuesto esencial para poder decidir libremente sobre la solución más conveniente a su salud, a su integridad física y psíquica y a su dignidad" (FD. 2º).

El Tribunal Supremo asumió la instancia y cuantificó el daño en 30.000 euros "teniendo en cuenta la intervención médica realizada, de menor entidad que la que había sido proyectada inicialmente, así como [que la intervención] tampoco puso fin a sus dolencias" (FD. 3º).

- STS, 3ª, de 25 de mayo de 2011, RJ 2012\415

El demandante, de 52 años y enfermo del estómago por un pólipo gástrico ulcerado, fue intervenido en el Hospital de Bellvitge donde se le practicó una gastrectomía parcial, pero, como consecuencia de una hemorragia, fue intervenido de urgencia para practicar gastrectomía total con el resultado de síndrome de Dumping post-gastrectomía --un efecto adverso que se materializa en un 14-20% en las gastrectomías parciales y en un 20-40% en las totales-- así como un trastorno ansioso depresivo. Las secuelas del actor determinaron su incapacidad permanente absoluta.

El TSJCat desestimó el recurso contencioso-administrativo del actor contra la resolución del *Institut Català de la Salut*(ICS) que se desestimaba la reclamación administrativa.

El TS estimó el recurso de casación y revocó la STSJCat, condenando al ICS a pagar 75.000 euros:

"[N]o se cumplieron con ocasión de la primera intervención quirúrgica, en el modo y forma que era preciso, los deberes de información que en aquel entonces ordenaban los apartados 5 y 6 del art. 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad . Y más en concreto, que no se observó el de la obtención de un previo consentimiento escrito del paciente para la realización de la intervención, basado en una información completa sobre su proceso … la Sala de instancia no tuvo por acreditado el cumplimiento de aquellos deberes. (FD. 5º) … [E]l resarcimiento del daño moral, por su carácter afectivo y de pretium doloris, carece de módulos objetivos, lo que conduce a valorarlo en una cifra razonable, que deberá ser producto de ponderar todas las circunstancias concurrentes en el caso... la edad del demandante al tiempo de la intervención quirúrgica (52 años), la importante pérdida de calidad de vida que acompaña a los pacientes gastrectomizados y, sobre todo o muy en especial, el alto porcentaje (entre el 14 y el 20%) con que aparece la secuela del síndrome de dumping en las gastrectomías parciales, pues este

último dato o circunstancia es muy expresivo de la relevancia que una completa información tenía para el mejor ejercicio de aquel derecho de autodeterminación..." (FD. 6º).

8. Nacimiento indebido / *Wrongful Conception, Wrongful Birth, Wrongful Life*

En la cultura del *common law* se distinguirse entre *Wrongful Conception, Wrongful Birth y Wrongful Life*. En el primer grupo de supuestos, la reclamación se interpone por el hecho mismo del embarazo, normalmente cuando el hombre o la mujer se habían sometido a una intervención fallida de esterilización y el actor reclama al médico que la practicó. En el segundo, el médico no advirtió a la gestante sobre malformaciones congénitas del feto y se la privó de la posibilidad de decidir abortar. En el tercero, es el niño mismo, víctima de una invalidez, quien reclama contra sus padres o contra el médico por no haber impedido que llegara al mundo o, más sencillamente, porque la vida de una persona disminuida es mucho más difícil y costosa que la de otra que no lo es.

Las cuestiones relacionadas con los tres supuestos están en el centro de uno de los debates culturales, morales, económicos y sociales más enconados del último medio siglo y empiezan por la traducción misma de las expresiones en inglés: "wrongful", significa "injusto", "indebido", pero los autores de habla española hacen equilibrios para evitar hablar de "nacimiento indebido" o de "vida injusta" –se usan expresiones tales como "nacimiento indeseado", por ejemplo--. La incomodidad es explicable, pero el eufemismo, al fin frustrado, es acaso peor.

8.1. *Wrongful Conception*

El grupo de casos más sencillo de resolver es el primero, el de concepción indebida por evitable (*Wrongful Conception*), realmente querida evitar, pero finalmente acaecida. El fracaso de la medida anticonceptiva, más o menos drástica, adoptada (dispositivo intrauterino, vasectomía, ligadura de trompas) por sí sólo no da lugar a responsabilidad civil del médico o del centro sanitario siempre que el paciente haya sido previamente informado de las posibilidades de fracaso de la intervención (SSTS, 1ª; 447/2001, de 11 de mayo -vasectomía-, 3ª, 3.10.2000 -vasectomía-]. Los casos de responsabilidad civil suelen fundamentarse o bien en la práctica negligente de la intervención (STS, 1ª, 10.10.1995 -ligadura de trompas-; STS, 1ª, 531/1998, de 5 de junio -ligadura de trompas-), o bien en el carácter defectuoso del producto sanitario utilizado (STS, 1ª, 766/1999, de 24 de septiembre - dispositivo intrauterino defectuoso-).

- STS, 1ª, 531/1998, de 5 de junio:

"Doña Petra P. V., por sí y en representación de la comunidad conyugal formada con su esposo, demandó a los médicos especialistas del Servicio de Ginecología del Hospital Provincial de Zamora, a don Jesús F. R. y a don Carlos Ernesto G. G. solicitando fueran condenados al pago de una indemnización de quince millones de pesetas más intereses legales y costas. La «causa petendi» la hacía residir en una incorrecta operación de ligadura de trompas a que se sometió para evitar la concepción, pues quedó embarazada y dio a luz a dos niñas gemelas.

El Juzgado de 1.ª Instancia estimó la demanda en lo que respecta a don Jesús F. R., que fue condenado a indemnizar a la actora en la suma de [90151,9 euros] (...), absolviendo al resto de

los demandados. En grado de apelación, la Audiencia confirmó esa absolución, pero revocó la condena impuesta al señor F. R., al cual absolvió (...)

Contra la sentencia de la Audiencia la actora interpuso recurso de casación (...)

[L]a apreciación de las pruebas, detallada y minuciosa en la sentencia de primera instancia que es revocada por la Audiencia, es acertada; la recurrente quería la operación de ligadura de trompas, seguramente no se le ligó más que la derecha, porque se estimó que ello era suficiente por creer que no tenía ovario ni resto mínimo del mismo en el lado izquierdo como consecuencia de [una] operación anterior a la que ahora se considera, siendo así que en el informe pericial se dice que «se conserva la trompa y una parte del ovario» (...) El error de la Audiencia ha sido estimar como intocable lo que se dice en la historia clínica (...)

En consecuencia los motivos se estiman, dando lugar a la anulación y casación de la sentencia (...) La sentencia de primera instancia incluye entre los conceptos indemnizables el daño moral a la actora, producido, dice, por los embarazos no deseados. No puede esta Sala compartir tal punto de vista, porque la vida humana es un bien precioso en cualquier sociedad civilizada, cuyo ordenamiento jurídico la protege ante todo y sobre todo. No puede admitirse que el nacimiento de hijos no previstos sea un mal para los progenitores, ni siquiera cuando, como ocurre en el presente caso, los nacidos carecen de tara o enfermedad que pudiera servir de excusa para sostener lo contrario de lo anteriormente afirmado. Otra cosa es que el patrimonio de los progenitores tenga que afrontar mayores gastos o dejar de obtener ingresos por la suspensión o abandono del trabajo ante la contingencia inesperada del embarazo y parto, y en este sentido es admisible una compensación económica, que se fija aquí, por las circunstancias que denotan la poca prueba practicada, en [48.080,96 euros] (...)

8.2. *Wrongful Birth*

El segundo grupo de casos, el de **nacimiento indebido (*wrongful birth*)**, por hipotéticamente no querido, es más complejo. En la actualidad, la responsabilidad del médico en los casos de nacimientos de niños con malformaciones o anomalías congénitas no detectadas durante el embarazo (*wrongful birth*) suele fundamentarse en el diagnóstico incorrecto sobre la condición del feto, con la consiguiente privación a la mujer de la posibilidad de decidir sobre la continuación del embarazo cuando su interrupción, dado el caso, era legalmente posible. La indemnización suele comprender dos partidas: el daño moral asociado a tal privación y las consecuencias económicas asociadas a la anomalía, esto es, los sobrecostes derivados de tratar, mantener o educar especialmente a un niño diferente, por su invalidez física, su disminución psíquica o por ambas (SSTS, 1ª, 1002/2005, 21.12.2005, 669/2010, 4.11.2010; 4.11.2010, RJ 2010\7988STS, 3ª, 21.2.2006, RJ 2006\1046;). Algunos tribunales, sin embargo, rechazan la indemnización por el daño patrimonial (STS, 1ª, 31.5.2011, RJ 2011\4000). Una cuestión de fondo es que, en nuestro país, no todos los niños con las mismas dificultades son asistidos médica, social y económicamente, del mismo modo, sino que la responsabilidad civil, por hipótesis, solo indemniza los casos de nacimiento o de vida indebidos y litigados. Esto es paradójico: una gestante que es informada de que el hijo que ha concebido padece de una condición relevante según la legislación en materia de interrupción legal del embarazo no obtiene lo mismo que otra gestante que no es informada, pero que luego reclama y obtiene una indemnización por responsabilidad civil.

Así, la jurisprudencia manifiesta una incomodidad obvia, pues la sombra del nihilismo se proyecta sobre las decisiones judiciales: ningún tribunal tiene ningún género de problemas a la hora de indemnizar cualesquiera lesiones físicas o psíquicas permanentes causadas a una persona, entre otras cosas, porque el término de comparación es la condición de la víctima antes de sufrir la lesión de que se trate. Pero el drama ineludible del aborto es que el término de comparación es el vacío insondable de la inexistencia misma. Con todo, piénsese en lo que ocurre con la (mayor) indemnización de lesiones muy gravemente invalidantes comparada con las (normalmente menores) indemnizaciones por causa de muerte: la asistencia al paciente puede implicar costes mucho más elevados que el importe usualmente concedido por indemnización por causa de muerte.

- **STS, 1ª, 14.3.2013, RJ 2013\2422 (*MP: José Antonio Seijas Quintana*).**

En el caso, a la actora, embarazada desde diciembre de 1987, le fueron practicadas tres ecografías en la consulta médica privada de su ginecólogo (en las semanas treinta y uno, treinta y cinco y treinta y nueve del embarazo), aunque de ninguna de ellas quedó constancia en la historia clínica. El parto se produjo el 29.7.1988 y nació una niña sin manos ni antebrazos. La actora demandó al ginecólogo y a su aseguradora, General Española de Seguros, S.A, por responsabilidad civil en reclamación de una indemnización de 300.506 euros. Desestimada la demanda en las dos instancias, el Tribunal Supremo estimó el recurso de la actora, apreció una indebida denegación de la prueba en segunda instancia consistente en un requerimiento al demandado para que aportara el historial médico y las ecografías realizadas y ordenó reponer las actuaciones al momento en que se había denegado la prueba en segunda instancia. La AP Las Palmas (17.5.2010) dictó una segunda sentencia en cuya virtud condenó a los demandados al pago de 300.506,05 euros en concepto de daño moral y económico, resolución luego confirmada por el TS:

> "[H]ay indicios cualificados por anormales en el cumplimiento de los deberes médicos para emitir su diagnóstico (...). [R]esulta contrario a la lógica, con las circunstancias concurrentes, no visualizar en las tres últimas ecografías (sobre todo en las dos últimas muy próximas al final de la gestación) anomalías físicas como las del presente caso (...). El daño que fundamenta la responsabilidad existe. Estamos ante una indebida gestión médica del embarazo que impidió detectar a tiempo las malformaciones y que de haberlo hecho hubiera provocado soluciones distintas, al margen de un posible aborto, que no resulta sustancial. El daño, dice la STS 31 de mayo de 2011 (RJ 2011, 4000) , "es independiente de la decisión de abortar y resulta no sólo del hecho de haber privado negligentemente a la madre de la posibilidad de decidir acerca de su situación personal y familiar y de consentir, en definitiva, dar vida a un nuevo ser, que afectará profundamente a la suya en todos los sentidos, sino de los efectos que dicha privación conlleva derivados de los sufrimientos y padecimientos ocasionados por el nacimiento de una hija afectada por un mal irremediable -daño moral-, y de la necesidad de hacer frente a gastos o desembolsos extraordinarios o especiales -daños patrimoniales- teniendo en cuenta en cualquier caso que no estamos ante la concepción no deseada de un hijo, sino ante un embarazo voluntario en el que el niño no representa un daño más allá de lo que comporta ese plus que resulta de la incapacidad" (FF.DD. 5º y 6º).

8.3. *Wrongful Life*

El tercer grupo de casos incluye las acciones de los hijos que han nacido con malformaciones no detectadas durante el embarazo (*Wrongful Life*) contra sus padres por no haber impedido que llegara al mundo o contra el médico que erró en el diagnóstico por los daños morales y los gastos asociados a las malformaciones.

Las SSTS, 1ª, 4.11.2010, RJ 2010\7988; 837/2007, 6.7.2007 y 1197/2007, 23.11.2007 rechazan expresamente la demanda de la madre o los padres en nombre de sus hijos. En concreto, el TS establece en los dos últimos casos, sobre nacimientos de niños con síndrome de Down:

"[Cabe] mantener el criterio indemnizatorio de la primera instancia, si bien con exclusión del hijo menor, en cuyo nombre también actúan los recurrentes, por tratarse de una situación que afecta exclusivamente a los padres" (FD. 4º STS, 1ª, 837/2007, 6 de julio).

"1º El daño ocasionado por [la] falta de información afecta en exclusiva a los padres demandantes, a los que se ha ocasionado un daño moral al verse privados de la información necesaria para poder tomar de forma adecuada sus decisiones.

2º Debe descartarse que se haya producido un daño a la menor, ya que esta Sala ha venido considerando, desde la sentencia de 5 junio 1998 (RJ 1998, 4275), que no puede admitirse que este tipo de nacimientos sea un mal en sí mismo (así mismo STS de 19 junio 2007 [RJ 2007, 5572])" (FD. 4º STS, 1ª, 1197/2007, de 23 de noviembre).

La **STS, 3ª, 16.6.2010 (RJ 2010\5716)** resuelve otro caso en el que la actora dio a luz a un niño con Síndrome de Down después de haberse sometido a la prueba de la amniocentesis y de haber sido informada erróneamente que el resultado de la prueba era normal. El TS confirma la STSJ Comunidad Valenciana en la que se condenaba a la Generalitat Valenciana a pagar al menor una pensión vitalicia mensual de 1.500 euros, revalorizables de acuerdo con el IPC, en concepto del daño económico asociado a las necesidades de cuidado y atención. Además, la STSJ condenaba a la Generalidad Valenciana a pagar a cada uno de los padres 75.000 euros en concepto de daño moral.

Turpin v. Sortini, 31 Cal.3d 220, 643 P.2d 954, 182 Cal.Rptr. 337 (1982)

KAUS, J. This case presents the question of whether a child born with an hereditary affliction may maintain a tort action against a medical care provider who - before the child's conception - negligently failed to advise the child's parents of the possibility of the hereditary condition, depriving them of the opportunity to choose not to conceive the child. Although the overwhelming majority of decisions in other jurisdictions recognize the right of *the parents* to maintain an action under these circumstances, the out-of-state cases have uniformly denied *the child's* right to bring what has been commonly termed a "wrongful life" action. In *Curlender v. Bio-Science Laboratories* (1980) 106 Cal.App.3d 811 [165 Cal.Rptr. 477], however, the Court of Appeal concluded that under California common law tort principles, an afflicted child could maintain such an action and could "recover damages for the pain and suffering to be endured during the limited life span available to such a child and any special pecuniary loss resulting from the impaired condition" (*id.*, at p. 831), including the costs of medical care to the extent such costs were not recovered by the child's parents. In the case at bar, a different panel of the

Court of Appeal disagreed with the conclusion in *Curlender* and affirmed a trial court judgment dismissing the child's cause of action on demurrer. We granted a hearing to resolve the conflict.

[The Turpins, husband and wife, brought suit on behalf of themselves and their two children against their physician and a hospital for negligence for failing to inform them that their offspring would very likely be totally deaf. Subsequent to this alleged negligence, a daughter, Joy, was conceived and was born totally deaf. Four causes of action were alleged. The only one involved in this appeal was brought on behalf of Joy, who sought damages for being "deprived of the fundamental right of a child to be born as a whole, functional human being without total deafness," and for expenses for "specialized teaching, training and hearing equipment."] (Henderson, Pearson, Kysar, Siliciano, The Torts Process, 7th ed., Aspen Publishers, New York, 2007, p. 339) (...)

The basic fallacy of the *Curlender* analysis is that it ignores the essential nature of the defendants' alleged wrong and obscures a critical difference between wrongful life actions and the ordinary prenatal injury cases noted above (…). [T]he obvious tragic fact is that plaintiff never had a chance "to be born as a whole, functional human being without total deafness"; if defendants had performed their jobs properly, she would not have been born with hearing intact, but - according to the complaint - would not have been born at all (…)

Given this view of the relevant injury which the plaintiff has sustained at the defendant's hands, some courts have concluded that the plaintiff has suffered no legally cognizable injury on the ground that considerations of public policy dictate a conclusion that life - even with the most severe of impairments - is, as a matter of law, always preferable to nonlife. The decisions frequently suggest that a contrary conclusion would "disavow" the sanctity and value of less-than-perfect human life (…)

[W]e question whether these considerations alone provide a sound basis for rejecting the child's tort action. To begin with, it is hard to see how an award of damages to a severely handicapped or suffering child would "disavow" the value of life or in any way suggest that the child is not entitled to the full measure of legal and nonlegal rights and privileges accorded to all members of society.

Moreover, while our society and our legal system unquestionably place the highest value on all human life, we do not think that it is accurate to suggest that this state's public policy establishes - as a matter of law - that under all circumstances "impaired life" is "preferable" to "nonlife." (…)

In this case, in which the plaintiff's only affliction is deafness, it seems quite unlikely that a jury would ever conclude that life with such a condition is worse than not being born at all. (…)

[W]e believe that the out-of-state decisions are on sounder grounds in holding that - with respect to the child's claim for pain and suffering or other general damages - recovery should be denied because (1) it is simply impossible to determine in any rational or reasoned fashion whether the plaintiff has in fact suffered an injury in being born impaired rather than not being born, and (2) even if it were possible to overcome the first hurdle, it would be impossible to assess general damages in any fair, nonspeculative manner (…)

Although we have determined that the trial court properly rejected plaintiff's claim for general damages, we conclude that her claim for the "extraordinary expenses for specialized teaching, training and hearing equipment" that she will incur during her lifetime because of her deafness stands on a different footing (…)

Although the parents and child cannot, of course, both recover for the same medical expenses, we believe it would be illogical and anomalous to permit only parents, and not the child, to recover for the cost of the child's own medical care. If such a distinction were established, the afflicted child's receipt of necessary medical expenses might well depend on the wholly fortuitous circumstance of whether the parents are available to sue and recover such damages or whether the medical expenses are incurred at a time when the parents remain legally responsible for providing such care.

The judgment is reversed and the case is remanded to the trial court for further proceedings consistent with this opinion.

9. Daño exclusivamente económico / *Pure Economic Loss*

- Fernando GÓMEZ POMAR/Juan Antonio RUIZ GARCÍA (2002), "The Plural -and Misleading- notion of Economic Loss in Tort. A Law and Economics Perspectiva", *InDret* 4/2002, (www.indret.com)

- American Law Institute, *Restatement of the Law Third, Torts: Liability for Economic Harm* (Tentative Draft No. 1, April 4, 2012, Preliminary Draft No 2, September 3rd 2013):

Black Letter of Tentative Draft No. 1 (§§ 1-6)

§ 1. Liability for the Unintentional Infliction of Economic Loss: General Principles
(a) An actor has no general duty to avoid the unintentional infliction of economic loss on another
(b) Duties to avoid the unintentional infliction of economic loss are recognized in the circumstances set forth in §§ X-Y.

§ 2. Economic Loss Defined
For purposes of this Restatement, "economic loss" is pecuniary damage not arising from injury to the plaintiff's person or from physical harm to the plaintiff's property.

§ 3. Preclusion of Tort Liability Arising from Contract (Economic Loss Rule)
Except as provided elsewhere in this Restatement, there is no liability in tort for economic loss caused by negligence in the performance or negotiation of a contract between the parties.

§ 4. Professional Negligence Resulting in Economic Loss
A professional is subject to liability in tort for economic loss caused by the negligent performance of an undertaking to serve a client.

§ 5. Negligent Misrepresentation
(1) One who, in the course of his business, profession or employment, or in any transaction in which he has a pecuniary interest, supplies false information for the guidance of others, is

subject to liability for pecuniary loss caused to them by their reliance upon the information, if he fails to use reasonable care in obtaining or communicating it.
(2) [T]he liability stated in Subsection (1) is limited to loss suffered
(a) by the person or one of a limited group of persons for whose guidance the actor intends to supply the information (…); and
(b) through reliance upon the information in a transaction that the actor intends to influence (…)

§ 6. Negligent Performance of Services
(1) One who, in the course of his business, profession or employment, or in any transaction in which he has a pecuniary interest, performs a service for the benefit of others, is subject to liability for pecuniary loss caused to them by their reliance upon the service, if he fails to exercise reasonable care in performing it.
(2) The liability stated in Subsection (1) is limited to loss suffered
(a) by the person or one of a limited group of persons for whose benefit the actor performs the service; and
(b) through reliance upon it in a transaction that the actor intends to influence.

Black Letter of Preliminary Draft No. 2 (§§ 7-13)

§ 7. Economic loss from injury to a third person or to property not belonging to the claimant
Except as provided in § 8, a claimant cannot recover for pure economic loss caused by
(a) unintentional personal injury to another party; or
(b) unintentional injury to property in which the claimant has no proprietary interest.

§ 8. Public nuisance resulting in pure economic loss
An actor whose wrongful conduct harms or obstructs public property or a public resource is subject to liability for resulting pure economic loss if the claimant's losses are distinct from those suffered by the public at large.

§ 9. Fraud
An actor who knowingly makes a misrepresentation of material fact is subject to liability for economic loss caused by another's justifiable reliance on it.
(…)
§ 13. Damages
(a) Compensatory damages for the tort of fraud are calculated to restore the financial position that the plaintiff would occupy if the tort had not been committed.
(b) Punitive damages may be assessed as necessary to ensure deterrence and to further other policies not adequately secured by a compensatory award.

- STS, 3ª, 23.3.2009 (RJ 2009 2502):

En abril de 1996 se llevaron a cabo unas obras públicas de conexión de las líneas 8 y 10 del metro de Madrid, según el proyecto elaborado por la Administración y cuya ejecución había adjudicado a FCCSA y FCC. Las obras implicaron, durante un año y medio y las 24 horas del día, una excavación, a cielo abierto, en la puerta principal y a lo largo de toda la fachada del Hotel Miguel Ángel. Ello obligó al hotel a modificar los accesos, a bajar el precio del servicio y a cerrar

determinadas zonas, además de soportar el despliegue de maquinaria pesada y de operarios, polvo, ruidos y vibraciones inherentes a los trabajos.

El 10.4.1997, el hotel reclamó a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid 381 millones de pesetas (unos 2 millones de euros) por la minoración de ingresos y pérdida de clientela que la ejecución de las obras había supuesto para el desarrollo del negocio.

El 11.12.1997, la Comisión Permanente del Consejo de Estado emitió dictamen desestimando la reclamación sometida a su consulta. El 18.12.1997, la Consejería denegó la reclamación expresamente.

El Hotel interpuso recurso contencioso-administrativo. El TSJ Madrid (9.6.2004) desestimó el recurso porque consideró que el daño no era antijurídico: "Tal perjuicio salvo circunstancias concretas de agravación no excede en tales casos de las cargas generales ligadas al status jurídico de ciudadano sin resultar por ello antijurídico ... Esto acontece en la mayoría de los casos de construcción de obras públicas" (Antecedente de Hecho 1o de la STS 23.3.2009).

El TS estimó el recurso de casación interpuesto por el hotel y, en parte, el recurso contencioso-administrativo, al limitar la cuantía indemnizatoria solicitada:

"Los trabajos por su ubicación no incidieron con la misma intensidad en otros inmuebles, negocios o actividades del entorno ... Ni por la ubicación ni por las características de las obras ni por la naturaleza del negocio que explota dicha entidad estaba jurídicamente obligada a soportar el daño" (FD. 2o).

En relación a la cuantía indemnizatoria, el TS rechazó el cálculo propuesto por la recurrente y determinó que se calculara en ejecución de sentencia conforme a los siguientes criterios:

"Hotel Miguel Ángel» reclama 381.376.000 pesetas (2.292.115,92 euros) con fundamento en un informe elaborado por «ECU, Auditores y Consultores, S.A.» (...). En dicho informe se opera con dos magnitudes: el lucro cesante y el daño emergente. La primera responde a la minoración de los resultados como consecuencia de la caída de los ingresos por el efecto de las obras, mientras que la segunda consiste en la pérdida de clientela ocasionada por las mismas hasta su total recuperación, estimando la correspondiente disminución de ingresos y su impacto en los resultados (...)

Dicho estudio (...) resulta, sin embargo, inútil para el fin perseguido, que no consiste en determinar la incidencia que las obras litigiosas pueden haber tenido en la evolución de su negocio, sino en cuantificar los daños y perjuicios concretos y ciertos (...) que sean consecuencia directa e inmediata de la ejecución de los trabajos (...). Por consiguiente, debe quedar fuera del cálculo el llamado «daño emergente» (...)

Con la denominación de «lucro cesante», el dictamen incorpora la caída de los ingresos durante la ejecución de las obras, esto es, entre junio de 1996 y mayo de 1997 (en realidad comenzaron antes, en abril de 1996). Para ello, vuelve a operar con hipótesis y proyecciones (...) de escaso valor cuando se trata de escudriñar el ayer y constatar lo que ha pasado, cuantificando una lesión real y particular (...) [P]ara medir el daño (...) pueden manejarse valores reales de la propia empresa, tal cual son los declarados a efectos del impuesto sobre sociedades para los

ejercicios 1995, 1996, 1997 y 1998. Bastará que, en la fase de ejecución de sentencia, partiendo de aquellos datos, se calcule la evolución que deberían haber seguido los beneficios entre junio de 1996 y mayo de 1997 (...) de no haber mediado las obras, comparándolos con los realmente obtenidos y declarados en dicho período, limitándola a los que sean imputables a las actividades desarrolladas en el hotel (...). De este modo pueden calcularse las ganancias dejadas de obtener durante el tiempo en el que las obras tuvieron lugar" (FD. 4º).

10. Pérdida de oportunidad / *Loss of a chance*

- STS, 3ª, 27.9.2011 (JUR 2011\350537). MP: Antonio Martí García . Pérdida de oportunidad por el retraso en el diagnóstico médico.

El 4.11.2004, Melchor, nacido en 1946, acudió al Servicio de Urgencias del Hospital 12 de octubre (Madrid) y quedó ingresado en el Servicio de Medicina hasta el alta hospitalaria, el 24.12.2004. Durante ese tiempo, de las pruebas que se le practicaron, llamó la atención la presencia en el TAC de un nódulo parenquimatoso de contornos irregulares de 12 mm. de diámetro situado en el lóbulo inferior derecho (pulmón). El 19.4.2005, después de ser examinado en la consulta del Servicio de Neumología del mismo hospital, se apreció que la lesión pulmonar era de 18 mm. de diámetro. El 29.4.2005, se solicitó un nuevo TAC, y el 8.6.2005, se informó de la sospecha de neoplasia de pulmón, que se consideró irresecable. Se inició tratamiento de quimioterapia y, a partir del 23.9.2005, también se administró radioterapia al paciente. Melchor falleció el 27.9.2005.

El 22.9.2006, Inmaculada, la esposa del fallecido, interpone reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Servicio Madrileño de Salud solicitando una indemnización de 160.000 euros más intereses, que se desestima por silencio administrativo.

El TSJ Madrid (Sala C-A, Secc. 8ª, 31.7.2009) desestima el recurso contencioso-administrativo.

El TS estima parcialmente el recurso de casación porque "(…) atendiendo al tenor de los informes citados y anteriormente transcritos (…), [se concluye] que concurren los requisitos definidores de la responsabilidad patrimonial de la Administración (…), pues el retraso en el diagnóstico y la realización tardía de las pruebas que hubiesen permitido una anterior confirmación del diagnóstico de presunción, supone[n] una infracción de la <<lex artis>> que ha generado una pérdida de oportunidad, en cuanto los resultados hubieran podido ser otros". El TS añade en relación con la indemnización que "(…) ha de tenerse en cuenta que no se indemniza por el fallecimiento de Don Melchor (…) sino (…) por la pérdida de oportunidad sufrida pues, a la vista de los referidos informes cabe sostener que, en este caso, el retraso en la práctica del <<estudio neumológico del paciente hizo imposible su tratamiento con posibilidades de curación por la extensión tumoral>>, una vez acreditada <<la presencia de un nódulo pulmonar solitario de bordes irregulares y ya de un tamaño de 12 mm>>, unido a las especiales circunstancias del paciente, [y a] sus antecedentes personales de haber sido trabajador de asbesto y disolventes orgánicos, además de los antecedentes familiares de neoplasia pulmonar del padre y un hermano". Finalmente, el TS condena a la Administración Pública a abonar a Inmaculada la cantidad de 30.000 euros en concepto de indemnización (FD 7º).

- STS, 3ª, 26 de junio de 2008

[Pablo Salvador, Fernando Gómez, Sonia Ramos (Eds.), Apéndice 2009 al Tratado de Responsabilidad civil del fabricante, Thomson Civitas, Cizur Menor, 2010, pp. 21-23].

En el caso aquí resuelto, la cuestión planteada era si la falta de administración de un fármaco que contrarrestaba los efectos adversos de otro distinto, pero que sólo ocurren en un 0,001% de los casos, era o no contraria a la *lex artis* de la medicina.

El Tribunal respondió afirmativamente a la cuestión, en el marco de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, es decir, en el de una regla de responsabilidad objetiva. No sin cierta dificultad, con todo, como habremos de ver.

En abril de 1999, los servicios públicos de atención médica primaria diagnosticaron al reclamante y recurrente en casación un cuadro sospechoso de tuberculosis. El paciente fue entonces tratado con Rifinah 300 (Rifampicina e Isionacida) y Piracinamida, a la espera de resultados analíticos. En agosto se le retiró la Isoniacida-Rifampicina tras diagnosticársele un cuadro de disminución de agudeza visual por probable toxicidad por antituberculosis, iniciándose tratamiento con complejo vitamínico B.

En octubre y diciembre de 1999, los servicios de neurología y de oftalmología de dos hospitales públicos confirmaron un diagnóstico de neuritis óptica bilateral con disminución de agudeza visual, como consecuencia de una reacción tóxica a la medicación antituberculosa, probabilidad de origen iatrogénico que se estableció tras descartar otras causas.

La neuritis óptica, es un efecto adverso muy infrecuente del tratamiento con Rifinah 300, producido por la isoniacida: "[S]e produce en aproximadamente uno de cada diez mil tratamientos", es decir, en un 0,001 % de los casos, pero "[l]a administración de piridoxina o vitamina B6, concomitantemente al tratamiento con isoniacida, intenta prevenir la deficiencia de dicho compuesto en el organismo, disminuyendo así considerablemente la probabilidad de padecer neuritis" (F. D. 4º de la Sentencia reseñada, que cita el F. D. 10 de la Sentencia recurrida, SAN, Sección 4ª, 3.3.2004).

El paciente reclamó una indemnización, por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, por importe de 156.000 € (26 millones de pesetas) que había sido rechazada, primero en vía administrativa y, después, en vía jurisdiccional por la SAN, Sección 4ª, 3.3.2004 (PROV 2004/133590). La sentencia fue recurrida en casación, entre otros, por dos motivos relacionados con la concurrencia en el caso de los requisitos de la responsabilidad patrimonial –objetiva- de las Administraciones Públicas por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, de los artículos 106 CE y 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común[3] (Ley 30/1992).

La Sentencia del Tribunal Supremo afirmó:

---

[3]BOE núm. 285, 27.11.1992.

"[E]s doctrina jurisprudencial consolidada la que entiende que la misma [la responsabilidad patrimonial es objetiva o de resultado., de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la Administración, sino la antijuricidad del resultado o lesión aunque (…) es imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido." (F. D. 3º)

No obstante, en el párrafo siguiente de mismo Fundamento de Derecho se puede leer:

"[E]s también doctrina jurisprudencial reiterada [siguen citas a las SSTS 20.3.2007; 7.3.2007; 16.3.2005] que a la Administración no es exigible nada más que la aplicación de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la práctica médica, sin que pueda sostenerse una responsabilidad basada en la simple producción del daño, puesto que (…) lo que sanciona en materia de responsabilidad sanitaria es una indebida aplicación de medios para la obtención del resultado." (F. D. 3º)

El Tribunal concede una indemnización de 30.000 euros, algo menos de la quinta parte de la solicitada, "por la pérdida de oportunidad" (FD 6). En términos del derecho tradicional de la responsabilidad civil, la pérdida de una probabilidad apreciable de evitar un daño grave, cuya posibilidad de ocurrencia es, a su vez, del 0,001%, constituye una infracción del deber de cuidado médico y es, por tanto, una negligencia relevante. La conclusión a la que llega la Sala Tercera es correcta. Su razonamiento, de todos modos, es extraño a la lógica de la responsabilidad objetiva. La Administración pública demandada debería responder, en todo caso, por los daños causalmente vinculados con el funcionamiento normal o anormal del servicio, con independencia de la diligencia empleada por el personal a su cargo.

11. Lesiones personales y mitigación / *Compensatory damages: personal injury and mitigation*

11.1. *Williams v. Bright* (632 N.Y.S.2d 760 N.Y.Sup.,1995)

WALLACH, JUSTICE. Plaintiff Robbins was a passenger in an automobile driven by her 70-year-old father on an upstate highway. An eyewitness saw the car veer off the road at about 65 mph and turn over in a culvert on adjoining farmland. There was circumstantial evidence that the driver, who had driven with this plaintiff and other family members early that morning from New York City to Plattsburgh and was returning the same day, had fallen asleep at the wheel. This was conduct that the jury found to be both negligent and a proximate cause of the accident. On this appeal, defendants, who include the lessors of the vehicle, do not seriously contest liability; the main issue is the trial court's treatment of plaintiff Robbins' alleged failure to mitigate damages due to her religious beliefs as a Jehovah's Witness.

The central question for us, on appellate review, is […] the broader controversy involving plaintiff's beliefs and their proper effect upon her monetary award. That, in turn, obliges us to grapple with grave constitutional issues ordinarily not involved in a motor vehicle accident-even one as tragic and catastrophic as this one.

I.

For a hundred years it has been settled law in this state that a party who claims to have suffered damage by the tort of another is bound “to use reasonable and properefforts to make the damage as small as practicable” […] and if an injured party allows the damages to be unnecessarily enhanced, the incurred loss justly falls upon him […].

Plaintiff Robbins suffered a severely damaged left hip, as well as a painful injury to her right knee. Her own expert testified that if these injuries were not alleviated by well recognized and universally accepted surgical procedures, her prognosis was for a wheelchair-bound life because of the inevitability of necrotic development in the bone structure of these limbs. Moreover, all the experts agreed that the surgical intervention available to this plaintiff (52 years of age at the time of the accident) offered her the prospect of a good recovery and a near normal life. However, Robbins, a devout Jehovah's Witness, presented proof (chiefly from her own hospital records) that she was obliged to refuse these recommended surgeries because her church prohibits the blood transfusions they would necessarily entail.

In accordance with settled law, the New York pattern jury instruction on the subject of damage mitigation refers to the actions of “a reasonably prudent person” and measures the duty to mitigate in accordance with that standard.Although the trial court acquainted the jury with the existence of that standard, it charged that in this case the standard to be applied was something very different[…].

In abandoning the “reasonably prudent person” test in favor of a “reasonable Jehovah's Witness” standard, over defendants' objection, the trial court perceived the issue as involving this plaintiff's fundamental right to the free exercise of her religion, protected by the First Amendment to the United States Constitution […].

In our view, the analysis of the trial court contained many flaws. The first error was in defining the fundamental issue as whether any jury verdict could be permitted to conflict with this plaintiff's “religious belief that it may be better to suffer present pain than to be barred from entering the Kingdom of Heaven” […].

No one suggests that the State, or, for that matter, anyone else, has the right to interfere with that religious belief. But the real issue here is whether the consequences of that belief must be fully paid for here on earth by someone other than the injured believer […].

American courts have no business endorsing or condemning the truth or falsity of anyone's religious beliefs. […] An extraordinary example of the perils of such an excursion is the recent Minnesota case of Lundman v. McKown, 530 N.W.2d 807, 828, where damages were awarded against a Christian Scientist stepfather who blocked conventional treatment that, to a medical certainty, would have saved a young child's life. Here was a healthy 11-year-old boy who succumbed to a sudden onset of juvenile diabetes, a disease that is easily diagnosible and treatable by conventional medical practice. Instead, his mother and stepfather enlisted the services of Christian Science practitioners who provided only “spiritual treatment.” The child's condition deteriorated rapidly, and he died three days later. There was evidence that a shot of insulin administered as late as two hours before death could have saved him. A wrongful death action was commenced by the child's natural father and his older sister against the mother and stepfather, the various spiritual practitioners and the Christian Science Church itself. A jury awarded compensatory damages against all defendants in the amount of $5.2 million (reduced on post-trial motion to $1.5 million), and $9 million in punitive damages against the church.The

Minnesota Court of Appeals overturned the verdict against the church and its officials, but upheld the portion of the award against the mother, stepfather and local practitioners [...].

II.

[...]It seems apparent to us that a person in plaintiff Robbins' position must be permitted to present to the jury the basis for her refusal of medical treatment; otherwise, the jury would simply be left with the fact of her refusal, without any explanation at all. Once such evidence is (as it should be) received, the court is called upon to instruct the jurors as to how such evidence should affect their deliberations. Addressing this issue, we hold that the pattern jury instruction must be supplemented here with the following direction: "In considering whether the plaintiff acted as a reasonably prudent person, you may consider the plaintiff's testimony that she is a believer in the Jehovah's Witness faith, and that as an adherent of that faith, she cannot accept any medical treatment which requires a blood transfusion. I charge you that such belief is a factor for you to consider, together with all the other evidenceyou have heard, in determining whether the plaintiff acted reasonably in caring for her injuries, keeping in mind, however, that the overriding test is whether the plaintiff acted as a reasonably prudent person, under all the circumstances confronting her".

11.2. STC 154/2002, de 18 de julio

(...)

II. Fundamentos de derecho

1. La presente demanda de amparo [interpuesta por Pedro Alegre Tomás y doña Lina Vallés Rausa], se dirige contra las dos Sentencias, ambas de fecha 27 de junio de 1997, dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (...) La primera de ellas estima el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca, de fecha 20 de noviembre de 1996, que había absuelto a los ahora demandantes de amparo del delito de homicidio por omisión que aquél les imputaba. La segunda de dichas Sentencias, como consecuencia de la expresada estimación del recurso, los condena, "como autores responsables de un delito de homicidio, con la concurrencia, con el carácter de muy cualificada, de la atenuante de obcecación o estado pasional, a la pena de dos años y seis meses de prisión".

Los datos esenciales a que se refieren los términos transcritos del fallo son los siguientes: a) en primer lugar, la persona por cuya muerte se condena a los demandantes de amparo era un hijo de éstos, de 13 años de edad; b) en segundo lugar, la condena lo es por omisión de la conducta exigible a los padres del menor, dada su condición de garantes de la salud de éste (condición que actualmente se recoge expresamente en el art. 11, en relación con el art. 138, ambos del Código penal de 1995); c) en tercer lugar, la conducta omitida consistía bien en una acción de los ahora recurrentes en amparo dirigida a disuadir a su hijo de su negativa a dejarse transfundir sangre, bien en la autorización de aquéllos a que se procediese a la transfusión de sangre al menor; y d) en cuarto lugar, la causa de la actuación de los padres (propiamente, la razón de que éstos hubiesen omitido la conducta que se dice debida) se sustentaba en sus creencias religiosas pues, dada su condición de Testigos de Jehová, entienden, invocando al efecto diversos pasajes de los Libros Sagrados, que la transfusión de sangre está prohibida por la ley de Dios.

2. En la demanda de amparo se invoca la lesión de los derechos fundamentales a la libertad religiosa (art. 16.1 CE) y a la integridad física y moral y a no sufrir tortura ni trato inhumano o degradante (art. 15 CE).

La titularidad de tales derechos fundamentales se atribuye explícitamente en la demanda de amparo tanto al menor fallecido como a sus padres (…)

Ahora bien, dado que el recurso de amparo se dirige contra el pronunciamiento condenatorio de los padres del menor, ha de entenderse que la vulneración constitucional denunciada en la demanda de amparo es la del derecho fundamental a la libertad religiosa de los padres recurrentes.

3. La determinación del objeto y alcance de la demanda de amparo exige que previamente precisemos cuáles son los concretos hechos sobre los que se sustentan las cuestiones jurídico-constitucionales que aquélla suscita y cuál la respuesta de las Sentencias recurridas a tales hechos (…)

a) El menor Marcos, de trece años de edad, hijo de los recurrentes en amparo, tuvo unas lesiones por caída de bicicleta, a consecuencia de las cuales fue llevado por sus padres al Hospital Arnáu de Vilanova, de Lérida, el día 8 de septiembre (jueves) de 1994 hacia las nueve o diez de la noche. Examinado el menor por los médicos, éstos les informaron de que se hallaba en situación de alto riesgo hemorrágico por lo que era necesaria una transfusión de sangre. Los padres se opusieron a la transfusión por motivos religiosos y, habiéndoles hecho saber los médicos que no había tratamientos alternativos, solicitaron el alta de su hijo para llevarlo a otro centro sanitario. El centro hospitalario, en lugar de acceder al alta, por entender que peligraba la vida del menor si no era transfundido, solicitó del Juzgado de guardia (siendo las 4:30 horas del día 9) autorización para la práctica de la transfusión, que fue concedida a continuación para el caso de que fuera imprescindible para la vida del menor.

b) Los padres acataron dicha autorización judicial. Al disponerse los médicos a efectuar la transfusión, el menor, sin intervención alguna de sus padres, la rechazó "con auténtico terror, reaccionando agitada y violentamente en un estado de gran excitación, que los médicos estimaron muy contraproducente, pues podía precipitar una hemorragia cerebral". Por ello los médicos, después de haber procurado repetidas veces, sin éxito, convencer al menor para que consintiera la transfusión, desistieron de realizarla.

c) El personal sanitario pidió entonces a los padres que trataran de convencer al menor, a lo cual no accedieron por dichos motivos religiosos, pese a desear la curación de su hijo. Los médicos desecharon la posibilidad de realizar la transfusión contra la voluntad del menor, por estimarla contraproducente […]. Por ello, "después de 'consultarlo' telefónicamente con el Juzgado de guardia", en la mañana del día nueve, viernes, accedieron a la concesión del alta voluntaria.

d) […] El menor salió del hospital por la tarde de dicho día nueve (viernes), continuando aquéllos con las gestiones para localizar al nuevo especialista, concertando finalmente con él una cita para el lunes, día 12 de septiembre, en el Hospital Universitario Materno-infantil del Vall D´Hebrón, de Barcelona.

e) A las 10 horas de dicho día 12 ingresó el menor en este Hospital. Tras reconocerle en consulta, consideraron los médicos que era urgente una transfusión de sangre […]. El menor y sus padres manifestaron que sus convicciones religiosas les impedían aceptar la transfusión, firmando estos últimos un escrito en dicho sentido. […] Así las cosas, los padres del menor se trasladaron con él al Hospital General de Cataluña, centro privado cuyos servicios habían de ser directamente sufragados por los particulares.

f) Los servicios médicos del Hospital General, al igual que en los centros anteriores, consideraron necesaria la transfusión por no haber tratamiento alternativo. La transfusión fue nuevamente rechazada por motivos religiosos por el menor y sus padres. […] Por todo ello los padres, no conociendo ya otro centro al que acudir, regresaron con el menor a su domicilio, al que llegaron sobre la una de la madrugada del martes, 13 de septiembre.

g) Los padres y el menor permanecieron en su domicilio todo el día 13, sin más asistencia que las visitas del médico titular de la localidad, Ballobar (Huesca), […]. El miércoles, 14 de septiembre, el Juzgado de Instrucción de Fraga (Huesca), tras recibir un escrito del Ayuntamiento de Ballobar, acompañado de informe del médico titular, autorizó la entrada en el domicilio del menor a fines de asistencia médica […].

h) Seguidamente se personó la comisión judicial en el domicilio del menor, el cual estaba ya en grave deterioro psico-físico, acatando los padres la decisión del Juzgado —después de manifestar sus convicciones religiosas—, siendo su padre quien lo bajó a la ambulancia, en la que fue trasladado al Hospital de Barbastro. El menor llegó en estado de coma profundo a este Hospital, en el cual se le realizó la transfusión de sangre, contra la voluntad y sin la oposición de los padres. A continuación fue llevado al Hospital Miguel Servet, de Zaragoza […]. El menor falleció en este hospital a las 21:30 horas del día 15 de septiembre.

Consta igualmente en el relato de hechos probados que "si el menor hubiera recibido a tiempo las transfusiones que precisaba habría tenido a corto y a medio plazo una alta posibilidad de supervivencia y, a largo plazo, tal cosa dependía ya de la concreta enfermedad que el mismo padecía, que no pudo ser diagnosticada".

5. (…) La ratio del pronunciamiento condenatorio es el imputado incumplimiento por los padres del menor fallecido —los recurrentes en amparo— de las obligaciones dimanantes de su atribuida condición de garantes como titulares de la patria potestad, concretada en este caso en relación con el derecho del menor a la vida, condición que resulta directamente de lo dispuesto en el art. 39.3 CE (…) [E]l objeto del recurso —objeto que delimita el ámbito de nuestro examen— se centra en la relación que puede existir (y que, en todo caso, ha de precisarse) entre la condición de garante (en los términos expuestos) y el derecho fundamental a la libertad religiosa y, en su caso, la afectación de tal relación por el principio de legalidad (…)

6. […] La dimensión externa de la libertad religiosa se traduce además "en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso" (STC 46/2001) […].
7. La aparición de conflictos jurídicos por razón de las creencias religiosas no puede extrañar en una sociedad que proclama la libertad de creencias y de culto de los individuos y comunidades así como la laicidad y neutralidad del Estado. La respuesta constitucional a la situación crítica resultante de la pretendida dispensa o exención del cumplimiento de deberes jurídicos, en el intento de adecuar y conformar la propia conducta a la guía ética o plan de vida que resulte de

sus creencias religiosas, sólo puede resultar de un juicio ponderado que atienda a las peculiaridades de cada caso.

9. (…) Todo ello ha de ser considerado en relación con tres concretos extremos: en primer lugar, si el menor puede ser titular del derecho a la libertad religiosa; en segundo lugar, significado constitucional de la oposición del menor al tratamiento médico prescrito; en tercer lugar, relevancia que, en su caso, pudiera tener dicha oposición del menor (…).

En el caso traído a nuestra consideración el menor expresó con claridad, en ejercicio de su derecho a la libertad religiosa y de creencias, una voluntad, coincidente con la de sus padres, de exclusión de determinado tratamiento médico. Es éste un dato a tener en cuenta, que en modo alguno puede estimarse irrelevante y que además cobra especial importancia dada la inexistencia de tratamientos alternativos al que se había prescrito.

10. (…) Es cierto que el Ordenamiento jurídico concede relevancia a determinados actos o situaciones jurídicas del menor de edad.

[…P]ara el examen del supuesto que se plantea, es obligado tener en cuenta diversos extremos. En primer lugar, el hecho de que el menor ejercitó determinados derechos fundamentales de los que era titular: el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la integridad física. En segundo lugar, la consideración de que, en todo caso, es prevalente el interés del menor, tutelado por los padres y, en su caso, por los órganos judiciales. En tercer lugar, el valor de la vida, en cuanto bien afectado por la decisión del menor […]. En cuarto lugar, los efectos previsibles de la decisión del menor: tal decisión reviste los caracteres de definitiva e irreparable, en cuanto conduce, con toda probabilidad, a la pérdida de la vida.

[N]o hay datos suficientes de los que pueda concluirse con certeza —y así lo entienden las Sentencias ahora impugnadas— que el menor fallecido, hijo de los recurrentes en amparo, de trece años de edad, tuviera la madurez de juicio necesaria para asumir una decisión vital, como la que nos ocupa. Así pues, la decisión del menor no vinculaba a los padres respecto de la decisión que ellos, a los efectos ahora considerados, habían de adoptar

11. Sentados los anteriores extremos, debemos establecer si la condición de garantes, atribuida por las Sentencias impugnadas a los recurrentes en amparo, resulta (…) por el derecho de éstos a la libertad religiosa (…)

[H]emos de examinar si la realización de las concretas acciones que se han exigido de los padres en el caso concreto que nos ocupa —especialmente restrictivas de su libertad religiosa y de conciencia— es necesaria para la satisfacción del bien al que se ha reconocido un valor preponderante (…)

[L]a decisión de arrostrar la propia muerte no es un derecho fundamental sino únicamente una manifestación del principio general de libertad que informa nuestro texto constitucional, de modo que no puede convenirse en que el menor goce sin matices de tamaña facultad de autodisposición sobre su propio ser.

14. Sentados los anteriores extremos, procederemos al examen de qué concretas acciones se exigían a los padres, en el caso sometido a nuestra consideración, en relación con la prestación del tratamiento médico autorizado por la resolución judicial.

En primer lugar, se les exigía una acción suasoria sobre el hijo a fin de que éste consintiera en la transfusión de sangre. Ello supone la exigencia de una concreta y específica actuación de los padres que es radicalmente contraria a sus convicciones religiosas. Más aún, de una actuación que es contradictoria, desde la perspectiva de su destinatario, con las enseñanzas que le fueron transmitidas a lo largo de sus trece años de vida. Y ello, además, sobre la base de una mera hipótesis acerca de la eficacia y posibilidades de éxito de tal intento de convencimiento contra la educación transmitida durante dichos años.

En segundo lugar, se les exigía la autorización de la transfusión, a la que se había opuesto el menor en su momento. Ello supone, al igual que en el caso anterior, la exigencia de una concreta y específica actuación radicalmente contraria a sus convicciones religiosas, además de ser también contraria a la voluntad —claramente manifestada— del menor (…)

En tercer lugar, es oportuno señalar que los padres, ahora recurrentes, llevaron al hijo a los hospitales, lo sometieron a los cuidados médicos, no se opusieron nunca a la actuación de los poderes públicos para salvaguardar su vida e incluso acataron, desde el primer momento, la decisión judicial que autorizaba la transfusión, bien que ésta se llevara a cabo tardíamente (concretamente, cuando se concedió una segunda autorización judicial, varios días después de la primera). Los riesgos para la vida del menor se acrecentaron, ciertamente, en la medida en que pasaban los días sin llegar a procederse a la transfusión, al no conocerse soluciones alternativas a ésta, si bien consta, en todo caso, que los padres siguieron procurando las atenciones médicas al menor.

15. Partiendo de las consideraciones expuestas cabe concluir que la exigencia a los padres de una actuación suasoria o de una actuación permisiva de la transfusión lo es, en realidad, de una actuación que afecta negativamente al propio núcleo o centro de sus convicciones religiosas. Y cabe concluir también que, al propio tiempo, su coherencia con tales convicciones no fue obstáculo para que pusieran al menor en disposición efectiva de que sobre él fuera ejercida la acción tutelar del poder público para su salvaguarda, acción tutelar a cuyo ejercicio en ningún momento se opusieron (…)

En tal sentido, y en el presente caso, la condición de garante de los padres no se extendía al cumplimiento de tales exigencias (…).

Así pues, debemos concluir que la actuación de los ahora recurrentes se halla amparada por el derecho fundamental a la libertad religiosa (art. 16.1 CE). Por ello ha de entenderse vulnerado tal derecho por las Sentencias recurridas en amparo.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional (…) ha decidido [o]torgar el amparo solicitado y, en consecuencia:
1º Reconocer que a los recurrentes en amparo se les ha vulnerado su derecho fundamental a la libertad religiosa (art. 16.1 CE).

2º Restablecer en su derecho a los recurrentes en amparo y, a tal fin, anular las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ambas —primera y segunda— de fecha 27 de junio de 1997 (…)

12. Compatibilidad de fuentes indemnizatorias / *Collateral Source Rule*

— Pablo SALVADOR CODERCH et. al. (2006), "El derecho español de daños en 2005: Características diferenciales", *Global Jurist*, *Bepress*, Vol. 6 (http://www.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1187&context=gj), págs. 17-22.

— Fernando Gómez Pomar, Responsabilidad extracontractual y otras fuentes de reparación de daños:"Collateral Source Rule" y afines, InDret 1/2000, www.indret.com

— Art. 5 Ley 35/1995, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (de 11 de diciembre):

Art. 5. Incompatibilidades.

«1. La percepción de las ayudas reguladas en la presente Ley no será compatible con la percepción de las indemnizaciones por daños y perjuicios causados por el delito, que se establezcan mediante sentencia.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, procederá el eventual abono de toda o parte de la ayuda regulada en la presente Ley y normas de desarrollo cuando el culpable del delito haya sido declarado en situación de insolvencia parcial, sin que en ningún caso pueda percibirse por ambos conceptos importe mayor del fijado en la resolución judicial.

2. Asimismo, las ayudas contempladas en esta Ley serán incompatibles con las indemnizaciones o ayudas económicas a que el beneficiario de las mismas tuviera derecho a través de un sistema de seguro privado, así como, en el supuesto de incapacidad temporal de la víctima, con el subsidio que pudiera corresponder por tal incapacidad en un régimen público de Seguridad Social.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, procedería el eventual abono de la ayuda regulada en la presente Ley y normas de desarrollo, al beneficiario de un seguro privado cuando el importe de la indemnización a percibir en virtud del mismo fuera inferior a la fijada en la sentencia sin que la diferencia a pagar pueda superar el baremo fijado.

3. En los supuestos de lesiones o daños determinantes de la incapacidad permanente o muerte de la víctima, la percepción de las ayudas será compatible con la de cualquier pensión pública que el beneficiario tuviera derecho a percibir.

4. Las ayudas por incapacidad permanente serán compatibles con las de incapacidad temporal».

— Art. 9.1 Ley 32/1999, de solidaridad con las víctimas del terrorismo (de 8 de octubre):

«Si la responsabilidad civil hubiera sido fijada mediante sentencia firme, la víctima o sus derechohabientes sólo percibirán las indemnizaciones previstas en esta Ley en la medida en que dicha responsabilidad no se hubiera hecho efectiva».

— Art. 8 Ley 32/1999, de solidaridad con las víctimas del terrorismo (de 8 de octubre):

«Artículo 8. Transmisión de la acción civil al Estado.

1. El Estado se subrogará en los derechos que asisten a los beneficiarios contra los obligados inicialmente al resarcimiento como autores de los delitos, de acuerdo con lo previsto en el presente artículo.

2. Con carácter previo a la percepción de las indemnizaciones establecidas en esta Ley, los beneficiarios deberán transmitir al Estado las acciones civiles de las que fuesen titulares.

3. Si no hubiere recaído sentencia firme, la víctima o, en su caso, los derechohabientes transmitirán al Estado su expectativa de derecho fundada en la futura fijación judicial de responsabilidad civil».

Prestaciones de la Seguridad Social e indemnización de daños y perjuicios.

- STS, 4ª, 14.7.2009 (RJ 2009\6096): Las prestaciones de la Seguridad Social sólo restan la partida de lucro cesante de la indemnización por responsabilidad civil.

El 11.2.2003 a Eulogio, de 31 años de edad y operador de máquinas perfiladoras de chapas, se le quedó atrapado el brazo en los rodillos de la máquina que estaba utilizando y se le produjo un desgarro muscular, con resultado, después de varias intervenciones quirúrgicas, de "déficit de la extensión del codo y muñeca derechos y mano en garra cubital".

La Dirección Provincial del INSS impuso a la empresa un recargo del 30% en las prestaciones derivadas del accidente y declaró al trabajador en situación de incapacidad permanente total (IPT). El capital coste de la IPT ascendió a 103.348,58 €. Eulogio cobró, además, de Catalana de Occidente 12.020,24 € en concepto de incapacidad permanente total y de la Seguridad Social 16.015,40 € en concepto de incapacidad temporal (IT).

Eulogio reclamó 250.000 € en concepto de responsabilidad civil a la empresa para la que trabajaba, Fabricados Metálicos, S.A., a la empresa que sucedió a esta última, y a Groupama Plus Ultra, aseguradora de la responsabilidad civil de aquéllas.

El Juzgado de lo Social no 1 de Avilés (3.9.2007) estimó en parte la demanda y, aplicando orientativamente el sistema de baremos, condenó a los demandados a pagar 12.311,78 €, cantidad que resulta de descontar de la indemnización global según baremos (actualizados a 2006) – 143.696 euros- el capital coste de IPT y lo percibido del seguro. El TSJ Asturias (20.6.2008) desestimó el recurso de suplicación y confirmó la Sentencia del Juzgado.

El TS estimó el recurso para la unificación de doctrina del actor, revocó la SAP y condenó al pago de 91.800 euros. El TS no incluyó en la indemnización calculada según baremos el factor de corrección por perjuicios económicos (5.000 euros), la parte de la indemnización por lesiones permanentes que el Tribunal consideró que respondían a la discapacidad laboral (unos 34.000 euros) y lo cobrado del seguro por IT.

Por un lado, el Tribunal confirmó que era de aplicación al caso la regla de la deducción de las

prestaciones de la Seguridad Social:

"[A] efectos de fijar la indemnización ... deb[e]n descontarse del importe del daño total las prestaciones de la Seguridad Social, en la medida en que éstas cubren la responsabilidad objetiva del empresario por el mismo hecho y han sido financiadas por éste dentro de un sistema de cobertura pública en el marco de la Seguridad Social; descuento del que, sin embargo, se excluye el recargo en la medida en que el mismo cumple, según la doctrina de la Sala, una función preventiva autónoma" (FD. 4o).

Por otro lado, el Tribunal, siguiendo la doctrina establecida en la STS, 4a, 17.7.2007 (RJ 8303), declaró la necesidad de que la deducción o compensación se realice entre conceptos homogéneos:

"[T]ratándose de prestaciones de la Seguridad Social, que resarcen por la pérdida de ingresos que genera la disminución de la capacidad de ganancia, temporal o permanente, estas prestaciones sólo puedan compensarse con las indemnizaciones reconocidas por el llamado lucro cesante: igualmente las que se reconocen por la incapacidad temporal no pueden compensarse con las que se otorgan por la incapacidad permanente y viceversa" (FD. 4o).

En particular, como el cálculo de la indemnización se había realizado conforme a baremos, el Tribunal aplicó la doctrina anterior al caso de la siguiente manera:

"[S]ólo se descontarán la indemnización reconocida por lucro cesante (Tabla IV, factor de corrección por perjuicios económicos) y, parcialmente el factor de corrección de lesiones permanentes que constituyen una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima, pues este último factor compensa no sólo la pérdida de capacidad laboral en sentido estricto, sino también la pérdida de otras actividades, satisfacciones y oportunidades del disfrute de la vida ... [Q]uedará al prudente arbitrio del juzgador de la instancia ... determinar qué parte de la cantidad reconocida ... incapacidad permanente se imputa a la incapacidad laboral y qué parte se imputa al impedimento para otras actividades y ocupaciones de la víctima, a la imposibilidad o dificultad para realizar los actos más esenciales de la vida (comer, vestirse, asearse, etc.) y a la imposibilidad para los disfrutes y satisfacciones de la vida que cabía esperar en los más variados aspectos (sentimental, social, práctica de deportes, asistencia a actos culturales, realización de actividades manuales, etc.)" (FD. 4o).

- STS, 1ª, 688/2008, de 24.7.2008

El 9.2.1998, Jesús trabajaba en la colocación de planchas metálicas en la cubierta de un pabellón industrial sobre una viga de un metro de anchura y ocho metros de altura, sin medidas de seguridad, salvo un cinturón que no podía enganchar por falta de elementos de anclaje. Jesús cayó al suelo tras perder el equilibrio y, como consecuencia del accidente, sufrió lesiones y secuelas muy graves que motivaron la declaración de la incapacidad permanente absoluta para la realización de cualquier ocupación.
La víctima recibió prestaciones económicas de "Mutua Fremap" y del "Seguro de Negociación Colectiva".

Jesús y Marco Antonio, Mónica y Valentina, familiares de la víctima, demandan a Carlos Francisco, director de la obra, a "Ingyser S.C.", proyectista de la obra, a "Montajes Industriales Mirmo, S.L.", a "Alucoil, S.A." y a Pedro Francisco, y solicitan una indemnización de 910.870,30 €.

El JPI no 5 de Álava (27.12.2000) estima en parte la demanda y condena a Carlos Francisco, "Ingyser Sociedad Civil", "Montajes Industriales Mirmo, S.L.", "Alucoil, S.A." y Pedro Francisco a pagar 582.398,44 € a Jesús y 48.080,97 € a los restantes actores. La AP de Álava (Sección 2a, 30.3.2001) estima el recurso de apelación interpuesto por Pedro Francisco, a quien absuelve, manteniendo el resto de pronunciamientos.

El TS estima el recurso de casación interpuesto por Carlos Francisco y acuerda descontar de las indemnizaciones las cantidades percibidas por Jesús de la "Mutua Fremap" y del "Seguro de Negociación Colectiva":

"1ª. Pueden existir acciones diferentes para alcanzar la total compensación del daño ocasionado por un accidente de trabajo; la compatibilidad no queda excluida cuando mediante las prestaciones de la Seguridad Social no se alcanza la completa reparación del daño causado.

2ª. No obstante, no debe existir una independencia absoluta de lo percibido en concepto de indemnizaciones por las contingencias aseguradas y por las de responsabilidad civil complementaria; estas últimas deben completar lo ya percibido, para evitar la "sobreindemnización", esto es, el enriquecimiento injusto; de ahí que corresponda sentar que las distintas indemnizaciones son interdependientes debido a que, además, cuando el accidentado se dirige al empresario por la compensación de lo no resarcido, el daño ya se ha limitado, dado que una parte del mismo fue indemnizada.

3ª. En definitiva, se trata de indemnizar un daño distinto o de completar las indemnizaciones ya percibidas a cargo de la Seguridad Social hasta satisfacer el daño realmente sufrido.

4ª. Esta respuesta deriva de la combinación del principio de resarcimiento completo del daño (artículo 1902 del Código Civil [LEG 1889, 27]), con el principio de la prohibición del enriquecimiento injusto (...)

6ª. En relación al recargo de prestaciones, la Ley nos indica que se trata de un supuesto sancionador del empresario negligente, por lo que no debería acumularse esta cantidad, que no tiene como finalidad reparar el daño causado, sino sancionar a quién lo ha ocasionado" (FD. 4º).

Prestaciones del seguro de responsabilidad civil y prestaciones del seguro de accidente

- STS, 1ª, 705/2011, 25.10.2011

El 11.7.1998, Carlos Alberto, era operador de grúa puente de Comercial Unión. Su trabajo consistía en trasladar paquetes de chapa metálica en la sección de corte de chapa para su posterior almacenamiento. El día del accidente, el trabajador retiró el tope móvil existente entre el final del camino de rodillos, por el que caían las chapas cortadas, y el pérfil móvil final en forma de doble T e introdujo los dos pies en el hueco resultante. Al retirar el tope, se produjo un un leve desnivel en el tren sobre el que estaban las chapas, suficiente para provocar su caída. Carlos Alberto pudo retirar sólo uno de sus pies de dicho hueco y sufrió graves fracturas y secuelas en el pie que quedó atrapado debido al impacto de las chapas metálicas.

Carlos Alberto demandó a Abal Transformados, S.L. (sucesora de Comercial Unión) y a Groupama Plus Ultra, S.A., y reclamó una indemnización por daños y perjuicios de 139.006,86 euros, con el límite de 85.949,68 euros para la aseguradora.

El JPI núm. 5 de Vitoria (30.6.2006) estimó parcialmente la demanda y condenó a los demandados al pago de 118.002,54 euros, con el límite de 85.949,68 euros para la aseguradora.

La AP Álava (Secc. 1ª, 20.2.2007) desestimó el recurso de apelación presentado por Carlos Alberto, y estimó en parte los de Abal Transformados y Groupama, reduciendo el importe de la indemnización a 97.608,20 euros.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por Groupama:

"La recurrente es la aseguradora de la póliza que determina una cobertura cuantitativa y en base a la misma se fija una prima, y, ahora, pretende enriquecerse la Compañía de seguros afrontando un pago menor del que se comprometió en el contrato de seguro. En este sentido el art. 101 de la LCS (RCL 1980, 2295) impide a la aseguradora descontar cantidad alguna por la existencia de varios seguros de accidentes. Lo pretendido por la aseguradora viola el art. 1 de la LCS , en cuanto no cumpliría con las obligaciones pactadas".

Capítulo 13º
El proceso civil de reclamación de responsabilidades civiles

1. El proceso civil de reclamación de daños y perjuicios **239**
2. El proceso ordinario **240**
2.1. Fase alegatoria: demanda y contestación. Reconvención 240
2.2. Fase intermedia: audiencia Previa 244
2.3. Fases probatoria y final: juicio 246
2.4. Sentencia: aclaración, corrección y complemento 248
3. Recursos **248**
4. Ejecución provisional y definitiva. Medidas cautelares **250**
5. Juicio verbal **251**

"Para obtener Justicia no basta tener razón,
es necesario saberla exponer y demostrarla,
encontrar quien la entienda y la quiera dar,
y por último -que es lo más importante-,
encontrar un deudor que pueda pagar."

Piero CALAMANDREI

Estudios sobre el proceso civil, Tomo III,
Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1962, p. 261.

El derecho de daños no se entiende sin las reglas que regulan el proceso en que se exigirán las eventuales responsabilidades civiles, esto es, sin el derecho procesal. El primero, sin el segundo, es un derecho abstracto, y el segundo, sin el primero, es un derecho vacío.

Con mucha frecuencia, al revisar la jurisprudencia, nos encontramos con resoluciones judiciales que, desde un punto de vista estrictamente material, pueden tener difícil explicación. Sin embargo, el fallo se explica las más de las veces en atención a las vicisitudes del proceso: si no se admitió tal o cual prueba, si precluyó la alegación de algún hecho o fundamento jurídico, o si las partes no llevaron a cabo alguna actuación que podía perjudicar la futura interposición de algún recurso procesal, por ejemplo.

En las páginas que siguen se contiene una aproximación sintética a las reglas del procedimiento civil y una explicación práctica de algunas de las cuestiones procesales más relevantes del proceso desde la perspectiva del derecho de daños. En modo alguno pretende ser un tratado exhaustivo sobre la materia ni, por tanto, sustituye el estudio de las leyes procesales, la jurisprudencia y la doctrina al respecto.

1. El proceso civil de reclamación de daños y perjuicios

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (en adelante, LEC) regula en el Título II del Libro II dos procesos declarativos ordinarios, que son los que están enumerados en el artículo 248.2 LEC: el juicio ordinario y el juicio verbal.

Como veremos a continuación, nuestro legislador ha delimitado el ámbito de ambos, si bien ha establecido una cláusula de cierre, mediante la cual ha dispuesto que todas las contiendas judiciales que no tengan señalada por la Ley una tramitación específica, serán ventiladas y decididas por los trámites del juicio ordinario.

La Ley utiliza dos criterios para decidir qué materias jurídicas, o conflictos jurídicos, se resolverán a través de los trámites del juicio ordinario o el juicio verbal: el criterio objetivo y el de la cuantía, una vez excluidas ciertas materias que tienen señalada en la LEC una tramitación especial.

En el ámbito de las reclamaciones de daños y perjuicios, con carácter general:

i) Se decidirán en juicio ordinario las reclamaciones de más de 6.000 euros de cuantía. La cuantía de un pleito se fija según el interés económico de la demanda, que se calcula de acuerdo con las reglas contenidas en los artículos 251 y siguientes LEC.

ii) Se decidirán en juicio verbal las reclamaciones de menos de 6.000 euros de cuantías.

iii) Se decidirán en todo caso por los trámites del juicio ordinario los pleitos en materia de derechos al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen.

En las páginas que siguen a continuación se exponen las reglas generales del juicio ordinario. Ulteriormente (*vid*. apartado 5), y a modo de apunte, se expondrán sintéticamente las principales diferencias entre el juicio ordinario y el verbal.

2. El proceso ordinario

Con el objeto de estudiar el juicio ordinario, podemos dividirlo en las siguientes fases: alegatoria, intermedia, probatoria y final.

2.1. Fase alegatoria: demanda y contestación. Reconvención

a) Demanda

Dice el artículo 399 LEC que "*el juicio principiará por demanda*". La demanda es, así, el acto de incoación del juicio, el acto de petición o postulación y, en suma, el escrito rector del procedimiento que delimita el objeto del juicio[4].

La demanda debe incluir la identificación del tribunal, de las partes, del procurador y del abogado del demandante, los hechos -narrados "*de forma ordenada y clara*" y con expresión de "*los documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que*

[4] Francisco RAMOS MÉNDEZ, *Enjuiciamiento Civil,* Tomo II, Atelier, Barcelona, 2008, pp. 1157-1158.

fundamenten las pretensiones" (artículo 399.2 LEC)-, los fundamentos de derecho procesales y sustantivos, y la petición o suplico.

> La LEC regula, en sus artículos 256 y siguientes, las diligencias preliminares, un conjunto de posibles actividades que obedecen a la finalidad de preparar el juicio y que se llevan a cabo antes de interponer la demanda. En el catálogo se encuentran, entre otras, la solicitud de exhibición de la cosa o la solicitud de exhibición de documentos necesarios para el juicio. En relación con las llamadas acciones colectivas o de clase (*Class actions*), las diligencias preliminares son esenciales para la averiguación de los integrantes de un grupo de afectados.

Una demanda defectuosa está abocada al fracaso. No basta tener la razón: hay que conocer las reglas del juego para convertir esa razón en una resolución judicial estimatoria. A este respecto, y por su relevancia práctica en los procedimientos de responsabilidad civil –tanto contractual como extracontractual-, conviene abordar el problema de la preclusión. De conformidad con el artículo 400 LEC:

> "Cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior.
>
> 1. La carga de la alegación a que se refiere el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las alegaciones complementarias o de hechos nuevos o de nueva noticia permitidas en esta Ley en momentos posteriores a la demanda y a la contestación.
>
> 2. De conformidad con lo dispuesto en al apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste".

Destacan las dos consecuencias prácticas siguientes:

2. **No se puede corregir una demanda defectuosa**. Más allá de las alegaciones complementarias y aclaratorias, y de las pretensiones complementarias, a que se refiere el artículo 426 LEC en el marco de la audiencia previa, una vez planteada la demanda y delimitado el objeto del litigio no es posible alterar el mismo, ni siquiera para corregir un defecto en la demanda.

   Véase, por ejemplo, la STS, 1ª, 1172/2003, de 12 diciembre, en un caso en que se ejercitaba una acción declarativa de dominio con posterioridad a un proceso de tercería de dominio:

   "La sentencia de esta Sala de 30 de julio de 1996 declaró que «no desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada cuando, mediante el segundo pleito, se han querido suplir o subsanar los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero, **pues no es correcto procesalmente plantear de nuevo la misma pretensión cuando antes se omitieron pedimentos**, o no pudieron demostrarse o el juzgador no los atendió»".

3. **No se pude dejar para un pleito posterior la reclamación de los daños y perjuicios**. Con carácter general, no se puede instar una demanda en la que se solicite, exclusivamente, que el Juzgado declare la responsabilidad del causante del daño si esta pretensión no se acompaña de la reclamación de las consecuencias derivadas de aquella declaración de responsabilidad, e.g., la indemnización de daños y perjuicios.

   La doctrina considera que las acciones meramente declarativas no pueden ejercitarse en los supuestos en que a la actora no le conviene o no le interesa solicitar una tutela de condena, como sucede en el presente caso. En este sentido, el Profesor ORTELLS RAMOS, *Derecho Procesal Civil*, Thomson-Aranzadi, 2007, p. 52, sostiene que:

   "[S]i por la naturaleza jurídica del derecho puede ser pedida la condena a prestación, no es admisible pedir una tutela de mera declaración, porque es contrario a la economía en el ejercicio de la potestad jurisdiccional permitir la realización de dos procesos si la tutela necesaria puede ser dispensada en uno sólo".

   Más recientemente, y con referencia expresa al artículo 400 LEC, la STS, 1ª, 164/2011, de 21 marzo, dictada en un caso en que se discutía la reclamación de daños derivados de un siniestro, establece que no puede dejarse para un pleito posterior una indemnización de daños y perjuicios no solicitada en el pleito anterior, siempre que entre dicha pretensión y el objeto principal del pleito exista una íntima conexión:

   "**No desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada cuando, mediante el segundo pleito, se han querido suplir o subsanar los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero**, porque no es correcto procesalmente plantear de nuevo la misma pretensión **cuando antes se omitieron pedimentos**, o no pudieron demostrarse o el juzgador no los atendió (SSTS 30.7.96, 3.5.00 y 27.10.00)", y, b) además, según esta misma sentencia, alcanza a cuestiones que se han deducido de manera implícita en la demanda: "La cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, pero que resultan cubiertas igualmente por la cosa juzgada impidiendo su reproducción en ulterior proceso, **cual sucede con peticiones complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no deducidas, como una indemnización de daños no solicitada, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito exista un profundo enlace**, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una demanda donde objetiva y causalmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las garantías jurídicas del amenazado (SSTS 28.2.91 y 30.7.96), postulados en gran medida incorporados explícitamente ahora al art. 400 de la nueva LEC".

La solicitud de declaración de responsabilidad civil no acompañada de la reclamación de daños y perjuicios es una estrategia relativamente frecuente –aunque arriesgada- cuando la demanda sirve al exclusivo fin de forzar una negociación y, muy particularmente, cuando se trata de limitar el riesgo de costas procesales. Y puede tener éxito, si se acredita la necesidad de adopción urgente de una resolución judicial que declare la responsabilidad civil del causante.

Junto con la demanda deben acompañarse todos los documentos de que quiera valerse la parte para sostener su posición. Son excepcionales los casos en que, con posterioridad a la

presentación de la demanda, se permitirá a la parte demandante introducir una prueba documental o pericial (véanse los artículos 265, 270, 337, 338, 339, 386, 387, 426 y 427 LEC).

b) Contestación a la demanda y reconvención

La parte adversa dispondrá de un plazo de 20 días desde la notificación de la demanda para contestarla (artículo 404 LEC).

La contestación a la demanda se redactará en la forma prevista para la demanda (artículo 399 LEC) y, parecidamente a ésta, deberán exponerse todos los fundamentos de la oposición a las pretensiones del actor, alegando no sólo las excepciones materiales sino, además, cuantas excepciones procesales obsten a la válida prosecución del procedimiento (artículo 405 LEC).

El demandado puede también, y dentro del plazo para contestar a la demanda, plantear reconvención frente al demandante. La reconvención es la demanda que formula el demandado contra el demandante, aprovechando la oportunidad que le ofrece la pendencia del juicio[5]. La reconvención, que ha de proponerse a continuación de la demanda, adopta su misma forma y en ella habrá de expresarse la concreta tutela judicial que se pretende obtener respecto del actor y, en su caso, de terceros. El demandante reconvenido y, en su caso, los terceros, dispondrán de un plazo de 20 días para contestar a la reconvención, en los mismos términos que la contestación a la demanda (artículo 407 LEC).

Con la entrada en vigor de la LEC de 2000, la referencia del artículo 406.4 LEC a la preclusión, a la que antes nos hemos referido ("*será de aplicación a la reconvención lo dispuesto para la demanda en el artículo 400 LEC*"), extendió entre los abogados el temor de que resultara necesario plantear las reclamaciones que se tuvieran contra el demandante vía reconvención para evitar la preclusión y, en consecuencia, la extinción de las acciones que se tuvieran frente a aquel[6]. El temor resultó infundado. Con base en la doctrina jurisprudencial de las audiencias provinciales, creemos poder afirmar que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, con carácter general, una obligación de reconvenir. Véase el AAP Barcelona, Secc. 11ª, 35/2009, de 17 de febrero: "*tal carga (la de formular reconvención) no existe ni siquiera en la legislación procesal vigente. La LEC de 2000 establece la naturaleza puramente potestativa de la reconvención para el demandado, quien es libre de formularla*". Cuestión distinta es que, formulada reconvención, la misma deba fundarse en todas las causas de pedir, sin que pueda reservárselas para un procedimiento posterior.

c) Fijación de los términos del debate

Los términos del debate, salvo las excepciones previstas para la audiencia previa que pasamos a examinar a continuación, vendrán determinados por demanda y contestación, por lo que con

---

[5] Francisco RAMOS MÉNDEZ, 2008, p. 1301.
[6] Francisco RAMOS MÉNDEZ, 2008, p. 1302: "*la ley ha silenciado aposta el hecho de que, si no se hace uso de la reconvención, el demandado conserva vivas todas sus acciones, que pueden ejercitar en el juicio correspondiente, tal como decía la ley anterior. El silenciamiento parece intencionado, como digo, porque la ley quiere aplicar a la reconvención no formulada la preclusión definitiva*".

posterioridad no se admitirá ninguna modificación sustancial que altere las pretensiones objeto principal del pleito, so pena de incurrir en la denominada *mutatio libelli*, prohibida en nuestro ordenamiento jurídico (véase la STS, 1ª, 372/2011, de 1 de junio).

2.2. Fase intermedia: audiencia Previa

Tras las alegaciones iniciales de las partes, esto es, una vez contestada la demanda o, en su caso, la reconvención, la LEC prevé en sus artículos 414 y siguientes la celebración de la llamada audiencia previa, que tiene como finalidad:

a) En primer lugar, conseguir, si ello fuera posible, que las partes alcancen un acuerdo o transacción que evite la continuación del procedimiento (artículo 19 LEC). En la práctica, es altamente improbable que las partes alcancen un acuerdo en este momento, ni siquiera con la mejor voluntad del Juez. De ahí que la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles reconociera al Juez el poder de invitar a las partes a una mediación y le otorgara potestad para conminarlas a asistir a una sesión informativa. Son pocos los casos en que el Juez ha hecho uso de esta potestad hasta la fecha, y menos aún los casos en que tras un proceso de mediación las partes han alcanzado un acuerdo. No obstante, existe una voluntad clara de impulsar la mediación, como lo demuestra la reciente firma en septiembre de 2013 de un convenio de colaboración entre el CGPJ y la Cámara de Comercio de Barcelona por el que todos los jueces mercantiles de Barcelona remitirán de forma preferente los asuntos de mediación a la Cámara a través del Consolat de Mar.

b) En el caso de que el acuerdo no fuera posible -y, en consecuencia, hubiera de continuar el procedimiento-, examinar y resolver las cuestiones procesales planteadas por el demandado, por el actor a la vista de la contestación del demandado o en la eventual contestación a la reconvención, o incluso las que pueda plantear de oficio el propio órgano judicial.

c) La audiencia previa sirve, asimismo, para que las partes fijen de forma definitiva los términos del debate:

   Las partes pueden formular alegaciones complementarias (artículo 426.1 LEC), aclaraciones o rectificaciones (artículo 426.2 LEC), pretensiones complementarias o accesorias (artículo 426.3 LEC); dar a conocer hechos nuevos o de nueva noticia (artículo 426.4 LEC) e incluso aportar, con los límites establecidos, nuevos documentos y dictámenes (artículo 426.5 y 427.3 y .4 LEC).

   Las partes deben manifestar su posición sobre los documentos, particularmente si cuestionan o no su autenticidad, y sobre los dictámenes e informes que se hayan podido presentar por las partes, pudiendo proponer su ampliación (artículo 427.1 y .2 LEC). También pueden las partes solicitar la aportación de nuevos dictámenes cuya necesidad se hubiera puesto de manifiesto a raíz de las alegaciones complementarias o aclaratorias, aclaraciones o rectificaciones, o pretensiones complementarias o accesorias (artículo 427.3 LEC).

Por último, las partes fijarán de forma definitiva cuáles son los hechos controvertidos, esto es, las cuestiones estrictamente fácticas de la controversia sobre las que no coinciden. La fijación de los hechos controvertidos tiene una importancia evidente: la prueba que se solicite deberá venir referida, exclusivamente, al esclarecimiento de estos hechos controvertidos, por lo que si no se fija de forma correcta se corre el riesgo de que, posteriormente, en la fase de proposición de prueba, se inadmitan los medios de prueba propuestos por impertinentes.

d) Si existe disconformidad sobre los hechos, las partes pueden a continuación proponer las pruebas de que intenten valerse para demostrarlos.

Si no existe disconformidad y, en consecuencia, la controversia queda reducida a una cuestión estrictamente jurídica, la proposición y práctica de prueba resulta innecesaria y el caso queda visto para sentencia sin necesidad de celebración de juicio. Lo mismo sucede si, posteriormente, la única prueba propuesta fuera la documental (artículo 429.8 LEC). En este sentido, es muy frecuente que los abogados traten de evitar manifestar una plena conformidad con los hechos para garantizarse la práctica de alguna prueba (por ejemplo, interrogatorio de parte o declaración de testigos o peritos) –por el impacto que pueda causar al Juez oír sus explicaciones de viva voz- y, sobre todo, el trámite de conclusiones.

Es el Juez el que decide sobre la admisión o inadmisión de las pruebas propuestas por las partes, en atención a su necesidad, pertinencia y utilidad (artículo 283 LEC). Si un medio de prueba es denegado, es absolutamente indispensable recurrir en reposición (artículos 285.2 y 451 LEC) en el mismo momento y si, como sucede en la mayor parte de los casos, el recurso es desestimado, formular protesta, a efectos de poder reiterar la solicitud de admisión de la prueba en segunda instancia.

En la práctica, la fase de proposición y admisión de prueba es, acaso, la más tensa de todas las que componen la audiencia previa, pues se convierte en un buen número de ocasiones en una lucha encarnizada para lograr la admisión de las pruebas propias y la inadmisión de las ajenas, desarbolando de este modo la estrategia del contrario. ¡Buena parte del pleito va en ello!

e) Por último, el juez señala día y hora para la celebración del juicio y cita a las partes, al tiempo que acuerda citar a las restantes personas que hayan de intervenir en el juicio y que las partes no se comprometan a citar por ellas mismas.

Típicamente, el guión de una audiencia previa sería el siguiente:

I. Intento de conciliación o transacción
II. Examen de cuestiones procesales
III. Delimitación de los términos del debate
  A) Alegaciones complementarias (art. 426.1 LEC).
  B) Aclaraciones y rectificaciones (art. 426.2 LEC).
  C) Pretensiones accesorias o complementarias (art. 426.3 LEC).
  D) Hechos nuevos o de nueva noticia (art. 426.4 LEC).
  E) Nuevos documentos y dictámenes (arts. 426.5 y 427.3-4 LEC).
  F) Posicionamiento ante documentos y dictámenes (art. 427.1-2 LEC).
  G) Fijación de los hechos controvertidos (art. 428.1 LEC)
IV. Proposición de Prueba

2.3. Fases probatoria y final: juicio

En un juicio ordinario, todas las actuaciones tienen como fin último la celebración de una sesión oral en la que se practican las pruebas propuestas y admitidas y tienen lugar, en último término, las conclusiones del procedimiento. A este acto se le denomina, propiamente, juicio. Dice el artículo 431 LEC:

> "El juicio tendrá por objeto la práctica de las pruebas de declaración de las partes, testifical, informes orales y contradictorios de peritos, reconocimiento judicial en su caso y reproducción de palabras, imágenes y sonidos.
>
> Asimismo, una vez practicadas las pruebas, en el juicio se formularán las conclusio-nes sobre éstas".

El juicio se celebra, de ordinario, en unidad de acto, y sólo cuando ello no sea posible (por ejemplo, debido al elevado número de pruebas a practicar) se continúa en las sesiones necesarias para completar las actividades previstas en la LEC y que, generalmente, ya habrán sido programadas en la audiencia previa. No es infrecuente, en este sentido, que una vista que comenzó a primera hora de la mañana pueda alargarse –sin apenas alguna pequeña pausa- hasta bien entrada la tarde.

Al juicio han de concurrir los abogados y procuradores de las partes y, en el caso de que se hubiera solicitado su interrogatorio, la propia parte o representante legal de la misma. Si ninguna de las partes comparece, el pleito queda visto para sentencia, pero continuará si concurriese cualquiera de ellas (artículo 432 LEC). Ahora bien, si la parte llamada a declarar no concurriera al juicio, podrá tenérsela por confesa (*ficta confessio*, artículo 304 LEC), esto es, podrán considerarse reconocidos por ella los hechos en que hubiera intervenido y cuya fijación como ciertos le sea perjudicial.

Con carácter previo a la práctica de las pruebas, las partes podrán hacer alegaciones acerca de hechos nuevos acaecidos o conocidos con posterioridad a la audiencia previa. Asimismo, también con carácter previó, se resolverá cualquier cuestión planteada en relación con la vulneración de derechos fundamentales en la obtención u origen de alguna prueba.

Resueltas las eventuales cuestiones previas, la vista se dedicará a continuación a la práctica de la prueba. Las pruebas se practican por el orden establecido en la LEC: declaración de las partes, testigos, informes orales y contradictorios de peritos, reconocimiento judicial y reproducción de palabras, imágenes y sonidos (artículo 431 LEC).

> Debido a que puede transcurrir largo tiempo entre la interposición de la demanda o contestación y la vista de juicio, y para garantizar la práctica de la prueba, la LEC prevé en sus artículos 293 y siguientes las llamadas medidas de aseguramiento de prueba. Estas medidas se dirigen a evitar que "*por conductas humanas o acontecimiento naturales, que puedan destruir o alterar objetos materiales o estados de cosas, resulte imposible en su momento practicar una prueba o incluso carezca de sentido proponerla*". Desde la interposición de la demanda hasta la celebración del juicio puede transcurrir más de un

año, según el partido judicial, por lo que es conveniente valorar la adopción de estas medidas para garantizar que la prueba pueda llegar a practicarse.

Por último, y al término de la práctica de la prueba, las partes concluyen con un informe oral –sólo excepcionalmente, y aunque no está previsto legalmente, los jueces admiten conclusiones escritas para facilitar su labor- en el que se extraen las consecuencias de su actividad probatoria en relación con sus respectivas peticiones de juicio. Dice el artículo 433.2 LEC:

> "Practicadas las pruebas, las partes formularán oralmente sus conclusiones sobre los hechos controvertidos, exponiendo de forma ordenada, clara y concisa, si, a su juicio, los hechos relevantes han sido o deben considerarse admitidos y, en su caso, probados o inciertos.
>
> A tal fin, harán un breve resumen de cada una de las pruebas practicadas sobre aquellos hechos, con remisión pormenorizada, en su caso, a los autos del juicio. Si entendieran que algún hecho debe tenerse por cierto en virtud de presunción, lo manifestarán así, fundamentando su criterio. Podrán, asimismo, alegar lo que resulte de la carga de la prueba sobre los hechos que reputen dudosos.
>
> En relación con el resultado de las pruebas y la aplicación de las normas sobre presunciones y carga de la prueba, cada parte principiará refiriéndose a los hechos aducidos en apoyo de sus pretensiones y seguirá con lo que se refiera a los hechos aducidos por la parte contraria".

Las conclusiones son una pieza clave en el proceso judicial. No basta con que, tras la práctica de la prueba, tales o cuales hechos hayan quedado demostrados. Ulteriormente, hay que poner de manifiesto al juez la relevancia de los hechos probados en el marco de la cuestión jurídica debatida en el procedimiento.

> Los jueces dan una gran importancia a las conclusiones del juicio siempre que las mismas consistan, precisamente, en este ejercicio de síntesis de la prueba practicada y relación de la prueba con los fundamentos de derecho que sustentan las pretensiones de las partes. Un buen informe de conclusiones es esencial en la formación del juicio del tribunal.

De este modo, en el informe de conclusiones se resumen y valoran las pruebas practicadas y se expone si, a juicio del abogado informante, los distintos hechos controvertidos han quedado o no probados; en segundo lugar, se informa sobre los argumentos jurídicos que sustentan las pretensiones de las partes; y por último, se indica al tribunal si se mantienen las respectivas peticiones o si, como consecuencia del resultado de la prueba practicada, se modifican (por ejemplo, se reduce el monto de la indemnización reclamada, se concreta una petición genérica, etc.)[7].

Antes de dictar sentencia es posible la adopción de las llamadas diligencias finales (artículos 435 y 436 LEC), que consisten en diligencias o actuaciones de prueba que se pueden llevar a

---

[7] Francisco RAMOS MÉNDEZ, 2008, p. 70.

cabo, principalmente, cuando (i) no se hubiera podido practicar una prueba admitida; (ii) se refieran a hechos nuevos o de nueva noticia previstos en el artículo 286 LEC.

2.4. Sentencia: aclaración, corrección y complemento

Terminado el juicio, es función del tribunal decidir la controversia, esto es, enjuiciar el asunto. La estructura de las sentencias, que se regula en los artículos 248 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 209 LEC, es la siguiente: encabezamiento, donde se expresan los datos identificativos del procedimiento y de las partes; antecedentes de hecho, donde se consignan con claridad y concisión los hechos que sustentan las pretensiones de las partes; fundamentos de derecho, que contienen las razones jurídico-legales que sustentan el fallo; y por último, el fallo, que contiene los pronunciamientos de la sentencia.

Los artículos 214 y 215 LEC prevén la posibilidad, a instancia de parte o, según los casos, incluso de oficio, de aclarar, corregir, subsanar o complementar las sentencias oscuras, que contengan errores o que sean incompletas. La falta de solicitud de aclaración, corrección, subsanación o complemento puede ser causa de inadmisión de ulteriores recursos frente a la sentencia.

> Esto es especialmente relevante en cuanto al acceso al recurso extraordinario por infracción procesal, en la medida en que constituye causa de inadmisión la omisión del "*deber de agotar todos los medios posibles para la denuncia o subsanación de la infracción o el defecto procesal (artículo 470.2 LEC, en relación con el artículo 469.2 LEC)*", cusa en la que se incluye la "*alegación de falta de motivación (artículo 469.2 LEC), de la vulneración del principio de congruencia y de otros vicios in iudicando o in procedendo de la sentencia recurrida si no se ha solicitado la aclaración, corrección, subsanación o complemento de la sentencia (artículos 214 y 215 LEC)* (Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, de 30 de diciembre de 2011).

3. Recursos

Contra la sentencia de primera instancia cabe interponer recurso de apelación que será resuelto por la Audiencia Provincial que corresponda (artículos 455 y siguientes LEC). El recurso no permite introducir nuevas pretensiones, excepciones o cuestiones nuevas, sino que sólo podrá versar sobre las pretensiones que se hubieran planteado en la instancia.

Tras la reforma de la LEC por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, el recurso se interpone ante el juzgado que hubiera dictado la sentencia recurrida en el plazo de 20 días. Ulteriormente, una vez presentadas las eventuales oposiciones el recurso, será elevado a la Audiencia Provincial correspondiente que deba resolverlo (artículo 458 LEC).

El recurso de apelación es una segunda instancia, de tal modo que la Audiencia Provincial no estará vinculada por la valoración de la prueba efectuada por el juzgado *a quo* ni por la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida.

Cuestión distinta son los recursos extraordinarios: el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación, que resuelven el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia que corresponda, en función de que el derecho aplicable a la controversia sea común o foral, respectivamente, son recursos extremadamente formalistas que presentan importantes limitaciones:

(i) El recurso extraordinario por infracción procesal procede contra sentencias y autos dictados en segunda instancia (artículo 468 LEC). Los motivos son tasados (artículo 469 LEC): infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva y funcional; infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia; infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del juicio, cuando la infracción determina la nulidad conforme a la ley o haya podido producir indefensión; vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española.

(ii) El recurso de casación, por su parte, procede contra sentencias dictadas en segunda instancia y habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso (artículo 477 LEC). El recurso contra sentencias dictadas en segunda instancia procede en los siguientes casos: cuando se hayan dictado para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución; siempre que la cuantía del proceso exceda de 600.000 euros; y, cuando la cuantía del proceso no exceda de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional.

Tras la reforma de la LEC por la Ley 37/2011, estos recursos se interponen, individual o conjuntamente, según los casos (Disposición Final 16ª LEC) directamente ante el órgano que dictó la resolución recurrida en plazo de 20 días. Ulteriormente el recurso será elevado al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia que deba resolverlo.

A diferencia de la apelación, en los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación los autos se elevan al Tribunal Supremo o Superior de Justicia inmediatamente después de su interposición. Una vez que se personen las partes, el Tribunal decidirá sobre la admisión de los motivos. Típicamente, el Tribunal pondrá de manifiesto a las partes las posibles causas de inadmisión del recurso y se abrirá un plazo de alegaciones de 10 días para que las partes se manifiesten al respecto.

> El Tribunal Supremo, sobre todo, pero también algunos Tribunales Superiores de Justicia, han emitido criterios sobre la admisión de los recursos, que interpretan y complementan la regulación contenida en la LEC. El examen de admisión es muy riguroso y ha sido muy criticado por la doctrina, en la medida en que, las más de las veces, el recurso simplemente se inadmite (sucede en más del 90% de los recursos interpuestos ante la Sala Primera del Tribunal Supremo), avanzándose de este modo la resolución del recurso sin entrar a conocer del fondo.

Las causas de admisión de los motivos de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación son tasadas. Así, por ejemplo, en relación con la valoración de la prueba, el Tribunal Supremo no puede llevar a cabo una valoración de la prueba distinta, salvo que se acredite que la valoración de la Audiencia Provincial es ilógica o arbitraria. La casación, por su parte, no es una nueva alzada; no es una tercera instancia, y en consecuencia, el Tribunal se limita "*a*

conocer de la regularidad de la aplicación del derecho o de determinados principios básicos del juicio por los tribunales de instancia[8]".

La inadmisión de los recursos, o en su caso, la sentencia que se dicte, ya sea estimatoria o desestimatoria, pone fin al proceso judicial de manera firme, y de ella se predican los efectos de la cosa juzgada (artículos 207 y 222 LEC).

4. Ejecución provisional y definitiva. Medidas cautelares

Como decía CALAMANDREI, a quien citamos al comienzo de estas páginas, no basta con obtener una resolución favorable, sino que hace falta encontrar un deudor que pueda pagar.

Si el demandado no cumple voluntariamente con la sentencia, es necesario entonces instar su ejecución para dar de este modo cumplimiento al fallo de la resolución judicial y así obtener satisfacción.

Son ejecutables las sentencias firmes (artículos 538 y siguientes), pero también las sentencias de primera instancia o apelación que no sean firmes porque hayan sido objeto de recurso, en lo que se conoce como ejecución provisional (artículos 524 y siguientes). Aunque con algunas limitaciones. En síntesis, son ejecutables provisionalmente los pronunciamientos de condena dineraria pero no los pronunciamientos que condenen a emitir una declaración de voluntad. Además, no cabe la ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Cuando la resolución no es firme, el demandado no tiene propiamente obligación de cumplir la sentencia si el demandante no insta su ejecución provisional, sin perjuicio de que, desde que se dictó, se devengan los intereses de la mora procesal del artículo 576.1 LEC:

> "Desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley".

Por este motivo, existe reiterada doctrina que señala que en el caso de que el ejecutado consigne voluntariamente el importe de la condena, dentro de los 20 días siguientes a la notificación del auto despachando ejecución provisional, sin formular oposición, no procede el pago de las costas de la ejecución (SAP Madrid, Secc. 10ª, 1049/2004, de 16 de noviembre, o SAP Madrid, Secc. 14ª, 603/2007, de 30 de octubre).

Para un estudio exhaustivo de la ejecución, provisional y definitiva, nos remitimos a Francisco RAMOS MÉNDEZ (2008), *Enjuiciamiento Civil*, Tomo I, Atelier, Barcelona, pp. 109 y ss.

---

[8] Francisco RAMOS MÉNDEZ, 2008, p. 1489.

Por último, es necesario advertir que para garantizar la ejecución de la sentencia que se dicte en el procedimiento es posible solicitar la adopción de medidas cautelares, cuya regulación se contiene en los artículos 721 y siguientes LEC. En particular, dice el artículo 726 LEC:

> "1. El tribunal podrá acordar como medida cautelar, respecto de los bienes y derechos del demandado, cualquier actuación, directa o indirecta, que reúna las siguientes características:
>
> 1.ª Ser exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente.
>
> 2.ª No ser susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado.
>
> 2. Con el carácter temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificación y alzamiento previsto en esta Ley para las medidas cautelares, el tribunal podrá acordar como tales las que consistan en órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte".

La adopción de medidas cautelares requiere justificar (i) el peligro de la mora procesal (*periculum in mora*), esto es, el riesgo de que durante la pendencia del proceso se produzcan situaciones que dificulten o impidan la efectividad de la tutela judicial que se pueda otorgar en la eventual sentencia estimatoria; (ii) la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*), esto es, sin prejuzgar el fondo del asunto, el juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión; (iii) de ordinario, prestar caución suficiente para responder de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pueda causar al patrimonio del demandado (artículo 728 LEC).

5. Juicio verbal

En el juicio verbal (artículos 437 y siguientes LEC), a diferencia del juicio ordinario, la fase alegatoria queda dividida: la demanda (ordinaria o sucinta) es escrita, pero la contestación a la demanda se produce en la primera parte del juicio o de la vista a la que son convocadas las partes (artículo 440 LEC). A efectos prácticos (artículo 443 LEC), en esta vista se contesta a la demanda y, posteriormente, se acumulan en un mismo acto las actuaciones propias de la audiencia previa del juicio ordinario y del juicio. Así, se resuelven las posibles excepciones, se fijan los hechos controvertidos y se propone la prueba que se practica inmediatamente a continuación (de ahí que las partes puedan solicitar al Juzgado con antelación que cite a los testigos que no puedan aportar ellas mismas y de cuyo testimonio pretendan valerse en el juicio, caso de que posteriormente, en el juicio, se admita la prueba). A diferencia del juicio ordinario, la LEC no prevé un trámite de conclusiones, aunque en atención a la complejidad del asunto algunos jueces pueden invitar a las partes a formularlas.